공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2006 - 042호 2006. 2. 24.

사 건 번 호 2002경촉0453, 2005경촉0375

사 건 명 마이크로소프트 코퍼레이션 및 한국마이크로소프트 유한회사의 시장지배적 지위남용행위 등에 대한 건

피 심 인 1. 마이크로소프트 코퍼레이션(Microsoft Corporation)
미합중국 워싱턴주 레드몬드시 마이크로소프트 웨이 1
대표이사 스티브 발머(Steve Ballmer)
2. 한국 마이크로소프트 유한회사
서울특별시 강남구 대치동 892 포스코 센터 6층
대표이사 유재성
위 피심인들 대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 정경택, 안재홍, 임용

주 문

1. 윈도우 미디어 서비스(Windows Media Service)의 결합판매 부분

가. 피심인들은 이 시정명령을 송달받은 날(이하 “시정명령일”이라 한다)부터 180일 이후에는 윈도우 서버(Windows Server) 운영체제(윈도우 서버 2003 및 기타 모든 하위 버전과 명칭에 관계없이 피심인들이 향후 개발하여 판매하는 윈도우 서버 운영체제를 포함한다. 이하 같다)에 윈도우 미디어 서비스(Windows Media Service, 이하 "WMS"라 하며, 이와 동등 또는 유사한 기능을 수행하는 피심인들의 일체의 프로그램을 포함한다. 이하 같다)를 결합하여 공급하여서는 아니 된다.

(1) 윈도우 서버 운영체제에서 WMS를 분리하기 위하여 포함되어서는 아니되는 소스코드(source code) 및 파일(file)의 범위는 공정거래위원회가 피심인들의 의견을 참작하여 이 시정명령일부터 60일 이내에 지정한다.

(2) 피심인들은 향후 개발되는 윈도우 서버 운영체제에서 위 (1)항에 따라 포함되어서는 아니되는 소스코드의 각 버전(version)별 목록과 파일(file)별 구체적 설명자료를 그 판매개시 60일 전까지 공정거래위원회에 제출·보고하여야 한다.

나. 피심인들은 이 시정명령일부터 180일 이후에는 WMS를 윈도우 서버 운영체제와 독립된 방법으로 판매·배포하여야 하며, WMS 판매·배포의 독립성을 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니된다. 다음 각호의 행위는 금지된다.

(1) 윈도우 서버 운영체제 패키지(package)에 WMS가 포함된 콤팩트디스크(compact disk, 이하 "CD"라 한다) 또는 이와 유사한 저장물을 포함하거나, 윈도우 서버 운영체제에 대한 서비스 팩(service pack)이나 업데이트(update) 등에 WMS를 포함하여 제공하는 행위

(2) 윈도우 서버 운영체제 또는 그에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등에서 WMS의 다운로드 링크(download link)를 제공하는 행위

(3) 윈도우 서버 운영체제 또는 그에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등에서 WMS의 설치 또는 사용을 유도하거나 유도할 우려가 있는 표시 또는 광고를 하는 행위

(4) 사용자(소비자, 제조업체 및 유통업체 등을 포함한다. 이하 같다)의 직접 선택에 의하지 않고, 윈도우 서버 운영체제에서 WMS를 기본적 사항으로 지정하는 행위

다. 피심인들은 위 가.항의 조치사항을 적용한 윈도우 서버 운영체제가 이를 적용하지 않은 제품보다 그 성능이나 안정성 등이 떨어지지 않도록 하여야 하며, 위 가.항에 의하여 포함되지 아니한 소스코드 및 파일을 다시 윈도우 서버 운영체제에 설

치할 경우에도 이를 포함하였으면 작동하였을 상태와 동일하게 작동될 수 있도록 하여야 한다.

라. 피심인들은 서버 제조업체와의 관계에서 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

(1) WMS만을 공급, 판매, 임대, 판촉, 사용, 설치 또는 지원하는 것을 조건으로 거래하는 행위 또는 그러한 것을 조건으로 대가를 지급하거나 윈도우 서버 운영체제의 가격할인, 유리한 거래조건설정 등 경제적 또는 비경제적 이익을 제공하는 행위

(2) 서버 제조업체가 WMS와 경쟁관계에 있는 소프트웨어(software)를 개발, 판매, 임대, 판촉, 사용, 설치 또는 지원하거나 하려한다는 이유로, 경제적 또는 비경제적 이익의 제공을 축소 또는 중단하거나 기타의 거래조건을 불리하게 하는 등 어떠한 형태로든 보복하거나 보복할 것을 예고하는 행위

2. 윈도우 미디어 플레이어(Windows Media Player) 및 메신저(Messenger)의 결합판매 부분

가. 피심인들은 이 시정명령일부터 180일 이후에는 윈도우(Windows) 피시(Personal Computer, 이하 “PC”라 한다) 운영체제(윈도우 XP, 윈도우 비스타 및 기타 하위 버전과, 명칭에 관계없이 피심인들이 향후 개발·판매하는 일체의 윈도우 PC 운영체제를 포함한다. 이하 같다)에 기존의 윈도우 미디어 플레이어(Windows Media Player, 이하 “WMP″라 하며, 명칭 여하를 불문하고 WMP의 후속버전 등 WMP와 동등 또는 유사한 기능을 수행하는 피심인들의 일체의 프로그램을 포함한다)와 메신저(윈도우 메신저, MSN 메신저 및 이와 동등 또는 유사한 기능을 수행하는 피심인들의 일체의 프로그램을 포함한다. 이하 “피심인 메신저”라 한다)를 결합하여 공급하여서는 아니된다(이하 “분리된 PC 운영체제”라 한다). 다만, 이와 별도로 경쟁제품에 대하여 아래 다.항의 조치를 한 경우에는 “분리된 PC 운영체제”외에 현재와 같이 WMP 및 피심인 메신저를 PC 운영체제에 결합하여 공급할 수 있다(이하 “탑재된 PC 운영체제”라 한다). 공정거래위원회는 이 시정명령일 이

후 피심인들의 요청이 있는 경우 시장점유율이 전년도말 기준 5%이하로서 현저히 낮다고 인정되는 피심인들의 특정된 버전의 운영체제에 대하여는, 이 사건 시정명령에 따른 경쟁회복 정도나 피심인들의 부담 및 향후 시장에서 예상되는 지위 등을 고려하여 이 시정명령의 전부 또는 일부의 적용을 제외할 수 있다.

(1) “분리된 PC 운영체제”는 아래 나.항에서 정한 방법 및 절차에 의한다.

(2) “탑재된 PC 운영체제”는 아래 다.항에서 정한 방법 및 절차에 의한다.

나. 피심인들이 “분리된 PC 운영체제”를 공급할 경우에는 다음과 같이 한다.

(1) 피심인들은 “분리된 PC 운영체제”를 공급하기 위하여 기존의 윈도우 PC 운영체제에서 WMP 및 피심인 메신저 프로그램을 분리하여야 한다.

(가) 윈도우 PC 운영체제에서 WMP 및 피심인 메신저를 분리하기 위하여 포함되어서는 아니되는 소스코드 및 파일의 범위는 이 시정명령일부터 60일 이내에 공정거래위원회가 피심인들의 의견을 참작하여 지정한다.

(나) 피심인들은 향후 개발되는 윈도우 PC 운영체제에서 위 (가)항에 따라 포함되어서는 아니되는 소스코드 및 파일의 각 버전(version)별 목록과 파일(file)별 구체적 설명자료를 그 판매개시 60일 전까지 공정거래위원회에 제출·보고하여야 한다.

(2) 피심인들은 이 시정명령일부터 180일 이후에는 WMP 및 피심인 메신저를 “분리된 PC 운영체제”와 별개로 판매·배포하여야 하며, WMP 및 피심인 메신저 판매·배포의 독립성을 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니된다. 다음 각호의 행위는 금지된다.

(가) “분리된 PC 운영체제” 패키지에 WMP 또는 피심인 메신저가 포함된 CD 또는

이와 유사한 저장물을 포함하거나, “분리된 PC 운영체제”에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등을 제공하면서 WMP 또는 피심인 메신저를 포함시키는 행위

(나) “분리된 PC 운영체제” 또는 그에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등에서 WMP 또는 피심인 메신저의 다운로드 링크를 제공하는 행위

(다) “분리된 PC 운영체제” 또는 그에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등에서 WMP 또는 피심인 메신저의 설치 또는 사용을 유도하거나 유도할 우려가 있는 표시 또는 광고를 하는 행위

(라) 사용자의 직접 선택에 의하지 아니하고, “분리된 PC 운영체제” 또는 그에 대한 서비스 팩이나 업데이트 등에서 WMP, 피심인들이 보유하는 디지털 오디오 또는 비디오 포맷(format), 저작권 보호 프로그램(Digital Rights Management, 이하 “DRM”이라 한다), 코덱(codec) 또는 피심인 메신저, 메신저용 통신 프로토콜(protocol) 등을 기본적 사항으로 지정하는 행위

(3) 피심인들은 위 (1)항의 조치사항을 적용한 “분리된 PC 운영체제”가 조치사항을 적용하지 않은 제품보다 그 성능이나 안정성이 떨어지지 않도록 하여야 하며, 위 (1)항에 따라 포함되지 아니한 소스코드를 다시 “분리된 PC 운영체제”에 설치할 경우에도 이를 포함하였으면 작동하였을 상태와 동일하게 작동될 수 있도록 하여야 한다.

다. 피심인들이 “탑재된 PC 운영체제”를 공급할 경우에는 다음과 같이 한다.

(1) 피심인들은 “탑재된 PC 운영체제”에 다음 각호에 따라 "미디어 플레이어 센터" 및 "메신저 센터"(이하 양자를 통칭할 경우 “미디어/메신저 센터”라 한다)를 설치·운영하여야 하며, 이에 따라 설치되는 미디어/메신저 센터는 아래와 같이 경쟁제품을 다운로드 받을 수 있는 실질적 기회를 사용자에게 제공하여야 한다.

(가) 미디어/메신저 센터의 아이콘(icon) 및 메뉴(menu)는 “탑재된 PC 운영체제”의 프로그램 메뉴목록 또는 바탕화면 등 사용자들이 쉽게 인식할 수 있는 위치에 설치하여야 하며, 그 크기와 형태는 WMP 및 윈도우 메신저의 해당 메뉴 또는 아이콘(이하 “아이콘등”이라 한다)의 크기 및 형태와 동등 또는 유사한 수준을 유지하여야 한다.

(나) 미디어/메신저 센터는 사용자들이 해당 아이콘등을 클릭(click)할 경우 각각 국내에서 제공되는 스트리밍 미디어 플레이어(streaming media player) 또는 인스턴트 메신저(instant messenger, 이하 “메신저”라 한다) 중에서 공정거래위원회가 지정하는 원천기술 보유 사업자의 스트리밍 미디어 플레이어 및 이 시정명령일 현재 공정거래위원회가 지정하는 시장조사기관의 자료상 월 순 사용자 기준 시장점유율 5%이상인 사업자의 메신저의 아이콘등과 “미디어 플레이어 웹센터” 및 “메신저 웹센터”(이하 양자를 통칭할 경우 “미디어/메신저 웹센터”라 한다)의 아이콘등을 각각 포함하여야 한다.

(다) 피심인들은 사용자들이 미디어/메신저 센터를 클릭한 후 표시되는 각 프로그램의 아이콘 또는 미디어/메신저 웹센터의 아이콘을 클릭하면, 각각 해당 사업자 또는 웹센터의 웹사이트로 연결되어 사용자들이 원하는 프로그램을 다운로드 받을 수 있도록 하여야 한다.

(라) 피심인들은 스트리밍 미디어 플레이어 또는 메신저를 공급하는 사업자가 자신의 제품이 미디어/메신저 센터에 포함되기를 원하지 않는 경우 또는 대가의 지급을 요구하거나 보증의무를 부담하지 않는 등 현저히 부당한 조건을 제시하는 경우에는 당해 제품을 포함시키지 않을 것을 공정거래위원회에 요청할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 다. (1) (나)항의 기준에 해당되는 제품이라도 미디어/메신저 센터에 포함시키지 않을 수 있다.

(마) 공정거래위원회는 이 시정명령일부터 1년이 경과한 후 이해당사자들의 요청이 있는 경우 시장상황의 변동 등을 고려하여 위 미디어/메신저 센터에 포함되는

미디어 플레이어나 메신저를 변경·지정할 수 있다.

(바) 미디어/메신저 센터에 해당 제품의 아이콘이 표시되는 스트리밍 미디어 플레이어 및 메신저의 범위, 등재절차 및 동 센터의 운영에 관한 구체적 사항은 공정거래위원회가 이 시정명령일부터 60일 이내에 정한다.

(2) 피심인들은 “탑재된 PC 운영체제”를 제공함에 있어 윈도우 비스타(Windows Vista, 명칭과 관계없이 윈도우 XP의 후속제품으로 판매되는 모든 윈도우 PC 운영체제와 그 하위버전을 포함한다. 이하 같다)에 있어서는 고유한 포맷을 가지고 있는 다른 사업자의 스트리밍 미디어 플레이어를 쉽게 다운로드 받을 수 있도록 하는 장치를 다음과 같이 제공하여야 한다.

(가) 피심인들은 공정거래위원회가 지정하는 다른 원천기술 보유 사업자들에게 피심인들이 공정거래위원회의 승인을 받아 정하는 합리적 조건에 따라 자신의 포맷을 등록할 수 있도록 하여야 한다. 포맷 등록으로 인하여 등록하는 사업자의 소스코드 기타 영업비밀이 피심인들에게 알려질 우려가 있는 경우 그 우려를 해소하기 위한 조치에 관하여는 공정거래위원회가 당해 사업자의 의견을 참작하여 정한다.

(나) 피심인들은 사용자가 다른 포맷으로 작성된 인터넷(Internet) 스트리밍 콘텐츠(contents) 또는 사용자의 하드 디스크(hard-disk), CD 등에 저장된 콘텐츠를 재생하려고 할 때 그러한 파일을 재생할 수 있는 소프트웨어가 윈도우 PC 운영체제에 등록되어 있지 않았을 경우, 사용자가 해당 미디어 플레이어 사업자의 웹 사이트로 연결되어 재생에 필요한 소프트웨어를 다운로드 받을 수 있도록 하여야 한다.

(다) 피심인들은 이 시정명령일 또는 윈도우 비스타의 최종 시제품(beta version, 이하 “베타 버전”이라 한다)의 출시일 중 늦은 날로부터 90일 이내에 피심인들이 제공하는 장치의 내용과 사용방법을 구체적으로 기재한 문서를 피심인들의 인

터넷 웹 사이트에 공개해야 한다.

(3) 피심인들은, 다른 메신저 사업자들과 상업적 및 기술적으로 합리적인 조건 하에 상호 통신의 개시가 상업적 및 기술적으로 실현 가능한 시점부터, 국내의 엠에스엔(MSN) 메신저 사용자들이 다른 메신저 사용자들과 상호 통신할 수 있도록 하기 위한 합의(이하 “상호호환 합의”라고 한다)가 이루어지도록 성실하게 노력하여야 한다.

(가) 피심인들은 이 시정명령일부터 120일 이내에 이 시정명령일 현재 공정거래위원회가 지정하는 시장조사기관의 자료상 월 순사용자 기준 시장점유율 5%이상인 메신저 사업자와 위 상호호환 합의를 위한 협의를 개시하여야 한다. 다만, 피심인들은 상호호환 합의 의사가 명백히 없는 사업자와는 협의하지 않을 수 있다.

(나) 피심인들은 상호호환 합의를 위한 협의를 개시한 날부터 매 6개월마다 그 협의 진행상황을 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

(4) 피심인들은 위 (1) 내지 (3)항의 조치사항을 적용한 “탑재된 PC 운영체제”가 이를 적용하지 않은 제품보다 그 성능이나 안정성이 떨어지지 않도록 하여야 한다.

라. 피심인들은, 위 가. 내지 다.항의 조치사항이 적용되지 않은 기존 윈도우 PC 운영체제 사용자들에게 시정명령일부터 180일 이내에, 피심인들의 비용으로 직접 또는 제3자를 통해 WMP 및 피심인 메신저의 각 경쟁제품이 포함되어 있는 서비스 팩을 아래에서 정한 바와 같이 제공하여야 하며, 윈도우 업데이트(윈도우 PC 운영체제 업데이트, WMP 업데이트 및 윈도우메신저 업데이트를 모두 포함한다)를 통해 위 다.(1)항에서 정한 바와 같이 미디어/메신저 센터를 제공하여야 한다.

(1) 서비스 팩을 CD에 저장하여 배포할 경우 CD에 포함되는 프로그램을 정하는 기준은 위 다. (1) (나)항에서 정한 바와 같다.

(2) CD 제작 및 CD에 포함되는 프로그램을 공급하는 각 사업자의 지원과 보증 의무의 범위 등 이 명령을 이행하기 위한 구체적 사항에 대해서는 공정거래위원회가 피심인들의 의견을 참작하여 시정명령일부터 120일 이내에 정한다.

(3) 피심인들은 위 (1)항에 의한 업데이트를 함에 있어 피심인들의 비용으로 CD를 배포하고 있으며, 이를 원하는 사용자는 누구든지 신청할 수 있다는 사실을 공정거래위원회가 정하는 바에 따라 고지하고, 이 시정명령일부터 1년의 범위 내에서 신청한 사용자들에게 CD를 무료로 제공하여야 한다.

마. 피심인들은 마이크로소프트 오피스(Microsoft Office) , 마이크로소프트 워드(Microsoft Word), 마이크로소프트 파워포인트(Microsoft PowerPoint), 마이크로소프트 엑셀(Microsoft Excel) 등 이 시정명령일 현재 매출액 기준 국내시장 점유율이 50%를 넘는 자신의 다른 제품에 WMP 또는 피심인 메신저를 탑재하거나 기타 이에 준하는 행위를 하여서는 아니된다. 피심인들의 다른 제품의 구체적 범위는 공정거래위원회가 이 시정명령일부터 90일 이내에 정한다.

바. 피심인들은 국내의 PC 제조업체(유통업체를 포함한다. 이하 같다) 및 관련 하드웨어 사업자(국내에서 윈도우 PC 운영체제를 탑재한 PC 또는 윈도우 서버 운영체제를 탑재한 서버 컴퓨터에 포함되거나 이들과 함께 사용되는 하드웨어를 개발하는 독립된 하드웨어 사업자를 말한다. 이하 같다), 소프트웨어 개발자(국내에서 소프트웨어 제품을 개발 또는 판매하는 피심인들 이외의 사업자를 말한다. 이하 같다), 인터넷 서비스 제공자(자기 고유의 콘텐츠를 보유하고 있는지 여부와 상관없이 국내 소비자들에게 인터넷 접속 서비스를 제공하는 사업자를 말한다. 이하 같다), 인터넷 콘텐츠 사업자(웹사이트를 운영하여 국내 인터넷 사용자들에게 콘텐츠를 제공하는 국내 사업자를 말한다. 이하 같다)에게 마이크로소프트 개발자 네트워크(Microsoft Developer Network, 이하 “MSDN”이라 한다)를 통하여, WMP와 윈도우 메신저가 윈도우 PC 운영체제와 상호연결 및 작동을 하기 위하여 사용하는 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스{Application Programming Interface, WMP와 윈도우 메신저가 윈도우 PC 운영체제로부터 서비스를 제공받기 위하여

부르는 인터페이스[관련 콜백 인터페이스(callback interface)를 포함]를 말한다. 이하 “API”라 한다}와 관련 정보문서(관련 분야에 일반적인 지식을 가지고 있는 자가 API를 효과적으로 사용하기 위하여 필요한 API 식별과 사용법에 관한 모든 정보를 말한다)를 그러한 상호 연결 및 작동의 목적으로 공개하여야 한다. API와 관련 정보문서는 피심인들이 MSDN에 통상적으로 공개하는 API와 동등한 정도로 정확하고 구체적이어야 하며, 업계 통상의 지식과 능력을 갖는 사용자가 이를 이용하는데 어려움이 없을 정도로 마련되어야 한다. 이 시정명령에 의한 정보의 공개는 WMP 및 윈도우 메신저의 주요 버전이 새로이 출시될 경우에는 각 제품의 최종 베타 버전이 출시되는 시점까지, 윈도우 PC 운영체제의 버전이 새로이 출시될 경우에는 국내외기준 150,000개 이상의 베타 버전이 배포되는 시점 또는 MSDN 유료 사용자에게 제공되는 시점까지 이루어져야 한다.

사. 피심인들은 국내의 PC 제조업체, 소프트웨어 개발자, 하드웨어 사업자, 인터넷 서비스 제공자 또는 인터넷 콘텐츠 사업자 등(이하 “PC 제조업체등”이라 한다)과의 관계에서 다음의 행위를 하여서는 아니된다.

(1) PC 제조업체등이 WMP, 피심인들의 미디어 포맷, DRM, 코덱, 피심인 메신저 등(이하 “WMP등”이라 한다) 만을 공급, 판매, 임대, 판촉, 사용, 설치 또는 지원하는 것을 조건으로 거래하는 행위 또는 그러한 것을 조건으로 대가를 지급하거나 윈도우 PC 운영체제의 가격할인, 유리한 거래조건설정 등 경제적 또는 비경제적 이익을 제공하는 행위

(2) 피심인들은 PC 제조업체등이 WMP등의 경쟁제품을 판매, 임대, 판촉, 사용, 설치 또는 지원하거나 하려 한다는 것을 이유로, 경제적 또는 비경제적 이익의 제공을 축소 또는 중단하거나 기타의 거래조건을 불리하게 하는 등 어떠한 형태로든 보복하거나 보복할 것을 예고하는 행위

3. 이 시정명령의 시간적, 장소적 적용 범위는 다음과 같다.

가. 이 시정명령은 피심인들이 한국 내에 공급하는 윈도우 서버 운영체제 및 윈도우 PC 운영체제에 대하여 모두 적용된다. 다만, 한국 내에 공급하더라도 외국으로 반출될 것이 명백한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 이 시정명령은 시정명령일부터 10년간 효력을 유지한다. 다만, 피심인들은 시정명령일부터 5년의 기간이 경과한 이후 매년 이 시정명령을 재검토하여 줄 것을 공정거래위원회에 요청할 수 있다.

(1) 공정거래위원회는 피심인들의 요청이 있을 경우 시장여건의 변화 및 관련시장의 경쟁상황 등을 재검토하며, 검토 결과 이 시정명령이 실효성 있게 이행되어 관련시장의 경쟁상태가 현저히 호전되었다고 인정되는 경우에는 이 시정명령의 전부 또는 일부를 철회하거나 변경할 수 있다.

(2) 위 (1)항의 규정에 의한 철회 또는 변경의 효력은 철회 또는 변경 이전의 피심인들의 행위에 영향을 미치지 아니한다.

4. 이 시정명령의 집행에 관하여 이 시정명령에서 직접 정하지 아니한 구체적 사항은 이 시정명령일부터 120일 이내에 공정거래위원회가 피심인들의 의견을 참작하여 정한다.

5. 공정거래위원회는 이 시정명령의 이행에 필요한 기술적 사항을 정하고 이행사실 확인을 위한 자문을 얻기 위하여 '이행감시 자문기구'를 둘 수 있다. 그 구성 및 직무범위 등에 관한 사항은 공정거래위원회가 정한다.

6. 공정거래위원회는 합리적인 이유가 있을 경우 이 시정명령에 규정된 이행기간을 피심인들의 요청에 따라 변경할 수 있다.

7. 공정거래위원회가 피심인들의 의견을 참작하여 이행조치 내용을 결정하는 경우에는

피심인들은 성실하게 이에 협조하여야 하며, 피심인들이 협조하지 않거나 허위자료를 제출하는 등 신의성실의 원칙에 위반되는 행위를 하는 경우 공정거래위원회는 이 시정명령에서 정한 의견수렴 절차를 생략할 수 있다.

8. 피심인들은 다음 각 호에 정한 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액 : 총 32,490백만원(피심인 마이크로소프트 코퍼레이션 27,230백만원, 피심인 한국마이크로소프트 유한회사 5,260백만원)

(1) WMS의 결합판매 부분

(가) 피심인 마이크로소프트 코퍼레이션 626백만원

(나) 피심인 한국마이크로소프트 유한회사 1,667백만원

(2) WMP 및 피심인 메신저의 결합판매 부분

(가) 피심인 마이크로소프트 코퍼레이션 26,604백만원

(나) 피심인 한국마이크로소프트 유한회사 3,593백만원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 공통사실

가. 피심인 마이크로소프트 코퍼레이션에 대한 관할권

피심인 마이크로소프트 코퍼레이션(이하 '엠에스'라 한다)은 미합중국(이하 '미국'이라고 한다)의 관련법에 의해 설립된 외국사업자이나, 자회사인 마이크로소프트 라이센싱 제너럴 파트너쉽[1](Microsoft Licensing General Partnership, 이하 'MSLGP'라 한다)을 통하여 직접 국내 컴퓨터 제조업체(Original Equipment Manufacturer)에게 운영체제를 비롯한 소프트웨어 제품을 라이센스하는 계약을 체결하고 있고, 피심인 한국 마이크로소프트 유한회사(이하 '한국 엠에스'라 한다)에 대하여 경영정책이나 전략은 물론 마케팅, 기술 지원 등 세부 사항까지 지시와 감독을 하고 있다. 따라서, 피심인 엠에스의 결합 판매 행위는 한국 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다)의 규율대상이고, 공정거래위원회(이하 '위원회'라 한다)는 피심인 엠에스에 대한 관할권을 가진다.

피심인 엠에스가 MSLGP와 국내 컴퓨터 제조업체 간의 제품을 판매하기 위한 계약 과정에 직접적으로 관여하는 사실은 다음과 같은 계약 절차를 통하여 확인할 수 있다.

피심인 엠에스는 매년 2월경 피심인 제품의 라이센스에 대한 대략적인 계약서 초안을 피심인 한국 엠에스 및 국내 컴퓨터 제조업체에게 알려 준다. 국내 컴퓨터 제조업체는 이를 검토한 후 이에 대한 의견을 피심인 엠에스에게 제시한다. 위와 같은 과정을 여러 번 거침으로서 피심인 엠에스와 국내 컴퓨터 제조업체는 계약서 문안을 최종적으로 확정하는데, 피심인 엠에스는 위 과정에서 자사의 직원을 한국에 보내 직접 국내 컴퓨터 제조업체와 계약 체결을 위한 협의를 하기도 한다.

---

1) 마이크로소프트 코퍼레이션이 대부분의 지분을 가지고 있는 회사로서 윈도우 운영체제를 비롯한 엠에스 제품의 전세계 라이센스를 담당하고 있다

피심인 엠에스가 국내 컴퓨터 제조업체와의 협의 과정을 거쳐 도출된 계약서의 최종 문안을 피심인 한국 엠에스에 보내면, 피심인 한국 엠에스는 계약서를 2부 작성하여 국내 컴퓨터 제조업체에 송부한다. 국내 컴퓨터 제조업체는 송부받은 계약서 원본 2부에 각각 서명한 후, 이를 다시 피심인 한국 엠에스에 전달한다. 피심인 한국 엠에스는 전달받은 계약서 원본 2부를 MSLGP에 전달하고, MSLGP는 위 계약서 2부에 서명한 후 그 중 원본 1부를 국내 컴퓨터 제조업체에 송부함으로써 계약절차가 종료한다. 이후 MSLGP는 원본 계약서의 사본을 피심인 엠에스에 송부한다.

나. 피심인 적격성

피심인 엠에스, 한국 엠에스는 서버 운영체제, 개인용 컴퓨터(이하 'PC'라 한다) 운영체제 및 미디어 서버 프로그램, 미디어 플레이어, 메신저 등의 소프트웨어를 개발 및 제작하고 이를 판매하는 자들로서 공정거래법 제2조 제1호에 정한 사업자에 각 해당한다.

다. 피심인 엠에스와 피심인 한국 엠에스의 관계

피심인 한국 엠에스는 피심인 엠에스가 지분을 100% 소유하고 있는 한국 현지법인으로서, 피심인 엠에스의 전세계 조직 중 아시아·태평양 지역의 하부 조직에 해당하고, 위에서 검토한 바와 같이 경영 정책이나 전략은 물론 마케팅, 기술지원 등 세부 사항까지 피심인 엠에스의 지시와 감독을 받는다.

따라서 당해 사건과 관련하여 시장지배적 지위의 판단, 경쟁제한성의 판단 등에 있어서는 피심인 엠에스와 피심인 한국 엠에스(이하 이를 통칭할 경우 '피심인들'이라 한다)를 경제적으로 동일한 실체로 보아 하나의 사업자의 행위로 간주하기로 한다.

라. 피심인들의 일반 현황

피심인 엠에스는 주요 제품을 설계 및 제조하고, 제품의 판매는 세계 각지에 설립된 현지 법인을 통하는 것이 일반적이다. 그러나, 일부 제품은 피심인 엠에스가

MSLGP를 통하여 제품을 판매하기도 한다. 피심인 한국 엠에스는 피심인 엠에스의 국내 영업을 담당하고 있는 현지 법인으로 피심인 엠에스의 주요제품을 한글화하고, 한국내 판매업무 등을 주로 담당한다. 피심인들의 일반 현황 및 피심인들의 각 매출액은 다음 표에서 보는 바와 같다.

<표 1-1> 피심인들의 일반현황

(2004. 6. 기준)

피심인	설립일자	주요사업내용	자본금	매출액	당기순이익	상시종업원수
엠에스	1975.4	소프트웨어 개발 및 판매	35,344백만불	36,835백만불	8,168백만불	48,030명
한국 엠에스	1988.9	소프트웨어판매 및 무역업	1억5천만원	233,037백만원	8,749백만원	420명

*출처 : 피심인들 제출자료

<표 1-2> 피심인 엠에스의 매출액 등

(단위 : 미화 백만달러)

회계연도	2000	2001	2002	2003	2004
매출액	22,956	25,296	28,265	32,187	36,835
영업이익	11,006	11,720	11,910	13,217	9,034
당기순이익	9,421	7,721	7,829	9,993	8,168

*출처 : 피심인들 제출자료

<표 1-3> 피심인 한국엠에스의 매출액 등

(단위 : 백만원)

회계연도	2000	2001	2002	2003	2004
매출액	148,176	235,931	236,878	213,253	233,037
영업이익	49,281	46,989	3,296	-24,363	-10,835
당기순이익	40,665	47,754	12,431	34,976	8,748

*출처 : 피심인들 제출자료

마. 미국과 유럽연합에서의 피심인 엠에스에 대한 경쟁당국의 조사 및 조치 경위

위원회의 이 사건 심사와 별도로, 피심인 엠에스는 미국과 유럽연합(European Union, 이하 'EU'라 한다)에서도 자신이 제조·판매하는 PC 운영체제 등의 소프트웨어 공급과 관련하여 독점금지법 위반 협의로 경쟁당국의 조사를 받고 법 위반으로 시정조치 등을 받거나 관련 소송 중에 화해를 한 바 있다.

미국에서의 피심인 엠에스에 대한 경쟁당국의 조사 및 조치 경위를 살펴보면 다음과 같다.

1998년 미국 법무부 및 20개 주정부는 피심인 엠에스를 셔먼법(The Sherman Act) 위반으로 제소하였다. 제소내용은 주로 피심인 엠에스가 넷스케이프(Netscape)의 웹 브라우저인 네비게이터(Navigator)와 썬 마이크로시스템즈(Sun Microsystems Inc. 이하 '썬'이라고 한다)의 자바테크놀로지(Java Technology)에 대응하여 취한 다양한 행위들에 관한 것이었다.

즉, 원고는, 피심인 엠에스가 불법적으로 배타적 거래 행위를 하고, PC 운영체제인 윈도우 95와 윈도우 98에 인터넷 익스플로러를 끼워 팔아 셔먼법 제1조를 위반하고, 불법적으로 PC 운영체제의 독점을 유지하기 위한 행위를 하고, 인터넷 브라우저 시장에서 독점화를 기도한 행위를 하여 동법 제2조를 위반하였다고 주장하였다.

2000. 4. 3. 관할 연방지방법원(US District Court for the District of Columbia)은 끼워팔기, 독점화 유지, 독점화 기도 부분에 대해서는 피심인 엠에스의 책임을 인정하였으나 배타적 거래 부분은 충분한 증거가 없다고 기각하였다. 동 법원은 같은 해 6. 7. 법무부 등이 제안한 피심인 엠에스의 분할명령을 승인함과 아울러 분할될 때까지 피심인 엠에스의 영업행위를 임시적으로 제한하는 조치를 하였다. 이에 대하여 원고는 기각부분에 대하여, 피심인 엠에스는 인용부분에 대하여 각각 항소하였다.

2심인 연방항소법원(The Court of Appeals)은 연방지방법원의 판결 중 PC 운영체제 시장의 독점화 유지 부분은 원심을 유지하여 피심인 엠에스의 항소를 기각하였으나, 브라우저 시장 독점화 기도부분은 원고가 관련시장 획정과 진입장벽을 증명하지 못하였다는 이유로 피심인 엠에스의 항소를 받아 들여 원고의 청구를 기각하였다. 다만, 끼워팔기 부분은 결합판매로 인한 효율성 증대효과가 발생할 수 있으므로 당연위법 원칙이 아닌 합리의 원칙에 의거하여 재심리 할 것을 원심인 연방지방법원에 명령하였다.

연방항소법원의 판결 이후 미국 법무부와 뉴욕주를 포함한 9개주는 피심인 엠에스와 소송상 화해를 하였다. 나머지 주는 위법성 여부에 대한 판단을 구하는 소송을 계속 진행하였다.

이에 따라 연방지방법원에서는 동 화해안이 공익에 부합하는지 여부를 심리하는 절차와 소송 절차를 동시에 진행하였고, 2002. 11. 화해안이 공익에 부합한다는 판결을 내림과 동시에 소송을 계속 진행한 9개주의 청구를 기각하였다. 매사츄세츠주는 이러한 연방지방법원의 판결에 불복하여 항소를 제기하였으나 2004. 6. 항소가 기각되었다.

한편, EU에서의 피심인 엠에스에 대한 경쟁당국의 조사 및 조치 경위를 살펴보면 다음과 같다.

서버 운영체제 사업자인 썬은 1998. 12. 유럽집행위원회(European Commission, 이하 'EC'라 한다)에 피심인 엠에스의 행위가 EU 조약(The Rome Treaty) 제82조에 위반한다고 신고하였다. 썬에 의하면 PC 운영체제 시장에서 독점적 지위에 있는 피심인 엠에스가 썬의 서버 운영체제와 피심인 엠에스의 PC 운영체제가 상호 작동하기 위해 필요한 정보를 자신에게 충분히 제공하지 않고 있는데, 이러한 행위는 시장지배적 지위남용행위에 해당한다는 것이다.

위 신고사건 진행 중에 EC는 2000. 2.부터 추가로 피심인 엠에스가 윈도우 PC 운영체제에 오디오 및 비디오 재생 소프트웨어인 WMP를 결합하여 판매한 행위에 대하여 직권으로 조사를 시작하였다.

2004. 3. EC는 피심인 엠에스의 위 '서버 운영체제와 관련된 정보공개 거부행위' 및 'WMP 끼워팔기'가 시장지배적 지위남용행위에 해당한다고 판단하여 피심인 엠에스에 대해 통신 프로토콜에 대한 정보를 제공할 것과 WMP를 분리한 윈도우 PC 운영체제 외에도 기존에 공급하던 WMP를 탑재한 윈도우 PC 운영체제를 공급할 것을 명령하고 약 4억 9,700만 유로(6억 1,300만 달러)의 벌금(fine)을 부과하였다.

2004. 6. 피심인 엠에스는 EC의 결정에 불복하여 EU 1심법원(CFI : Court of First Instance)에 EC 결정의 취소를 구하는 소송을 제기하고 동시에 EC의 시정조치에 대한 집행정지 가처분 신청을 하였으나, EU 1심법원은 2004. 12. 23. 피심인 엠에스의 집행정지 가처분 신청에 대하여 피심인 엠에스가 EC의 시정조치가 회복 불가능한 피해를 입힌다는 점을 입증하지 못하였다는 이유로 동 신청을 기각하였고 본안소송은 2006. 2. 현재 아직 계속 중이다.

마. 이 사건의 심의 경위

주식회사 다음커뮤니케이션은 2001. 9. 5. 피심인들이 제작·판매하는 윈도우XP에 메신저를 끼워팔기 함으로써 메신저 시장의 경쟁을 제한하고 있다는 취지로 위원회에 신고하였다.

이에 따라, 위원회는 2002. 4. 4. 사건심사 착수보고를 하였고 수 차례에 걸쳐 기초자료를 수집하고 신고인과 피심인들의 의견을 다음과 같이 청취하였다. 위원회는 2002. 4. 29. 신고인의 프로그램 시연 및 진술을, 같은 해 5. 20. 피심인들의 윈도우 XP 시연 및 진술을, 2004. 3. 24. 비공개로 신고인 및 피심인들의 의견을 각 청취하였다.

이러한 조사과정에서 위원회는 2004. 4. 윈도우 서버 운영체제와 WMS를 결합판매한 행위와 윈도우 PC 운영체제와 WMP를 결합판매한 행위를 직권으로 인지하고 2004. 6. 10.부터 14.까지 피심인 한국 엠에스에 대한 현장조사를 실시하였다. 리얼네트웍스는 2004. 10. 28. 위원회가 직권 인지한 내용과 동일한 취지의 신고서를 위원회에 접수하였다.

위원회는 피심인들의 결합판매행위가 시장에 미치는 영향을 분석하기 위해 2004. 7. 19.부터 8. 20.까지 중앙리서치를 통해 미디어 서버 사용현황과 미디어 서비스 시장 상황에 대한 소비자 인식 그리고 미디어 플레이어 사용현황과 미디어 플레이어 관련 쟁점들에 대한 소비자 인식을 조사하였다.

이러한 조사자료, 신고인 및 피심인들의 의견을 바탕으로 피심인들의 결합판매행위에 대한 검토의견을 2004. 11. 4. 피심인들에게 송부하여 의견을 조회하였고 2005. 1. 6. 피심인들의 답변서를 접수하였으며, 신고인 리얼네트웍스가 같은 해 1. 19. 피심인들의 결합판매행위에 대한 의견 및 소명자료를 제출하였다.

심사관은 피심인들의 결합판매행위에 대한 심사보고서를 2005. 3. 31. 위원회의 전원회의에 상정하고 피심인들에 대해 의견을 조회하였으며, 같은 해 7. 8. 피심인들이 심사보고서에 대한 의견을 제출하였다.

이후 위원회는 2005. 7. 13.부터 10. 26.까지 총 7차례에 걸쳐 피심인들의 결합판매행위에 대한 위법성 존재여부를 판단하기 위한 심의를 열었는 바, 그 과정에서 피심인들은 같은 해 10. 13. 신고인 리얼네트웍스와, 같은 해 11. 11. 신고인 주식회사 다음커뮤니케이션과 각 합의[2]를 하였고, 위 신고인들은 신고를 각 취하하였다. 그러나, 신고인의 위원회에 대한 신고는 사건의 단서를 제공하는데 불과하므로 위원회는 신고 취하 여부와 상관없이 심의를 계속하였고 2005. 12. 7. 이 사건의 최종결정이 내려졌다.

2. 윈도우 서버 운영체제와 윈도우 미디어 서비스 결합판매

가. 기초사실

(1) 서버 운영체제의 현황

서버 운영체제는 클라이언트·서버(client-server) 개념에서 서버쪽 컴퓨터의 운영체제를 말하는 바, 서버 운영체제는 서버용 응용 프로그램이 잘 작동할 수 있도록 플랫폼[3] 역할을 하며, 프린터 제어나 파일 공유 등 네트워크 전체를 감시·제어하거나 메인

2) 신문기사 등에 의하면 피심인들과 주식회사 다음커뮤니케이션이 3천만달러에 합의한 것으로 보도되었다.

3) 컴퓨터 2004. 2. 10. 선고시스템의 기반이 되는 하드웨어나 소프트웨어를 말한다. 컴퓨터는 맨 아래층인 집적 회로 칩(IC chip) 수준의 하드웨어층, 그 다음 층인 펌웨어(firmware)와 운영 체계(OS)층, 맨 위층인 응용 프로그램층으로 구성되는 계층화된 장치이므로, 이 장치의 맨 아래층만을 흔히 플랫폼이라고 부른다. 그러나 응용 프로그램의 설계자들은 하드웨어와 소프트웨어를 모두 플랫폼이라고 부른다. 그 이유는 하드웨어와 소프트웨어가 응용에 대한 지원을 제공하기 때문이다.

프레임이나 통신망을 통한 다른 네트워크와의 연결, 데이터 프로그램, 파일 같은 자원이나 모뎀, 팩스, 프린터, 기타 장비 등 하드웨어 자원을 공유하도록 하는 기능을 수행한다. 이러한 서버 운영체제는 다양한 사업자들에 의해 개발·공급되고 있는데, 그 현황은 다음과 같다.

(가) 피심인들의 윈도우 서버 운영체제

피심인들은 자신의 서버 운영체제로 '윈도우 엔티 어드밴스드(NT Advanced) 서버 3.1'을 1993. 7. 처음 출시한 이래로 일련의 윈도우 엔티(NT) 시리즈를 개발·공급하였고, 윈도우 엔티(NT) 서버는 '윈도우2000 서버' 및 '윈도우 서버 2003'으로 이어져 현재에 이르고 있다.

<표 2-1> 피심인들의 서버 운영체제 출시 내역

제품명	출시일
윈도우NT Advanced 서버 3.1	1993. 7
윈도우NT 서버 3.5	1994
윈도우NT 서버 4.0	1996
윈도우NT 서버 4.0. Enterprise Edition	1997
윈도우NT 서버 4.0. Terminal Server Edition	1998
윈도우2000 서버	2000. 2
윈도우서버 2003	2003. 4

* 출처 : 피심인 엠에스 웹사이트 (http://www.microsoft.com/windows/WinHistoryServer.mspx)

피심인들이 윈도우 엔티(NT) 서버 시리즈에 이어 2000. 2. 출시한 윈도우2000 제품군에는 클라이언트용과 서버용 운영체제가 모두 있는 바, 클라이언트용으로는 윈도우2000 프로페셔널(이후 윈도우XP로 발전), 서버용으로는 윈도우2000 서버, 윈도우2000 어드밴스드(Advanced) 서버, 윈도우2000 데이터센터(Datacenter) 서버 등이 있다.

2003. 4. 출시된 윈도우 서버 2003은 스탠다드 에디션(Standard Edition), 엔터프라이즈

에디션(Enterprise Edition), 데이터센터 에디션(Datacenter Edition), 웹 에디션(Web Edition) 등 네 가지 제품이 있고 그 중 엔터프라이즈 에디션과 데이터센터 에디션은 32비트(bit) 버전과 64비트 버전이 있다.

윈도우2000 서버와 윈도우 서버 2003의 각 버전 중 윈도우 서버 2003 엔터프라이즈 에디션, 데이터센터 에디션의 64비트 버전, 윈도우 서버 2003 웹 에디션의 경우에는 WMS가 포함되어 있지 않으나, 나머지 버전들은 모두 WMS를 포함하고 있다.

피심인들은 순수한 소프트웨어 사업자에 해당하므로 자신이 개발한 운영체제를 컴퓨터 제조업체(Original Equipment Manufacturer)에 라이센스하여 컴퓨터를 구매하는 소비자로 하여금 이용하도록 하거나, 소비자에게 직접 라이센스하는 방법으로 제품을 공급한다.

윈도우2000 서버 및 윈도우 서버 2003의 각 버전별 특징 및 가격은 <표 2-2>와 같고, 피심인들의 국내 서버 운영체제의 매출액 현황은 <표 2-3>과 같다.

<표 2-2> 윈도우 서버 운영체제의 각 버전별 특징 및 가격

(단위 : 천원)

종 류	버 전	판매가격	특 징
윈도우2000 서버	Standard	1,347	소규모 업체와 부서에 비즈니스 솔루션 제공
	Advanced	5,347	모든 규모의 업체와 부서에 비즈니스 솔루션 제공
	Datacenter	+	가장 높은 수준의 확장성 및 가용성을 제공
윈도우서버 2003	Standard	1,507	소규모 업체와 부서에 비즈니스 솔루션 제공
	Enterprise	5,784	중대규모 업체와 부서에 비즈니스 솔루션 제공
	Datacenter	+	가장 높은 수준의 확장성, 가용성 및 안정성을 제공
	Web	+	웹서버와 호스팅 기능 제공

* '+'는 미국 본사와 하드웨어 제조업체 간의 직접 계약을 통해서 공급되기도 하고, 해당 업체에 대한 공급량에 따라 가격이 변동되므로 정확한 판매가격을 확인하기 어려움

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 7. 30.)

<표 2-3> 피심인들의 국내 서버 운영체제 매출액 현황

(단위 : 천원)

구분		윈도우2000 서버			윈도우서버 2003			업데이트	총계
		Standard	Advanced	Datacenter	Standard	Advanced	Datacenter		
2000	한국MS								
	MS								
2001	한국MS								
	MS								
2002	한국MS								
	MS								
2003	한국MS								
	MS								
2004	한국MS								
	MS								
2005. 10.26.	한국MS								
	MS								
합계									104,295,353

* 출처 : 피심인들 제출자료(단, 피심인들이 사업상 비밀이라는 이유로 비공개 요청하여 합계만 공개)

(나) 피심인들 이외의 서버 운영체제

1) 유닉스 제품군

유닉스(UNIX)는 1970년대 미국 벨 연구소가 컴퓨터 프로그램의 연구 및 개발을 촉진하기 위한 환경을 조성하기 위해 개발한 운영체제로서, 다수의 사용자를 전제로 개발되었는 바, 이후 유닉스는 프리웨어(freeware)인 공개 소프트웨어 제품의 한 종류로 발전하였다.

그 결과, 사업자들은 유닉스의 공개된 소스 코드를 이용하여 이를 수정하거나 개선시켜 유닉스에 기반한 다양한 제품들을 개발하여 공급하고 있다. 널리 알려진 것으로 썬의 솔라리스(Solaris) 운영체제, 휴렛팩커드(Hewlett Packard)의 에이치피 유엑스(HP-UX), 아이비엠(IBM)의 에이아이엑스(AIX) 등이 있다. 이러한 유닉스군 공급업체들은 유닉스 서버 운영체제를 대부분 자신의 하드웨어와 일체로 공급하기 때문에, 운

영체제만을 별도로 판매하는 경우는 드물다.

2) 리눅스 제품군

리눅스(Linux)는 1991년 핀란드 헬싱키대학 학생이던 리누스 토발즈(Linus Torvalds)가 대형 컴퓨터에서만 작동하던 운영체제인 유닉스를 PC 서버 뿐만 아니라 PC에서도 작동할 수 있도록 만든 운영체제이다. 이 운영체제는 인터넷을 통해 프로그램 소스 코드를 무료로 공개하였기 때문에 사용자는 원하는 대로 특정 기능을 추가할 수 있을 뿐 아니라 각종 주변기기에 따라 혹은 사용하는 시스템의 특성에 맞게 소스 코드를 변경할 수 있어 많은 사업자들이 다양한 리눅스 제품들을 개발하여 공급하고 있다.

국내외에 존재하는 리눅스 공급업체로는 레드햇(Red Hat)리눅스, 수세(SuSE)리눅스, 한컴리눅스, 와우리눅스 등이 있는데, 그 중에서도 대표적인 리눅스 사업자들인 레드햇 리눅스나 수세 리눅스는 운영체제만을 개발·공급할 뿐이고, 하드웨어를 개발하여 공급하지는 않는다. 따라서 이들은 썬, 휴렛 패커드, 아이비엠(IBM), 델(Dell) 등 하드웨어 제조업체들과 협력관계를 맺어 이들이 공급하는 하드웨어에 자신의 리눅스 운영체제를 탑재하여 일체로 판매하거나, 하드웨어와는 별개로 소프트웨어만을 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 영업하고 있다.

3) 기타 운영체제

서버 운영체제에는 위에서 본 것 외에도, 애플(Apple, 이하 '애플'이라 한다)이 유닉스를 기반으로 만든 맥 오에스 엑스(Mac OS X) 서버 운영체제, 아이비엠(IBM)이 인텔 호환용으로 만든 OS/2 워프(Warp) 서버 운영체제 등이 있다.

(2) 미디어 서버 프로그램 현황

미디어 서버 프로그램[4] 사업자들은 피심인들이나 애플처럼 서버 운영체제 사업자인

4) 사용자의 요청에 의해 인터넷 등을 통하여 '디지털 콘텐츠'를 전송해 주는 기능을 수행하는 서버용 응용프로그램을 말한다.

동시에 미디어 서버 프로그램을 개발·판매하는 업체들과 리얼네트웍스(RealNetworks, Inc. 이하 '리얼네트웍스'라 한다), 주식회사 디디오넷(이하 '디디오넷'이라 한다)과 같이 미디어 서버 프로그램만을 개발하여 공급하는 업체들로 분류될 수 있다. 이러한 미디어 서버 프로그램은 대부분 윈도우를 포함한 다양한 운영체제 위에서 설치·작동할 수 있도록(cross-platform) 개발·공급된다.

미디어 서버 프로그램은 일반적으로 전문적인 솔루션(solution)업체나 시디엔(CDN : content delivery network)서비스[5] 업체 등을 통하여 최종사용자에게 판매되는데, 전문 솔루션 업체들은 일반적으로 최종사용자인 콘텐츠 사업자들에게 캡쳐 카메라, 하드웨어와 소프트웨어 등을 포함한 스트리밍 미디어 서비스를 제공하기 위해 필요한 기기 일체를 공급·설치하여 준다.

따라서 미디어 서버 프로그램 공급업체들은 보통 솔루션업체들이나 CDN서비스 업체에 제품을 공급하는 방식으로 제품을 판매한다. 그러나, 국내업체인 디디오넷, 쌘뷰텍과 같이 스스로 솔루션 사업자가 되어 자신의 제품이 포함된 스트리밍 미디어 서비스에 필요한 기기일체를 소비자에게 직접 공급하는 경우도 있다.

(가) 피심인들의 미디어 서버 프로그램

피심인들은 1996년 사용자가 주로 자신의 인트라넷(intranet)[6] 을 통하여 직원들에게 기본적인 스트리밍 서비스를 제공할 수 있는 '넷쇼'(NetShow)를 출시하고, 1997. 5. 에는 인터넷을 통해서도 일반인들에게 스트리밍 서비스를 할 수 있는 넷쇼 2.0 베타버전을 제공하기 시작하였다. 넷쇼 2.0은 클라이언트용 소프트웨어인 넷쇼 플레이어(NetShow Player)와 함께 제공되었다.

피심인들은 1998. 7. 넷쇼 3.0을 제공하면서 미디어 플레이어(Media Player)와 넷쇼

5) CDN 서버를 이용하여 콘텐츠 전송을 전문적으로 하는 인터넷 서비스를 말하는데 넓은 공간에 산재한 인터넷 사용자들이 빠른 속도로 편리하게 콘텐츠를 이용하도록 하기 위해 CDN 서비스 업체가 미리 곳곳에 서버를 설치하여 놓고 콘텐츠 제공업체들로 하여금 이러한 CDN 업체의 서버를 이용하여 이용자들에게 서비스를 제공하도록 하는 것을 말한다

6) 인터넷 기술과 통신규약을 이용하여 조직 내부의 업무를 통합하는 정보시스템을 말한다

씨어터 서버(NetShow Theater Server)를 함께 발표하였다. 미디어 플레이어는 종전의 넷쇼 플레이어를 명칭만 바꾼 것으로서 넷쇼에서 제공하는 콘텐츠를 보기 위한 클라이언트용 프로그램이다. 넷쇼 씨어터 서버는 넷쇼 3.0과 마찬가지로 서버용 소프트웨어이나 넷쇼가 제공하는 미디어 서비스보다 품질이 좋은 서비스, 즉 넓은 대역폭에서 고품질(MPEG 1, 2를 지원하며 data rate가 500Kbps로부터 8Mbps에 이른다)의 비디오 스트리밍 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 넷쇼와 차별성이 있었다. 넷쇼 씨어터 서버는 서버 운영체제와는 별도로 서버당 약 $2,499에 판매되었으며, 1998. 7. 출시되어 2000. 12. 판매가 중단되었다.

넷쇼 3.0은 1999. 4.부터 버전 4.0이 되면서 명칭이 WMS로 바뀌어 WMS 4.0으로 제공되었다. WMS 4.0은 윈도우NT 서버 4.0에 이용될 목적으로 개발·공급된 것으로, 인터넷을 통한 다운로드에 의해서만 사용자들에게 제공되었다. WMS 4.0은 어떠한 윈도우 서버 운영체제에도 포함되지 않았다.

피심인들은 2000. 2. 출시된 윈도우2000 서버부터는 서버 운영체제에 WMS 4.1을 포함하여 판매하기 시작하였는 바, 현재는 윈도우서버 2003에 WMS 9를 포함하여 판매하고 있다. WMS 4.1과 WMS 9는 기본으로 설치되지는 않고 윈도우서버 2000 및 2003의 옵션기능으로서 추가적인 설치과정을 거친다.

(나) 피심인들 이외의 미디어 서버 프로그램

1) 리얼네트웍스의 리얼미디어 서버

리얼네트웍스는 독자적인 디지털 미디어 시스템을 보유한 소프트웨어 업체로서 1995년 인터넷을 통한 상업적인 스트리밍[7] 오디오 서비스를 가능하게 한 리얼오디오 서버(RealAudio Server)와 리얼오디오 플레이어(RealAudio Player)를 업계 최초로 출시하였다. 그 후, 리얼네트웍스는 리얼미디어 서버(RealMedia Server), 리얼플레이어

7) 인터넷에서 음성이나 영상 등을 실시간으로 재생하는 기술을 말한다. 인터넷에서 음성이나 영상 등의 파일을 하드 디스크에 다운로드 받아 재생하던 것을 다운로드 없이 실시간으로 재생해주는 기술로서, 전송되는 데이터가 마치 물이 흐르는 것처럼 처리된다고 해서 '스트리밍'이라는 명칭이 붙여졌다.

(RealPlayer), 리얼프로듀서(RealProducer) 등 일련의 발전된 디지털 미디어 제품을 개발·공급하고 있다.

리얼네트웍스는 2002. 7. 윈도우 미디어 포맷을 비롯한 다양한 미디어 포맷을 스트리밍할 수 있는 미디어 서버인 헬릭스 유니버셜 서버(Helix Universal Server, 이하 '헬릭스 서버 프로그램'이라 한다)를 출시하였다. 헬릭스 서버 프로그램은 윈도우 서버 운영체제, 리눅스는 물론 솔라리스(Solaris), 에이아이엑스(AIX), 에치피유엑스(HP-UX) 등 다양한 유닉스 제품에 모두 탑재될 수 있는 프로그램이기 때문에 WMS와는 달리 대부분의 서버 운영체제에서 모두 사용될 수 있다.

한편, 리얼네트웍스는 RA, RM 등 고유의 미디어 포맷[8](이하 '리얼미디어 포맷'이라 한다)을 개발·보유하고 있다.

2) 디디오넷의 씨비디오

디디오넷은 2001. 9. 12. 설립된 멀티미디어 스트리밍 전문 벤처기업으로, MPEG[9]4 규격으로 인코딩된 고화질 동영상 파일을 인터넷 등을 통하여 스트리밍할 수 있는 고화질 실시간 주문형 비디오(VOD: Video On Demand)[10] 솔루션인 씨비디오(SeeVideo)를 판매하고 있다. 씨비디오는 윈도우 운영체제를 제외한 리눅스 운영체제와 유닉스 운영체제에 탑재되어 사용될 수 있다.

디디오넷의 씨비디오 디지털시스템은 그들이 독자 개발한 미디어 서버인 씨비디오, 코덱[11]인 SMV/SMA, 인코더[12]인 SeeEncoder, 미디어플레이어인 SVWeb Player

8) 미리 정해진 자료의 배치방식을 말한다. 데이터의 저장이나 전송시의 구성방법, 특히 자료를 파일로 저장할 때 그 파일의 구조를 의미하는 경우도 있다. 컴퓨터 프로그램에 있어서는 흔히 .wav와 같은 형태로 표현된다.

9) 세계 디지털 영상 기술자들이 모여 1998년 결성한 표준화 그룹인 MPEG(Moving Picture Experts Group)위원회에서 제정한 동영상/음성의 압축과 재생에 관한 규약을 말한다. MPEG 1은 CD에 동영상을 압축한 Video CD의 압축규격으로, MPEG 2는 고화질 방송용 영상을 얻는 것을 목적으로 개발되어 DVD 압축기술로 이용되고 있다. 최근에는 MPEG 4, MPEG 7 등으로 발전하여 차세대 디지털 방송의 표준으로 주목받고 있다.

10) 원하는 영상 파일을 인터넷을 통해 원하는 시간에 들을 수 있는 일체의 서비스를 말한다. 이러한 서비스를 구성하는 요소 중 가장 중요한 구성요소가 미디어 서버 프로그램과 미디어 플레이어이다.

등으로 구성되어 공급된다.

3) 쌘뷰텍의 쌘스트림

쌘뷰텍은 2001. 10. 26. 설립된 멀티미디어 스트리밍 전문 벤처기업으로, 콘텐츠 압축기술(MPEG4 ASP 및 AVC)과 연동된 고화질 스트리밍 서비스를 제공하는 쌘스트림(SanStream)을 판매한다. 쌘스트림은 리얼네트웍스의 미디어 서버 프로그램과 마찬가지로 윈도우 서버 운영체제, 리눅스는 물론 솔라리스(Solaris) 등 다양한 운영체제에 모두 탑재될 수 있는 프로그램이다.

쌘스트림 디지털시스템은 독자 개발한 스트리밍 기술을 이용한 미디어 서버 프로그램인 쌘스트림, 코덱인 MPEG4 ASP/AVC, 미디어플레이어인 샌스트림 플레이어(SanStream Player) 등으로 구성되어 공급된다.

4) 기타

미디어 서버 프로그램의 국내외 대표적인 제품에는, 위에서 본 것 외에도 애플의 퀵타임 스트리밍 서버(QuickTime Streaming Server), 다윈 스트리밍 서버(Darwin Streaming Server) 및 한국 업체인 보람 C&C의 인터넷아이(Internet Eye) 등이 있다.

나. 행위 사실

피심인들은 2000. 2.부터 윈도우2000 서버에 WMS 4.1을, 2003. 4.부터는 윈도우 서버 2003에 WMS 9를 각 결합하여 판매하는 행위를 하고 있다.

---

11) 음성 또는 영상의 신호를 압축하여 디지털 신호로 변환하는 코더(coder)와 그 반대로 변환시켜 주는 디코더(decoder)의 기능을 함께 갖춘 기술을 말한다. 보통 비디오와 같이 용량이 큰 파일이 차지하는 많은 저장공간을 최소화하기 위하여 코덱을 사용하여 압축한 후 이를 전송하고, 전송받은 측에서는 코덱의 디코더 기능을 이용하여 압축을 풀어 전송받은 비디오 파일을 보거나 듣는데 이용한다.

12) 영상이나 음성 등 소스(Source:디지털 형태로 만들기 전에 실제 장면을 촬영 혹은 녹음한 기록물)를 디지털 형태로 전환하는 프로그램이다. 리얼네트웍스(RealNetworks)의 리얼시스템 프로듀서(RealSystem Producer), 헬릭스 프로듀서(Helix Producer), 마이크로소프트(Microsoft)의 윈도우 미디어 인코더(Windows Media Encoder) 등이 인코더의 예이다.

다. 관련 시장의 획정

공정거래법 제2조 제8호에 의하면 관련 시장인 일정한 거래분야라 함은 거래의 객체별·단계별 또는 지역별로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 분야를 말하는 바, 거래 대상으로 구분되는 관련 상품 시장과 거래 지역으로 구분되는 관련 지역 시장은 다음과 같다.

(1) 관련 상품 시장

「시장지배적 지위남용 행위의 심사기준」(위원회 고시 제 2000-6호) 및 「기업결합 심사 기준」(위원회 고시 제1999-2호)에 의하면, 관련 상품 시장은 거래되는 특정상품의 가격이 상당기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상될 경우 동 상품의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 상품의 집합을 의미하고, 특정상품이 이에 포함되는지 여부는 상품의 기능 및 효용의 유사성, 상품 가격의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식, 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(가) 이 사건의 주된 상품 시장은 'PC 서버 운영체제 시장'이다.

PC 서버 운영체제와 가장 인접한 상품으로는 클라이언트용 PC 운영체제와 중대형 서버 운영체제를 들 수 있으나, 이들 상품들은 PC 서버 운영체제와 다음과 같이 대체성이 거의 없어 PC 서버 운영체제의 관련 상품 시장에 포함되지 않는다.

1) 클라이언트용 PC 운영체제는 PC 서버 운영체제를 대체하기 어렵다.

PC에 보통 탑재되는 클라이언트용 PC 운영체제는 PC 서버 운영체제와 기능·효용 및 가격이 뚜렷이 구별되고, 수요자와 공급자가 양 제품을 구분하여 인식하고 있어 서로 대체하기 어려우므로 본 건의 관련 상품 시장에 포함되지 않는다.

PC 서버 운영체제는 '서버/클라이언트' 라는 두 개의 컴퓨터 사이에 이루어지는 역할관계에서 서버쪽 컴퓨터 운영체제임에 비해, 클라이언트용 PC 운영체제는 서버에게 서비스를 요청하는 컴퓨터에 탑재되는 운영체제를 나타내므로 수행하는 기능 및 효용의 차이가 매우 뚜렷하고, PC 서버 운영체제는 클라이언트용 PC 운영체제에 비해 3배가 넘는 고가[13]로서 가격 면에서의 유사성이 없으며, 클라이언트용 PC 운영체제의 수요자가 일반 최종 사용자인데 반하여 PC 서버 운영체제의 수요자는 대부분 인터넷이나 네트워크를 통하여 고객에게 서비스를 제공하는 개인 또는 사업자라는 점에서 수요가 특정되어 양자가 구분되고, 공급자들도 위와 같은 차이를 인식하고 양자를 구분하여 공급하고 있으므로, PC 서버 운영체제의 가격이 상당기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상된다고 하더라도 PC 서버 운영체제 소비자들이 클라이언트용 PC 운영체제로 구매를 전환할 가능성이 없어 클라이언트용 PC 운영체제는 PC 서버 운영체제의 관련 상품 시장에 포함되지 않는다.

2) 중대형 서버 운영체제는 PC 서버 운영체제를 대체하기 어렵다.

PC 서버 운영체제는 다음과 같이 중대형 서버 운영체제와 기능 및 효용, 가격의 차이가 크고, 소비자가 양 운영체제를 구분하여 인식하고 판매자들도 구분하여 공급하는 바, PC 서버 운영체제의 가격이 상당기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상된다고 하더라도 PC 서버 운영체제의 수요자가 이에 대응하여 중대형 서버 운영체제로 구매를 전환하지는 않을 것으로 인정되므로 중대형 서버 운영체제는 PC 서버 운영체제의 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

가) PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제는 기능 및 효용의 차이가 크다.

PC 서버 운영체제는 x86계열[14] 서버 컴퓨터에 탑재되는데 비해, 중대형 서버 운영체

13) 피심인들의 경우 PC서버운영체제가 100만원 이상인데 비해 클라이언트용 PC운영체제는 30만원 수준이다

14) x86 프로세서는 인텔이 개발한 마이크로프로세서의 명칭을 단순화하여 부르는 명칭이다. 인텔 호환의 마이크로프로세서는 서로 유사한 구조를 가지며 8086, 80286, 80386, 80486, 펜티엄 등의 이름으로 출시되었는데 보통 이를 x86계열 마이크로프로세서라 부른다. '마이크로프로세서'란 컴퓨터의 연산장치와 제어장치를 1개의 작은 실리콘 칩에 집적시킨 디지털 논리회로로서 일종의 중앙처리장치(CPU)이다.

제는 주로 자사의 운영체제만이 탑재될 수 있는 non-x86계열[15] 서버 컴퓨터에 탑재되는 바, 이러한 하드웨어의 차이가 기능상 차이를 발생시킨다. 따라서, PC 서버 운영체제는 주로 웹 서버, 스트리밍 서버[16] 등 간단한 어플리케이션 플랫폼으로 통상 프론트엔드(front-end)[17] 서버에 사용되는데 비해, 중대형 서버 운영체제는 대부분 중요 업무에 전용으로 사용되는 데이터베이스 서버 등 백엔드(back-end)[18] 서버에 사용되어 양자 간에는 용도상 큰 차이가 존재한다. 따라서 PC 서버 운영체제를 중대형 서버 하드웨어에, 중대형 서버 운영체제를 PC 서버 하드웨어에 탑재하여 사용할 수 없다.

이에 대하여 피심인들은 리눅스 및 솔라리스(Solaris)와 같은 일부 유닉스는 x86과 non-x86 칩에 모두 사용될 수 있고 아이비엠은 소형서버부터 메인프레임까지 다양한 종류의 하드웨어에 탑재되어 구동될 수 있는 리눅스를 제공하고 있으므로 중앙처리장치(이하 'CPU'라 한다)의 종류에 따라 서버 운영체제 시장을 구분하는 것은 자의적이라고 주장한다.

그러나, 중대형 서버 운영체제와 PC서버 운영체제는 각각의 하드웨어에 사용되는 CPU가 주소 지정방식, 명령어 집합 등이 서로 각기 다르기 때문에 PC 서버 운영체제를 non-x86 계열의 CPU가 장착된 중대형 서버 하드웨어에 사용할 수 없고, 이러한 차이는 위에서 본 바와 같이 양 운영체제가 각각 어느 용도로 사용될 것인지를 결정짓게 된다. 따라서, 이러한 기능 및 효용의 차이는 소비자와 판매자가 양 운영체제를 구분하여 인식하고 이를 용도에 따라 소비하고 판매하게 하는 바, 피심인들의 주장과 같이 CPU의 차이만으로 시장을 획정한 것이 아니라 CPU 등 하드웨어의 차이가 중대형 서버 운영체제와 PC 서버 운영체제 간의 기능 및 효용의 차이를 발생시키는 주요 원인이라는 점에서 탑재되는 컴퓨터 CPU의 차이를 언급한 것일 뿐이다. 또한, 썬의 솔라리

15) x86 계열을 제외한 나머지 종류를 총칭하는 말로서 주로 인텔 외의 CPU 업체들(모토롤라, Sun, IBM 등)이 공급한다.

16) 한국소프트웨어진흥원의 미디어 서버 설문조사 결과에 따르면, 스트리밍 미디어 서비스의 대부분을 차지하고 있는 인터넷 방송업체의 약 97.5%가 PC 서버(x86서버)를 이용하여 서비스하고 있는 것으로 나타났다.

17) 프론트엔드와 백엔드는 프로그램 인터페이스와 서비스의 최초 사용자(이에는 사람 또는 프로그램이 모두 해당가능하다)와 관련된 특성을 나타내는 용어로서, 프론트엔드 서버는 시스템이나 장치의 맨 앞단에 위치하면서 외부로부터 입력을 받아들이는 서버를 의미한다.

18) 백엔드 서버는 웹사이트의 이면에서 동작하는 각종 데이터베이스, 업무처리 시스템, 웹사이트 관리시스템 및 타 시스템과 연계되는 서버를 말한다.

스(Solaris)의 경우 제품명이 같더라도 x86 CPU에서 작동되는 유닉스 서버 운영체제와 non-x86 CPU에서 작동되는 유닉스 서버 운영체제는 별개의 다른 제품으로, 소비자가 x86용 솔라리스를 구매하여 non-x86 CPU가 장착된 중대형 서버 컴퓨터에 탑재할 수는 없고, 이는 리눅스 서버 운영체제도 마찬가지라 할 것이므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

나) PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제는 가격이 유사하지 않다.

PC 서버 운영체제를 포함한 PC 서버 컴퓨터의 가격이 적게는 100만원부터 많게는 500만원인데 비해, 중대형 서버 운영체제를 포함한 중대형 서버 컴퓨터의 가격은 적게는 500만원부터 많게는 10억원 이상이 넘어가는 경우도 있어 가격차이가 5배에서 200배가 된다.

그런데 앞에서 살펴 본 바와 같이 PC 서버 운영체제는 x86계열 서버 컴퓨터에, 중대형 서버 운영체제는 non-x86계열 서버 컴퓨터에만 각 탑재될 수 있기 때문에 소비자는 PC 서버 운영체제를 구매하면 그에 맞는 x86 계열 서버 컴퓨터를, 중대형 서버 운영체제를 구매하기 위해서는 이를 포함한 중대형 서버 컴퓨터 전체를 구매하여야 하는 바, 서버 운영체제를 포함한 서버 컴퓨터의 가격 차이는 곧 소비자들에게는 PC 서버 운영체제 또는 중대형 서버 운영체제를 구매하는데 있어서의 가격 차이에 다름 아니므로 서버 운영체제를 구매하는 소비자들에 대하여 PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제 사이에 가격 면에서의 유사성이 존재하지 않는다.

다) 소비자들은 PC 서버 운영체제 및 중대형 서버 운영체제를 구분하여 인식하고 소비한다.

중대형 서버 운영체제는 중대형 서버 하드웨어에만 탑재될 수 있으므로, 소비자는 중대형 서버 하드웨어를 구입하지 아니하고서는 중대형 서버 운영체제를 사용할 수 없다. 따라서 PC서버 운영체제 및 주변기기를 포함한 PC 서버 컴퓨터 시스템을 이미 사용하고 있는 소비자가 중대형 서버 운영체제로 전환하기 위해서는 새로운 운영체제 뿐만 아니라 고가의 새로운 하드웨어와 주변장치들을 구입하여야 하고, 이와 같은 비용

외에도 소비자가 새로운 응용프로그램을 익히고 새로운 시스템에 적응하기 위하여 들여야 하는 학습비용이 또한 발생하므로 소비자는 양 상품을 구분하여 인식하고 용도에 따라 소비할 수 밖에 없다.

이에 대하여, 피심인들은 서버 운영체제의 주요 고객층이 기업에 고용된 아이티(IT) 전문가이며 이들은 모든 서버 운영체제의 작동방법에 대한 전반적 지식을 갖추고 있기 때문에, PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제 간의 전환비용이 크지 않다고 주장한다

그러나, 위에서 살펴 본 바와 같이 운영체제간의 전환을 위해서는 소비자가 부담해야 하는 학습비용을 제외하더라도 서버 운영체제 자체 및 응용프로그램, CPU 및 주변장치 등 하드웨어 전체를 교체하는데 따른 비용 발생이 상당히 크고, 서버 운영체제 간 운영방식의 차이에서 오는 숙련 비용도 발생하는 것이므로, 피심인들의 주장은 이유 없다.

라) 판매자들은 양 서버 운영체제에 대한 판매 전략 등 경영 계획을 구분하여 수립하고 실행한다.

휴렛팩커드(HP), 델(Dell), 아이비엠(IBM) 등 하드웨어와 중대형 서버 운영체제를 일체로 공급하는 공급자들은 PC 서버 운영체제시장과 중대형 서버 운영체제시장을 명백히 구분하여 판매 및 마케팅 전략을 수립하고, 각 시장에서의 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있는 바, 이는 서버 운영체제 사업자들이 PC 서버 운영체제시장과 중대형 서버 운영체제시장이 서로 다른 특성을 지니고 있을 뿐만 아니라 이점을 양시장의 참여자가 인식하고 있음을 나타낸다.

이는 2005. 7. 28.자[19]와 2005. 5. 9.자[20] 전자신문, 2004. 12. 22.자 디지털 타임즈[21] 등의 각종 컴퓨터 관련 전문 언론매체의 기사에서도 간접적으로 확인할 수 있다.

---

19) http://www.etnews.co.kr/news/print.html?id=200507270098

20) http://www.etnews.co.kr/news/print.html?id=200505060109

21) http://www.dt.co.kr/dt_txt_see.htm?article_no=20041222

이에 대하여, 피심인들은 기술적으로 소형 PC 서버(x86CPU) 여러 대가 수행하는 스트리밍 미디어 서비스를 고성능 유닉스 서버 1대로 대체할 수 있으므로 양자간에 대체성이 있다고 주장한다.

그러나, 복합적 기능을 갖는 상품들에 있어서 일부 기능적 대체성이 있더라도 경제적인 의미에서 대체성이 당연히 충족되는 것은 아니고, 앞서 살펴본 바와 같이 PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제는 기능 및 효용, 가격에서 뚜렷이 구별된다. 또한 콘텐츠 제공업자들은 수많은 곳에 산재한 인터넷 사용자들에게 빠른 전송 속도로 콘텐츠를 제공하기 위해서 CDN서비스를 이용하여 이를 해결하고 있는 바, 위 서비스는 비디오나 오디오와 같이 용량이 크거나 사용자들의 요구가 잦은 콘텐츠를 여러 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 접속점(POP: point of presence)에 설치한 CDN서버에 저장해 놓고 이용자들로부터 가장 가까운 CDN서버가 콘텐츠를 전송하도록 하는 서비스로서, 각 접속점에는 스트리밍 미디어 서버가 반드시 존재하여야 하므로 각 접속점에 분산되어 스트리밍 미디어 서버로 사용되는 여러 대의 PC서버를 한 장소에 위치한 1대의 고성능 유닉스 서버로 대체한다는 것은 불가능하다. 따라서 피심인들의 주장은 이유 없다.

(나) 이 사건의 종된 상품 시장은 '미디어 서버 프로그램 시장'이다.

웹 서버 프로그램, 메일 서버 프로그램 등은 다음에서 보는 바와 같이 미디어 서버프로그램과 기능 및 효용에서 차이가 존재하고, 이러한 차이로 수요자가 미디어 서버프로그램과 여타의 서버 프로그램을 구분하여 인식하므로, 미디어 서버 프로그램의 가격이 상당기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상된다고 하더라도 미디어 서버 프로그램의 수요자가 이에 대응하여 웹 서버 프로그램, 메일 서버 프로그램 등으로 구매를 전환하지는 않을 것이므로 웹 서버 프로그램 등은 미디어 서버 프로그램의 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

미디어 서버 프로그램은 스트리밍 미디어 서비스의 핵심으로서, 서버에 저장된 디지털 콘텐츠[22]를 최종사용자가 원할 때 언제든지 제공해 주거나 PC로부터 전달받은 스트

리밍 데이터를 최종사용자에게 실시간으로 제공하는 기능 등을 수행하는 점에서 웹페이지가 들어있는 파일을 사용자에게 제공하는 웹 서버 프로그램이나 전자메일의 송· 수신 등의 관리를 담당하는 메일 서버 프로그램 등의 다른 서버 프로그램과 기능 및 효용에서 차이가 크다.

특히 디지털 콘텐츠를 다운로드 방식으로 사용자에게 서비스할 수 있는 웹 서버프로그램은 디지털 콘텐츠를 스트리밍 방식으로 서비스할 수 있는 미디어 서버 프로그램과 그 기능 및 효용에서 아래에서 보는 바와 같이 뚜렷한 차이가 있다.

미디어 서버 프로그램을 이용한 스트리밍 방식은 사용자의 하드 디스크에 저장할 필요가 없어 실시간으로 콘텐츠를 재생하여 볼 수 있고, 자유로운 화면이동이 가능하며, 불법복제가 어려운데 비하여 웹 서버 프로그램을 이용한 다운로드 방식은 다운로드를 받아 하드디스크에 저장하여야 콘텐츠를 볼 수 있어 실시간 재생이 불가능하고, 다운로드를 받기 전에는 자유로운 화면이동도 할 수 없으며, 불법복제 및 배포가 상대적으로 쉽다 할 것인바, 웹 서버를 이용한 다운로드 방식은 미디어 서버 프로그램을 이용한 스트리밍 방식에 비해 기능 및 효용에서 한계가 존재한다.

미디어 서버 프로그램의 소비자인 콘텐츠 사업자들도 미디어 서버 프로그램을 이용한 스트리밍 방식과 웹서버를 이용한 다운로드 방식이 양 방식을 이용하는 고객 및 사용행태에 차이가 있고, 스트리밍 방식은 인터넷을 전제로 한 PC기반의 서비스인데 반하여 다운로드는 멀티 플랫폼 환경에서 이동성을 향유할 수 있는 서비스라는 점에서 구분된다는 사실을 잘 알고 있어 양자를 서로 대체가능하다고 인식하지 않는다.

이와 같은 사실은 위원회가 2005. 8. 11 실시한 국내 상위 10개 음악사이트에 대한 설문조사 결과와 피심인들이 2005. 7. 12. 위원회에 제출한 의견서에 첨부된 사업자 진술서의 진술 중 주식회사 A, 주식회사 B, 주식회사 C의 각 일부 진술, 피심인들이 신청한 참고인 a의 2005. 7. 14. 심판정에서의 일부 진술 등을 종합하여 볼 때 인정할 수 있다.

---

22) 부호·문자·음성·음향·이미지 또는 영상 등으로 표현된 자료 또는 정보로서 그 보존 및 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것을 말한다. 이하 '콘텐츠'라 한다.

또한, 미디어 서버 프로그램 시장에 진입하기 위해서는 미디어 서버 프로그램뿐만 아니라 이와 함께 호환되는 디지털 미디어 시스템(Digital Media System)[23]의 각 구성요소들 즉, 코덱, 포맷, 인코더, 미디어 플레이어[24] 등을 라이센스받거나 이를 독자적으로 개발하여야 하는 부담이 있고, 설사 이를 개발한다 하더라도 개발기간과 비용이 적지 않아 신규사업자의 시장 진출이 쉽지 않고, 디지털 미디어 시스템 구성요소 간의 긴밀한 관계는 신규 사업자의 진입을 더욱 어렵게 한다 할 것이므로 공급 측면에서도 미디어 서버 프로그램 시장은 다른 시장과 구분된다.

따라서, 웹 서버 프로그램 등은 미디어 서버 프로그램과 기능 및 효용에서 차이가 크고, 수요자 및 공급자도 이를 알고 제품을 소비 및 공급하고 있는 바, 미디어 서버 프로그램의 가격이 상당기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 상승한다고 하더라도 수요자가 다른 웹 서버 프로그램 등으로 구매를 전환할 가능성은 거의 없다.

이에 대하여, 피심인들은 오늘날 콘텐츠 사업자들이 동일한 콘텐츠를 미디어 서버 프로그램을 이용한 스트리밍 방식뿐만 아니라 웹 서버 프로그램을 이용하여 프로그레시브 다운로드, 그리드 전송(grid delivery)[25] 방식으로 제공하고, 프로그레시브 다운로드와 그리드 전송 방식은 소비자들이 콘텐츠를 완전히 다운로드 하지 않고 재생이 가능하여 스트리밍 방식과 차이를 느끼지 못한다 할 것이므로 스트리밍 방식과 대체성이 존재한다고 주장한다.

그러나, 프로그레시브 다운로드와 그리드 전송 방식은 기술적으로 모두 웹 서버를 이용한 다운로드 방식의 일종으로, 일반적인 다운로드 방식과 마찬가지로 최종사용자의 하드디스크에 저장 공간이 필요하고, 불법복제 및 배포의 위험이 높으며, 라이브(live), 멀티캐스팅, 패스트 스트리밍(fast streaming), 인텔리젼트 스트리밍(intelligent streaming) 등의 유용한 서비스 방식이 제한되어 있다는 점 등에서 다운로드 방식이 가지고 있는 한계를 그대로 지니고 있고, 이외에도 스트리밍 방식에 비하여 다음과 같

23) 인터넷 등을 통하여 오디오/ 비디오 파일 등 멀티 미디어 디지털 콘텐츠를 전송토록 하는 일련의 체계를 말한다.

24) 컴퓨터에 저장된 비디오·오디오 등의 미디어 파일을 단순재생(play-back)하는 기능 뿐 아니라, 스트리밍 미디어 서버에 의해 제공되는 미디어 파일을 다운로드하지 않고도 재생(streaming)시켜 주는 기능을 가진 응용프로그램을 말한다. 이러한 스트리밍 미디어 플레이어는 다른 응용프로그램과 마찬가지로 멀티미디어 재생 기능을 가능토록 해주는 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface)와 소프트웨어 코드(software code)로 구성되어 있다.

25) 파일을 잘게 쪼개어 컴퓨터 대 컴퓨터(PtoP)의 방법으로 콘텐츠를 전송하는 방식을 말한다.

은 일정한 한계가 있다.

첫째, 웹 서버를 이용한 프로그레시브 다운로드 방식은 처음부터 순차적으로 다운로드 받은 부분만을 감상할 수 밖에 없어 자유로운 화면이동이 불가능하고, 저대역이거나 전송속도가 부족한 인터넷 통신망의 경우에는 이용되기 어렵다. 그래서, 온라인 영화사업자인 '아이팝'은 <그림 2-1>에서 보는 바와 같이 사용자 안내문에서 프로그레시브 다운로드 방식으로 영화를 관람하려면 KT/두루넷 프리미엄, 하나로 프로 이상의 대역에서 사용할 것을 권장하고 있다.

<그림 2-1> 온라인 영화사업자 아이팝의 사용자 안내문

	다운로드 관람방식	스트리밍 관람방식
방식	다운로드 방식은 영화데이터를 다운로드 받아 끊김없이 DVD급의 고화질을 감상하실 수 있는 서비스입니다.	스트리밍 방식은 실시간으로 DVD급의 고화질을 감상하실 수 있습니다.
특징	- 끊김현상(버퍼링)없이 DVD급의 화질과 5.1채널의 사운드로 영화 관람 가능 - 다운로드 받으면서 영화 관람가능 - 여러편의 영화를 다운로드 예약 후 차례로 관람가능	- 실시간으로 원하는 부분을 자유롭게 DVD급의 화질로 감상이 가능함 - 영화의 원하는 부분부터 관람가능
주의	- 전송속도가 부족할 경우 일정시간이상 다운로드 후에 원활한 영화관람 가능 (KT/두루넷 프리미엄, 하나로 프로 이상 권장) - 영화데이터를 다운로드 받을 PC의 하드(HDD)에 여유 공간이 필요함 - 처음부터 순차적으로 다운로드 받은 부분만을 감상할 수 있음.	전송속도가 부족하거나 네트워크 환경이 불안정하면 끊김현상이 발생할 수 있음 (끊긴부분에서 재버퍼링한 후 상영이 계속됩니다)

* 출처: 피심인들 제출자료(2005. 7. 11)

둘째, 그리드 전송 방식은 최종사용자의 PC가 콘텐츠 사업자의 스트리밍 서버로 이용됨으로써 사용자 PC의 속도를 느리게 하거나 해커들에 의한 정보유출의 위험을 증가시킨다.

이는 NHN의 터보플레이어 사례에서 확인할 수 있다. 터보 플레이어는 그리드 전

송 방식을 이용하는 미디어 플레이어인데, NHN은 최근 터보플레이어를 비롯한 모든 터보솔루션 사업을 중단하였다. 이와 관련하여 NHN이 2005. 9. 12. 위원회에 제출한 서면에서 NHN은 터보솔루션으로 운영되는 서비스는 이용자들로 하여금 터보플레이어의 설치라는 부담을 안겨준다는 점, 이용자들이 터보플레이어에 대한 인지도가 떨어진다는 점, 터보플레이어를 장기간 사용하면 사용자 PC 스토리지 부족 현상이 발생할 우려가 있다는 점 등이 터보솔루션 사업을 중단한 이유라고 진술한 바 있다.

따라서 웹 서버를 이용한 다운로드 방식에 기반한 서비스 방식들은 미디어 서버 프로그램을 이용한 스트리밍 서비스가 가지는 기술적 특성과는 다른 특성을 가지고 있고, 최종 사용자들의 불법복제나 이용을 방지하면서 사용 부담을 줄여 사용자의 저변을 늘이려는 콘텐츠 사업자들의 욕구를 충족시켜주기 어렵다는 점에서 스트리밍 방식을 대체하는데 한계가 있다. 그러므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

(2) 관련 지리적 시장

「시장지배적 지위남용행위 심사기준」(위원회 고시 제2002-6호) 및 「기업결합 심사기준」(위원회 고시 제1999-2호)에 의하면, 관련 지역시장은 다른 모든 지역에서의 당해 상품의 가격이 일정하나 특정 지역에서만 상당기간 어느 정도 의미있는 가격 인상이 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 지역전체를 의미하고, 특정 지역이 동일한 거래 분야에 속하는지 여부는 상품의 특성 및 판매자의 사업 능력, 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매지역 전환행태, 판매자의 구매지역 전환가능성 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태와 시간적, 경제적, 법제적 측면에서의 구매지역 전환의 용이성 등을 고려하여 판단한다.

PC 서버 운영체제는 소프트웨어라는 제품의 특성상 국가간 그 운송 및 거래비용이 미미하고, 국내에 거주하는 공급자 또는 소비자가 PC 서버 운영체제의 판매 또는 구매를 외국의 제품으로 전환하는데 별다른 장애가 없으며, PC 서버 운영체제 사업자들은 대부분 세계적으로 동일한 제품을 원칙적으로 동일한 가격 및 거래 조건에 판매

하고 있고, 제품의 개발 및 판매 전략을 비롯한 중요한 사업전략을 세계시장에서 유사하게 수행하고 있는 점 등을 고려하면 PC 서버 운영체제 시장의 관련 지리적 시장은 세계 시장이다

그러나, 종된 상품인 미디어 서버 프로그램은 주로 국내 솔루션업체들을 통하여 공급되고, 판매 후에도 신속한 기술지원, 지속적인 사후관리 등이 필요한 점, 국내 미디어 서버 프로그램 시장은 세계시장과 달리 WMS의 점유율이 매우 높은데 반해 세계시장에서 상당한 점유율을 가지고 있는 리얼네트웍스나 애플의 시장점유율은 거의 없거나 미미하다는 점을 고려하여 볼 때 미디서 서버 프로그램의 관련 지리적 시장은 국내 시장이다.

라. 시장지배적지위의 남용행위 중 사업활동 방해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2 제1항 제3호는 시장지배적 사업자가 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위를 금지하고, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호 및 「시장지배적지위 남용행위 심사기준」 Ⅳ. 3. 라. (3)은 이를 구체화하여 금지유형으로 시장지배적사업자가 '부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 행위로서 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위'를 규정하고 있다.

따라서, 피심인들의 행위가 위 규정에 해당하기 위해서는 첫째, 피심인들이 시장지배적지위에 있어야 하고, 둘째, 부당하게 거래상대방에 대하여 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하여야 하며, 셋째, 피심인들의 부당한 행위가 다른 사업자의 사업 활동을 어렵게 하여야 한다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 시장지배적 사업자이다.

공정거래법 제2조 제7호에 의하면, '시장지배적 사업자'란 일정한 거래분야의 공급자나 수요자로서 단독으로 또는 다른 사업자와 함께 상품이나 용역의 가격·수량·품질 기타의 거래조건을 결정·유지 또는 변경할 수 있는 시장지위를 가진 사업자를 말하는데 이에 해당하는지 여부는 시장점유율, 진입장벽의 존재 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모, 경쟁사업자간의 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

공정거래법 제4조에 의하면, 당해 사업자가 일정한 거래분야에서 시장점유율이 100분의 50 이상이거나 상위 3위 이내에 포함되고 상위 3사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75이상인 경우[26] 시장지배적 사업자로 추정되고, '시장점유율'은 위반한 혐의가 있는 행위의 종료일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 1년 동안에 "국내"에서 공급 또는 구매된 상품 또는 용역의 금액 중에서 당해 사업자가 "국내"에서 공급 또는 구매한 상품 또는 용역의 금액이 점하는 비율을 의미한다.

다만, 시장점유율을 산정함에 있어서 공정거래법 시행령 제4조 제2항은 상품 또는 용역의 매출액을 기준으로 하되, 시장점유율을 금액기준으로 산정하기 어려운 경우에는 물량기준 또는 생산능력을 기준으로 산정할 수 있다고 규정하고 있는 바, 본건 운영체제와 같은 소프트웨어 산업에서는 다음에서 보는 바와 같이 시장점유율을 금액기준으로 산정하기 어려운 경우에 해당하므로 매출액(revenue)이 아닌 물량〔이하 "출하량(shipment)"이라 한다〕을 기준으로 시장점유율을 산정한다.

첫째, 서버 운영체제와 같은 소프트웨어는 하드웨어와 분리된 그 자체만의 가격을 산정하기 곤란하여 소프트웨어만의 매출액을 산출해 내기 어렵고, 둘째, 공개 소프트웨어로서 가격이 사실상 '0'에 가까운 리눅스 서버 운영체제 제품이 존재하고 있어 출하량이 매출액보다 시장의 경쟁상황을 더 정확히 반영한다. 다만, 하드웨어와 소프트웨어

26) 다만, 시장점유율이 100분의 10미만인 사업자는 제외할 수 있다

의 가격을 통합한 금액을 매출액으로 보아 이를 시장점유율 분석에 참고토록 한다.

피심인들의 윈도우 서버 운영체제는 국내 PC 서버 운영체제 시장에서 <표 2-4>에서 보는 것처럼 2001년부터 2003년까지 평균 시장점유율이 출하량 기준 77%이므로, 피심인들은 공정거래법 제4조에 따라 시장지배적사업자로 추정되고, 이는 매출액 기준(시장점유율 78%)에 의할 때에도 마찬가지다.

<표 2-4> 국내 PC 서버 운영체제 시장점유율

① 출하량(shipment) 기준(단위: %)

서버 운영체제	2001년	2002년	2003년	3개년 평균
윈도우	77.4	76.9	76.8	77.0
리눅스	6.3	8.3	13.0	9.2
유닉스	6.9	6.7	5.3	6.3
기 타	9.4	8.1	4.9	7.5

출처 : 한국소프트웨어진흥원/IDC(Internet Data Center)

② 매출액(revenue) 기준 (단위: %)

서버 운영체제	2001년	2002년	2003년	3개년 평균
윈도우	77.7	77.4	79.1	78.0
리눅스	6.1	8.0	10.4	8.2
유닉스	7.0	7.0	5.7	6.6
기 타	9.2	7.6	4.8	7.2

출처 : 한국소프트웨어진흥원/IDC

피심인들은 PC 서버 운영체제 시장을 세계로 확장하더라도 <표 2-5>에서 보는 바와 같이 2003년도 출하량 기준 70.6%, 매출액 기준 72.1%이므로 시장지배적 지위를 가진다.

<표 2-5> 세계 PC 서버 운영체제 시장점유율

서버 운영체제	2003년	
	출하량 [단위:개(%)]	매출액 [단위:M$(%)]
윈도우	3,342,971 (70.6)	15,476 (72.1)
리눅스	812,511 (17.2)	2,963 (13.8)
유닉스	169,602 (3.6)	1,100 (5.1)
기 타	409,602 (8.6)	1,920 (9.0)

* 출처: “Worldwide Server Sihpments by Chip and Operating System, 2003-2008”
“Worldwide Server Customer Revenue by Chip and Operating System, 2003-2008” ,IDC, 2004
* “기타”는 x86 서버 중 윈도우, 리눅스, 유닉스를 제외한 NetWare와 Other를 합산하여 계산한 것임

또한, PC 서버 운영체제를 여러 용도로 사용하기 위해서는 이를 위한 다양한 응용프로그램이 존재하여야 하기 때문에 PC 서버 운영체제에 진입하고자 하는 자는 이러한 다양한 응용프로그램을 개발하여야 하는 부담을 안게 되고 이는 신규 사업자에게 진입장벽으로 작용한다.

이와 같은 사실은 피심인들이 PC 서버 운영체제 시장에 진입하기 위해 4년 또는 5년의 기간동안 막대한 연구개발 비용을 투자한 사실[27] 및 중대형 서버 운영체제 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 유닉스 계열의 사업자들이 PC 서버 운영체제 시장에서는 7% 이하의 낮은 점유율에 그치고 있다는 점을 고려할 때 인정할 수 있다.

따라서, 피심인들은 시장점유율에 의할 때 공정거래법상 시장지배적 사업자로 추정될 뿐만 아니라 시장 점유율 및 기술적, 경제적 진입장벽이 높다는 점을 종합적으로 고려할 때도 시장지배적 사업자로 인정된다.

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 별개제품인 WMS를 결합하여 판매하는 것은 WMS의 구입을 원하지 않는 거래상대방에게 WMS의 구입을 강제하는 것으로서 이는 부당하게 거래상대방의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해하고, 양질의 제품을 사용할 기회를 사전에 차단하여 거래상대방에게 불이익이 되는 거래를 강제하는 행위이다.

1) 윈도우 서버 운영체제와 WMS는 별개의 제품이다.

결합판매 되는 상품들이 서로 다른 별개의 상품인지 여부는 이 제품들이 시장에서 통상 별도로 거래되는지 여부, 양 제품의 상업적 용도나 기능적 특성이 다른지 여부, 양 제품에 대한 소비자의 인식 태도에 차이가 존재하는지 여부 등을 종합적으로 고려

27) EC의 피심인 엠에스에 대한 결정문 제394항 참조

하여 판단한다.

참고로, 서울 고등법원은 한국토지공사의 불공정거래행위 중 끼워팔기와 관련한 처분 취소소송에서 “거래상대방이 구입하고자 하지 않는 종된 상품이란 주된 상품의 밀접불가분한 구성요소가 아닌 별개의 상품으로서 독립하여 거래의 대상이 될 수 있고, 통상적으로 주된 상품과 짝지어 하나의 단위로 판매 또는 사용되지 않는 상품이면 족하다”고 판시[28]한 바 있다.

가) WMS는 윈도우 서버 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니다.

운영체제는 컴퓨터의 기본적 기능을 제어하고 응용소프트웨어(application software)가 작동할 수 있는 기반 역할을 하는 ‘시스템 소프트웨어’(system software)[29]를 의미한다. 그 중에서도 서버 운영체제는 프린터 제어, 파일 공유 등 네트워크 전체를 감시·제어하거나 메인프레임(mainframe), 통신망을 통한 다른 네트워크와의 연결하도록 하거나, 데이터, 프로그램, 파일 자원이나 모뎀, 팩스, 프린터, 기타 장비 등 하드웨어 자원을 공유하도록 하는 기능 등을 가지고 있다.

미디어 서버 프로그램은 서버 운영체제를 기반으로 하여 스트리밍 미디어 서비스를 제공하기 위한 응용소프트웨어로서 그 상업적 용도나 기능적 특성이 서버 운영체제와 확연히 구분된다.

WMS도 서버 운영체제를 기반으로 작동하는 미디어 서버 프로그램의 일종으로서 하나, 그 효용은 서버 운영체제와 완전히 다르고, 사용자는 언제든지 서버 구성을 변경하여 WMS를 안전하게 설치 또는 제거할 수 있으며, 이 때 서버 운영체제는 아무런 문제없이 잘 작동하므로 WMS는 윈도우 서버 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아닌 하나의 독립적인 별개의 프로그램이다.

---

28) 서울 고등법원 2004. 2. 10. 선고 2001누16288 판결

29) 시스템 소프트웨어란 컴퓨터 하드웨어를 콘트롤하면서 응용소프트웨어가 잘 작동할 수 있도록 컴퓨터의 기본적 기능을 제공하는 소프트웨어이다.

이에 대하여 피심인들은 WMS가 윈도우 서버 운영체제와 단일한 제품으로서 스트리밍 미디어 기능은 다양하게 제공되는 일반 목적용 서버 운영체제의 여타 기능들과 다를 것이 없다고 주장한다.

그러나, WMS가 윈도우 서버 운영체제가 다양하게 제공하는 여타 기능과 다를 것이 없다는 점만으로는 WMS의 별개제품성 여부를 부인하는데 충분한 근거가 되지 못하고, 그러한 기능들이 윈도우 서버 운영체제의 밀접불가분한 구성요소인지 여부가 별개의 독립된 상품인지 여부의 판단기준이라 할 것이므로, 피심인들의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나) WMS는 윈도우 서버 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

미디어 서버 프로그램은 다음과 같이 서버 운영체제와는 별도로 충분한 수요가 존재하고, 공급자도 미디어 서버 프로그램 시장을 서버 운영체제와는 다른 별개의 시장으로 인식하고 제품을 공급하고 있으므로 미디어 서버 프로그램인 WMS는 윈도우 서버 운영체제와 별개의 제품으로서 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

미디어 서버 프로그램은 인터넷을 통하여 방송, 홍보, 동영상, 음악 서비스 등을 실시간 혹은 실시간 주문형 비디오(VOD: Video On Demand) 로 제공하기 위하여 수요되는 반면, 서버 운영체제는 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시, 제어하거나, 메인프레임이나 공중망을 통한 다른 네트워크와의 연결, 데이터 프로그램, 파일 같은 소프트웨어 자원이나 모뎀, 팩스, 프린터 공유, 기타 장비 등 하드웨어 자원의 공유를 위해 수요되고 있어 양 제품의 용도 및 기능이 확연히 구분되는 바, 소비자들은 위 두 제품간의 차이를 인식하고 사용 목적에 따라 구매하고 있다.

많은 미디어 서버 사업자들이 서버 운영체제와는 별도로 미디어 서버 프로그램만을 개발하여 판매하고 있는 바, 이는 미디어 서버 프로그램 공급자들도 미디어 서버 프로그램을 서버 운영체제와 별개의 제품으로 인식하고 이를 공급하고 있음을 보여준다.

피심인들의 WMS를 제외하고 미디어 서버 프로그램은 리얼네트웍스, 쌘뷰텍 등과 같이 동시 접속자 수 등을 고려하여 상당한 가격에 별도로 판매되거나, 디디오넷, 보람 등과 같이 하드웨어와 일체로 판매되는 바, 리얼미디어 서버, 쌘스트림 등 다수의 미디어 서버 제품들은 크로스 플랫폼(cross platform)으로서 다양한 서버 운영체제에 설치, 사용될 수 있어 소비자가 어떤 운영체제를 선택하는지에 관계없이 미디어 서버 프로그램을 별도로 각각 구입하여 이용할 수 있다.

피심인들도 WMS 4.0 버전의 경우에는 윈도우 NT 서버 운영체제와 별도로 이를 인터넷을 통해 다운로드 받아 사용하도록 제공하였고, 윈도우2000 서버에 WMS 4.1 버전을 결합하여 판매하기 시작한 후에도 윈도우 NT 서버 운영체제를 위한 다운로드용 WMS 4.1 버전을 별개로 제공하였다. 이는 피심인들 역시 미디어 서버 프로그램을 서버 운영체제와 밀접불가분한 구성요소가 아닌 별개의 제품으로 인식하고 공급하였음을 보여준다.

또한, 피심인들이 시스코(Cisco), 탄트베르크(Tandberg) 등과 같은 독립 소프트웨어 제공업자(Independent Software Vendor; ISV)에게 자신의 윈도우 미디어 기술 및 프로토콜을 서버 운영체제와는 별도로 라이센스하고 있다는 점도 피심인들이 WMS를 운영체제와 별개로 취급하고 있음을 보여 주는 사실이다.

다) 통상적으로 서버 운영체제와 미디어 서버 프로그램은 짝지어 하나의 단위로 판매 되지 않는다.

미디어 서버 프로그램을 제조·판매하는 리얼네트웍스, 쌘뷰텍, 디디오넷 등과 같은 피심인들의 주요 경쟁사업자들은 다양한 서버 운영체제에서 작동할 수 있는 미디어 서버 프로그램만을 상당한 가격에 별도로 판매하고 있고, 소비자들 또한 이들 제품을 운영체제와는 별도로 구입하고 있다.

이는 서버 운영체제도 마찬가지인바, 서버 운영체제를 제조 및 판매하는 사업자들인 주식회사 한컴리눅스, 와우리눅스 주식회사, 레드햇 리눅스, 수세 리눅스 등과 휴렛팩커

드나 아이비엠 등은 서버 운영체제만을 판매할 뿐 미디어 서버 프로그램을 운영체제에 포함시켜 판매하지 않는다.

피심인들을 제외하고 애플이 유일하게 미디어 서버 프로그램을 운영체제에 포함시켜 판매하고 있으나, 애플의 이러한 행위는 PC 서버 운영체제 시장에서 시장지배적 사업자인 피심인들과 경쟁하기 위한 행위에 불과하다는 점에서 통상의 거래 관행으로 보기에는 무리가 있고, 솔루션업체들이 미디어 서버 프로그램과 서버 운영체제를 하드웨어와 일체로 함께 판매하는 것은 수요자의 구체적·개별적 요구에 의하여 별개의 소프트웨어를 최적의 상태로 설치하고 이에 대한 비용을 받는 것에 불과하다는 점에서 피심인들의 행위와 차이가 있다.

따라서 통상적으로 서버 운영체제와 미디어 서버 프로그램은 결합하여 하나의 단위로 판매되지 않는다.

2) 피심인들의 행위는 부당하게 WMS를 원하지 않는 거래상대방에게 WMS의 구입을 강제한 것이다.

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매하는 행위는 PC 서버 운영체제 시장의 지배적 사업자인 피심인들이 WMS의 판매를 촉진하기 위하여 윈도우 서버 운영체제 구입시 WMS도 함께 제공하는 것으로써 이는 종된 상품인 WMS를 구입하지 아니하고서는 시장지배적 상품인 윈도우 서버 운영체제를 구매할 수 없게 하는 행위인 바, 주된 상품인 윈도우 서버 운영체제를 구입하여 다른 용도로 쓰고자 하는 소비자로서는 사실상 종된 상품인 WMS를 구입할 수 밖에 없는 상황에 처하게 되었다 할 것이다. 그러므로 이러한 행위는 거래상대방인 소비자들의 상품 선택의 자유를 침해하고, 양질·염가의 상품을 제공함으로써 고객을 확보한다는 장점에 의한 경쟁을 저해할 우려가 있다. 따라서 피심인들의 행위는 PC 서버운영체제 시장의 지배력에 편승하여 '부당하게 거래상대방에 대하여 WMS의 구입을 강제한 행위에 해당한다.

이에 대하여 피심인들은 일반 목적용 운영체제에는 다양한 기능들이 포함되어 있

고, 스트리밍 미디어 기능도 이러한 기능 중 하나로서, 소비자가 실제로 다양한 기능 중 일부를 사용하지 않는다 하더라도 구입이 강제된 것이 아니라고 주장한다.

그러나 시장지배적사업자가 부당하게 거래상대방에게 불이익한 거래 또는 행위를 강제한 행위가 성립하려면 주된 상품을 공급하는 것과 연계하여 거래 상대방이 종된 상품을 구입하도록 하는 상황을 만들어 내면 족한 것이지 이를 구입한 이후 거래상대방인 소비자가 사용하는지 여부는 그 위법성 구성의 요건사실이 아니라 할 것이므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

또한, 피심인들은 WMS가 무료로 제공되고 있어 소비자에게 아무런 부담을 주고 있지 않으므로, 소비자에 대한 유상성을 그 요건으로 하는 구입 강제성은 인정될 수 없다고 주장한다.

그러나, 공정거래법 및 시행령에는 결합판매가 성립하기 위한 요건으로서 소비자들이 유상으로 부상품을 구입할 것을 규정하고 있지 않다. 따라서 강제성 이외에 유상성은 결합판매가 성립하기 위한 필수적인 요건이 아닌 바, 이는 미국[30]이나 EU[31]의 공정거래법 관련규정이나 판례상으로도 인정된다. 그러므로, 설사 피심인들이 WMS를 무료로 거래상대방인 소비자에게 제공하고 있어 유상이 아니라 하더라도, 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매함으로써 WMS 구매 자체에 대한 강제성이 인정되는 한 구입강제성은 인정되는 것이므로 피심인들의 주장은 받아들이지 아니한다.

---

30) 미국 연방항소법원은 결합판매의 위법성 여부는 경쟁상품이 장점(merits)에 의하여 직접 경쟁할 수 있는 기회가 결합판매로 인하여 봉쇄되었는지 여부가 핵심 쟁점이고, 그것은 결합판매에 따라 경쟁상품이 “구매자의 독립적 판단”(buyer's independent judgment)에 의해 선택받을 기회가 박탈당했느냐 여부가 기준이라고 판시하여 부상품의 유상성 여부가 강제성 성립 여부 판단에 있어서 문제되지 않는다고 한 바 있다(United States of America V. Microsoft Corporation, 253F.3d34, 73 (D.C.Cir., 2001)).

31) EC 또한 피심인 엠에스의 WMP 결합판매와 관련된 결정문에서, 소비자가 WMP에 대해 추가적인 가격을 지불할 필요가 없으므로 끼워팔기가 성립할 수 없다는 MS의 주장에 대해, 끼워팔기의 성립에 댓가 지불(paying)을 요하지 않는다고 설시한 바 있다.(EC 결정문 제830-831항)

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 미디어 서버 프로그램을 결합하여 판매하는 행위는 WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 구매자가 WMS를 구입하도록 강제한 행위로서 이는 거래상대방의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해함과 동시에 양질의 제품을 접할 수 있는 기회를 현저히 제약하고, 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 불필요한 비용을 지불하게 하는 불이익을 거래상대방에게 초래한다.

피심인들이 2003년 전문 리서치 기관인 티엔에스(TNS)에 의뢰하여 실시·작성한 시장조사 보고서에 따르면, 국내에서 사용되는 윈도우 NT 서버의 9%, 윈도우2000 서버의 7%만이 'Collaboration and Communication Servers'(국내 전체 서버를 작업의 종류에 따라 12가지로 분류할 수 있는데 그 중 스트리밍 미디어 서버는 인스턴트 메시징, 팩스 등과 함께 'Collaboration and Communication Servers'로 정의된다)로 사용되고 있고, 피심인들의 내부 전자메일에 나타난 윈도우서버 2003 신제품 발표회장에서 진행한 퀵 서베이 결과에 의하면 응답자의 11%만이 윈도우서버 2003을 구매하여 이를 미디어 서버로 사용하겠다고 답하였음을 확인할 수 있는 바, 위와 같은 사실은 윈도우 서버 운영체제를 구입하는 거래상대방의 약 90%가 윈도우 서버 운영체제를 미디어 서버 이외의 다른 용도로 사용하고 있고, 이들은 WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 구매자임을 알 수 있게 해준다.

따라서, 윈도우 서버 운영체제를 구매하는 소비자는 원하든 원하지 않든 피심인들의 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배적 지위로 인하여 WMS를 구입할 수 밖에 없는 바, 이는 거래상대방인 소비자가 미디어 서버 프로그램을 선택할 수 있는 권리를 침해하는 것이다.

한국소프트웨어진흥원의 콘텐츠 사업자 대상 미디어 서버 설문조사 결과(이하 '콘텐츠 사업자 대상 미디어 서버 설문조사 결과'라 한다)[32]에 의하면, 디지털 미디어시스템으

32) 이 설문조사는 한국소프트웨어진흥원이 국내 스트리밍 서비스 업체의 스트리밍 미디어 서버 운용현황 및 서비스 방식 사용현황을 파악하여 스트리밍 미디어 기술 시장의 활성화 방안을 모색할 목적으로 중앙리서치에 의뢰하여 실시된 것이다. 조사의 구체적인 내역은 다음과 같다. ①조사기간: 2004. 7. 19~8. 20. ②조사대상: 스트리밍 미디어 서비스 업체의 스트리밍 미디

로 피심인들의 윈도우 디지털 미디어 시스템을 선택한 인터넷 방송업체의 약 82.8%가 윈도우 서버 운영체제에 윈도우 미디어 테크날러지(Windows Media Technologies, 이하 'WMT'라 한다)[33]가 포함되어 있다는 사실이 디지털 미디어 시스템 선택에 영향을 주었다고 응답하였으며 그 중 매우 영향을 주었다는 응답이 45.2%에 달하고 있음을 확인할 수 있다.

이는 피심인들의 결합판매가 미디어 서버 프로그램 소비자가 제품을 선택하는데 큰 영향을 주어 다른 우수한 제품을 접할 기회를 현저히 제약하는 결과를 초래한다는 사실을 잘 보여준다.

또한, 리얼네트웍스가 2005. 1. 19. 제출한 자료, 위원회가 2004. 7. 6. 인터넷 방송 솔루션 업체들에게 보낸 질문에 대한 답변내용 및 피심인들이 일부 인정한 사실 등을 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

피심인들은 미디어 서버 프로그램을 개발하기 위해 총 5억 4천만 달러에 달하는 비용을 투자한 사실, WMS를 윈도우 서버 운영체제에 결합판매 함으로써 WMS에 대한 비용을 별도로 소비자로부터 받고 있지는 않으나 윈도우 서버 2003 운영체제 중 WMS가 결합되어 있지 않은 웹 에디션의 경우에는 WMS가 결합되어 있는 스탠다드 에디션에 비하여 상당히 저렴한 가격에 팔리고 있는 사실, 그런데 피심인들은 제품을 라이센스 계약을 체결하면서 윈도우 2003 서버 웹 에디션을 구입한 소비자가 이를 미디어 서버를 위한 서버 운영체제로 이용하지 못하도록 하고 있는 사실 및 다른 미디어 서버 프로그램 사업자들은 연구 개발비용 등을 고려함과 아울러 미디어 서버 프로그램에서 가장 중요한 접속자 수에 따라 가격에 차등을 두어 판매하고 있는 사실 등을 인정할 수 있다.

이러한 사실들을 종합하여 볼 때, PC 서버 운영체제 시장의 지배적 지위에 있는

어 서비스 담당 부서의 실무 책임자급 ③조사지역: 서울 및 수도권 ④조사방법: 일대일 면접조사 ⑤표본크기: 100샘플 ⑥표본추출방법: Purposive Sample

33) 피심인들의 고유한 디지털 미디어 시스템으로서 윈도우 미디어 서비스(WMS), 윈도우 미디어 플레이어(WMP), 윈도우 미디어 인코더, 윈도우 미디어 코덱, 저작권 보호 프로그램(DRM) 등으로 구성되는 일련의 시스템을 말한다.

피심인들이 WMS를 윈도우 서버 운영체제와 결합하여 단일한 가격으로 판매하는 행위는 WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 지불하지 않아도 되는 비용을 지불하게 하는 것으로 인정된다. 따라서 피심인들의 행위는 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 비용상의 불이익을 야기한다.

4) 소결

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 WMS를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로서 이는 부당하게 소비자의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해하고, 미디어 서버 프로그램 시장에서 품질 및 가격에 의한 경쟁을 침해하여 소비자가 우수한 제품을 접할 기회를 현저히 제약하며, 윈도우 서버 운영체제 소비자에게 불필요한 비용을 지불하게 하는 불이익을 초래하는바, 피심인들의 결합판매행위는 불이익한 거래를 강제한 행위에 해당한다.

참고로, 피심인들은 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합한 행위는 WMS가 제조단계에서 결합되어 추가비용의 지불 없이 판매되므로 사용자가 쉽게 설치하고 무료로 사용할 수 있다는 점에서 거래비용을 감소시키고, 새로운 응용프로그램의 개발을 용이하게 하여 소프트웨어 개발업자에게 이익이 되며, 서버 하드웨어에 대한 수요의 증가를 가져와 서버 컴퓨터 제조업체에 대한 혜택을 제공하는 등의 효율성이 있다는 취지의 주장을 한다.

그러나, 피심인들의 주장하는 편익은 WMS가 아니라 다른 미디어 서버 프로그램을 결합하여 판매하는 경우에도 달성할 수 있어 피심인들의 결합판매만이 달성할 수 있는 편익이 존재함을 인정하기 힘들 뿐만 아니라, 나아가 설사 피심인들이 주장하는 결합판매로 인한 편익이 어느 정도 인정된다 하더라도 피심인들의 결합판매행위가 가져오는 아래에서 보는 바와 같은 심각한 경쟁상의 폐해 및 행위 자체로 인한 위법성을 상쇄하고도 남을 정도에 이르렀음을 인정할 만한 어떤 근거 자료도 피심인들은 제출하고 있지 못하고 있으므로 피심인들의 주장은 받아들이기 곤란[34]하다.

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 미디어 서버 프로그램 시장에서 WMS가 편재성에 의하여 경쟁상 우월한 지위를 획득하게 하고, WMS에 대한 쏠림현상을 초래하여 경쟁제한 효과를 심화시키는바, 이는 미디어 서버 프로그램 시장에서 경쟁 사업자의 사업활동을 현저히 어렵게 하고, 신규 사업자의 진입을 곤란하게 하여 경쟁 사업자의 사업 활동을 방해한다.

1) 피심인들의 행위는 WMS의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 미디어 서버 프로그램 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

PC 서버 운영체제 시장의 지배력을 이용한 피심인들의 윈도우 서버 운영체제와 WMS의 결합판매행위는 다른 미디어 서버 프로그램이 획득할 수 없는 편재성을 WMS에 부여한다.

피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 77%를 점유하고 있는 시장지배적 사업자인 바, 이러한 서버 운영체제에 미디어 서버 프로그램인 WMS를 결합하여 판매하는 것은 피심인들의 서버 운영체제의 점유율만큼 WMS가 소비자들의 PC 서버운영체제에 광범위하게 존재하게 된다는 것을 의미한다. 이는 미디어 서버 프로그램의 수요자들이 WMS를 선택할 가능성을 증가시켜 피심인들이 미디어 서버 프로그램 시장에서 다른 경쟁업체가 누릴 수 없는 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매하는 결과, 콘텐츠 사업자가 윈도우 서버 운영체제를 기반으로 스트리밍 미디어 서비스를 제공하는 방법에는, 윈도우 서버 운영체제에 포함되어 있는 WMS를 이용하는 방법과, 별도로 리얼네트웍스, 쌘뷰텍 등 다른 업체의 미디어 서버 프로그램을 구입하여 사용하는 방법이 존재하게 된다. 서버 운영체제에 결합판매 되는 피심인들의 미디어 서버 프로그램을 사용하지 않고, 경쟁 사업자인 리얼네트웍스, 쌘뷰텍 등의 미디어 서버 프로그램을 사용하

34) 이에 관한 구체적 주장에 대한 반박은 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기부분에서 자세히 기술한다.

여 스트리밍 미디어 서비스를 하는 후자의 방법은 소비자인 콘텐츠 사업자가 별도의 미디어 서버 프로그램을 구입하기 위해 아래 <표 2-6> 및 <표 2-7>에서 보는 바와 같이 상당한 비용을 들여야 하는 부담이 있다.

<표 2-6> 리얼네트웍스 동시접속자별 미디어 서버 가격

(단위: USD)

미디어 서버 명	100명	무제한
헬릭스서버	5,000	13,000

* 위 가격은 2005. 1. 19.을 기준으로 한 것임
* 출처 : 신고인 리얼네트웍스 제출자료

<표 2-7> 국내업체 동시접속자별 미디어 서버 가격

(단위: 천원)

미디어 서버 명	100명	500명	1,000명
쌘스트림	25,000	81,000	120,000
씨비디오	23,000	60,000	90,000

* 가격은 솔루션(하드웨어 포함) 전체가격이 아닌 순수한 미디어 서버 소프트웨어만의 가격임
* 출처 : 위원회가 인터넷방송 솔루션 업체들에게 보낸 질문(2004. 7. 6.)에 대한 답변내용

다른 사업자의 미디어 서버 프로그램을 구입하기 위해 소요되는 매우 큰 추가비용은 미디어 서버 프로그램 시장에서 다른 경쟁사업자의 정상적인 영업활동을 사실상 방해하는 효과를 유발한다. 왜냐하면 윈도우 서버 운영체제를 구입한 소비자는 윈도우 서버 운영체제에 포함된 WMS를 이용하여 추가비용을 들이지 아니하고 스트리밍 서비스를 제공할 수 있는 상황이므로, WMS 이외의 미디어 서버 프로그램을 상당한 비용을 들여 추가로 구입하여 스트리밍 미디어 서비스를 제공하는 것을 상정한다는 것은 경험칙상 매우 어렵기 때문이다.

따라서 경쟁업체들이 피심인들의 WMS와 경쟁하기 위해서는 최신기술 개발을 위해 수년간 투자한 상당한 연구 개발비용을 회수하기에는 턱없이 부족한 수준으로 가격을 책정할 수 밖에 없는 바, 이러한 가격상 불리함을 타개하기 위해 리얼네트웍스, 쌘뷰텍 등의 업체들은 여러 운영체제를 지원하도록 미디어 서버 프로그램을 만들거나, 디디오넷, 보람C&C 등은 공개 소프트웨어이며 비용이 거의 들지 않는 리눅스 운영체제를 기본 플랫폼으로 사용한다. 그러나 이러한 방법은 전체 PC 서버 운영체제 시장에서 피심인들이 약 77%를 점하고 있는 부분을 제외한 나머지 부분에서 경쟁하는 수단일 뿐으로서

결국 미디어 서버 프로그램 사업자는 PC 서버 운영체제 시장의 대부분을 점하고 있는 윈도우 서버 운영체제가 점유하고 있는 시장의 77% 부분에서 배제되는 결과를 낳는다.

참고로, 아래 <표 2-8> 및 <표 2-9>는 피심인들 이외의 미디어 서버 프로그램 사업자들이 미디어 서버 프로그램을 개발하기 위해 상당한 연구개발 비용을 투자하고 있음을 보여 준다.

<표 2-8> 리얼네트웍스의 연구개발 비용

(단위: 천$)

연도	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 (3/4분기)
리얼 네트웍스	202	1,380	4,812	13,268	20,828	38,415	57,819	55,904	48,186	46,763	38,516

* 출처 : 신고인 리얼네트웍스 제출자료(2005. 1. 19.)

<표 2-9> 국내 미디어 서버 사업자들의 연구개발 비용

(단위: 천원)

업체명	2001	2002	2003
쌘뷰텍	254,291	196,659	116,644
디디오넷	33,700	84,205	302,000

* 출처 : 위원회가 인터넷방송 솔루션 업체들에게 보낸 질문(2004. 7. 6.)에 대한 답변내용

리얼네트웍스가 2005. 1. 19. 위원회에 제출한 자료에 의하면, 미디어 서버 프로그램을 개발하기 위해 상당한 비용이 소요된 것은 피심인들도 마찬가지로서, 피심인들은 지금까지 WMT를 개발하기 위해 리얼네트웍스에 대한 투자 및 라이센스 비용으로 약 60백만 달러, 독자적 스트리밍 기술을 보유하고 있던 VXtreme Inc.를 인수하는데 약 75백만 달러, 비디오 기술의 선구자였던 VDOnet Corp.의 기술에 5백만 달러, WMT 8에서 WMT 9으로 업그레이드하는데 기술개발 비용으로 5억 달러의 금액을 투자하였음을 인정할 수 있다.

그러나, 피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 지배적 지위를 이용하여 WMS를 윈도우 서버 운영체제와 결합하여 단일한 가격으로 판매하는 방법을 사용함으로써 미디어 서버 프로그램 개발에 투여된 연구개발 비용 등을 회수할 수 있다. 반면, 미디어

서버 프로그램 시장의 경쟁사업자들은 피심인들과 달리 PC 서버 운영체제 시장의 지배적 사업자가 아니므로 피심인들과 같은 방법을 사용하여 미디어 서버 프로그램을 개발하기 위해 들어간 비용을 회수할 수 없고, 미디어 서버 프로그램에 별도의 상당한 가격을 책정하여 판매할 수 밖에 없다.

2) 편재성으로 인한 경쟁상 우위는 쏠림현상을 발생시켜 경쟁제한 효과를 심화시킨다.

가) WMS의 편재성은 소비자들이 접근성 및 이용가능성을 증가시킨다.

피심인들의 결합판매는 윈도우 서버 운영체제 소비자들의 PC에 WMS가 광범위하게 존재하게 하고, 이는 미디어 서버 프로그램의 잠재적 소비자인 윈도우 서버 운영체제 소비자들이 WMS를 비롯한 윈도우 미디어 시스템에 접근하기 쉽게 한다. 그 결과 소비자들은 스트리밍 미디어 서비스를 개시하는 경우 미디어 서버 프로그램을 사기 위해 추가비용 및 학습비용이 들어가는 다른 경쟁 사업자의 제품을 구매하기보다 이미 PC 서버 운영체제에 존재하여 자신에게 익숙한 WMS를 선택하게 된다. 이는 경쟁사업자가 가질 수 없는 매우 유리한 측면으로서 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁 사업자에게 매우 불리하게 작용한다.

이는 다음과 같은 사실에서 확인할 수 있다.

콘텐츠 사업자 대상 미디어 서버 설문조사 결과에 의하면, 전체 응답자의 57%가 기존에 보유하고 있는 콘텐츠 포맷이 특정 포맷이라는 사실이 스트리밍 미디어 서비스 방식을 선택할 때 영향을 주었다고 하고 있고, 디지털 미디어 시스템으로 피심인들의 미디어 시스템인 WMT를 선택한 인터넷 방송업체의 약 82.8%가 WMT가 윈도우 서버 운영체제에 포함되어 있다는 사실이 디지털 미디어 시스템 선택에 영향을 주었다고 응답하였으며 그 중 매우 영향을 주었다는 응답은 45.2%에 달하는 것은 앞에서 확인한 바와 같다.

또한, 위원회가 2004. 7. 6. 인터넷방송 솔루션업체들에게 보낸 질문에 대한 답변에서도, 5개 응답업체 모두가 이미 기존의 미디어 콘텐츠가 모두 어느 특정 미디어 포맷으로 되어 있다면 이것이 콘텐츠 사업자들의 미디어 기술 선택에 있어서 매우 중요한 요소라고 진술한 바 있다.

따라서, 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 미디어 서버 프로그램 선택에 매우 큰 영향을 미친다.

나) 피심인들의 결합판매행위는 WMS로의 쏠림현상을 발생시켜 경쟁을 더욱 제한한다.

결합판매로 인한 WMS에 대한 접근 및 이용의 용이함은 미디어 서버 프로그램 시장에서 피심인들의 WMS로의 쏠림현상을 발생시켜 경쟁을 더욱 제한하는 결과를 초래하게 되는데, 이러한 쏠림현상 발생으로 인한 경쟁 제한 효과가 발생한 사실을 콘텐츠 사업자대상 미디어서버 설문조사 결과에 의해 확인할 수 있다.

이 조사에 의하면, 스트리밍 서비스 방식으로 WMT를 사용하는 사업자 중 54.3%가 일반적으로 '많이 사용'하기 때문에 이를 사용한다고 하고 있고, 국내 콘텐츠 사업자들이 가장 많이 사용하는 미디어 포맷으로 '피심인들의 미디어 포맷'을 꼽은 업체의 56.7%가 그렇게 응답한 이유를 '많이 사용해서'라고 하고 있으며, 향후 표준으로 될 가능성이 있는 미디어 포맷이 어느 것인지에 대한 답변으로 응답자의 75%가 '피심인들의 미디어 포맷'이라고 답변하였는데, 이 중 77.3%가 그 이유를 '사용자가 많아서'라고 응답하였다.

이러한 피심인들의 WMS로의 쏠림현상은 콘텐츠 사업자들이 복수의 미디어 포맷으로 서비스하는 경우에 하나의 미디어 포맷으로 서비스하는 경우에 비하여 추가비용이 발생한다는 사실과 밀접한 관련이 있다. 왜냐하면 콘텐츠 사업자가 복수의 미디어 포맷으로 서비스하기 위해 상당한 추가비용이 들면 콘텐츠 사업자는 자신의 사업에 가장 유리한 하나의 디지털 미디어 시스템을 선택하여 서비스를 할 것이기 때문이다. 따

라서, 소비자들이 경쟁 사업자의 미디어 서버 프로그램을 구매하기 위해 지불해야 하는 추가비용은 피심인들의 WMS로의 선택을 더욱 많게 하여 쏠림현상을 가중시키게 된다.

윈도우 서버 운영체제와 결합하여 단일한 가격으로 판매되는 WMS 외에 다른 미디어 서버 프로그램을 구입하기 위해 드는 추가비용이 소비자들에게 어떤 영향을 미치는 지는 콘텐츠 사업자에 대한 미디어 서버 설문조사 결과에서 잘 나타나 있다.

이에 의하면, '잘모름/무응답'을 제외한 51개 응답업체 중 약 92.2%가 복수의 미디어 포맷으로 서비스하는 경우에 하나의 미디어 포맷으로 서비스하는 경우보다 추가비용이 발생한다고 응답하고 있으며, 실제로도 100개 업체 중 약 22개 업체만이 복수의 미디어 포맷으로 서비스하고 있다고 응답하여, 복수의 미디어 서버 프로그램을 이용한 복수의 미디어 포맷 서비스가 시장에서 선택되기 힘들다는 것을 잘 보여주고 있다.

따라서, 피심인들의 결합판매는 윈도우 서버 운영체제 소비자들의 PC에 WMS가 존재하게 만들고, 이는 WMS에 대한 접근을 용이하게 하여 WMS에 대한 선택을 증가시키게 되는 바, 이러한 WMS로의 쏠림현상은 미디어 서버 프로그램 시장에서 더욱 경쟁을 제한하게 된다.

다) 피심인들의 결합판매행위는 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소간 의존성으로 인하여 경쟁을 더욱 크게 제한한다.

① 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소 간에는 서로 의존성이 존재한다.

디지털 미디어 시스템은 인터넷 등을 통하여 오디오/비디오 파일 등 멀티미디어 디지털 콘텐츠를 전송토록 하는 기기의 집합체로서, 실제 음향 또는 영상을 디지털화하고 특정 미디어 포맷으로 압축하는 인코더, 특정 포맷으로 압축된 디지털 콘텐츠를 인터넷을 통해 전송하는 미디어 서버 프로그램, 전송받은 디지털 콘텐츠를 재생하는 미디어 플레이어 세 부분으로 구성된다.

디지털 미디어 시스템이 콘텐츠를 효율적으로 보내고, 받고, 재생하기 위해서는 위 세부분의 프로그램들이 상호 긴밀하게 작동하여야 할 뿐만 아니라, 해당 디지털 미디어 시스템에서 재생될 수 있는 콘텐츠를 지원하는 포맷(format), 코덱(codec), 저작권보호프로그램(Digital Rights Management :DRM)[35], 프로토콜(protocol)[36]이 각 존재하여야 하는데, 이를 디지털 미디어 시스템 구성요소간 의존성이라 한다.

디지털 미디어 시스템 구성요소 간에 존재하는 의존성은 구성요소 상호간 서로의 효용을 배가시켜 어느 한 구성요소의 사용증가가 다른 구성요소의 사용 확산을 초래한다.

실제 WMS가 WMP 또는 WMP기반으로 한 html 플레이어[37]에 대한 선택을 촉진시키는 사실은 피심인들이 조사하여 제출한 '국내 상위 40개 웹사이트 조사결과'나, 한국소프트웨어 진흥원이 조사한 '120개 웹사이트 조사결과'에서 확인할 수 있다.

먼저, 피심인들이 제출한 국내 상위 40개 웹사이트 조사결과에 따르면, 콘텐츠 사업자가 WMS를 이용하여 오디오/비디오를 스트리밍하는 39가지 중 38가지의 경우가 스트리밍 미디어 플레이어로 WMP 또는 WMP를 기반으로 한 html 플레이어를 지정하고 있다.

한국소프트웨어진흥원이 수행한 120개 웹사이트 조사결과에서도, WMS를 이용하여 오디오/비디오를 스트리밍하는 웹사이트 모두가 미디어 플레이어로 WMP 또는 WMP를 기반으로 한 html플레이어를 지정하고 있다. 즉, 비디오 스트리밍에 WMS를

35) 디지털 콘텐츠의 무단 사용을 막아 저작권 관련 당사자들의 이익과 권리를 보호해 주는 기술 및 서비스를 말한다. 이는 콘텐츠 제공자의 권리와 이익을 안전하게 보호하고 불법복제를 방지하며 사용료 부과와 결제대행 등 콘텐츠의 생성에서 유통·관리까지를 일괄적으로 지원한다.

36) 컴퓨터나 시스템 혹은 프로그램간에 정보를 주고 받기 위해 정하여진 통신방법에 관한 규칙이나 규약을 의미한다. 즉, 상호간의 접속이나 절단방식, 통신방식, 주고받을 자료의 형식, 오류 검출방식, 코드변환방식, 전송속도 등에 관하여 정한 약속이다. 일반적으로 기종(機種)이 다른 컴퓨터는 통신규약도 다르기 때문에 기종이 다른 컴퓨터 간에 정보통신을 하려면 널리 쓰이는 표준 프로토콜을 이용하거나 공통의 프로토콜을 만들어 통신망을 구축해야 한다. 인터넷에서 보통 사용하고 있는 TCP/IP가 대표적인 표준 프로토콜의 하나이다.

37) WMP와 사용자 인터페이스 즉 외형만 다른 뿐 내용은 WMP인 플레이어를 총칭하여 말한다.

이용하는 방송사이트 22개, 영화사이트 23개, 포털사이트 19개, 음악사이트 14개가 모두 WMP 또는 WMP 기반 html플레이어를 지정하고 있으며, 오디오 스트리밍의 경우도 방송사이트 10개, 포털사이트 6개, 음악사이트 8개 모두 마찬가지이다.

이에 대하여 피심인들은 다양한 디지털 미디어 시스템(DMS) 구성요소 간의 혼합 사용(mix & match)이 기술적으로 가능할 뿐만 아니라 KBS VOD 플레이어, 맥스 웹 플레이어, 아드레날린, 알쇼, 클릭팝, KM 플레이어, 윈앰프 등의 미디어 플레이어들의 예에서 볼 수 있듯이 실제 시장에서 빈번하게 일어나고 있으므로, 디지털 미디어 시스템 구성요소 간의 의존성은 존재하지 않는다고 주장한다.

그러나, 피심인들이 주장하는 피심인들 디지털 미디어 시스템 구성요소간의 혼합 사용은 피심인들 스스로 권장하고 있지 않을 뿐만 아니라 피심인들의 주장과 달리 실제 시장에서도 거의 찾아 볼 수 없다.

피심인들 스스로 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소들을 다 함께 사용할 것을 권장하고 있는 사실은 피심인들이 작성하여 배포한 문서 및 피심인들 자신의 홈페이지에서 다음과 같이 확인할 수 있다.

피심인들이 윈도우 미디어 9 시리즈를 소개하기 위해 작성·배포한 문서(Introduction to Digital Media and Windows Media 9 Series)에 의하면, WMS 9와 WMP 9의 결합이 광대역 사용자에게는 즉시/언제나 스트리밍을 제공하고, 모뎀 사용자에게는 획기적으로 향상된 스트리밍 경험을 제공한다[38]고 하고 있고, 피심인들 자신의 홈페이지에서는 WMS가 스트리밍을 목적으로 특별히 디자인된 것이므로, 윈도우 미디어 서버를 이용하는 것이 미디어를 스트리밍 하기 위한 가장 좋은 방법이고, 모든 윈도우 미디어 컴포넌트가 함께 작동할 때 최종 사용자의 스트리밍 경험을 향상시킬 수 있는데, 일례로 인텔리전트 스트리밍(Intelligent Streaming)을 위해서는 윈도우 미디어 인코더, 윈도우 미디어 서비스, 윈도우 미디어 플레이어가 필요하다[39]고 한다.

---

38) 출처 ; Introduction to Digital Media and Windows Media 9 Series, John Shaw (Microsoft Corporation), 2004. 1월

39) 피심인 홈페이지 ; www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/webserver.aspx

그러므로, 콘텐츠 사업자가 WMS를 사용하는 경우에는 피심인들이 권장한 대로 거의 예외 없이 WMP를 사용자 측의 미디어 플레이어로 지정하게 되고, 그 결과 시장에서 피심인들의 디지털 미디어 시스템을 이루는 구성 요소간의 혼합사용은 거의 나타나지 않는다.

또한, 피심인들은 시장에서 혼합사용이 발생하고 있다고 주장하는 근거로 KBS VOD 플레이어, 맥스 웹플레이어, 아드레날린, 알쇼, 클릭팝, KM 플레이어, 윈앰프 등의 미디어 플레이어들을 들고 있으나, 이러한 미디어 플레이어들은 대부분 스킨(미디어 플레이어의 사용자 인터페이스)만이 다를 뿐 내용물은 그 자체가 사실상 WMP이거나 WMP 콤포넌트를 이용해 개발된 것으로, WMP와 기술적으로나 사실적으로 다를 바 없는 동일한 것들이다. 이러한 미디어 플레이어들은 이른바 WMP를 기본으로 겉모양만 약간 변형시킨 것에 불과한 것으로, 오히려 윈도우 미디어 시스템의 편재성을 강화시키는 역할을 한다.

따라서, 시장에서 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소 간에 혼합 사용은 거의 찾아 볼 수 없고, 위에서 본 바와 같이 오히려 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소 간에는 강한 의존성이 존재하므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

② 피심인들의 결합판매행위는 피심인들 디지털 미디어 시스템 구성요소 간의 의존성으로 인하여 경쟁을 더욱 크게 제한한다.

미디어 서버 프로그램 시장에서 WMS의 편재성으로 인한 경쟁제한 효과는 피심인들의 디지털 미디어 시스템을 구성하는 각 요소간의 의존성에 의하여 더욱 강화된다.

그 중에서도 콘텐츠 사업자들이 자신의 디지털 콘텐츠가 보다 많은 소비자에게 편리하고 쉽게 이용되는 것을 원하기 때문에 미디어 플레이어가 사용자 PC에 광범위하게 존재하는 사실은 콘텐츠 사업자들의 미디어 서버 프로그램 선택에 영향을 미치고, 이는 결국 미디어 서버 프로그램 시장에서의 경쟁 제한 효과를 더욱 크게 한다.

따라서, 윈도우 PC 운영체제와 결합판매 되기 때문에 WMP가 소비자의 컴퓨터에 99%이상 존재한다는 사실은 콘텐츠 사업자들이 윈도우 미디어 포맷 및 이를 전송할 수 있는 피심인들의 미디어 서버 프로그램인 WMS를 더욱 많이 선택하게 하고, 이러한 사실은 결합판매로 인한 경쟁제한 효과를 심화시킨다.

이는 다음과 같이 콘텐츠사업자 대상 미디어 서버 설문조사에서 확인할 수 있다.

콘텐츠 사업자대상 미디어 서버 설문조사에 의하면, 다음 <표 2-10>에서 보는 바와 같이 콘텐츠 사업자들의 약 79%가 미디어 서버 프로그램 선택의 가장 중요한 고려요소가 소비자의 이용가능성 및 접근성이라고 응답하였다.

<표 2-10> 스트리밍 미디어 서비스 방식 선택 기준

(Base=( ), 단위=%)

구 분	전체		WMT 주 사용 업체	
(Base)	(100)		(93)	
	1순위	중복응답	1순위	중복응답
이용자의 접근성 및 이용가능성	53.0	79.0	52.7	80.6
안정성	24.0	74.0	22.6	74.2
제품의 가격	12.0	60.0	12.9	61.3
보안성	4.0	17.0	4.3	32.3
서버와의 호환성	3.0	31.0	3.2	28.0
스트리밍 기술의 우수성	3.0	31.0	3.2	17.2
속도	1.0	1.0	1.1	1.1
기타	0.0	3.0	0.0	2.2

또한 스트리밍 미디어 서비스 방식을 선택할 때, '어떤 미디어 플레이어가 얼마나 많은 이용자들에게 배포되어 있는지를 고려 한다'는 응답이 91%(매우 고려 58%, 약간 고려 33%), 스트리밍 서비스를 위한 콘텐츠의 포맷을 결정할 때 역시 콘텐츠 사업자들의 96%(약간 고려 30%, 매우 고려 66%)가 이용자들이 사용하는 미디어 플레이어가 무엇인지를 고려한다고 응답하였다.

한편, 위원회가 중앙리서치에 의뢰하여 미디어 플레이어 사용자들을 대상으로 실시

한 설문조사(이하 '미디어 플레이어 설문조사'라 한다)[40]에 의하면 다음 <표 2-11>에서 보는 바와 같이 향후 특정 미디어 플레이어가 보편화될 것으로 보는 이유에 대하여 사용자의 46.4%가 "그 소프트웨어로 볼 수 있는 파일형식이 많아서"라고 응답한바 있다.

<표 2-11> 미디어 플레이어별 보편화 이유

(Base=( ), 단위= %, 중복응답)

구분	전체	WMP	윈앰프	아드레날린	곰 플레이어	리얼 플레이어	KM 플레이어	퀵타임
(Base)	(993)	(527)	(189)	(113)	(102)	(51)	(7)	(3)
컴퓨터에 원래 설치되어 있어서	52.6	82.5	23.8	8.0	13.7	33.3	14.3	33.3
그 소프트웨어로 볼 수 있는 파일형식이 많아서	46.4	47.4	49.2	49.6	43.1	25.5	57.1	33.3
성능이 우수해서	42.2	26.0	56.1	68.1	63.7	58.8	42.9	33.3
음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서	35.9	19.4	53.4	59.3	55.9	49.0	42.9	33.3
콘텐츠 제공업체에서 그 소프트웨어로 보도록 설정해서	19.3	22.0	15.3	14.2	13.7	27.5	14.3	33.3
사용이 편리해서	1.1	0.6	1.6	0.0	3.9	0.0	14.3	0.0

피심인들도 2004. 6. 10. 위원회에 제출한 내부자료에서, "윈도우 미디어 9 도입의 장점"으로 "Windows Media Player 9에 대한 이용자 보급률을 생각할 때 이용자 편이성 대(大)"라고 하여 WMP를 클라이언트 PC에 널리 보급함으로써 WMS의 효용을 증가하게 하는 것을 중요한 판매 전략으로 사용하고 있음을 보여 준다.

또한, 위원회가 2004. 7. 6. 인터넷방송 솔루션업체를 대상으로 실시한 설문조사에서도, 5개의 업체 중 4개 업체가 특정 미디어 포맷을 이용한 콘텐츠의 증가는 자연스럽게 특정 미디어 플레이어, 미디어 서버 프로그램의 사용을 증가시킨다고 응답하였다. 이는 특정 미디어 포맷을 이용한 디지털 콘텐츠가 많아질수록 이를 재생할 수 있는 미

40) 이 설문조사는 공정거래위원회가 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 피심인들의 행위가 소비자의 미디어플레이어 선택과 시장경쟁에 어떠한 영향을 미쳤는지를 파악할 목적으로 중앙리서치에 의뢰하여 실시하였다. 설문조사의 개요는 다음과 같다. ①조사기간: 2004. 7. 19~8. 13 ②조사대상: 만 15~49세 남녀 중, 주 3회 이상 인터넷을 사용하며 최근 1주일이내 인터넷 스트리밍 서비스를 1회 이상 사용자 ③조사지역: 서울 ④조사방법: 일대일 면접조사 ⑤표본크기: 1,000샘플 ⑥표본추출방법: 정보통신부와 한국인터넷정보센터의 '2003년 하반기 정보화 실태조사' (2003년 12월, 전국 29,062명 조사) 결과 중 인터넷 이용률에 근거한 성별/연령별 할당 추출 ⑦표본오차: 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p

디어 플레이어의 사용 및 배포가 증가하고, 그에 따라 콘텐츠 사업자나 기업들이 향후 미디어 시스템 선택에 있어 이와 일치하는 미디어 서버 프로그램을 사용하게 됨을 의미하는 것이다.

신고인 리얼네트웍스도 2005. 1. 19. 위원회에 제출한 자료에서, “스트리밍 미디어 산업은 네트워크 효과를 통해 제품과 서비스들이 상호 보강하고 영향을 미치는 관계를 가지는 하나의 생태계와 같은 것입니다. 예컨대, 특정 포맷으로 만들어진 컨텐츠 양이 많으면 많을수록, 해당 콘텐츠를 재생하는 클라이언트와 전송하는 서버에 대한 수요는 늘어나게 됩니다.” 라고 진술하고 있다.

다음으로 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 응용프로그램 개발자들에게도 영향을 끼친다. 왜냐하면 피심인들의 WMT가 광범위한 시장 점유율을 보유하고 있으므로 디디오넷, 쌘뷰텍 등을 제외한 국내 인터넷방송 솔루션업체의 대부분이 WMT를 기반으로 사업을 하고 있기 때문이다. 그러므로 WMT를 기반으로 하여 솔루션사업을 하는 해당 업체들은 자연적으로 WMT의 기능을 보완하거나 향상시키는 자체 응용프로그램을 개발하게 되는 바, WMT를 기반으로 한 응용프로그램의 지속적인 개발은 응용프로그램 개발업자들의 피심인들에 대한 기술적 종속성을 강화시킨다. 한편, 이러한 WMT에 대한 여러 응용프로그램의 존재는 신규 사업자에게 미디어 서버 프로그램 시장에 대한 진입장벽으로 기능하게 된다.

이에 대하여 피심인들은 콘텐츠 사업자들이 스트리밍 미디어 서비스를 선택함에 있어서 중요한 고려요소는 미디어 서버의 성능이나 비용과 같은 요소이고, 모든 윈도우 PC 운영체제에 WMP가 존재한다는 사실은 중요한 고려 요소가 아니라고 주장한다.

그러나, 콘텐츠 사업자가 제작한 콘텐츠를 소비자들이 많이 이용 할수록 콘텐츠사업자의 수익은 증가하게 되므로, 콘텐츠 사업자들은 콘텐츠에 대한 소비자들의 이용가능성을 증가시키는 방법을 찾게 된다. 그 결과 콘텐츠 사업자는 미디어 포맷 및 이를 전송할 미디어 서버 프로그램을 선택함에 있어 사용자의 PC에 가장 널리 배포되어 있는 미디어 플레이어가 무엇인지를 고려하게 된다.

이는 콘텐츠 사업자를 대상으로 한 미디어 서버 설문조사 결과에서 이미 살펴 본 바와 같이 콘텐츠 사업자 중 약 90% 이상이 스트리밍 미디어 서비스와 미디어 포맷을 결정할 때 사용자들의 PC에 어떤 미디어 플레이어가 가장 많이 배포되어 있는 지를 고려한다고 하는 사실 및 위원회가 2005. 9. 12. 국내 최대의 포털사이트 사업자인 엔에치엔(NHN)에 자신의 독자적인 미디어 플레이어였던 터보 플레이어를 WMP로 변경한 이유에 대한 답변을 종합하여 볼 때 인정할 수 있다.

소비자들이 어떤 상품을 선택할 때 그 상품의 품질을 고려하는 것은 당연하다고 할 수 있으나, 피심인들의 WMS가 다른 경쟁제품과 비교하였을 때 성능이나 품질에서 확실한 우위를 갖고 있다는 사실이 명백하지 않은 상태에서는, 스트리밍 미디어 서비스의 특성상 사용자들에게 쉽게 접근할 수 있는 길은 모든 사용자들이 이미 보유하고 있는 미디어 플레이어를 이용하는 방법이 될 수 밖에 없고 이러한 사실 즉 WMP가 사용자들의 PC에 이미 모두 존재한다는 사실이 콘텐츠 사업자들에게 매우 중요한 고려요소가 된다 할 것이므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

라) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장에 진입장벽을 구축하여 경쟁을 제한한다.

WMS의 편재성은 소프트웨어 개발자들로 하여금 WMS를 이용한 응용프로그램의 개발을 촉진시키게 되고, WMS를 이용한 다양한 응용프로그램의 증가는 WMS의 효용을 높이게 되는데, 바로 이러한 WMS를 위한 응용 프로그램(어플리케이션)의 존재가 신규 진입자에게 진입장벽으로 작용한다.

또한, 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매함으로써 소비자들이 다른 미디어 서버 프로그램을 구매 또는 선택할 가능성이 크게 감소하게 되는바, 이는 미디어 서버 프로그램 시장에 현존하는 사업자뿐만 아니라 잠재적 진입자에게 있어서 현실적 및 잠재적 시장규모의 축소를 의미한다. 따라서 투자 및 개발비용의 회수 등이 불투명하게 되어 신규 사업자의 시장 진입이 그만큼 힘들어 지게 된다.

이러한 미디어 서버 프로그램에 대한 진입장벽은 디지털 미디어 시스템 구성요소 간의 의존성에 의하여 더욱 강화되는데, 신규 사업자가 미디어 서버프로그램 시장에 진입하기 위해서는 디지털 미디어 시스템을 이루는 구성요소인 미디어 서버 프로그램, 미디어 플레이어, 포맷 등에 대한 시장진입이 필요하나 피심인들이 결합판매를 함으로써 미디어 서버 프로그램 및 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한하고 진입 장벽을 높이고 있어 신규 사업자의 미디어 서버 프로그램 시장에의 진입은 더욱 어렵다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

피심인들이 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 미디어 서버 프로그램 시장에서 부당하게 경쟁을 제한함으로써 경쟁사업자의 사업활동을 곤란하게 하고 신규 사업자의 진입을 어렵게 하는 등 미디어 서버 프로그램 시장에서 다른 사업자의 사업 활동을 방해한다.

가) 윈도우2000 서버 운영체제와 WMS 4.1의 결합판매는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

① 피심인들의 결합판매 후 시장점유율이 급격하게 변화한 사실이 있다.

피심인들이 윈도우2000 서버에 WMS 4.1을 결합하여 판매하기 시작한 2000. 2월경에는 통신망의 대역폭, 하드웨어 및 소프트웨어의 성능 등이 상대적으로 높지 않은 상태였기 때문에 대부분의 인터넷 방송업체들은 저화질(300kbps 이하) 위주의 스트리밍 미디어 서비스를 제공하고 있었다.

국내 인터넷 방송업체가 아래 <표 2-12>에서 보는 바와 같이 2000년을 기점으로 폭발적으로 증가한 것은 국내 인터넷 사용 인구의 증가 및 인터넷 기반의 확충에 따른 스트리밍 미디어 서비스의 수요 증가가 중요한 요인이 되었다. 이와 같은 수요급증은 미디어 서버 프로그램에 대한 콘텐츠 사업자의 수요도 증가시켰다.

<표 2-12> 국내 인터넷방송 업체 수 현황

연도	1997	1998	1999	2000.11	2001.3	2001.11
업체수	5	80	200	800	910	970

* 출처: 문주영, 정보통신산업동향(2001. 8.)

<표 2-13>에서 보는 바와 같이 국내 인터넷 방송업체들의 디지털 미디어 시스템 채택 변화 추이에서 특기할 만한 점은 피심인들이 결합판매를 시작한 2000년 초를 기점으로 피심인들의 WMT를 채택하는 업체들이 폭발적으로 증가하기 시작하였다는 점이다. 현재는 인터넷 방송업체의 약 93%가 피심인들의 WMT를 채택하고 있다.

<표 2-13> 디지털 미디어 시스템 시장점유율 변화 추이

(단위: %)

	리얼 미디어 시스템	WMT	동시사용 또는 기타	비고
1999. 9.	90	-	-	
2000. 5.	51.6	44.1	4.3	
2000. 11.	19	59	22(동시사용 12)	
2004. 8.	0	93	7	

② 피심인들의 결합판매는 경쟁사업자인 리얼네트웍스의 한국시장에서의 사업활동을 방해한 사실이 있다.

2000년을 기준으로 한 피심인들의 디지털 미디어 시스템인 WMT의 급격한 시장점유율 증가 및 리얼 미디어 시스템의 급격한 시장 점유율 감소는 다음과 같이 이 사건 결합 판매 이외에 다른 원인이 있다고 인정할 만한 사정이 존재하지 않는다.

미디어 서버 프로그램 시장에서 급격한 점유율의 변화가 있었던 2000년과 2001년 당시 리얼 미디어 시스템이 피심인들의 미디어 시스템보다 기술적으로 우수하거나 최소한 동등한 정도의 성능을 가지고 있었는바, 이는 다음에서 확인할 수 있다.

미국의 저명한 컴퓨터 잡지인 네트워크 컴퓨팅(Network Computing)은 2001. 2. 19.자 “리얼네트웍스, 애플과 마이크로소프트에 앞서다(RealNetworks Skins Apple,

Microsoft)"라는 기사에서, 리얼네트웍스 플랫폼의 성능이나 품질이 피심인들이나 애플의 제품보다 뛰어나다고 하고 있고,[41] 인터넷위크(InternetWeek)의 2001. 8. 20.자 "Screaming Streaming Servers"라는 기사 등 다수의 IT 및 컴퓨터 전문 잡지, 신문 등에 따르면, 리얼네트웍스의 미디어 서버가 인터넷을 통한 스트리밍 서버로서 우수한 성능과 품질을 제공하고 있다고 기술하고 있다[42].

피심인들도 2000. 5. 10. 미국 법무부에 제출한 자료에서 리얼네트웍스가 스트리밍 미디어 소프트웨어 분야에서 의심할 여지없는 선두주자(the clear leader in Internet Streaming Software)임을 인정하기도 하였다[43].

따라서 다음 <표 2-14>에서 보는 바와 같이 피심인들이 결합판매를 시작할 당시 품질이나 성능 면에서 리얼 미디어 시스템은 피심인들의 WMT보다 앞서거나 적어도 동등한 상태였음을 인정할 수 있다.

<표2-14> 2001년 리얼 서버와 윈도우 미디어 서버의 비교

	Real System Server 8.0	WMT(WMS 4.1)
장점	-다이내믹한 콘텐츠를 제작할 수 있는 SMIL 지원 -Real Side Show 기능으로 프리젠테이션 구성 강화 -SureStream기능으로 저대역폭(56Kbps이하)/ 고대역폭 등의 멀티타겟오디언스를 한 파일로 인코딩 가능 -Unix, Linux 등 다중 플랫폼 지원 -뛰어난 오디오 음질	-MPEG4 Codec을 사용하여 막강한 압축률 제공 -고대역폭(100Kbps) 타겟오디언스로 인코딩시 고화질 비디오 제공 -Windows 9x, ME등에 Me 등에 미디어플레이어 기본제공
단점	-WMT에 비해 저대역폭에 약한 비디오 화질	-NT 플랫폼에서만 지원 -추가 버퍼링으로 인한 중간 끊김

* 출처 : 김생수·김덕현(2001. 9. 1.), 폭발적인 스트리밍을 위한 웹캐스팅 ON AIR, (주)영진닷컴, 40쪽

위와 같은 상황에서 피심인들이 2000. 2월경부터 윈도우2000 서버 운영체제에

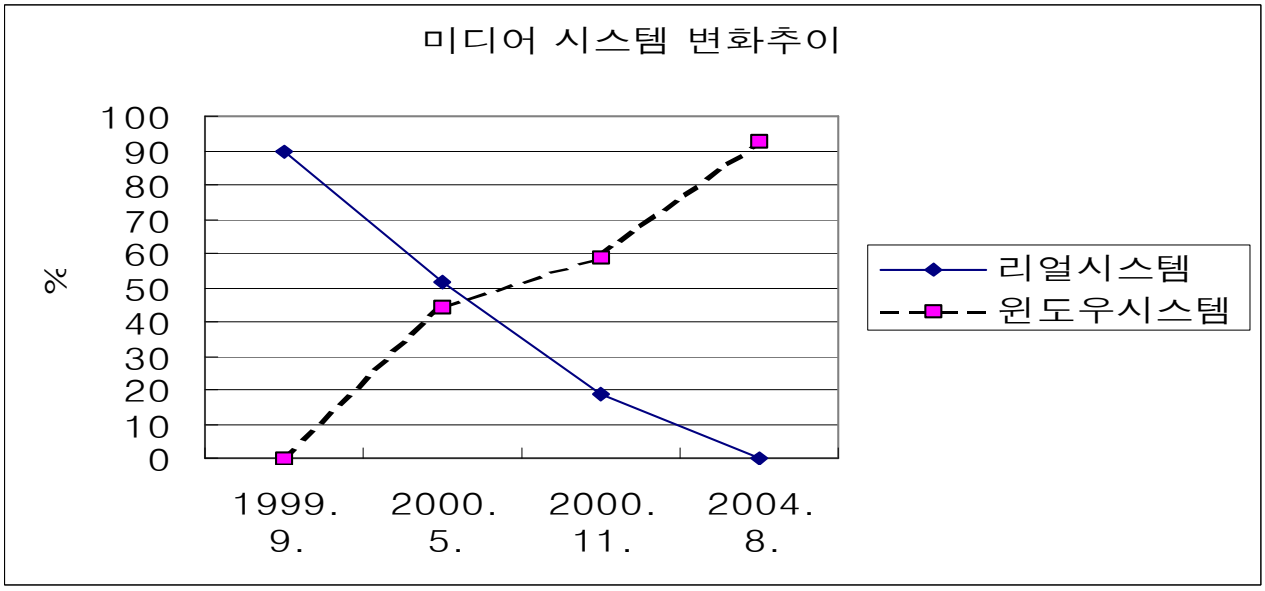
41) Network Computing 웹페이지, http://www.networkcomputing.com/1204/1204f1b1.html

42) InternetWeek 웹페이지, http://www.interweek.com/reviews01/rev082001.htm

43) 이 내용의 원문은 다음과 같다. "(중간 생략) For example, RealNetworks (*still the clear leader in streaming media software*) owns a variety of compression/decompression algorithms ("codecs") used to transmit multimedia content over networks. (이하 생략)"

WMS 4.1을 결합하여 판매하였는 바, <그림 2-2>에서 보는 바와 같이 이후 시장 점유율이 극적으로 변하여 1999년 9월 이후 불과 4년 사이 리얼 미디어 시스템의 시장점유율은 90%에서 0으로 하락한 반면 피심인들의 WMT는 10%도 안 되는 아주 미미한 점유율에서 90% 이상 높아졌다.

<그림 2-2> 미디어 시스템 시장점유율 변화 추이



이는 피심인들이 WMS 4.1을 윈도우2000 서버 운영체제에 결합하여 판매한 행위가 미디어 서버 프로그램 시장에서의 경쟁을 심각하게 제한하여 기술과 품질 즉 장점에 의한 경쟁을 침해하고 리얼네트웍스 등 경쟁사업자의 사업 활동을 방해하여 한국시장에서 축출하는 결과를 낳았음을 시사하여 준다.

리얼네트웍스는 '프로그레시브 네트웍스(Progressive Networks)'라는 이름으로 1994년 설립되고 출범 후 4개월이 채 안된 시점부터 소프트웨어 제작도구(tool), 서버 제품, 전문적인 서비스(자문제공), 여러 소비자 및 사업관련 서비스를 한국에 판매하기 시작하였는 바, 1999년 리얼플레이어 버전(RealPlayer version) 7을 시작으로 이후 모든 버전의 클라이언트용 제품(RealJukebox 1.0, RealJukebox 2.0, RealPlayer 7 등)을 한국어판으로 출시하였다.

<표 2-15>에서 보는 바와 같이 미디어 시스템 업계의 선두주자답게 리얼네트웍스

의 한국 내 매출액은 꾸준히 증가하여 2000년에는 사상 최고 매출액인 508,590USD에 달하게 되나, 피심인들이 결합판매를 시작한 2000년을 정점으로 급격하게 감소하여 2004년에는 7043USD가 된다. 매출액 감소를 해결하기 위해 리얼네트웍스는 2001. 10. 에 한국에 지사를 여는 등 영업활동을 강화 하였으나, 시장 점유율을 전혀 회복하지 못하고 2002. 10. 결국 한국 지사를 철수하였다.

<표 2-15> 리얼네트웍스의 연도별 국내 매출액

(단위: USD)

연도	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004(3/4)
서버 매출액	452,907	406,001	508,590	172,114	80,637	25,304	7,043
총매출액	460,263	437,441	1,420,705	895,325	791,495	601,885	442,919

* 출처: 신고인 리얼네트웍스 제출자료(2005. 1. 19.)

* '총매출액'은 서버, 소프트웨어 제작도구(tool), 소비자에 대한 자문 등에 대한 매출액을 합산한 금액임

이에 대하여 피심인들은 스트리밍 미디어 기능이 윈도우 서버 운영체제에 포함된 것은 1996년부터로 국내에서 리얼네트웍스의 시장점유율이 하락한 시기와 일치하지 아니하므로, 리얼네트웍스의 점유율 하락은 결합판매에 기인한 것이 아니라고 주장한다.

살피건대, 피심인들이 1996년 '윈도우 NT 서버 4.0'의 일부로 포함되었다고 주장하는 넷쇼 서버(NetShow Server)는 대역폭이 큰 인트라넷을 통해서만 기본적인 서비스가 가능한 제품으로서 대역폭이 작은 인터넷을 통한 스트리밍에는 적합하지 않아 이를 이용한 상업적인 서비스가 거의 불가능하였고, 디지털 미디어 시스템의 없어서는 안 될 중요한 구성요소인 미디어 플레이어가 1998. 7월에나 출시되면서 이 때부터 인터넷을 통한 스트리밍 콘텐츠의 재생이 가능하게 되었으며, 저작권 보호기술(DRM) 역시 1999. 8월에서야 비로소 WMS에 포함되었음을 고려하여 볼 때 넷쇼 서버(NetShow Server)와 피심인들의 서버 운영체제의 결합이 관련 미디어 서버 시장에 영향을 미치는 행위라고 보기 어렵다.

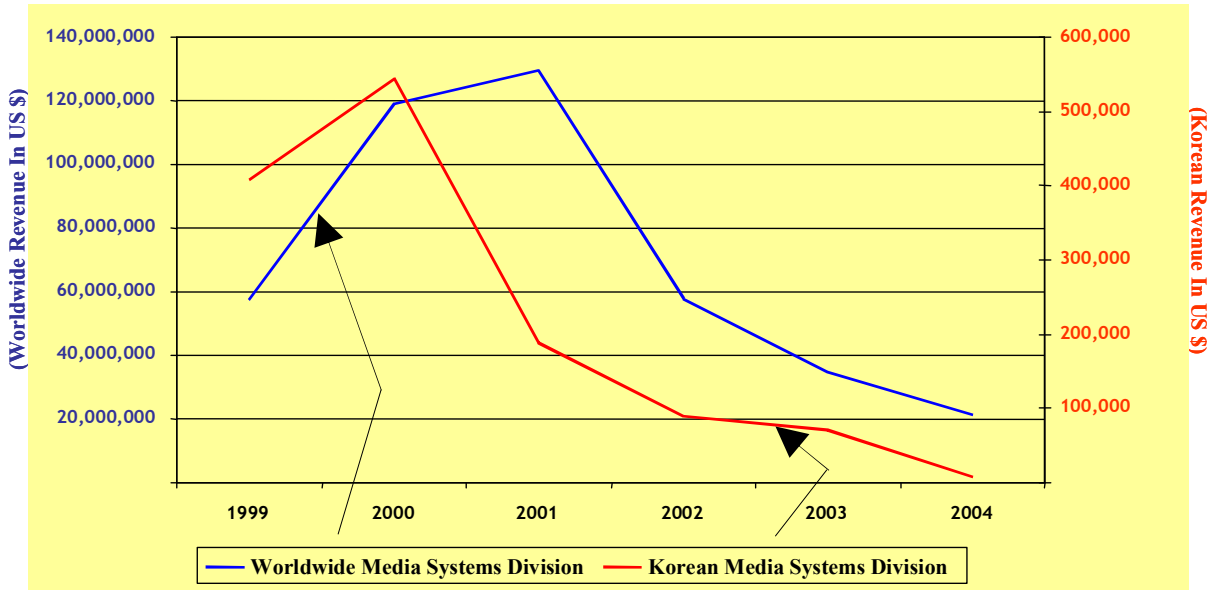
더구나 피심인들은 1997. 7월경 리얼네트웍스와 스트리밍 미디어 분야에서 상호 협력할 것을 약정하고 이에 따라 넷쇼 서버(NetShow server)에는 리얼오디오와 리얼비디오 코덱이 포함되었으며, 피심인들의 인터넷 익스플로러에 리얼플레이어가 포함되

었다. 이러한 협력관계는 피심인들이 1998. 11. 리얼네트웍스에 대한 투자를 회수함과 동시에 종료되었는데 협력관계가 지속되었던 기간 동안에는 리얼네트웍스에 대한 사업 활동 방해 효과가 발생하기 어려웠다. 따라서 결합판매를 통하여 경쟁 저해 행위가 개시된 시점을 1996년부터라고 인정하기 어렵다. 따라서 피심인들의 주장은 이유 없다.

또한 피심인들은 결합판매로 인하여 리얼네트웍스의 시장점유율이 하락하였다면 리얼네트웍스의 전세계 시장점유율 또한 하락했어야 마땅할 것임에도, 이와 달리 한국 시장을 제외하고는 2000년도 리얼네트웍스의 전 세계 시장점유율은 그러한 변화가 없었다고 하며 결합판매로 인한 경쟁 제한성이 없다고 주장한다.

그러나, 리얼네트웍스는 한국시장과 마찬가지로 세계시장에서도 미디어 서버 매출에 현저한 감소를 겪었는바, 아래 <그림 2-3>에서 보는 바와 같이 세계시장에서 리얼네트웍스의 매출액 감소(전년도와 비교하여)는 2000년이 아닌 2001년을 기점으로 발생하였지만, 2000년을 기점으로 세계시장의 매출액 증가 추세가 현저히 둔화되었음을 알 수 있다. 이는 피심인들의 결합판매가 국내시장은 물론 세계시장에도 다소의 시차는 있지만 동일한 영향을 미쳤음을 보여주는 것이라 할 것이므로 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

<그림 2-3> 리얼네트웍스의 미디어 시스템 부문 매출



* 미디어 시스템 부문 매출은 서버와 약간의 프로그램 툴 매출을 포함한다.
** 출처: 신고인 리얼네트웍스 제출자료(2005. 1. 19.)

나) 윈도우 서버 2003 운영체제와 WMS 9의 결합판매행위는 다른 사업자의 사업 활동을 방해한다.

국내 광대역 통신망이 빠르게 보급되어 2002. 12.에는 국내 인터넷 서비스 가입자 중 94%가 초고속 인터넷 서비스에 가입할 정도로 국내 초고속 인터넷 보급률은 세계 최고 수준에 이르게 되는 바, 이러한 환경에 힘입어 고화질의 디지털 미디어 시스템이 국내에서 개발되어 시장을 형성하게 된다.

① 피심인들의 결합판매 후 시장점유율이 급격하게 변화한 사실이 있다.

우수한 인터넷 환경에 힘입어, 외국보다 먼저 국내에서 고화질 스트리밍 미디어 서비스가 출현하였는데, 이는 피심인들의 WMS 4.1을 기반으로 한 300Kbps급 인터넷 동영상 서비스보다 훨씬 발전한 500Kbps 이상의 고화질 동영상 서비스로, 2002년 초반경부터 디디오넷, 쌘뷰텍 등 국내 업체들을 중심으로 개발·보급되기 시작한다.

순수 국내업체인 디디오넷, 쌘뷰텍 등이 개발한 고화질 스트리밍 기술은 피심인들이나 리얼네트웍스 스트리밍 기술보다 한 발 앞선 것으로서 화질, 성능 면에서 우수할 뿐만 아니라 혁신적인 전송 기술로서 국내 고화질 디지털 미디어 시스템 시장을 창출하고 90% 이상을 선점하였다.

위와 같은 상황에서 피심인들이 2002. 9. 국내 업체와 비슷한 수준의 고화질 스트리밍을 지원하는 WMS 9 베타버전을 윈도우 닷넷 서버(Windows.NET Server)[44]에 결합하여 출시하고, 2003. 4.부터 현재까지 윈도우 서버 2003에 WMS 9을 결합하여 판매 하자, 국내 고화질 DMS 시장의 상황이 급격히 변화하기 시작했다.

2002. 10. 한국통신이 윈도우 닷넷 서버에 포함된 WMS 9를 이용하여 서비스를 제공한 것을 필두로 피심인들이 고화질 스트리밍 서비스 시장을 잠식하는 현상이 2003년 이후 지금까지 빠르게 나타나고 있다.

44) 윈도우 서버2003이 공식적으로 출시되기 전의 이름으로 윈도우 서버2003과 동일한 것이다.

위원회가 2004. 8. 18. 국내 고화질 인터넷 영화업체들을 대상으로 조사한 바에 따르면, 조사대상인 10개 업체 중 피심인들이 WMS 9을 출시하기 전부터 서비스를 제공하였던 2개 업체들이 모두 2003년 이전에는 디디오넷의 씨비디오를 이용하였으나 2003년 이후에는 모두 WMS 9를 이용하고 있고, 2003년 이후에 서비스를 개시한 다른 8개 업체 중 1개 업체를 제외한 7개 업체는 모두 WMS 9만을 이용하여 고화질 스트리밍 서비스를 제공하고 있음을 확인할 수 있다.

위와 같은 사실은 피심인들이 WMS 9를 윈도우 서버 2003에 결합판매 함으로써, 디디오넷, 쎈뷰텍 등 국내 경쟁사업자들의 사업활동을 심각하게 방해하였다는 사실을 보여 준다.

피심인들의 WMS 9, 디디오넷의 씨비디오 등을 이용하여 CDN 서비스를 제공하는 기업 "갑"의 아래 <표 2-16>에서 보는 바와 같은 매출실적표를 통하여도 위와 동일한 사실을 확인할 수 있다.

<표 2-16> 기업 '갑'의 연도별 서비스 공급내역

(단위: 개)

	2002년	2003년	2004년
WMS	2	51(49)	80(29)
씨비디오	11	11(0)	2(-9)

* ( )는 당해 년도에 신규로 서비스를 제공한 업체 수를 의미함
* 출처: 기업 갑 제출자료

② 피심인들의 결합판매는 경쟁사업자인 디디오넷 등의 사업활동을 방해한 사실이 있다.

2002. 9.을 기점으로 고화질 디지털 미디어 시스템 시장에서 일어난 급격한 시장점유율의 변화는 결합 판매 이외에 다른 원인이 있다고 볼 만한 사정이 없다.

국내 대표적인 CDN 서비스 업체인 기업 '갑'이 제출한 2004. 9. 9.자 답변서에 의하면 기업 '갑'이 피심인들의 WMT, 디디오넷의 씨비디오, 쎈뷰텍의 쎈스트림의 화질, 성능 등 품질을 비교한 결과, 스트리밍 기술 간에는 큰 차이가 없으나 음향부분에서 비(非)마이크로소프트 계열의 솔루션이 좀 더 품질이 좋음을 인정하고 있고, 전자 및

정보통신 분야를 전문적으로 다루는 신문인 디지털타임즈 2003. 12. 17.자 기사에 의하면 2003년 통신·방송부문 VOD솔루션으로 디디오넷의 씨비디오를 선정하면서 'MPEG4에서 최신 압축기술인 H.264를 적용해 고화질 동영상 스트리밍 서비스를 구현했고, 스크립트 기능이 있어 광고·교육 시스템·온라인 쇼핑 등에서 양방향 미디어로도 응용할 수 있다는 점이 부각'되었다고 하여 기술적 우수성을 높이 평가하고 있다.

그런데, 디디오넷이 2005. 9. 21. 위원회에 제출한 자료에 의하면 위와 같이 기술면에서 우수하거나 적어도 동등하다고 인정되는 디디오넷이 피심인들이 결합판매를 시작한 2002년 이후에는 고화질 스트리밍 미디어 서비스 시장의 급격한 성장에도 불구하고 매출액이 정체되거나 감소하고 있음을 인정할 수 있다.

따라서, 피심인들의 윈도우 서버 운영체제와 WMS의 결합판매행위는 미디어 서버 프로그램 시장에서 다른 사업자인 리얼네트웍스, 디디오넷 등의 사업활동을 방해한다.

이에 대하여, 피심인들은 엔에치엔(NHN)의 터보 솔루션, 그래텍의 곰솔루션, 테르텐의 미디어쉘 등 다양한 제품들이 콘텐츠 전송 솔루션 시장에서 활발히 경쟁하고 있으므로 경쟁봉쇄 효과가 발생하고 있지 않다고 주장한다.

그러나, 엔에치엔(NHN) 및 그레텍이 2005. 9. 12. 위원회에 제출한 자료에 의하면 엔에치엔(NHN)은 현재 솔루션 공급사업을 종래의 계약이 종료할 때까지만 제공하고, 계약 연장의 계획이 없으며, 추가적인 마케팅은 보류 중이라고 하여 사실상 솔루션 사업을 중단한 상태이고, 그래텍 역시 곰솔루션 수요가 2004년 16개 업체에서 2005년 9개 업체로 급감한 이후 곰솔루션 판매를 사실상 중단하고, 시장 상황이 개선되지 않는 한 사업성이 불투명한 솔루션 판매 사업을 진행할 계획이 없다고 밝히고 있다. 이는 피심인들의 결합판매행위가 미디어 서버 프로그램 시장에서의 경쟁을 현저히 저해하고 경쟁사업자의 사업활동을 방해하며, 신규진입을 저해하여 결과적으로 관련시장에서 경쟁사업자를 축출하는 효과까지 발생하고 있음을 보여주는 것이므로 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

또한 피심인들은 국내 40개 웹사이트를 조사한 결과 33개 사이트가 WMS 이외의 미디어 콘텐츠 전송 솔루션을 사용하고 있으므로, 피심인들의 결합판매행위가 경쟁을 제한하지 않는다고 주장한다.

그러나, 피심인들이 주장한 수치는 국내 40개 웹사이트 중에서 이 사건의 종된 상품 시장인 미디어 서버 프로그램 시장에 속하지 아니하는 다운로드, 프로그레시브 다운로드, 그리드 전송 방식인 P2P 등의 방식을 모두 포함하였기 때문에 산출된 결과이다.

오히려, 종된 상품 시장을 앞에서 살펴 본 바와 같이 “미디어 서버 프로그램” 시장으로 획정하여 피심인들이 조사한 국내 40개 웹사이트를 분석하면, 아래 <표 2-17>에서 보는 바와 같이 비디오 스트리밍을 제공하는 31개 사이트 모두(100%), 오디오 스트리밍을 제공하는 14개 사이트 중 8개 사이트(57%)가, 비디오와 오디오를 통합한 비디오 또는 오디오 스트리밍을 제공하는 38개 사이트 중 31개 사이트(82%)가 WMS를 사용하고 있다. 이에 비해, 2번째로 많이 사용되는 곰솔루션은 비디오 또는 오디오 스트리밍을 제공하는 38개 사이트 중 7개 사이트만이 사용하고 있어 그 비율이 18%에 지나지 않는다는 점을 보면, 스트리밍 미디어 서버 프로그램 시장에서 이미 WMS로의 시장 집중이 나타나 경쟁을 제한하고 있음을 알 수 있다.

<표 2-17> 스트리밍 미디어 서버 프로그램 사용 웹사이트 비율

순위	미디어 서버	비디오(%)	오디오(%)	총계(%)
1	WMS	31/31(100)	8/14(57)	31/38(82)
2	곰솔루션	5/31(16)	2/14(14)	7/38(18)
3	SHOUTcast	0/31(0)	4/14(29)	4/38(11)

* 솔루션을 복수로 사용하는 사이트들이 있어 합이 맞지 아니함
* 출처 : 피심인들 제출

스트리밍 시장에서 WMS에 의한 경쟁제한이 이미 이루어졌음은 한국소프트웨어진흥원이 2005. 11. 7.에 실시한 국내 120개 웹사이트 조사결과에서도 알 수 있다. 아래 <표 2-18>에서 보는 바와 같이, 비디오 스트리밍을 제공하고 있는 81개 사이트 중 78개 사이트가 WMS를 이용하여 서비스를 제공함으로써 그 비율이 무려 96%에 달하는데 비하여, 2위에 해당하는 스트리밍 솔루션인 디디오넷의 씨비디오, NHN의 터보솔루션은 각각 4개

사이트에 불과하여 그 점유율이 5%에 불과하다.

<표 2-18> 비디오 스트리밍 방식 사용비율

	전송솔루션						
	Windwos Media Service	P^3 Engine	Turbo	SeeVideo /SeeLive	SanStream	Gom	Real Server
방송사이트	22/23	1/23	3/23	2/23	1/23	0/23	0/23
영화사이트	23/24	0/24	0/24	1/24	1/24	0/24	0/24
포털사이트	19/19	0/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19
음악사이트	14/15	2/15	0/15	0/15	0/15	0/15	0/15
합계(%)	78/81(96)	3/81(4)	4/81(5)	4/81(5)	3/81(4)	1/81(1.2)	1/81(1.2)

* 솔루션을 복수로 사용하는 사이트들이 있어 합이 맞지 않음
* 출처 : 한국소프트웨어진흥원 제출

다음으로 오디오 스트리밍의 경우에도, 아래 <표 2-19>에서 보는 바와 같이 오디오 스트리밍을 제공하는 46개 사이트 중 24개 사이트가 WMS를 사용함으로써 그 비율이 52%에 이르지만, 2위로 많이 사용되는 피어링포털의 P^3 Engine은 8개 사이트에 제공되어 그 비율이 17%에 불과하다.

<표 2-19> 오디오 스트리밍 방식 사용비율

	전송솔루션				
	WMS	P^3 Engine	ShoutCast	Gom	기타
방송사이트	10/11	0/11	1/11	0/11	0/11
영화사이트	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1
포털사이트	6/16	3/16	1/16	1/16	5/16
음악사이트	8/18	5/18	1/18	0/18	5/18
합계(%)	24/46(52)	8/46(17)	4/46(9)	1/46(2)	10/46(22)

* 솔루션을 복수로 사용하는 사이트들이 있어 합이 맞지 아니함
* 포털사이트 중 1개 사이트는 전송솔루션 확인이 불가하여 제외됨
* 출처 : 한국소프트웨어진흥원 제출

이러한 조사결과는 국내 스트리밍 시장에서 WMS로의 시장집중이 이미 이루어졌음을 입증하고 있다. 특히, 조사대상을 상위 40개 웹사이트에서 120개 웹사이트로 그 범위를 확대하자, 아래 <표 2-20>와 같이 WMS의 사용은 급격히 늘어난데 비해 다른 스트리밍 전송 솔루션의 사용은 거의 늘어나지 아니하였음을 알 수 있는 바, 이는 곧 자금

여력이 충분치 아니한 중소규모 업체의 경우 복수 포맷으로 콘텐츠를 제공하지 아니하고 오로지 WMS만을 이용하고 있음을 보여준다. 따라서 피심인들의 주장은 이유 없다.

<표 2-20> 사용비율 변화

구 분		A:상위 40개(%)	B:상위 120개(%)	증감율(B-A)
비디오	WMS	31/39(79)	78/81(96)	47(17%)
	피어링포털	4/39(10)	3/81(4)	-1(-6%)
오디오	WMS	8/25(32)	24/46(52)	16(20%)
	피어링 포털	7/25(28)	8/46(17)	1(-11%)

* 출처 : 한국소프트웨어진흥원 제출

다만, 위에서 피어링포털의 사용업체 수가 코리안 클릭 기준 상위 40개 업체에 대한 조사보다 상위 120개 사이트에 대한 조사에서 더 적게 나온 이유는 피심인들이 코리안 클릭에서 분류한 기준 및 순위를 따르지 않고, 자의적으로 다른 분류에 속하면서 피심인들이 경쟁관계에 있다고 주장하는 곰솔루션, 피어링 포털 등을 사용하는 사이트를 순위에 포함시켜 분석을 진행한 데 비하여 위원회는 코리안 클릭에서 분류한 객관적 기준대로 사이트를 선정하여 미디어 서버 프로그램 및 여타 솔루션을 사용하는 업체를 조사하였기 때문이다.

다) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장에 진입장벽을 구축하여 다른 사업자의 사업 활동을 방해한다.

피심인들의 결합판매행위는 미디어 서버 프로그램 시장에서의 경쟁사업자를 직접적으로 배제하는 효과 외에도 이 시장에 대한 신규 사업자의 진입장벽을 높이는 효과도 가져왔다.

피심인들의 결합판매행위는 피심인들에게 경쟁상의 우위를 부당하게 부여하여 WMS가 높은 시장점유율을 얻게 되었는바, 이와 같은 사정은 디지털 미디어 시스템 구성요소 간에 의존성이 크게 작용하는 미디어 서버 프로그램 시장에서 새로운 사업자에게 진입장벽으로 작용하게 된다.

WMS의 편재성은 소프트웨어 개발자들로 하여금 WMS를 이용한 응용프로그램의 개발을 촉진시키고, 이와 같이 WMS를 이용한 다양한 응용프로그램의 증가는 WMS의 효용을 높이게 되는데, WMS를 이용한 다양한 응용프로그램의 존재는 이를 활용할 수 없는 미디어 서버 프로그램의 잠재적 진입자에게 진입장벽으로 작용한다. 왜냐하면 미디어 서버 프로그램에 새로 진입하려는 자는 WMS에 필적할 수 있을만한 다양한 응용프로그램을 직접 또는 제3의 업체들을 통해 당장 또는 가까운 장래에 개발해야 하는 부담을 안게 되기 때문이다.

미디어 서버 프로그램과 더불어 디지털 미디어 시스템을 구성하는 가장 중요한 요소인 미디어 플레이어 시장에서 행한 피심인들의 WMP 결합판매는 WMS 시장의 진입장벽을 더욱 강화하는 역할을 한다.

이와 같이 결합판매는 피심인들 이외의 사업자들이 경쟁할 수 있는 미디어 서버 프로그램의 독자적 시장규모를 축소시킨다. 이는 경쟁 사업자 및 신규 사업자들에게 충분한 수요가 확보될 수 없음을 의미하므로, 잠재적인 경쟁업체들은 기대 수익이 감소하거나 아예 수익을 낼 수 없게 될 수도 있음을 예측하고 시장진입을 포기하게 된다.

그러므로, 피심인들의 결합판매로 인한 진입장벽 구축은 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 더욱 제한한다.

라) 소결

따라서, 피심인들의 결합판매행위는 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 WMS의 편재성을 야기하고 피심인들에게 미디어 서버 프로그램 시장에서의 경쟁상 우위를 획득하게 하며, 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 심각하게 제한하여 경쟁 사업자의 사업활동을 매우 곤란하게 만든다는 사실을 인정할 수 있다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 WMS를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로 부당한 행위이고, 이는 종된 상품인 미디어 서버 프로그램에 대한 소비자의 상품 선택권을 침해하고, 소비자가 우수한 제품을 접할 기회를 현저히 제약하는 불이익을 소비자에게 초래하는 동시에 미디어 서버 프로그램 시장에서 WMS의 편재성 및 쏠림현상을 가중시키는 결과 경쟁을 저해하여 경쟁사업자의 사업활동을 곤란하게 하는 행위로서 공정거래법 제3조의 2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호에 해당한다.

마. 시장지배적지위 남용행위 중 부당하게 소비자 이익을 현저히 저해하는 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 후단은 시장지배적 사업자가 부당하게 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위를 금지하고 있다.

따라서, 피심인들의 행위가 같은 법 제3조의 2 제1항 제5호 후단에 해당하기 위해서는 첫째, 피심인들이 시장지배적지위를 갖는 사업자이고 둘째, 피심인들이 부당한 행위를 하여 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있어야 한다.

이에 대하여, 피심인들은 공정거래법 제3조의 2 제1항 각 호는 시장지배적사업자의 지위남용 행위에 대한 한정적 열거 규정이고, 같은 조 제2항에 의하여 같은 조 제1항 제1호 내지 제4호는 시행령 및 고시에서 시장지배적지위 남용행위 유형을 구체화하고 있는 반면, 같은 조 제1항 제5호 후단은 법률의 규정만 있을 뿐 시행령이나 고시에서 남용 행위의 구체적 기준 및 유형을 정하지 않고 있는 바, 행정부가 법률에 따라 위임된 금지 행위의 유형을 시행령 등에 의하여 정하지 않고, 행위 유형을 임의로 정하여 개별적인 사안에 적용하는 것은 허용될 수 없다고 주장한다.

살피건대, 시장지배적사업자는 일정한 분야에서 상품이나 용역의 가격이나 수량 또는 거래조건의 결정에 지배적인 영향을 미칠 수 있는 지위에 있기 때문에, 그 지위를 남용하는 행위를 하면 시장구조를 악화시키거나, 경쟁사업자의 사업 활동을 방해할 수도 있고, 독점적 이윤의 추구로 일반 소비자의 이익을 침해할 우려도 있다.

그러나 시장지배적지위 남용행위는 매우 다양하여 이를 모두 법에서 규정하는 것은 불가능하므로, 이와 같은 다양한 시장지배적지위 남용행위를 규율하기 위해서는 공정거래법 제3조의2 및 시행령 제5조를 적용함에 있어서 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하여 소비자의 이익을 보호한다는 법의 입법취지를 고려하여 위 규정들을 합목적적으로 해석하는 것이 필요하다.

더구나 공정거래법 제3조의2 제2항은 '남용행위의 유형 및 기준은 대통령령으로 정할 수 있다'고 규정하고 있을 뿐이므로 하위법령인 시행령에서 구체화하지 않았다고 하여 법률을 직접 적용할 수 없는 것은 아니다.

따라서, 공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 후단에 정한 '부당하게 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위'의 경우, 시행령 및 고시에서 이 행위 유형을 구체화 하지 않았다고 하더라도, 같은 법의 해당 법조항을 직접 적용하여 시장지배적사업자의 지위남용행위를 규제할 수 있다 할 것이므로, 시행령이나 고시에서 구체적인 행위를 적시하지 않아 동법의 해당 조항을 직접 적용할 수 없다는 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

또한 피심인들은 공정거래법 제3조의2 제5호 후단에 규정한 시장지배적사업자가 부당하게 소비자 이익을 현저히 저해하는 행위에 대하여 시행령 및 고시에서 구체적인 행위 유형을 전혀 제시하고 있지 않고 있어 규제 대상자의 예측가능성을 침해하고, 법집행 당국의 자의적 처분이 가능하게 되어 헌법상 명확성의 원칙에 반한다고 주장한다.

살피건대, 법치국가원리의 한 표현인 명확성의 원칙은 기본적으로 모든 기본권 제한 입법에 대하여 요구된다 할 것이나, 모든 법률에 있어서 동일한 정도로 요구되는

것은 아니고, 개개의 법률이나 법조항의 성격에 따라 요구되는 정도에 차이가 있을 수 있으며 각각의 구성요건의 특수성과 그러한 법률이 제정되게 된 배경이나 상황에 따라 달라질 수 있다. 따라서 이러한 명확성의 원칙을 산술적으로 엄격히 관철하도록 요구하는 것은 입법기술상 불가능하거나 현저히 곤란하므로 어느 정도의 보편적 내지 일반적 개념의 용어 사용은 부득이 하다고 할 수 밖에 없고 당해 법률이 제정된 목적과 타 규범과의 연관성을 고려하여 합리적인 해석이 가능한 지의 여부에 따라 명확성의 구비 여부가 가려져야 한다[45].

또한, 구성요건이 명확하여야 한다는 것은 그 법률을 적용하는 단계에서 가치판단을 전혀 배제한 무색투명한 서술적 개념으로 규정되어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고, 입법자의 입법의도가 건전한 일반 상식을 가진 자에 의하여 일의적으로 파악될 수 있는 정도의 것을 의미하는 것이라고 할 것이다. 그러므로 다소 광범위하고 어느 정도의 범위에서는 법관의 보충적인 해석을 필요로 하는 개념을 사용하여 규정하였다고 하더라도 그 적용단계에서 다의적으로 해석될 우려가 없는 이상 그 점만으로 헌법이 요구하는 명확성의 요구에 배치된다고 하기는 어렵다 할 것이다.[46]

공정거래법은 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적 기업 활동을 조장하고, 소비자를 보호함과 아울러 국민 경제의 균형있는 발전을 도모하기 위해, 시장지배적지위 남용행위와 여타 공정한 경쟁을 저해하는 행위를 금지하고 있다. 그 중에서도 일정한 거래분야의 시장 지배적 사업자가 그 지위를 남용하는 경우, 시장 구조를 악화시키거나 경쟁 사업자의 사업활동을 방해하고, 독점적 이윤의 추구로 소비자의 이익을 저해할 우려가 있으므로, 공정거래법은 시장지배적사업자의 지위 남용행위를 금지하고 있는 것이다.

그런데 위와 같은 결과를 초래하는 행위는 매우 다양하게 나타날 수 있어, 법 및 시행령 등에서 그러한 행위 유형을 모두 정하는 것은 불가능하다 할 것이므로 다양한 행위 유형을 포섭 가능한 보충적인 조항이 필요하다 할 것이고, 이러한 조항에 해당하는 공정거래법 제3조의 2 제1항 제5호 후단의 규정을 공정거래법의 입법목적 및 법의

45) 헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104

46) 헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13

전체적 체계, 다른 시장지배적지위 남용행위 금지조항과 더불어 유기적으로 해석하여 볼 때 동 조항이 적용되는 경우를 예측할 수 있으므로 본 조항은 명확성의 원칙에 반하지 않는다. 따라서, 피심인들의 주장은 이유 없다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 시장지배적사업자이다.

피심인들이 시장지배적사업자라는 사실은 위 2. 라. (2) (가)에서 살펴 본 바와 같다.

(나) 피심인들의 결합판매행위는 부당한 행위이다.

위 2. 라. (2) (나)에서 살펴 본 바와 같이 PC 서버 운영체제 시장의 지배적 사업자인 피심인들이 PC 서버운영체제와 WMS를 결합하여 판매하는 행위는 부당하게 윈도우 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 소비자에게 별개제품인 WMS의 구입을 강제하는 것으로서 부당한 행위이다.

(다) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

피심인들이 윈도우 서버운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 WMS를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로 직접적으로는 소비자의 상품선택권을 침해하고, 장기적으로는 종된 상품 시장인 미디어 서버 프로그램 시장에서 경쟁을 제한하여 소비자의 후생을 현저히 감소시키게 되므로 공정한 경쟁과 혁신을 통해 얻을 수 있는 소비자 이익을 누릴 수 없게 하는 행위인 바, 이러한 피심인들의 행위는 소비자의 이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위이다.

1) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한함으로써 소비자의 이익을 저해하거나 저해할 우려가 크다.

위 2. 라. (2) (다)에서 살펴 본 바와 같이 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 WMS를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로써 미디어 서버 프로그램 시장에서 WMS의 편재성을 발생시킴과 동시에 경쟁사업자가 누릴 수 없는 경쟁상 우위를 획득하게 한다. 이는 거래상대방인 소비자가 다른 사업자의 제품과 달리 미디어 서버프로그램을 구입하기 위해 추가비용을 들일 필요 없이 WMS에 대한 접근을 용이하게 하여 WMS를 더욱 많이 선택하게 하는 결과를 초래한다. 이와 같은 경쟁제한 효과는 미디어 서버 프로그램 시장에서 피심인들의 시장점유율을 비약적으로 높여 기술적으로 우수하거나 동등한 기업들을 시장에서 부당하게 축출하거나 그들의 사업을 방해하고, 신규 사업자가 시장에 진입하는 것에 대한 장벽을 형성한다.

이는 소비자들이 다른 미디어 서버 제품을 이용할 기회를 사전에 현저히 제약하는 행위로서 공정한 경쟁에 의하여 소비자가 성능과 품질 면에서 우수한 제품을 선택할 권리를 침해한다 할 것이므로 장·단기적으로 소비자들의 후생을 감소시켜 소비자의 이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있다.

경쟁이 제한된 시장에서 소비자의 이익이 어떻게 저해되는 지는 서버 운영체제 시장에서의 피심인들의 가격 추이와 하드웨어 및 다른 경쟁사업자의 운영체제 가격의 추이를 살펴보면 알 수 있다.

리얼네트웍스가 2005. 10. 위원회에 제출한 자료에 의하면 서버 하드웨어에 대한 제조업체의 평균비용은 1995년 4,955달러에서 2004년 2,093달러로, 유닉스 서버 운영체제에 대한 평균가격은 1995년을 기점으로 2004년까지 415달러에서 315달러로 각 하락하였고, 리눅스 서버 운영체제의 경우는 그 가격이 1998년부터 2004년까지 99달러로 일정하였던 반면, 피심인들이 서버 하드웨어 제조업체들에게 제공한 윈도우 서버 운영체제에 대한 라이센스 가격은 1996년의 평균 700달러에서 2004년에는 999달러까지 상

승하였음을 확인할 수 있다.

이상에서 확인된 바와 같이 피심인들이 시장지배력을 보유하고 있는 윈도우 서버 운영체제에 대한 라이센스 가격은 서버 하드웨어 및 다른 서버 운영체제과 달리 지속적으로 상승하였는바, 이는 경쟁이 제한된 시장에서의 소비자의 이익이 침해 될 수 있음을 보여주는 사례이다.

2) 결합판매는 소비자들의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해한다.

피심인들의 결합판매행위는 PC 서버 운영체제 시장의 지배적 사업자인 피심인들이 서버 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 인기 상품인 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매하는 것으로써 이는 WMS의 구입을 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 소비자들의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해한다.

리얼네트웍스가 2005. 1. 19. 제출한 자료, 위원회가 2004. 7. 6. 인터넷 방송 솔루션업체들에게 보낸 질문에 대한 답변내용 및 피심인들이 일부 인정한 사실 등에 의하면, 피심인들은 미디어 서버 프로그램을 개발하기 위해 총 5억 4천만 달러에 달하는 비용을 투자한 사실, WMS를 윈도우 서버 운영체제에 결합판매 함으로써 WMS에 대한 비용을 별도로 소비자로부터 받고 있지는 않으나 윈도우2003 서버 운영체제 중 WMS가 결합되어 있지 않은 웹 에디션의 경우에는 WMS가 결합되어 있는 스탠다드 에디션에 비하여 상당히 저렴한 가격에 팔리고 있는 사실, 서버 운영체제 가격을 책정할 때 기능들을 고려하여 그 수준을 정하는 사실, 그런데 피심인들은 제품을 라이센스하면서 윈도우 2003 서버 웹 에디션을 구입한 소비자가 이를 미디어 서버로 이용하지 못하도록 하고 있는 사실 및 다른 미디어 서버 프로그램사업자들은 제품에 대한 가격책정시 연구개발비용 등과 접속자 수를 고려하여 차등을 두고 있는 사실을 인정할 수 있다.

이러한 사실들을 종합하여 볼 때, PC 서버 운영체제 시장의 지배적지위에 있는 피심인들이 WMS를 윈도우 서버운영체제와 결합하여 단일한 가격으로 판매하는 행위는

WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 지불하지 않아도 되는 비용을 지급하게 하는 행위이다. 따라서 피심인들의 행위는 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 비용상의 불이익을 야기한다.

결론적으로, 피심인들의 결합판매행위는 WMS를 원하지 않는 윈도우 서버 운영체제 소비자들의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해하고, 이러한 선택권 침해는 윈도우 서버 운영체제 소비자들에게 위에서 본 바와 같은 비용상의 불이익을 야기한다할 것이므로 피심인들의 행위는 소비자의 이익을 저해하는 행위이다.

3) 결합판매로 인한 경쟁제한 효과는 기술혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

피심인들의 결합판매행위는 미디어 서버프로그램 시장에서 경쟁을 제한하고, 진입장벽을 형성하여 신규 진입자가 시장에 진출하는 것을 매우 어렵게 한다는 사실은 위에서 살펴 본 바와 같다.

이는 피심인들이 미디어 서버프로그램 시장에서 품질 등 제품 자체에 의한 경쟁을 할 필요가 없다는 것을 의미한다. 왜냐하면 피심인들은 PC 서버 운영체제의 시장지배력을 이용한 윈도우 서버 운영체제와 WMS의 결합판매를 통하여 언제나 경쟁사업자의 미디어 서버 프로그램 제품과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있고, 우수한 제품이 시장에 진입하는 것도 막을 수 있기 때문이다.

피심인들이 결합판매 후 품질경쟁을 할 필요가 없어 제품개선을 하지 않아 기술혁신을 저해한다는 사실은 과거 피심인들이 시장지배력을 보유한 PC 운영체제에 웹 브라우저인 인터넷 익스플로러를 끼워팔기한 사례 및 관련 전문가의 의견[47] 등을 종합해

47) 노벨경제학상을 수상하기도 한 스티글리츠(Stiglitz) 교수가 본건 심의를 위하여 제출한 의견서에 따르면 결합판매로 인한 경쟁제한 효과는 다음과 같이 기술혁신을 저해한다고 한다. 먼저, 결합판매로 해당시장에서 독점적 지위를 구축한 사업자는 첫째, 독점으로 진입장벽을 높인 결과, 본인 스스로 기술혁신을 할 유인이 없어지게 되어 기술혁신을 저해하고, 둘째, 기술혁신을 하기는 하나, 소비자에게 이익이 되는 방향으로 하는 것이 아니라 해당시장에 대한 진입장벽을 높이고, 경쟁자의 비용을 증가시키는 방향으로 이를 하게 되며, 셋째, 기술혁신에 대한 독점적 사업자의 동기가 매우 제한적이어서 경쟁을 피하기 위한 낮은 수준의 혁신만을 꾀하게 되어 기술혁신을 저해하게 된다 할 것인바, 넷스케이프 사례는 위 세가지에 모두 해당될 수 있다고 하고 있다.

볼 때 그 가능성을 충분히 인정할 수 있다.

웹 브라우저 시장은 넷스케이프(Netscape)사에 의해 새로이 창출되었는데, 넷스케이프사에 의한 네비게이터(Navigator) 개발은 인터넷 산업에 대변혁을 가져왔고, 1994. 12. 네비게이터를 출시하자마자 소비자들로부터 폭발적인 인기를 구가하며 1995년경에는 시장점유율이 70%에 이르게 된다.

웹 브라우저 시장의 후발 주자였던 피심인들은 이와 같은 상황에서 PC 운영체제에 웹브라우저를 결합판매하기로 결정하고, 인터넷 익스플로러 3.0을 1996. 10월부터 윈도우95 OSR2에 결합판매하기 시작한다. 결합판매 후 피심인들은 브라우저 시장에서의 점유율이 비약적으로 높아졌고, 넷스케이프는 급속하게 점유율이 하락하여 현재 웹 브라우저 시장에서 퇴출된 상태이다. 넷스케이프사는 1999년 AOL[48]에 인수되었다.

위와 같이 피심인들의 인터넷 익스플로러가 웹 브라우저 시장에서 강력한 시장지배력을 보유하게 된 이후 최근 4년간 피심인들은 인터넷 익스플로러에 대해 본격적으로 업데이트 한 사실이 없다.

아래 <표 2-21>은 웹 브라우저 시장이 경쟁구조였을 때와 피심인들의 인터넷 익스플로러가 시장지배력을 보유하게 된 이후의 제품 업데이트 주기를 보여주고 있는데, 피심인들은 경쟁 상태에서는 업데이트를 매년 약 3회하였으나, 독점이 이루어지고 난 이후에는 아예 차기 버전을 발표하고 있지 않음을 알 수 있다.[49]

48) AOL-타임워너사는 2002.1월 반독점 민사소송을 제기하였나 2003.6월 약 7.5억달러에 피심인 엠에스와 합의하기에 이르렀다.

49) 미국의 저명한 IT 잡지인 ZDNet은 2004. 8. 11.자 “인터넷 익스프로러의 개선, 과연 충분한가? (IE is evolving, but is it enough?)”라는 기사에서 피심인 엠에스의 인터넷 익스플로러의 시장지배가 인터넷 브라우저 시장에 가져온 기술혁신 저해 효과를 설명하고 있다[1]. 이 기사에서는 다른 모든 인터넷 브라우저들은 최근 6개월 동안 업데이트가 이루어진데 비해, 마이크로소프트는 새로운 버전의 브라우저 신제품을 출시한 지 3년이 지났음에도 불구하고 업데이트가 이루어지지 않고 있어, 웹 개발업계에서는 이러한 느린 업데이트로 인해 온라인 기술혁신이 지체되고 있다는 목소리가 높아가고 있음을 지적하고 있다. (.ZDNet 웹페이지 (http://www.zdnet.com.au/insight/software/0,39023769,39155947,00.htm)

<표 2-21> 인터넷 브라우저 업데이트 주기

구 분	피심인의 독점화 이전 (1995 ~ 2000)	피심인의 독점화 (2001 ~ 2004)	파이어폭스 등장 이후 (2005~)
넷스케이프	매년 약 2회	-	-
피심인 익스플로러	매년 약 3회	2001.8월 v.6 개발 이후 차기 버전 발표 없음	2005.여름 v.7 발표 예정이었으나 발표 없음
Fire Fox			2005.2.15. 발표이후 수시
합계	매년 약 3회	없음	별 차이 없음

* 신고인 리얼네트웍스 제출자료('05. 9.)참고하여 작성

위와 같은 사실들은 인터넷 익스플로러의 시장독점으로 인한 경쟁의 부재가 웹 브라우저의 기술발전을 저해하는 요인이 되고 있음을 보여 준다.

따라서, 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매하는 행위는 부당하게 경쟁을 제한하고 이는 기술혁신을 저해하여 사회적 손실을 야기할 수 있음을 인정할 수 있다.

이에 대하여 피심인들은 윈도우 서버 운영체제와 WMS의 결합판매행위가 소비자에게 이익이 된다는 취지의 주장을 하나, 이러한 주장은 위 2. 라. (2). (나). 4)에서 살펴 본 바와 같이 이유없다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 PC 서버 운영체제 시장에서의 지배적 지위를 이용하여 종된 상품인 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한함으로써 소비자의 상품 선택권을 침해하고 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한하여 소비자 후생을 감소시키며, 기술혁신을 저해하여 사회적 손실 등을 야기하는 바, 이는 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위로서 공정거래법 제3조의 2 제1항 제5호 후단에 해당한다.

바. 불공정거래 행위의 거래강제 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제23조 제1항 제3호는 사업자가 “부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위”를 금지하고, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕에서 위 유형을 구체화한 ‘끼워팔기’를 규정하고 있는 바, 동 규정에 의하면 끼워팔기란 “거래상대방에 대하여 자기의 상품 또는 용역을 공급하면서 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 다른 상품 또는 용역을 자기 또는 자기가 지정하는 사업자로부터 구입하도록 하는 행위”이다.

따라서 피심인들의 행위가 이 규정에 해당하기 위해서는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 주된 상품과 별개인 종된 상품의 구입을 강제하여야 하고 둘째, 피심인들의 행위가 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

1) 윈도우 서버 운영체제와 WMS는 별개의 제품이다.

주된 상품과 종된 상품이 서로 다른 별개의 상품인지 여부는 이 제품들이 시장에서 통상 별도로 거래되는지 여부, 양 제품의 상업적 용도나 기능적 특성, 소비자의 인식 태도를 종합적으로 고려하여 판단하는 바, 이와 관련하여 우리 서울고등법원은 한국토지공사 처분 취소 사건에서 ‘거래상대방이 구입하고자 하지 않는 종된 상품이란 주된 상품의 밀접불가분한 구성요소가 아닌 별개의 상품으로서 독립하여 거래의 대상이 될 수 있고, 통상적으로 주된 상품과 짝지어 하나의 단위로 판매 또는 사용되지 않는 상품이면 족하다’고 판시한 바 있다[50].

따라서, 위 2. 라. (2) (나) 1)에서 살펴 본 바와 같이 WMS는 윈도우 서버 운영체제와 밀접 불가분한 구성요소가 아니고, 미디어 서버 프로그램인 WMS 자체로 독립하여 거래의 대상이 될 수 있으며, 통상적으로 미디어 서버 프로그램은 서버 운영체제와 짝지워 하나의 단위로 판매되는 상품이 아니므로 WMS는 별개의 제품이다.

(나) 피심인들은 부당하게 거래 상대방에게 WMS의 구입을 강제한 것이다.

「불공정거래행위 심사지침」(공정거래위원회 예규 제26호) Ⅴ. 5. 가. (나)에 의하면, 끼워팔기를 하는 사업자가 거래상대방에 대하여 주된 상품과 종된 상품의 동반 구입을 강제할 수 있는지 여부는, 당해 상품의 시장지배력, 브랜드 특성, 소비 실태 등을 고려하고, 특히 강제성이 존재하는지 여부는 거래상대방의 입장에서 서로 다른 두 상품을 따로 구입하는 것이 자유로운지를 기준으로 판단하는바, 주된 상품에 대한 구매자의 거래처 전환가능성이 적을수록 강제성은 커지게 된다.

따라서, 위 2. 라. (2) (나) 2)에서 살펴 본 바와 같이 피심인들의 결합판매행위는 종된 상품인 WMS의 판매를 촉진하기 위하여 주된 상품인 윈도우 서버 운영체제 구입시 WMS도 함께 제공하는 것으로써 주된 상품인 피심인들의 윈도우 서버 운영체제를 구입하여 다른 용도로 사용하고자 하는 소비자로서는 사실상 종된 상품인 WMS를 구입할 수 밖에 없는 상황에 처하게 되었다 할 것이고, PC 서버 운영체제 시장에서 77%를 점유하고 있는 피심인들이 끼워팔기에 해당하는 결합판매행위를 하는 경우 윈도우 서버 운영체제 구매자들은 구입을 원하지 않는 WMS를 구입할 수 밖에 없게 되므로, 피심인들의 결합판매행위는 윈도우 서버 운영체제와 WMS를 거래상대방에게 동반하여 구입하도록 강제한 것으로 인정된다.

3) 소결

따라서 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 윈도우 서버 운영체제와 미디어 서버 프로그램인 WMS는 별개의 다른 제품임에도 불구하

50) 서울 고등법원 2004. 2. 10. 선고. 2001누16288 판결

고, 거래상대방인 윈도우 서버 운영체제의 구매자들이 WMS를 원하지 않는데도 불구하고 WMS를 강제로 구입하게 한 것이다.

(나) 피심인들의 행위는 공정거래를 저해한다.

「불공정 거래행위 심사지침」(위원회 예규 제26호) Ⅲ. 1.에 의하면, '공정거래저해성'이란 경쟁제한성과 불공정성을 포함하는 개념으로서 경쟁제한성은 당해 행위로 인해 시장 경쟁의 정도 또는 경쟁사업자(잠재적 경쟁사업자 포함)의 수가 유의미한 수준으로 줄어들거나 줄어들 우려가 있음을 말하고, 불공정성은 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않음을 의미한다. 경쟁수단의 불공정성은 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있으면 인정되고, 거래내용의 불공정성은 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있으면 족하다.

따라서 끼워팔기로 인하여 종된 상품 시장에서 경쟁제한 효과가 발생하는 경우뿐만 아니라 경쟁제한 효과가 유의미한 수준이 아니라 하더라도 경쟁 수단이 불공정한 경우에는 공정거래 저해성이 인정될 수 있다.

다만, 위 지침 Ⅴ. 5. 가. (다)에 의하면, 이 경우 불공정거래 행위 중 끼워팔기가 불공정한 경쟁 수단에 해당하거나 경쟁 제한성이 있다고 하여도 끼워팔기로 인한 효율성 증대 효과나 소비자 후생 증대효과가 경쟁수단의 불공정성으로 인한 공정거래 저해 효과 또는 경쟁제한 효과를 현저히 상회하는 경우에는 법 위반으로 보지 않을 수 있다.

1) 피심인들의 결합판매 행위는 경쟁을 제한한다.

위 2. 라. (2) (다)에서 살펴 본 바와 같이, 피심인들의 결합판매행위는 WMS의 편재성을 발생시켜, 피심인들에게 미디어 서버 프로그램 시장에서 경쟁사업자가 누릴 수 없는 경쟁상 우위를 획득하게 하고, 이러한 경쟁상 우위는 피심인들의 디지털 미디어

시스템 구성요소 간의 상호의존성으로 인하여 더욱 심화되는바, 이와 같은 효과는 결국 미디어 서버 프로그램 시장에서 피심인들의 점유율은 비약적으로 높이는 동시에 유력한 경쟁사업자인 리얼네트웍스를 한국 시장에서 철수하게 하고, 디디오넷의 매출액을 점점 감소시키고 있으며, 신규 사업자에 대한 진입 장벽을 형성한다.

따라서, 피심인들의 행위는 우수한 경쟁기업들을 시장에서 축출하고, 진입장벽을 형성하며, 피심인들의 미디어 서버 프로그램 시장에서의 점유율을 비약적으로 높여 지배력을 행사할 수 있을 정도임을 인정할 수 있어 경쟁제한성이 있다.

2) 피심인들의 결합판매 행위는 거래조건 또는 수단이 불공정한 행위이다.

소비자들은 원칙적으로 자신이 원하는 상품을 선택할 자유가 있는 바, 피심인들의 끼워팔기는 소비자에 대하여 윈도우 서버 운영체제를 공급하면서 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 별개 제품인 WMS를 피심인들로부터 구입하도록 하는 행위로서 거래상대방인 소비자로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품인 WMS의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택의 자유를 침해한다. 그 결과 종된 상품 시장인 미디어 서버 프로그램 시장에서 양질 · 염가의 상품을 제공함으로써 고객을 확보한다는 장점에 의한 경쟁을 저해함은 앞에서 인정한 바 있으므로, 이러한 끼워팔기는 정상적인 거래관행이 아니라 할 것이고 이러한 피심인들의 행위는 거래 조건 또는 수단이 불공정한 행위임을 인정할 수 있다.

3) 피심인들의 행위로 인한 효율성증대 효과는 미약하여 경쟁제한 효과를 능가하지 못한다.

이에 대하여 피심인들은 서버 운영체제에 미디어 서버 프로그램인 WMS를 결합판매하는 것은 단독으로 판매하는 경우에 비하여 다음과 같은 효율성이 있다고 주장한다. 즉 미리 제조 단계에서 결합되어 나오므로 사용자가 쉽게 설치 및 사용할 수 있어 거래비용을 감소시키고, 소비자들이 추가비용을 지불할 필요 없이 일반목적용 서버 운영체제를 제공받을 수 있으며, 피심인들의 소프트웨어 개발도구를 이용하는 경우 윈도

우 서버 운영체제를 기반으로 한 다양한 응용프로그램을 용이하게 개발할 수 있어 소프트웨어 개발업자들에게 이익이 되고, 서버 컴퓨터 제조업체에게는 결합판매가 스트리밍 미디어 서버 하드웨어에 대한 수요의 증가를 가져와 혜택을 준다는 것이다.

그러나, 피심인들이 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합한 것은 WMS를 윈도우 서버 운영체제와 함께 배포하여 서버의 옵션으로 WMS를 설치할 수 있도록 한 것일 뿐 코덱이나 인코딩 기술의 향상, 스트리밍 및 버퍼링 시간의 단축과 같은 미디어 시스템의 중요한 기술 향상을 가져온다는 사실을 증명할 근거를 피심인들도 제출하고 있지 못하다. 또한, 개발업자에게 제공하는 편익은 다른 미디어 서버프로그램도 피심인들의 운영체제에 탑재될 수 있다면 동일하게 얻을 수 있는 편익이며, 스트리밍 기능을 할 수 있는 서버 컴퓨터에 대한 수요 개발 역시 피심인들이 끼워팔기를 하지 않더라도 소비자들이 원하는 시스템을 구성하여 판매하는 솔루션업체 등을 통해서도 이루어 질 수 있다. 게다가 위 2. 마. (2) 2)에서 살펴 본 바와 같이 피심인들은 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 단일한 가격으로 판매함으로써 윈도우 서버 운영체제 소비자에게 지불하지 않아도 되는 비용을 지불하게 하고 있어 미디어 서버 프로그램을에 대한 추가비용이 없다고 하기 힘들다. 그러므로, 위와 같은 점을 고려할 때 피심인들의 결합판매만이 달성할 수 있는 효율성이 존재함을 인정하기 어려울 뿐만 아니라 피심인들의 결합판매로 인한 경쟁제한 효과를 현저히 상회하는 별도의 효율성 증대효과도 인정되기 힘들다고 보여진다. 따라서 피심인들의 주장은 모두 이유 없다.

4) 소결

피심인들의 결합판매행위는 미디어 서버 프로그램 시장에서 우수한 경쟁 사업자의 사업 활동을 현저히 곤란하게 하고, 신규 사업자에 대한 진입장벽을 형성하며, 피심인들의 미디어 서버 프로그램 시장에서의 점유율은 비약적으로 높여 경쟁을 제한하였음을 인정할 수 있고, 이러한 행위는 윈도우 서버 운영체제 구매자들에게 WMS의 구입을 강제하여 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해하는 행위로서 정상적인 거래관행이라 인정할 수 없으므로 거래 수단도 또한 불공정하다.

(3) 결론

피심인들이 주된 상품인 윈도우 서버 운영체제에 종된 상품인 WMS를 결합하여 판매한 행위는 주된 상품 공급자라는 지위를 이용하여 별개 독립의 상품인 WMS를 구입하지 않고서는 주된 상품인 윈도우 서버 운영체제를 구입할 수 밖에 없는 상황을 만든 것으로서 이는 거래상대방인 소비자들의 상품 선택의 자유를 침해할 뿐만 아니라, 양질 ·염가의 상품을 제공함으로써 고객을 확보한다는 가격과 품질에 의한 경쟁을 침해하는 것이므로 불공정 거래행위 중 거래강제의 끼워팔기에 해당하는 행위로서 공정거래법 제23조 제1항 제3호 후단, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목에 해당한다.

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의 2)에 위반한 각 행위에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

'과징금 산정의 기준이 되는 고시'는 피심인들의 결합판매행위가 2000. 2.부터 본건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」(2005.7.13. 공정거래위원회 고시 제2005-15호, 이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용한다.

과징금 산정의 기초가 되는 '위반행위의 기간'은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하는데, 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는 당해 사건에 대한 위원회의 심의일을 위반행위의 종료일로 보는 바, 이때 심의가 2일 이상 진행되었다면 마지막 심의일이 위반행위의 종료일에 해당하게 된다. 따라서 피심인들의 위반 행위가 2000. 2.부터 지금까지 계속 되고 있는 본 사안은 2000. 2월이 법위반 행위의 개시일이, 본 사안의 마지막 심의 종료일인 2005. 10. 26.이 법위반 행위의 종료일에 해당하게 된다.

과징금 산정의 기준 금액이 되는 '관련 매출액'은 위반사업자가 위반기간 동안 판매 또는 매입한 관련 상품의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하는 것으로서 본 사안에서 법 위반기간 동안 윈도우 서버 운영체제의 매출액은 피심인 엠에스는 28,499,892천원, 피심인 한국 엠에스는 75,795,462천원이다.

(나) 과징금의 결정

'기본 과징금'은 관련매출액에 위반행위의 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는 바, 피심인들의 결합판매행위는 법위반행위의 내용과 정도가 매우 중대한 위반행위에 해당하므로 과징금 부과기준율 중 최대인 2.0%를 적용하여, 피심인 엠에스에 대해서는 569,997천원, 피심인 한국 엠에스에 대해서는 1,515,909천원을 각 기본 과징금으로 산출한다.

'의무적 조정 과징금'은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법 위반행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

'임의적 조정 과징금'은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반 행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로, 위에서 산정된 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 626,996천원, 피심인 한국 엠에스는 1,667,499천원을 각 임의적 조정 과징금으로 산출한다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 시장지배적 지위남용행위 중 다른 사업자에 대한 사업활동 방해행위 및 소비자 이익을 현저히 저해한 행위와 관련한 각 과징금액은 위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여 피심인 엠에스는 626백만원, 피심인 한국 엠에스는 1,667백만원이 각 산출된다.

(2) 불공정거래행위 금지규정(제23조)에 위반한 행위에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

'과징금 산정의 기준이 되는 고시'는 피심인들의 결합판매행위가 2000. 2.부터 본 건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금고시」를 적용한다.

(나) 과징금의 결정

'기본 과징금'은 관련매출액에 위반행위 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 피심인들의 결합판매행위는 법위반행위의 내용과 정도가 매우 중대한 위반행위에 해당하므로 과징금 부과기준율 중 최대인 1.0%를 적용하여 피심인 엠에스 284,998천원, 피심인 한국 엠에스 757,994천원을 각 기본과징금으로 산출한다.

'의무적 조정 과징금'은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법위반 행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

'임의적 조정 과징금'은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반 행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 313,497천원, 피심인 한국 엠에스는 833,749천원을 각 임의적 조정 과징금으로 산출한다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기와 관련한 과징금액은 위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여 피심인 엠에스는 313백만원, 피

심인 한국 엠에스는 833백만원이 산출된다.

(3) 부과과징금의 결정

이 사건 피심인들의 윈도우 서버 운영체제에 WMS를 결합하여 판매한 행위는 이미 살펴본 바와 같이 공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호에서 규정하고 있는 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위 및 같은 조항 제5호 후단의 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위, 같은 법 제23조 제1항 제3호 후단, 제2항, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련〔별표 1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목의 끼워팔기 행위에 각 해당한다.

시장지배적지위 남용행위와 불공정거래행위를 금지하는 입법목적이나 보호법익이 각기 다르고, 불공정 거래행위의 행위태양이 시장지배적 지위 남용행위의 행위태양에 모두 포섭될 수 있는 것은 아니므로 양 규정은 원칙적으로 경합적용될 수 있다 할 것이다.

다만 여러 법규정이 경합하여 적용된다 할지라도, 법위반 행위의 기초가 되는 사실이 하나인 것을 감안하여 법정 과징금 부과비율이 보다 중한 시장지배적 지위남용금지 규정에서 정한 바에 따라 과징금을 부과하기로 한다.

3. 윈도우 PC 운영체제와 윈도우 미디어 플레이어의 결합판매

가. 기초사실

(1) PC 운영체제 현황

PC 운영체제는 PC 운영체제가 탑재되는 컴퓨터의 중앙처리장치(이하 “CPU”라 함)의 종류에 따라 ‘인텔호환 PC 운영체제’와 ‘비인텔호환 PC 운영체제’로 구별된다. 국내 인텔호환 PC 운영체제 사업자로는 주식회사 한컴리눅스, 레드햇코리아(Red hat Korea) 주식회사 와우리눅스 등 리눅스(Linux) 계열의 공개소프트웨어를 공급하는 사업자들과, 비인텔호환 운영체제를 공급하는 사업자로는 애플컴퓨터코리아(주)(이하 “애플”이라 함) 등이 있다.

현재 세계시장의 시장점유율 분포는 2004년 출하량 기준으로 피심인들이 93.9%, 애플 3.7%, 리눅스 2.3%, 매출액 기준으로 피심인들이 96.6%, 애플 2.2%, 리눅스 0.3%를 차지[51]하고 있으며 국내시장에서는 피심인들의 독점적 지위가 더욱 심각하여 판매량 기준 약 99%의 시장점유율을 보유하고 있다.

(가) 피심인 엠에스의 윈도우 PC 운영체제 출시 및 가격

피심인 엠에스는 1980년대 초 엠에스 도스(MS-DOS)라는 PC 운영체제를 개발하기 시작하였다. 이후 엠에스 도스(MS-DOS)는 그림에 의한 화면구성(graphical user interface ; GUI)을 이용함으로써 <표 3-1>과 같이 사용자 편의성을 증진한 일련의 윈도우 운영체제로 발전되어 현재 윈도우XP에 이르고 있다.

<표3-1> 피심인들의 PC 운영체제 출시 내역

제품	출시일
윈도우95	1995. 11.
윈도우98	1998. 8.
윈도우98 SE(Second Edition)	1999. 7.
윈도우2000 Professional	2000. 3.
윈도우Me	2000. 9.
윈도우XP	2001. 10.

* 출처 : 「한국마이크로소프트 주요제품」(www.microsoft.com/korea/info/fastfact_korea/launch_year.htm)

51) 2005년 인터넷 데이터 센터(Internet Data Center: IDC) 자료

국내에 공급되는 윈도우 PC 운영체제의 가격은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 제품별 업그레이드 버전과 풀 버전의 가격

(단 위 : 원)

버전	업그레이드용[52]	풀 버전[53]
윈도우 Me	110,308	211,508
윈도우 2000 프로페서널	221,628	322,828
윈도우 XP 프로페서널	201,388	302,588
윈도우 XP 홈 에디션	100,188	201,388

* 출처 : 마이크로소프트 웹사이트(http:/shop.microsoft.com/Referal/Production.asp?siteID=10451)

(나) 피심인들의 윈도우 PC 운영체제 국내 판매현황

<표 3-3> 피심인들의 PC 운영체제 국내 판매현황(매출액)

(단위 : 천원)

구분		윈도우 98SE	윈도우 Me	윈도우 2000	윈도우 XP	총계
1999	한국MS					
	MS본사					
2000	한국MS					
	MS본사					
2001	한국MS					
	MS본사					
2002	한국MS					
	MS본사					
2003	한국MS					
	MS본사					
2004	한국MS					
	MS본사					
2005. 10.26.	한국MS					
	MS본사					
매출액 계						1,372,630,548

* 출처 : 피심인들 제출자료(단, 피심인들이 사업상 비밀이라는 이유로 비공개 요청)

* 매출액이 마이너스로 표시된 경우는 제품의 반품 등에 기인한 것임

52) 기본적으로 기존 제품과 동일한 제품이나, 오류 시정이나 기능을 향상시킨 소프트웨어를 의미한다.

53) 최초의 소비자가 운영체제를 구입할 때 사용하는 소프트웨어를 의미한다.

(다) 윈도우 PC 운영체제외의 PC 운영체제

1) 리눅스 제품군

리눅스(Linux)는 1991년 핀란드 헬싱키 대학 학생이던 리누스 토발즈(Linus Torvalds)가 대형 컴퓨터에서만 작동하던 운영체제인 유닉스를 개인용 컴퓨터(PC)에서도 작동할 수 있도록 만든 운영체제이다. 일반적으로 사용자가 추가적인 기능을 원하는 경우에는 다른 소프트웨어를 리눅스에 추가하여 사용한다. 리눅스는 인텔호환 PC에서 작동하며 유닉스와 경쟁할 목적으로 개발되었기 때문에 리눅스의 많은 특징들은 사실상 유닉스의 그것들과 비슷하다.

국내외에 존재하는 리눅스 공급업체로는 레드햇(Red Hat)리눅스, 수세(SuSE)리눅스, 한컴리눅스, 와우리눅스 등이 있다. 이들은 대부분 하드웨어와는 별개로 소프트웨어만을 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 영업하고 있다.

2) 맥(Mac) 운영체제

비(非) 인텔호환 PC 운영체제로서는 애플의 Mac 운영체제가 있다. Mac 운영체제는 애플의 하드웨어인 맥킨토시(Macintosh), 아이맥(iMac) , 이맥(eMac) 등에서만 작동되도록 디자인되었다.

(라) PC 운영체제의 유통경로

PC 운영체제의 유통경로는 크게 PC 제조업체를 통하여 최종사용자에게 판매되는 경로(이하 “PC탑재 경로”라 한다)와 PC 제조업체를 거치지 아니하고 최종 사용자에게 직접 판매되는 경로(이하 “직접 판매경로”라 한다)로 구분할 수 있다.

PC탑재 경로는 PC 운영체제가 PC 제조업체들에 의해 사전에 PC에 설치된 상태

로 최종사용자에게 판매되는 형태로서, PC를 새로 구매하는 소비자의 거의 대부분이 이러한 경로를 통하여 운영체제를 구매하게 된다. 피심인 엠에스의 경우도 전체 PC 운영체제 판매량의 대략 87% 정도가 이 경로를 통하여 판매되고 있다. 피심인 엠에스의 경우에는 자신의 자회사인 MSLGP(Microsoft Licensing General Partnership)를 통해 국내 PC 제조업체와 직접 운영체제 공급계약을 맺고 판매하는 형식을 취하고 있다.

피심인들의 경우 PC탑재 경로는 라이센스 방식에 따라 ①OEM(Original Equipment Manufacture)경로, 즉 엠에스(MSLGP)와 OEM계약을 체결한 대형 PC 제조업체(삼성, HP, IBM 등)에 의한 유통경로와 ②COEM(Commercial OEM)경로, 즉 한국 엠에스의 국내 총판이 중소규모 PC 제조업체(용산전자상가 등에 소재한 중소업체들)에게 판매하는 경로가 있다.

직접판매 경로는 PC 운영체제 사업자가 자신의 총판이나 대리점 등을 통하여 일반 소비자나 기업에게 직접 판매하는 방식이다. 한국 엠에스의 경우는 ①'피심인→총판→Reseller→개인/기업사용자'와 대기업이 고객인 때에 이용되는 ②'피심인→공인 라이센스 파트너(LAR ; Large Account Reseller)→대기업' 등의 유통경로를 이용하고 있다. 한국 엠에스는 현재 국내에 주식회사 한글과 컴퓨터, 한국 휴렛팩커드 등 13개 사업자를 공인 라이센스 파트너로 지정하고 이들이 한국 엠에스로부터 취득한 라이센스 권리를 최종수요처에게 재판매하는 형식으로 운영체제를 공급하고 있다. 한편, 초대형 수요처의 경우에는 한국 엠에스가 최종수요처와 직접 라이센스 계약을 체결하기도 한다.

(2) 디지털 콘텐츠(digital contents)

'디지털 콘텐츠'(digital contents)라 함은 부호·문자·음성·음향·이미지 또는 영상 등으로 표현된 자료 또는 정보로서 그 보존 및 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것을 말한다.

최근 초고속인터넷의 확산과 방송·통신간의 융합현상은 인터넷 콘텐츠와 방송용 콘텐츠의 경계를 허물고 과거 TV와 라디오, 극장 등에서 유통되던 콘텐츠들을 디지털

화하여 컴퓨터, 피디에이(PDA), 휴대폰 등을 통하여 자유롭게 이용할 수 있도록 하고 있다. 이에 따라, 디지털 콘텐츠 시장에서는 음향과 동영상이 가미된 멀티미디어 콘텐츠를 효과적으로 전송하기 위한 압축 및 전송 기술 등 멀티미디어 기술간 시장 확장을 위한 경쟁이 활발하게 전개되고 있다.

특히 PC를 기반으로 한 멀티미디어 기술인 '디지털 미디어 시스템'(digital media system) 분야는 21세기 성장산업인 디지털 콘텐츠 시장의 표준을 장악하기 위한 디지털 미디어의 교두보라는 점에서 그 중요성이 매우 크다. 왜냐하면, PC는 디지털 미디어를 위한 잘 정비된 플랫폼으로 지난 수년 동안에 음악 및 비디오 콘텐츠와 관련하여 성공적인 사업모델이 구축되어 왔고, 홈 엔터테인먼트 시스템·피디에이(PDA)·휴대폰 등과 같이 PC와 연결되거나 PC에 전송되는 것과 동일한 콘텐츠를 입력할 수 있는 다른 유·무선 장치들과의 관계에서 디지털 미디어의 중추로 성장하여 왔기 때문이다.

따라서, PC를 기반으로 한 디지털 미디어 시스템 특히 스트리밍 미디어 포맷, DRM 및 프로토콜을 기술표준으로 확립한 기업은 디지털 미디어 시스템 시장 자체로부터 수익을 창출할 수 있을 뿐 아니라, 스트리밍 미디어 분야에서 표준으로 채택된 점을 활용하여 그 기술표준을 관련시장으로 확대할 수 있는 기반을 갖추게 된다.

그 결과, 특정 사업자가 PC상의 미디어 포맷 등 디지털 미디어의 배포를 장악하게 된다면 그 사업자는 관련시장 및 새로운 장치와 서비스 분야에서도 디지털 미디어의 성장을 통제하고 조정하는 우월적 지위를 점하게 될 것이다.

(3) 스트리밍 미디어 플레이어 현황

스트리밍 미디어 플레이어(이하 특별한 언급이 없는한 "미디어 플레이어"라 한다) 사업자들은 ①자체 포맷, 인코더, 스트리밍 프로토콜, 미디어 서버 프로그램, 저작권 보호 프로그램(DRM) 등 미디어 서비스를 제공하기 위한 일체화된 고유한(proprietary) 원천기술을 보유하고 있는 사업자(이하 "원천기술 보유 사업자"라 함)와 ②상업적인 인코더 또는 미디어 서버 프로그램 판매 사업 등을 영위하지 않고 미디어 플레이어 등

일부 시장에만 참여하고 있는 사업자(이하 “2차 사업자”라 함)로 구분할 수 있다.

(가) 피심인들의 미디어 플레이어

피심인 엠에스는 1991. 11. 윈도우 3.0을 위한 이른바 ‘멀티미디어 익스텐션(Multimedia Extensions)’을 출시한 이래로 <표 3-4>에서 보는 바와 같이 일련의 발전된 미디어 플레이어를 출시하였다. 다만, 초기의 미디어 플레이어는 실시간 재생 기능을 갖추지 못하고 저장된 미디어 파일을 단순히 재생하는 기능만을 갖고 있었다.

<표 3-4> 피심인의 미디어 플레이어 출시 내역

명 칭	출시일	운영체제
Multimedia Extensions	1991. 11.	윈도우 3.0
Media Player 1.0	1992. 4.	윈도우 3.1
Media Player 2.0	1995. 4.	윈도우95 Gold
NetShow Player 1.0	1996. 9.	윈도우95 OSR2
NetShow Player 2.0	1997. 4.	윈도우95 OSR2, 윈도우98
Windows Media Player 5.2	1998. 8.	윈도우98
Windows Media Player 6.0	1999. 4.	윈도우98
Windows Media Player 6.1	1999. 4.	윈도우98 SE
Windows Media Player 6.4	1999. 8.	윈도우98 SE
Windows Media Player 7.0	2000. 9.	윈도우 Me
Windows Media Player 7.1	2001. 5.	윈도우 Me
Windows Media Player 8.0	2001. 10.	윈도우XP
Windows Media Player 9.0	2003. 1.	윈도우XP

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 7. 30.)

초기의 사용자들은 피심인 엠에스의 이 멀티미디어 익스텐션(Multimedia Extensions)이라는 미디어 플레이어를 이용하여 다운로드 받은 정지 사진이나, WAV와 MIDI 파일 포맷형식의 사운드만을 보거나 들을 수 있었다. 다운로드 받은 비디오 파일의 재생은 1995년 출시된 Media Player 2.0부터 비로소 가능하게 되었다.

피심인 엠에스는 1998. 5. 인터넷을 통해 스트리밍되는 미디어 파일을 재생할 수 있는 기능을 가진 WMP 베타버전을 처음으로 출시하였다. 이 미디어 플레이어는 MPEG, QuickTime, RealAudio, RealVideo 등 다양한 포맷의 미디어 콘텐츠를 재생할

수 있었다.

피심인 엠에스는 1999. 7.부터 국내에 윈도우98 SE를 출시하였는데, 이 PC 운영체제에는 스트리밍 미디어 플레이어인 WMP 6이 포함되어 있었다. WMP 6은 윈도우98 SE가 설치될 때 함께 자동으로 설치되며, 프로그램 제거 기능을 이용하여 안전하게 제거할 수 없도록 설치되었다. WMP 6은 초기에는 리얼네트웍스, 애플의 포맷으로 제작된 미디어 콘텐츠도 실행할 수 있었으나 1999. 8.부터 이들 경쟁사 포맷에 대한 지원을 중단하였다.

이후 피심인 엠에스는 윈도우98 SE의 후속 제품인 윈도우 Me(Windows Me), 윈도우2000 프로페셔널(Windows 2000 Professional), 윈도우 XP(Windows XP)에도 마찬가지로 WMP의 개량된 버전이 운영체제 설치시 자동으로 함께 설치되도록 포함시켰고, 이렇게 자동설치된 프로그램은 나중에 사용자가 프로그램 제거 기능을 이용하여 안전하게 제거할 수 없도록 설계하였다.

(나) WMP 외의 미디어 플레이어

1) 원천기술 보유 사업자

원천기술 보유 사업자로는 리얼네트웍스, 애플, 그래텍 등이 있다.

리얼네트웍스는 1995년에 세계 최초로 상업적으로 스트리밍 방식의 미디어 서비스를 시작한 업체로서, 현재 기본적 스트리밍 기능을 갖춘 '리얼플레이어'(RealPlayer)와 이에 더한 고급기능을 갖춘 '리얼플레이어 플러스'(RealPlayer Plus)라는 미디어 플레이어를 공급하고 있다. 리얼네트웍스의 미디어 플레이어 및 미디어 서버 프로그램은 20개 이상의 다양한 운영체제(Unix, Linux, Windows 등)에서 작동이 가능하다. 그리고 50개 이상의 다양한 파일 포맷 또는 데이터 유형(MP3, MPEG[54]-1, MPEG-2,

54) 'MPEG'이란 세계 디지털 영상 기술자들이 모여 1998년 결성한 표준화 그룹인 MPEG(Moving Picture Experts Group)위원회에서 제정한 동영상/음성의 압축과 재생에 관한 규약을 말한다. MPEG 1은 CD에 동영상을 압축한 Video CD의 압축규격으로, MPEG 2는 고화질 방송용 영상을 얻는 것을 목적으로 개발되어 DVD 압축기술로 이용되고 있다. 최근에는 MPEG

MPEG-4, QuickTime, RealAudio, RealVideo, Windows Media)을 전송하고 재생할 수 있다. 즉 리얼플레이어는 피심인들의 WMA, 애플의 퀵타임과 같은 다른 원천기술 사업자의 포맷도 재생할 수 있다.

애플은 1999년부터 스트리밍 방식의 미디어 플레이어를 공급하기 시작하였으며, 현재 기본형인 '퀵타임'(QuickTime)과 고급형인 '퀵타임 프로'(QuickTime Pro)라는 미디어 플레이어를 공급하고 있다. 1994년에 출시된 퀵타임 4.0은 MP3 포맷을 지원했고, 2001년 출시된 퀵타임5는 MPEG 포맷을 지원했으며 2002. 6. 출시된 퀵타임 6은 MPEG-4 포맷을 지원한다. 그러나, 퀵타임은 리얼 포맷이나 피심인들의 윈도우 미디어 포맷을 지원하지 않는다.

국내사업자로서 주식회사 그래텍은 '곰플레이어(Gom Player)'라는 명칭의 미디어 플레이어를 공급하고 있다. 곰플레이어는 피심인들이 제공하는 소프트웨어 개발도구인 다이렉트쇼우 SDK[55](DirectShow SDK)를 이용하여 개발되었으며 피심인들의 WMA, WMV 포맷, 그리고 MPG, MPEG 포맷 등을 지원한다. 곰플레이어의 경우 .gom 이라는 자신의 독자 포맷을 가지고 있어 포맷 경쟁에서 원천기술을 보유한 다른 사업자와 경쟁할 수 있다.

2) 2차 사업자

2차 사업자로는 널소프트, 거원시스템 등이 있다.

널소프트(Nullsoft)는 미국에 소재한 회사로서 '윈앰프'(WinAmp)라는 명칭의 미디어 플레이어를 공급하고 있다. 이 미디어 플레이어는 피심인들의 WMA, WMV 포맷, 그리고 MPG, MPEG 포맷 등을 지원한다.

주식회사 거원시스템은 '제트오디오'라는 명칭의 미디어 플레이어를 공급하고 있

4, MPEG 7 등으로 발전하여 차세대 디지털 방송의 표준으로 주목받고 있다.

55) SDK(Software Development Kit)란 소프트웨어 개발자가 PC 운영체제나 미디어 플레이어 등과 같이 인터페이스를 제공하는 프로그램과 호환되는 프로그램을 개발하는 도구가 되는 프로그램 집합을 의미한다.

다. 제트오디오는 2000년부터 2001년까지의 기간 중 일본의 PC 제조업체인 후지쯔와 아이비엠(IBM)에 라이센스 되어 이들 사업자가 생산·판매하는 PC에 기본 프로그램으로 탑재되기도 하였다. 제트오디오는 피심인들의 WMA, WMV 포맷, 그리고 MPG, MPEG 포맷, 리얼 포맷(RA) 등을 지원한다.

이외에도 국내외에 다수의 2차 사업자들이 존재하고 있는데, 이들 2차 사업자들은 대부분 고유한 미디어 포맷을 보유하고 있지 못하다는 점에서 피심인 엠에스, 리얼네트웍스, 애플 등 고유적 포맷을 보유하고 인코더, 미디어 서버 프로그램 등의 DMS 구성요소 소프트웨어를 콘텐츠 사업자에게 판매하는 원천기술 보유 사업자에 비해 한정된 경쟁자원을 보유하고 있다.

다시 말하면, 미디어 플레이어 시장에서는 자신이 개발한 포맷을 대중화시켜서 사실상의 표준으로 만들려는 '포맷 경쟁'이 치열하게 전개되고 있는데, 이들 2차 사업자들은 디지털 미디어 시스템의 한 구성요소에 불과한 미디어 플레이어 관련 사업만을 영위하기 때문에 그 속성상 인코더나 미디어 서버 프로그램 등을 주요수단으로 전개되는 포맷 경쟁에 참여할 수 있는 능력이 크게 제한된 경쟁사업자들이다.

(다) 미디어 플레이어의 유통경로

미디어 플레이어가 사용자들에게 공급되는 경로에는 피심인들처럼 자신의 PC 운영체제에 처음부터 결합하여 공급하는 방법 외에 크게 두 가지가 있다. 즉, PC 제조업체를 통해 공급되거나 혹은 인터넷 다운로드를 통하는 방법으로 사용자들에게 공급되고 있다.

먼저, PC 제조업체에 의해 미디어 플레이어를 탑재하는 경로에서는 미디어 플레이어 사업자들이 PC 제조업체에 대해 PC 제조업체들의 PC에 미디어 플레이어를 설치할 수 있도록 하는 라이센스 계약을 체결함으로써 이루어진다.

인터넷을 통해 다운로드의 방법으로 공급되는 경로는 다시 두 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 미디어 플레이어를 제작·공급하는 특정회사가 자신의 웹 사이트에서 공급

하는 경로가 있다. 피심인들 외에도 미디어 플레이어를 공급하는 거의 모든 사업자가 이 경로를 이용하고 있다.

둘째, 미디어 플레이어 뿐 아니라 여러 가지 다양한 소프트웨어를 공급하는 포탈 사이트 등에서 공급하는 경로가 있다. 예를 들어 심파일이라는 소프트웨어 다운로드 사이트[56]에 접속하면 피심인들의 WMP를 포함한 여러 가지 미디어 플레이어를 다운로드 받을 수 있다.

나. 행위사실

피심인들은 1999. 7. 윈도우98 세컨드 에디션(Windows 98 Second Edition : 이하 "윈도우98 SE"라 함)에 WMP를 포함하여 판매하였으며, 이후 후속 윈도우 PC 운영체제에도 모두 WMP를 포함하여 판매하는 행위를 하고 있다.

다. 관련시장의 획정

피심인들의 행위가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다)에 위반되는지 여부를 판단하기 위해서는 먼저 피심인들의 행위가 사업자들 간의 경쟁에 영향을 미치는 범위 즉 일정한 거래분야를 획정하여야 한다. 이를 위해서는 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 거래분야의 특정이 전제되어야 한다.

(1) 관련 상품 시장

「시장지배적 지위 남용 행위의 심사기준」(위원회 고시 제 2000-6호) 및 「기업결합 심사기준」(위원회 고시 제1999-2호)에 의하면, 관련 상품 시장은 거래되는 특정 상품의 가격이 상당기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상될 경우 동 상품의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 상품의 집합을 의미하고, 특정상품이 관련 상품 시장에 포함되는지 여부는 상품의 기능 및 효용의 유사성, 상품 가격의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식, 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 등을

56) http://simfile.chol.com/

종합적으로 고려하여 판단한다.

(가) 이 건에서 주된 상품 시장은 '인텔호환 PC 운영체제 시장'이다.

이 건에 있어서 주된 상품의 관련 시장은 다음과 같은 이유로 비(非) 인텔호환 PC 운영체제, PC 서버 운영체제 및 개인용 정보기기를 위한 운영체제와 구분되는 "인텔호환 PC 운영체제" 시장으로 획정된다.[57]

1) 비인텔호환 PC 운영체제는 인텔호환 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

PC 운영체제는 탑재되는 CPU의 종류에 따라 인텔호환(Intel-compatible) PC 운영체제와 비인텔호환 (non-Intel compatible) PC 운영체제로 구분하는 것이 일반적이다. 전자로는 피심인들이 제조·공급하는 윈도우(Windows)와 리눅스(Linux) 등이 있고, 후자로는 애플(Apple)에서 제작하는 맥(Mac) 운영체제가 있다는 사실은 앞에서 살펴본 바와 같다.

인텔호환 PC 운영체제는 비인텔호환 PC에 설치·운영될 수 없으며, 반대로 비인텔호환 PC 운영체제는 인텔호환 PC에 설치·운영될 수 없다. 따라서 양자의 수요는 대체가능성이 없다.

공급 측면에서도 양자는 프로그램의 설계 자체가 전혀 다르고 1980년대 이래 확연히 구별된 공급자가 계속 자신만의 영역을 지켜왔다. 따라서 공급 측면에서도 양자는 대체 가능성이 없다고 인정된다.

결국, 인텔호환 PC 운영체제의 가격이 상당한 기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상되더라도 대표적인 구매자가 비 인텔호환 PC 운영체제로 구매를 전환할 가능성이 없다는 점에서 비 인텔호환 PC 운영체제는 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

57) EC도 동일한 취지로 주된 상품 시장을 인텔호환 PC 운영체제 시장으로 획정하였다.(EC 결정문 321항~342항 참조)

2) PC 서버 운영체제는 클라이언트용 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

PC 서버 운영체제가 클라이언트용 PC 운영체제와 기능·효용 및 가격이 뚜렷이 구별되고 수요자와 공급자가 양 제품을 구분하여 인식하고 있어 서로 대체하기 어렵다는 사실은 이미 “윈도우 미디어 서버의 결합판매” 부분에서 살펴본 바와 같다.

따라서, 클라이언트용 PC 운영체제의 가격이 상당한 기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상되더라도 대표적인 구매자가 PC 서버 운영체제로 구매를 전환할 가능성이 없다는 점에서 PC 서버 운영체제는 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

3) 휴대용 개인정보 단말기 등 개인용 정보기기를 위한 운영체제는 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

휴대용 개인정보 단말기(PDA : Personal Digital Assistance)나 스마트 모바일 폰(smart mobile phone)과 같은 개인용 정보기기들은 이들의 개발 및 판매 목적과 실제 용도가 PC에 이용되기 위한 것이 아니며 PC용 운영체제에 비교하여 제한된 기능을 수행하고, 화면의 크기·용량 등에 큰 차이가 있다. 따라서, PC 운영체제의 가격이 상당기간 의미 있는 수준으로 인상된다고 하여도 그 수요가 개인용 정보기기 운영체제로 이동하는 것은 매우 어렵다.

또한, PC 운영체제의 가격이 일정기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 상승한다 하더라도, 휴대용 개인정보 단말기나 스마트 모바일 폰 같은 개인용 정보기기 사업자들이 자신의 제품을 PC 운영체제 용도로 전환하기는 쉽지 않다. 더욱이 새로운 사업자가 PC 운영체제 시장에 완전히 새로운 제품을 개발하여 진입하는 것은 더욱 어렵다.

왜냐하면, 개인용 정보기기를 위한 운영체제를 PC 운영체제용으로 전환하기 위해서는 사용자 인터페이스[58](interface)를 비롯한 운영체제 소스 코드(source code)의 많은 부분을 수정·보완하거나 상당부분을 새로 개발하여야 하기 때문이다.

58) ‘인터페이스(Interface)’란 서로 다른 두 시스템, 장치, 소프트웨어 등을 서로 연결해 주는 부분 혹은 그러한 접속장치를 의미한다.

따라서, 클라이언트용 PC 운영체제의 가격이 상당한 기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상되더라도 대표적인 구매자가 휴대용 개인정보 단말기 등 개인용 정보기기를 위한 운영체제로 구매를 전환할 가능성이 없다는 점에서 휴대용 개인정보 단말기 등 개인용 정보기기를 위한 운영체제는 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

(나) 이 건에서 종된 상품의 관련시장은 '스트리밍 미디어 플레이어' 시장이다.

스트리밍 미디어 플레이어는 CD나 DVD 재생기와 같은 전통적인 기기들과 오디오 전용 미디어 플레이어와 기능의 차이가 크며, 다운로드용 미디어 플레이어와 기술적·현실적으로 대체하기가 어려우므로 이들 제품들과는 별개의 시장에 속하는 것으로 인정된다.

1) CD나 DVD 재생기와 같은 전통적인 기기는 스트리밍 미디어 플레이어를 대체하기 어렵다.

기능 면에서, CD나 DVD 재생기는 스트리밍 미디어 플레이어가 제공하는 기능의 극히 일부만을 가지고 있다는 점에서 스트리밍 미디어 플레이어를 대체할 수 없다. 즉, 위와 같은 재생기기들은 오로지 CD나 DVD를 재생하는 기능을 수행함에 비해 스트리밍 미디어 플레이어는 그에 더하여 인터넷에 접속하여 디지털 콘텐츠를 재생하거나 저장하는 등 다양한 기능을 제공한다[59].

따라서, 스트리밍 미디어 플레이어의 가격이 상당한 기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상되더라도 대표적인 구매자가 CD나 DVD 재생기와 같은 전통적인 기기들로 구매를 전환할 가능성이 없다는 점에서 CD나 DVD 재생기 같은 전통적인 기기들은 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

59) EC의 경우도 동일한 취지로 스트리밍 미디어 플레이어와 CD나 DVD 재생기와 같은 전자기기들간의 대체가능성이 없다고 판시하고 있다.(EC 결정문 407~410항)

2) 오디오 전용 미디어 플레이어는 스트리밍 미디어 플레이어를 대체하기 어렵다.

비디오가 제외된 오디오 재생에 그 기능이 주로 특화되어 있는 미디어 플레이어는 비디오·오디오 재생, 실시간 스트림되는 파일재생 지원 등 모든 기능을 갖춘 스트리밍 미디어 플레이어와 기능적으로 차이가 존재한다. 따라서, 일반적으로 스트리밍 비디오 콘텐츠를 감상하고자 하는 소비자는 오디오전용 스트리밍 미디어 플레이어를 이용하여 비디오 콘텐츠를 감상하는 것이 기술적으로 불가능하다. 그렇기 때문에 스트리밍 오디오/비디오 미디어 플레이어의 가격이 상당기간 의미 있는 수준으로 상승하더라도 소비자들이 그 수요를 오디오 전용 미디어 플레이어로 대체할 수는 없을 것이다.

또한, 비디오 콘텐츠 사업자들이 콘텐츠를 스트리밍하는 대부분의 경우에 특정 비디오 재생용 스트리밍 미디어 플레이어를 이용하도록 지정하는 현실[60]에서, 소비자들이 이들 콘텐츠를 보기 위해 오디오 전용 스트리밍 미디어 플레이어를 사용하는 것은 불가능하다.

따라서, 스트리밍 미디어 플레이어의 가격이 상당한 기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상되더라도 대표적인 구매자가 오디어 전용 미디어 플레이어로 구매를 전환할 가능성이 없다는 점에서 오디오 전용 미디어 플레이어는 관련 상품시장에 포함되지 않는다.

3) 스트리밍 미디어 플레이어와 다운로드용 미디어 플레이어는 상호 대체하기 어렵다[61].

스트리밍 미디어 플레이어를 다운로드용 미디어 플레이어로 대체하기 어렵다는 점은 최종소비자와 콘텐츠 사업자 양 측면에서 모두 확인할 수 있다. 먼저, 최종소비자 입장에서 다운로드용 미디어 플레이어를 이용하여 스트리밍되는 콘텐츠를 재생할 수는 없다.

---

60) 2005. 7. 12. 피심인들이 제출한 국내 상위 40개 웹사이트 조사결과 및 2005. 8. 10. 실시한 한국소프트웨어진흥원의 120개 웹사이트 조사결과 WMS를 사용하는 콘텐츠 사업자는 거의 항상 WMP 또는 WMP 기반 html 플레이어를 지정하고 있음

61) EC는 디지털 미디어 시스템 구성요소간 상호의존성 및 네트워크 효과 등에 의해 소프트웨어 개발업자 등이 스트리밍 미디어 플레이어의 가격이 일정기간 의미있게 상승하여도 공급측면에서 다운로드용 미디어 플레이어를 스트리밍 미디어 플레이어로 대체하기 어렵다고 판시하고 있다.(EC 결정문 416~424항 참조)

이는 다운로드용 미디어 플레이어가 스트리밍 기능을 가지고 있지 않다는 기술적 측면뿐만 아니라, 현실에서는 콘텐츠 사업자들이 콘텐츠를 스트리밍하는 대부분의 경우에 특정 스트리밍 미디어 플레이어를 이용하도록 지정한다는 점 때문이다. 따라서, 최종사용자 입장에서 다운로드용 미디어 플레이어로 스트리밍 미디어 플레이어를 대체하는 것은 사실상 불가능하다고 할 수 있다.

다음으로, 미디어 콘텐츠에 대한 다운로드 또는 스트리밍 서비스를 제공하는 콘텐츠 사업자 역시 대상 고객 및 용도 등의 측면에서 스트리밍 시장과 다운로드 시장을 구별하여 인식하고 있다. 이는 위원회가 2005. 8. 11. 실시한 국내 상위 10개 음악사이트에 대한 설문조사 결과를 통해 확인되었다.

위 설문조사에서, 국내 상위 10개 음악사이트 중 9개 사이트는 스트리밍 시장과 다운로드 시장이 명확히 구분되는 시장이라고 응답[62]하였다.

<그림 3-1> 스트리밍과 다운로드 시장이 구분되는지 여부에 대한 답변

업체명	시장구분 여부	시장이 구분되는 이유
A	○	-정보이용과 소유에 대한 본질적인 차이가 있으며 동일 콘텐츠에 대한 이중소비가 가능하다는 점에서 확연히 구분됩니다. -스트리밍의 경우 단순한 PC기반의 서비스이며, 다운로드의 경우 MP3플레이어, PC, PMP, PDA 등 멀티 플랫폼 환경에서 이동성을 함께 가져갈 수 있는 장점이 있습니다. -따라서, 스트리밍 시장과 다운로드 시장은 구분이 가능하다고 단언합니다.
B	○	스트리밍 방식과 다운로드 방식의 이용 고객의 상황 및 사용행태가 차이가 있고 이에 따른 서비스 시장이 상이합니다.
C	○	스트리밍 방식의 서비스와 다운로드 방식의 서비스는 완전히 다른 형태의 서비스이며, 사용자의 용도나 서비스의 특성이 매우 차별적인 서비스입니다.

62) 한 업체는 정보통신기술의 발달에 의해 서비스 방식간의 경계의 구분이 어려워 다운로드와 스트리밍 방식의 구분이 어렵다는 취지로 진술하였다.

D	ㅇ	광대역 네트웍의 대중화로 그 차이가 희박해지고 있긴 하나, 파일 저장의 유무에 따라 분명히 구분되는 시장이며 스트리밍 서비스가 좀더 합법적 사업에 근접할 확률이 높은 것으로 판단됩니다.

* 출처: 국내 상위 10개 음악사이트 제출자료중 일부(2005. 8. 11)

4) 원천기술 사업자는 2차 사업자의 경쟁을 제한할 수 있으나, 2차 사업자는 원천기술 사업자와 대등한 경쟁을 하기 어렵다.

코덱, 포맷, 인코더, 저작권 보호 프로그램(DRM) 등 미디어 스트리밍 기술을 포함하는 독자적인 미디어 기술을 갖추고 그 구성요소로서 완전한 기능을 갖춘 미디어 플레이어를 제공하는 데에는 높은 수준의 기술력과 오랜 기간동안의 큰 투자가 필요하다. 이는 그 개발 및 진입비용이 매우 크다는 것을 의미하는데, 그렇기 때문에 2차 사업자가 가까운 시일 내에 기존 원천기술 사업자의 제품을 대체할 수 있는 제품을 공급할 것으로 기대하기는 어렵다. 특히 스트리밍 미디어 기술은 지적재산권에 의해 보호된다는 점에서 더욱 그러하다.

이에 대해, 피심인들은 2차 미디어 플레이어 역시 스트리밍 미디어 플레이어와 경쟁할 수 있다고 주장하나, 다음의 내용에 비추어 볼 때 원천기술 사업자와 2차 사업자는 경쟁관계에 있다고 보기 어려우므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

첫째, 국내에 존재하는 2차 사업자의 미디어 플레이어는 대부분 이른바 'WMP의 아류에 속하는 2차 미디어 플레이어'(이하 "WMP 아류")로서, 피심인들의 WMP의 효용을 증가시키는 보완재적 미디어 플레이어로서 윈도우 미디어 포맷 및 기술을 확산시키는 역할을 한다.

여기서 'WMP 아류'란, WMP의 구성요소[63]를 기반으로 하여 개발된 미디어 플레

63) 피심인들은 WMP는 (1) DirectShow, (2) Windows Media Format SDK(WMF SDK), (3) WMP용 동적 링크 라이브러리(Dynamically Linked Library, DLL) 및 'wmpplayer.exe' 라는 이름의 실행 파일, (4) Windows Media Player ActiveX 컨트롤(WMP OCX), (5) WMP 컴포넌트 사용자 인터페이스 등으로 구성되어 있다고 주장하고 있다(신강근, 신현식, Windows Media Technologies에 관한 분석, 0034쪽, 피심인들 제출자료(2005. 7. 12.); 피심인 의견서, 135쪽). 그러나 DirectShow는

이어를 말한다. 이는 WMP를 구성하는 파일들이 제공하는 기능을 API를 이용하여 개발된 것으로, 주로 피심인들이 고유한 원천기술을 가지는 코덱, 포맷(WMA, WMV), WMP의 사용자 인터페이스 등을 이용하고 있다. 이들 WMP 아류에 속하는 미디어 플레이어들은 WMP가 아닌 다른 이름으로 불리기도 하지만, 실행하기 위해서는 WMP 구성요소를 필요로 하는 소프트웨어로서, 설치와 실행 과정에서 WMP 구성요소를 배포하고, 윈도우 미디어 포맷의 이용을 확산시키는 역할을 하기 때문에 경제적으로 볼 때에는 피심인들의 WMP의 효용을 증가시키는 보완재 역할을 한다. 우리나라에서 이용중인 2차 미디어 플레이어 중 대부분이 WMP 아류에 속하는 미디어 플레이어이다.

이러한 WMP 아류의 예로는 터치플레이어, 맥스 웹플레이어 등 WMP 기반 html 플레이어와 아드레날린, 알쇼, 클릭팝, KM 플레이어 등과 같은 미디어 플레이어들이 있다.

둘째, WMP 아류 중에서도 특히 'WMP 기반 html 플레이어'의 경우에는 WMP와 모든 것이 동일하며 다만 사용자 인터페이스(스킨)만이 다른 것으로, 실질적으로 WMP라고 보아야 한다. 이러한 사실은 피심인들 자신의 의견서에 첨부된 경제전문가 보고서에서도 명백히 인정하고 있다. 피심인들의 MSN 사이트가 제공하는 VOD 서비스도 WMP 기반 html 플레이어를 사용하고 있다.

<그림 3-2> "디지털 미디어 기술 경쟁봉쇄 주장에 관한 경제분석 평가서"

... 표6에 보고된 플레이어들 중 일부는 사용자가 콘텐츠의 링크를 클릭했을 때 ActiveX 컨트롤(WMP OCX라고도 불림)을 통해 구동되는 미디어 플레이어로, DirectShow를 포함한 WMP의 컴포턴트에 콘텐츠 제공업체가 자신의 브랜드와 부가기능(예를 들어 북마크나 '내 음악 폴더') 등을 추가해서 만든 것이다. 이러한 플레이어들은 사실상 WMP로 보아야 할 것이다. 본 연구진은 그와 같은 플레이어를 'WMP에 기반한 html 플레이어'라고 부른다.

* 출처: 피심인들 제출자료(2005. 7. 12)

WMP의 구성요소가 아니라, WMP와 같은 미디어 플레이어 응용프로그램들에 의해 이용되는 운영체제 단계의 파일로서 EC 결정에 의해서도 윈도우 운영체제에서 제거되지 않았다(EC 결정문, 1020항).

결국, 현재 미디어 플레이어 제품시장은 그 자체를 판매함으로써 수익을 올리는 것이 주목적이라기 보다는 당해 미디어 플레이어가 사용하는 포맷, 코덱 등을 널리 보급하여 사실상의 표준으로 만들기 위한 목적으로 경쟁한다고 볼 때, 2차 미디어 플레이어는 원천기술 사업자의 미디어 플레이어와 직접 경쟁관계에 있는 독립한 상품이라기보다는 각 2차 미디어 플레이어가 기반하고 있는 원천기술 사업자 미디어 플레이어의 보완재로서 원천기술 사업자의 미디어 플레이어의 이용과 보급을 확산시키는 역할을 한다.

(2) 관련 지리적 시장

「시장지배적 지위남용행위 심사기준」(위원회 고시 제2002-6호) 및 「기업결합 심사기준」(위원회 고시 제1999-2호)에 의하면, 관련 지리적 시장은 다른 모든 지역에서의 당해 상품의 가격이 일정하나 특정 지역에서만 상당기간 어느 정도 의미있는 가격 인상이 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 지역전체를 의미하고, 특정 지역이 동일한 거래 분야에 속하는지 여부는 상품의 특성 및 판매자의 사업 능력, 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매지역 전환행태, 판매자의 구매지역 전환가능성 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태와 시간적, 경제적, 법제적 측면에서의 구매지역 전환의 용이성 등을 고려하여 판단한다.

주된 상품인 PC 운영체제 시장의 지리적 시장은 국가간 운송 및 거래비용이 미미한 점, PC 운영체제 사업자들 대부분 세계적으로 유사한 가격 및 거래조건으로 판매하고 있다는 점, 제품의 개발 및 판매 전략을 비롯한 중요한 사업전략을 세계시장에서 유사하게 수행하고 있다는 점 등을 고려할 때 세계시장이다.

미디어 플레이어 프로그램의 지리적 시장은 다음과 같은 이유로 국내 시장으로 획정하는 것이 타당하다고 판단된다.

첫째, 국내에서 주로 사용되는 스트리밍 미디어 플레이어는 대부분 한국어 버전이며, 국내 소비자들은 외국과는 차별되는 광대역 초고속 인터넷 환경과 특이할 정도

로 까다로운 소비성향을 갖고 있다.

둘째, 국내 미디어 플레이어 프로그램 시장은 세계 시장과 달리 WMP의 점유율이 매우 높고, 세계 시장에서 상당한 점유율을 가지고 있는 리얼네트웍스나 애플의 시장점유율은 거의 없거나 미미하다는 점 등 시장구조면에서 큰 차이를 보이고 있으며 이러한 상태가 비교적 오랜 기간 동안 유지되고 있다.[64]

셋째, 피심인들 스스로도 한국시장에서 리얼네트웍스가 실패한 원인이 현지화 전략에 실패하였다고 주장하는 등 국내시장이 세계시장과 차별됨을 인식하고 있다.

라. 시장지배적지위의 남용행위 중 다른 사업자의 사업활동 방해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2 제1항 제3호의 규정취지 및 이에 해당하기 위한 요건 등에 관하여는 위 2. 라. (1) 에서 살펴본 바와 같다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 운영체제 시장의 시장지배적사업자이다.

공정거래법상의 시장지배적사업자 결정에 관한 공정거래법 제2조 제7호, 제4조 등에 관하여는 위 2. 라. (2) (가) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

피심인들은 <표 3-5>에서 보는 바와 같이 출하량 기준 시장점유율이 매우 높고, PC 운영체제에 대한 신규사업자의 진입이 매우 어렵다는 점에서 시장지배적사업자로 인정된다.

64) 리얼플레이어의 EU에서의 시장점유율(2003. 8. 기준)은 19%이며, 애플의 퀵타임의 경우 11%를 차지하고 있어 한국에서의 시장점유율과 큰 차이를 보이고 있다.

첫째, 피심인들의 윈도우 운영체제는 국내 PC 운영체제 시장에서 출하량(shipment) 기준으로 2001년 이후 99% 이상의 시장점유율을 보유하고 있으므로 「시장지배적지위 남용행위 심사기준」에 따를 때, 시장지배적사업자로 추정된다.

<표 3-5> 국내 PC 운영체제 출하량 및 시장점유율(2000년~2004년)

(단위 : 개(unit))

운영체제		2000(년)	2001	2002	2003	2004*
피심인	윈도우 95/98	3,564,628	2,900,700	718,550	44,611	-
	윈도우 2000	150,507	419,398	387,834	202,980	37,569
	윈도우 XP	-	-	2,397,645	2,915,645	3,347,768
피심인 PC OS소계 (점유율, %)		3,715,135 (98.5)	3,320,098 (99.3)	3,504,029 (99.4)	3,163,236 (99.3)	3,385,337 (99.1)
리눅스		30,931	15,038	7,404	7,329	10,588
Mac OS		26,100	6,790	14,489	15,960	19,468
합계		3,772,166	3,341,926	3,525,922	3,186,525	3,415,393

* 단, 2004년 자료는 예측치임

* 출처 : 한국소프트웨어진흥원/(주)한국IDC 자료(2004. 9.)

또한, 매출액 기준에 의할 경우에도 리눅스가 무료로 제공되는 공개소프트웨어인 점 등을 고려할 때 매출액 기준으로 시장점유율을 산정할 경우 출하량 기준으로 산정할 경우보다 피심인들의 시장지배적 지위가 더욱 높을 것이므로 피심인들을 시장지배적사업자로 추정하는 것에는 변함이 없다.

참고로 피심인들은 전 세계 PC 운영체제 시장에서도 매출액 기준 및 출하량 기준 모두 90% 이상의 시장점유율을 보유하고 있다. 2000년 피심인들이 엠에스의 시장점유율은 출하량 기준 92.1% 매출액 기준 92.8%, 2001년에는 출하량 기준 93.2% 매출액 기준으로 93.8%를, 2002년에는 출하량 기준 93.8% 매출액 기준으로 96.1%를 차지하고 있다.

<표 3-6> 2000년 이후 세계 PC 운영체제 시장 점유율(IDC, 2003년)

구분	2000년		2001년		2002년	
	출하량	매출액	출하량	매출액	출하량	매출액
피심인	92.1	92.8	93.2	95.4	93.8	96.1
애플컴퓨터	3.9	3.3	3.1	2.4	2.9	2.2
리눅스	1.8	0.6	2.4	0.4	2.8	0.4
기타	2.4	3.3	1.3	1.8	0.5	1.3
전체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 출처 : IDC,「WORLDWIDE CLIENT AND SERVER ENVIRONMENTS FORECAST 2002-2007」

둘째, PC 운영체제를 개발하기 위해서는 고도의 기술과 막대한 자금·인력의 투자가 필수적이며 개발기간도 매우 길기 때문에 신규진입자의 시장 진입이 매우 어렵다.

이와 함께, 피심인들의 운영체제에서 작동되는 응용프로그램의 양과 질이 다른 운영체제에서 작동되는 응용프로그램 보다 많다는 점은 새로운 사업자의 PC 운영체제 시장 진입에도 장벽으로 작용하고 있다. 즉 대부분의 PC용 응용프로그램들이 피심인들의 PC 운영체제에서 작동하도록 개발되기 때문에, 다른 운영체제에서는 작동하지 않거나 작동하더라도 작동오류가 많이 발생할 수 있다는 사실은 다른 사업자들에게 응용프로그램에 의한 진입장벽(application barrier to entry)으로 작용하고 있다.

위에서 본 것과 같은 기술·투자비용 및 응용프로그램의 존재에 의한 진입장벽 외에, 소비전환비용의 존재 또한 PC 운영체제 시장에서 진입장벽으로 존재한다. 소비자가 기존에 사용하던 운영체제를 다른 사업자의 운영체제로 바꾸기 위해서는 구매비용 외에 새로운 운영체제에 대한 탐색비용 및 학습비용이 필요한데, 이러한 탐색비용 등의 존재는 소비자를 피심인들의 운영체제에 고착(lock-in)시키는 효과를 발생시킨다.

피심인들이 2003. 5. 미국 시장에서 실시한 설문조사에서도 응용프로그램 호환성 및 학습비용의 존재에 의한 진입장벽이 매우 강력하게 존재하고 있음을 확인할 수 있다. 이 조사에서는 소비자들에게 리눅스 같은 새로운 운영체제를 채택하는데 가장 큰 장벽이 무엇인지를 질문하였는데, 이에 대해 전체 응답자 중 24%가 응용프로그램의 호환성이라고 응답하였고 20%는 교육·학습비용이라고 응답하여 이들 요소가 피심인들과 경

쟁하고 있는 또는 새로운 사업자에게 매우 커다란 진입장벽이 되고 있음을 알 수 있다[65].

한편, 피심인들도 PC 운영체제 시장에서 시장지배적사업자임을 스스로 인정하고 있다.

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

피심인들은 PC 운영체제와 WMP가 별개제품임에도 불구하고 이를 결합하여 판매함으로써 WMP를 원하지 않는 소비자에게 구입을 강제 하였는바, 이는 부당하게 거래상대방의 미디어 플레이어에 대한 선택권을 침해하고, 양질의 제품을 사용할 기회를 박탈하여 거래상대방에게 불이익이 되는 거래를 강제하는 행위이다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 WMP는 별개제품이다.

결합판매 되는 상품들이 서로 다른 별개의 상품인지 여부는 이 제품들이 시장에서 통상 별도로 거래되는지 여부, 양 제품의 상업적 용도나 기능적 특성이 다른지 여부, 양 제품에 대한 소비자의 인식 태도에 차이가 존재하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 이에 관한 서울고등법원 판례[66]에 관하여는 위 2. 라. (2) (나)에서 살펴본 바와 같다.

가) WMP는 윈도우 PC 운영체제의 밀접 불가분한 구성요소가 아니다.

PC 운영체제는 응용프로그램의 기반(platform)이 되는 기능을 수행함에 비해(system software), 미디어 플레이어는 전자적 형태로 저장된 또는 스트리밍되는 콘텐

65) 2003년 상반기 총 493개 기업을 대상으로 조사하였으며, 가장 많은 응답은 “필요성이 없다. 현재 OS로 충분하다(No need/Current OS works fine)”로서 응답자중 25%가 선택하였다. 설문문항은 다음과 같다. 당신 조직에서 당신의 PC에 리눅스와 같은 새로운 운영체제를 배치하고나 평가하는데 가장 큰 장벽은 무엇입니까?(복수응답 가능) 영어 원문은 다음과 같다. “What are the biggest barriers to your organization deploying and/or evaluating/testing a new OS such as Linux on your PCs? 「US Business Desktop OS Tracker May 2003」 피심인 제출자료(2004. 6. 10.)

66) 서울고등법원 2004. 2. 10. 선고 2001누16288 판결

츠를 재생하기 위한 응용프로그램(application software)의 성격을 갖는다는 점에서 명확히 구별된다. 이러한 판단의 근거가 되는 사실은 다음과 같다.

WMP는 기능적 측면에서 PC 운영체제의 기능과 구분되는 응용프로그램에 해당한다. 이러한 사실은 우선 윈도우 PC 운영체제에 포함된 "다이렉트쇼(DirectShow)"라는 기능과의 비교를 통해서 알 수 있다.

다이렉트쇼 SDK는 윈도우 PC 운영체제에 포함되어 있는 다이렉트쇼 기능을 활용하여 그와 호환되는 응용프로그램을 제작하는데 도구로 이용되는 프로그램의 집합이다. 피심인들이 제공하는 다이렉트쇼 SDK 설명서[67]에는 "다이렉트쇼는 데이터 전송, 하드웨어의 차이점, 동조화(synchronization) 등의 복잡한 문제로부터 응용프로그램을 분리시킴으로써, 윈도우 플랫폼에서 디지털 미디어 응용프로그램을 창조하는 작업을 단순화하기 위한 목적으로 설계되었습니다"라고 되어 있다. 즉 이 설명서에 의하면 제3의 소프트웨어 개발자들은 윈도우 PC 운영체제에 포함되어 있는 다이렉트쇼라는 기능을 이용하여 미디어 플레이어 등 미디어 관련 응용프로그램을 개발할 수 있음을 설명하고 있다.

결국 윈도우 PC 운영체제는 "다이렉트쇼"라는 내부기능을 통하여 다른 미디어 플레이어에 대한 플랫폼 기능을 하고 있는 것이다. 반면 WMP는 윈도우 PC 운영체제에 포함된 다이렉트쇼 기능을 활용하는 것으로서, 다이렉트쇼 SDK를 이용하여 제작된 다른 미디어 플레이어들과 마찬가지로 응용프로그램에 속한다고 보는 것이 타당하다.

이에 대해, 피심인들은 WMP가 오랜 기간동안 윈도우 운영체제에 존재해 왔으며, 꾸준히 그 기능이 개선되어 온 일련의 멀티미디어 기능을 일컫기 위해 가장 최근에 사용되고 있는 명칭에 지나지 않으므로 이는 별개의 응용프로그램이 아니라고 주장한다. 그러면서, WMP로 불리우는 운영체제의 미디어 기능[68]은 WMP OCX, WMF SDK, 기타 WMP DLL 파일 및 위원회가 운영체제의 일부라고 인정한 다이렉트쇼로 구성되어

67) 영어 원문은 다음과 같다. "Its main design goal is to simplify the task of creating digital media applications on the Windows platform, by isolating applications from the complexities of data transport, hardware differences, and synchronization."「피심인 웹사이트 출력물 : DirectShow System Overview」

68) 구체적 내용은 각주 54 참조

있다고 한다. 이에 더하여 이러한 구성요소는 서로 구별되지 않음은 물론 응용프로그램 개발자에 대하여 에이피아이(API[69])를 제공하는 플랫폼 기능을 하고 있으므로 윈도우 운영체제의 일부라고 주장한다.

그러나, 피심인들의 주장과 달리 WMP 및 이를 구성하는 WMP OCX, WMF SDK가 윈도우 PC 운영체제 내부에 존재하는 멀티미디어 기능(다이렉트쇼)과 명백히 구분된다는 사실[70]은 다음과 같은 점들로 확인할 수 있으므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

첫째, 다이렉트쇼가 운영체제의 일부로서 모든 미디어 응용프로그램 개발자에게 그들이 사용하는 포맷이나 미디어 기술과 상관없이 이용할 수 있는 공개 또는 개방적 아키텍처임에 비하여, WMP는 다이렉트쇼 위에서 실행되는 별개의 응용프로그램이다. 즉, 다이렉트쇼와 WMP는 소프트웨어의 계층구조상 속하는 계층(layer) 자체가 다르다. 이러한 사실은 리얼네트웍스가 2005. 10. 11. 제출한 로날드 알핀(Ronald S. Alepin)의 “윈도우 미디어 플레이어가 결합되지 않은 윈도우 XP에 관한 기술평가서”를 통하여 확인할 수 있다.

---

69) ‘API(Application Programming Interfaces)’란 위에서 설명한 인터페이스 중 응용프로그램과 운영체제를 연결해 주는 인터페이스이다. 따라서, 응용프로그램 개발자들이 운영체제에 잘 작동할 수 있는 응용프로그램을 개발하기 위해서는 이러한 API를 활용하여 개발하여야 한다.

70) EC 또한 2004. 3. WMP 결합판매가 위법하다고 결정하면서 윈도우 운영체제에서 제거되어야 할 WMP를 정의하였는데, 이 WMP에는 WMP OCX, WMF SDK 등의 파일을 포함시킨바 있다.(피심인의 2004. 4. 13. EC 제출자료, EC 결정문 각주1277 참조)

<그림 3-3> Ronald S. Alepin의 “윈도우 미디어 플레이어가 결합되지 않은 윈도우 XP에 관한 기술 평가서”에서 발췌(44페이지)

다이렉트쇼는 다이렉트X 미디어 하부구조의 일부이며(그리고 일부였으며), WMP보다 시간상으로 앞서며 WMP와 전혀 다릅니다. 다이렉트X/다이렉트쇼의 하부구조는 컴퓨터 하드웨어 및 미디어 응용프로그램(예: 미디어 플레이어) 사이에서 중개 역할을 하는 운영체제 미디어 계층입니다. 다른 운영체제 계층에 대해서 기대하듯이, 다이렉트X/다이렉트쇼의 하부구조는 모든 미디어 응용프로그램 개발자가 그들이 사용하는 포맷이나 미디어 기술과는 상관없이 이용할 수 있는 공개 아키텍처입니다. WMP는 이 하부구조 계층의 일부가 아니고, 다이렉트X/다이렉트쇼 계층 위에서 실행됩니다. 실제로, WMP가 노출하는 플랫폼은 다이렉트X/다이렉트쇼와 같은 개방적 아키텍처를 제공하지는 않습니다. 대신, 그 플랫폼은 제3의 응용프로그램에게 MS의 윈도우즈 미디어 포맷 및 윈도우즈 미디어 기술을 실행하도록 요구합니다.

한편, 피심인들은 다이렉트쇼가 WMP의 구성요소라는 주장의 근거로 다운로드 형식으로 제공되었던 WMP 6.4의 경우 다이렉트쇼가 그 일부로 포함되어 공급되었음을 들고 있으나, 그러한 사실이 피심인의 주장을 뒷받침 할 수는 없다. 왜냐하면 피심인은 윈도우 PC 운영체제 구성요소의 일부를 응용프로그램(예: MS 오피스 제품)에 포함시켜 함께 배포하는 행위를 자주 해왔기 때문이다.

둘째, 에이피아이(API)를 제공한다고 하여 운영체제의 일부가 되는 것은 아니라는 점을 분명히 할 필요가 있다. 왜냐하면 운영체제의 일부가 아니면서도, 에이피아이(API)를 제공하는 등 제3자 응용프로그램에 대해 플랫폼 기능을 제공하는 소프트웨어 제품들이 시장에 많이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 피심인들의 사무관리용 응용프로그램인 윈도우 오피스(Windows Office)의 경우 이를 기반으로 구동되는 응용프로그램을 제작하는 소프트웨어 개발업체들이 증가하고 있는데, 그렇다고 해서 윈도우 오피스가 운영체제의 일부가 되는 것은 아니기 때문이다. 따라서, WMP를 구성하는 WMP OCX나 WMF SDK 등이 응용프로그램 개발자에 대하여 API를 제공한다고 하여 WMP가 운영체제의 일부가 되는 것은 아니다.

셋째, WMP가 윈도우 운영체제와는 별개의 응용프로그램임은 2005. 8. 24. 심의시 피심인측 참고인으로 참석한 A컴퓨터(주) 제품기획팀장 a의 진술에서도 확인할 수 있다. 참고인 a는 심판정에서 두 차례에 걸쳐 “윈도우 미디어 플레이어는 별도의 어플리케이션

임"이라고 진술하였다. 참고인 a는 PC 제조업체인 A사에서 PC에 어떤 소프트웨어를 탑재할 것인지에 관한 업무를 총괄하는 자로서, 참고인이 WMP를 응용프로그램으로 인식하고 있다는 점은 WMP의 별개제품성을 확인하는 의미 있는 진술이라고 판단된다.

<그림 3-4> 증거조사 신청 참고인 신문조서(50 페이지 참조)

미디어 플레이어와 메신저가 오퍼레이팅시스템이냐 아니냐 라고 따지면 분명히 아님. 하지만 제가 볼 때는 반드시 소비자들에게 필요한 아주 필수적인 요소이기 때문에 제 개인적인 생각은 오퍼레이팅 시스템과 거의 버금가는 것이다 라고 생각함

한편, 피심인들은 윈도우로부터 WMP라는 명칭과 관련된 소프트웨어 코드(EC가 지정한 186개 파일)를 제거하면 윈도우XP의 기능 중 적어도 40개의 기능이 전혀 또는 본래대로 작동하지 않게 된다고 주장한다.

그러나, 피심인들이 주장하는 WMP 제거시 발생하는 부정적 효과란 응용프로그램인 WMP가 운영체제에 설치되어 있지 않아 발생하는 당연한 결과이기 때문에 이를 근거로 그 응용프로그램이 운영체제의 일부라고 주장할 수 없다고 판단된다.

또한, 유력한 소프트웨어 성능 평가기관인 키랩스[71](KeyLabs)가 실시한 테스트결과에 의하면, 피심인들이 WMP 제거시 작동하지 않는다고 주장한 기능 중 많은 기능이 제3의 미디어 플레이어가 설치되는 경우 성공적으로 작동하는 것으로 나타났다. 즉, 키랩스의 실험결과에 의하면, '윈도우XP의 최초 설치 중 윈도우 미디어 ·오디오파일로 제작된 배경음향의 재생'이라는 단 1개의 사소한 기능을 제외하고는 다른 미디어 플레이어가 설치되면 정상적으로 기능을 수행하는 것으로 나타남을 알 수 있다. 이러한 사실은 WMP 역시 다른 미디어 플레이어와 마찬가지로 윈도우 PC 운영체제의 일부가 아닌 별개 응용프로그램임을 보여준다.

이에 더하여, 위원회가 2005. 11. 21. 한국소프트웨어진흥원에 의뢰하여 WMP 제거가 윈도우 운영체제에 미치는 영향을 실험하였는데, 윈도우 XP와 유사한 윈도우 XP embedded에서 WMP 제거 후 제3의 미디어 플레이어를 설치하더라도, '인터넷 익스플

71) 미국의 소프트웨어 실험회사로서 솔루션 인증, 소프트웨어 및 하드웨어의 성능 평가 등의 업무를 수행하며 현재, 시스코, 리얼네트웍스, GE 캐피탈, 이베이 등 다수의 고객을 확보하고 있음

로러를 통한 미디어 바 기능', '탐색기를 통한 미디어 바 기능', '나의 비디오, 비디오 미리보기', 'MS의 Active X 기술로 제어되는 인터넷 사이트의 비디오 재생 기능' 등 4가지 기능을 제외하고 모든 기능이 정상적으로 작동되는 사실을 확인한 바 있다. 또한, 오작동 하는 4가지 기능도 응용프로그램인 WMP 제거에 따른 예측가능한 결과에 불과하고 윈도우 운영체제의 오작동과는 관련이 없는 기능이었다.

결국, 윈도우 PC 운영체제에서 WMP를 제거한다고 하여도 일반적인 응용프로그램이 제거되는 경우보다 특별히 더 많은 부정적 효과가 발생한다고 보기는 어렵기 때문에 WMP가 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소라고 할 수는 없다.

나) WMP는 윈도우 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

소비자들은 WMP를 PC 운영체제와 별개로 수요하고 있으며, 공급자들도 PC 운영체제와 독립적으로 미디어 플레이어를 공급하고 있는 등 WMP를 비롯한 미디어 플레이어는 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 되고 있다.

① 소비자들은 PC 운영체제와는 별개로 미디어 플레이어를 수요하고 있다.

다음의 점을 고려할 때, 소비자들은 PC 운영체제와는 별개로 미디어 플레이어를 수요하는 것으로 인정된다.

첫째, 소비자들은 WMP를 비롯한 미디어 플레이어를 운영체제로부터 독립적으로 인터넷을 통하여 활발하게 다운로드 받고 있다. 즉, 다수의 소비자들은 새로운 PC를 구입할 때 PC에 탑재된 형태로 PC 운영체제를 함께 구입하는 것이 관행이다.[72] 반면, 미디어 플레이어는 PC를 구입한 이후 인터넷과 PC를 연결한 상태에서 다운로드를 받는 방식으로 수요되는 경우가 적지 않다. 피심인 또한 상당수의 미디어 플레이어를 이러한 다운로드 형태로 공급하고 있는데 이러한 거래형태는 피심인들이 1999년 윈도우 98 SE를 출시한 이후 4년이 지난 지금까지 계속되고 있다.

72) 피심인 제출자료(2001. 10. 16.)에 의하면, 피심인들이 판매하는 PC 운영체제의 대략 87%가 PC에 탑재되어 판매되고 있다.

사용자들이 PC 운영체제에 대한 수요와 별개로 WMP를 수요하고 있음은 피심인들도 사실상 인정하고 있다. 즉, 피심인들은 WMP 7[73]과 WMP 9[74]을 출시한 시점에서 인터넷을 통해 배포한 보도자료에서 새로운 버전의 WMP가 출시된 시점에서 이 WMP에 대하여 상당한 소비자 수요가 나타나고 있다는 점을 강조하고 있다.

위와 같은 사실은 피심인들이 파악한 WMP 공급 통계를 보아도 확인된다. 즉, 피심인 한국지사 직원들이 서로 주고받은 전자우편[75]에 포함된 자료에 의하면 WMP 9은 2003년에 3,355,710회, 2004년에는 2004. 6. 현재 2,215,190회가 인터넷을 통해 다운로드된 것으로 나타났다. 같은 기간 중에 판매된 윈도우 XP가 약 2,915,000개에 불과한 점, 그리고 소비자들이 윈도우 XP와는 전혀 다른 경로를 통해 미디어 플레이어를 구했다는 점 등을 고려하면, 소비자들은 윈도우 XP와 WMP 9을 서로 독립하여 수요한다고 보는 것이 합리적이다.

둘째, PC 운영체제와 별도로 미디어 플레이어를 개발하여 공급하는 리얼네트웍스나 그래텍과 같은 사업자가 존재하고 있다는 점 또한 PC 운영체제와 미디어 플레이어를 별개로 수요하는 소비자의 선호가 반영된 것으로 볼 수 있다.

피심인들은 인터넷을 통해 다운로드되는 WMP 패키지는 WMP라 불리우는 윈도우 운영체제에 통합된 미디어 기능에 대한 정기적인 업데이트에 불과하므로, 이러한 다운로드가 활발히 이루어지고 있다는 사실이 윈도우 운영체제와 WMP가 별개제품임을 나타내는 것은 아니라고 주장한다.

그러나, WMP 패키지의 다운로드는 WMP가 전혀 없는 맥(Mac) 운영체제용 등

73) 2002. 8. 2 보도자료 이 내용의 원문은 다음과 같다. “Microsoft Corp. today announced that over 3.4 million people worldwide have downloaded the new all-in-one Windows Media™ Player 7 in the first 10 days of its availability, at a rate of nearly four downloads every second. This strong customer demand for the player has driven the number of licensed copies of Microsoft® Windows Media Player to more than 200 million licensed copies worldwide.(이하 생략)”

74) 2003. 2. 6. 보도자료 이 내용의 원문은 다음과 같다. “Microsoft Corp. today released download statistics that show record-breaking consumer demand for the new Microsoft® Windows Media® Player 9 Series and Windows® Movie Maker 2 for Windows XP in their first month of availability. 14 million downloads of Windows Media Player 9 Series were recorded worldwide in just 30 days -- a rate of over 5 downloads every second. (이하 생략)”

75) 피심인 직원간 전자우편 제목 : Windows Media Player 9 download statistics(2004. 6. 10.)

으로 쓰이는 풀버전(full version)과 기존 WMP의 업데이트용으로 구별되어 제공되고, 업데이트용 역시 PC 운영체제와는 관계없이 WMP의 최신 버전만을 필요로 하는 소비자들이 운영체제와 별도로 수요하는 것이다. 따라서, 피심인들의 주장은 이유 없다[76].

② 공급자들은 PC 운영체제와 독립적으로 미디어 플레이어를 공급하고 있다.

다음의 점을 고려할 때 미디어 플레이어 공급자들은 PC 운영체제와 별도로 미디어 플레이어를 공급하고 있다고 인정된다.

첫째, 피심인들을 포함한 모든 미디어 플레이어 공급자들은 피심인들이 WMP를 운영체제에 포함하기 이전이나 이후 모두 최종사용자에게 인터넷 다운로드 등 운영체제와는 다른 유통경로를 이용하여 대부분의 미디어 플레이어를 공급하고 있다. 리얼네트웍스 등 일부 미디어 플레이어 사업자들이 자신들의 미디어 플레이어에 대한 소비자 접근성을 제고하기 위해 PC 제조업체와의 계약을 통해 새로운 PC에 사전탑재하는 경우도 있으나 이는 문서작성 프로그램 등 다른 응용프로그램에서도 사용되는 공급방식이며, 처음부터 PC 운영체제에 포함된다는 것과는 다른 방식이다.

둘째, 피심인들을 포함한 모든 미디어 플레이어 공급업체들은 윈도우, 리눅스를 포함한 인텔호환 PC 운영체제는 물론, 애플의 맥(Mac) 운영체제에서도 작동할 수 있는 미디어 플레이어를 별도로 만들어 공급하고 있다. 예를 들어 피심인들은 애플의 맥 운영체제에서도 작동하는 맥 운영체제용 WMP를 개발하여 공급하고 있으며, 소비자가 일단 WMP를 맥 운영체제에 설치한 이후에도 WMP를 안전하게 제거할 수 있는 기능(uninstalling)을 제공하고 있다. 즉, WMP는 PC 운영체제와 별개로 공급되고 있는 것이다.

셋째, 피심인들은 “윈도우 미디어”라는 “윈도우 운영체제”와 다른 별개의 상표를

76) 예를 들어, 윈도우98 SE에 포함된 WMP 6.4를 이용하고 있는 소비자가 WMP 9을 이용하기 위해서는 두 가지 방법이 있다. 윈도우 XP(WMP 9이 포함되어 있으므로)를 구입하는 방법과 윈도우98 SE용 WMP 9을 인터넷에서 다운로드 받아 설치하는 방법이 그것이다. 이러한 경우 후자는 윈도우 운영체제와는 별개의 WMP 9에 대한 독립한 수요가 존재함을 보여주는 것이다. 왜냐하면, WMP 9에 대한 수요만 있고 윈도우XP에 대한 수요가 없는 소비자가 윈도우98 SE를 버리고 윈도우XP를 구입하는 경우가 있을 수 없기 때문이다. 이는 또한 역으로 윈도우 XP에 대한 수요가 있는 소비자는 단순히 WMP 9만을 다운로드 받지는 않을 것임도 보여준다.

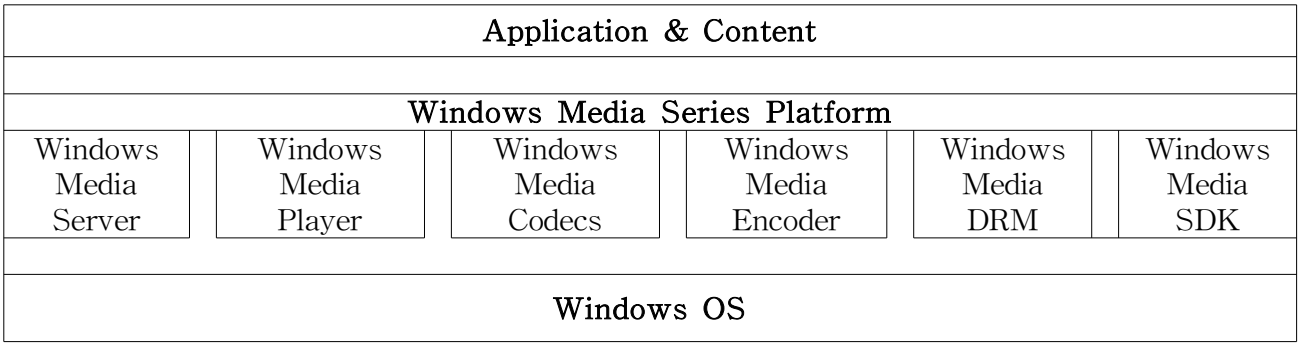
등록하고 있으며, 그 상표는 미디어 서버나 미디어 플레이어에 대하여 공통적으로 적용된다. 상표는 사업자가 소비자에게 자기의 상품을 다른 경쟁제품과 구별케 하고 특정하기 위하여 사용하는 표지로서 일반적으로 개별 상품에 대하여 상표권이 등록된다는 사실에 비추어 볼 때, 운영체제와 독립된 상표를 사용한다는 사실은 별개제품성 판단에 있어 중요한 고려요소가 된다.

③ 피심인들도 WMP를 운영체제의 일부가 아닌 응용프로그램의 일종으로 인식하고 있다.

다음의 점을 고려할 때 피심인 스스로 PC 운영체제와 미디어 플레이어를 별개의 제품으로 인식하고 있다고 인정된다.

첫째, 피심인들이 2002. 9. 소비자, 사업자 등에게 WMP 9 시리즈를 소개하기 위해 만든 한 문서에서는 윈도우 미디어 9 시리즈와 윈도우 운영체제를 별개의 제품으로 취급하고 있다. 즉, WMP를 저작권 보호 프로그램(DRM)이나 SDK(Software Development Kit) 등 PC 운영체제와 별개제품임이 명확한 제품들과 함께 '윈도우 미디어 시리즈 플랫폼(Windows Media Series Platform)의 범주에 속하는 것으로 기재하고 있다

<그림 3-5> 윈도우 미디어 시리즈 9을 설명하고 있는 피심인 웹페이지에서 발췌



* 출처 : 「Windows Media 9 Series - Windows Media 9 Series Capabilities and Benefit Overview」(2002.9.)

둘째, 피심인들은 자신이 운영하는 웹페이지에 WMP 7.1을 설명하면서 WMP를 '응용프로그램'이라고 표현하고 있다. <그림 3-6>에 의하면 피심인들은 WMP를 여러 가지 미디어 관련 기능을 모아놓은 일종의 응용프로그램으로 기재하고 있으며, 이러한 사실을 강조하여 소비자들에게 홍보하고 있음을 알 수 있다.

<그림 3-6> WMP 7.1을 설명하고 있는 피심인 웹페이지에서 발췌

All-in-One Integration

윈도우 미디어 플레이어 7.1은 7개의 기능을 한 응용프로그램(application)에 모아 놓은 것입니다. : CD 플레이어, 오디오·비디오 플레이어, 미디어 쥬크박스, 미디어 가이드, 인터넷 라디오, 휴대용 기기 음악 파일 전송기, 오디오 CD 제조기. 이러한 소프트웨어 프로그램들은 사용하기 쉬운 응용프로그램(application)으로 통합되었고, 디지털 미디어의 재생을 주요한 경험으로 만들기 위해 설계되었습니다.(이하 생략)

출처 : 피심인 운영 웹사이트[77]

셋째, 피심인 본사 고위급 직원 간에 1997. 6. 5. 주고받은 전자우편에 의하면 스트리밍 미디어 시장에서의 전쟁에서 승리하기 위해서는, 리얼네트웍스를 상대로 이겨야 하고, 미화 65백만 달러를 들여 관련기업들을 인수해야 하며, 포맷 전쟁, 클라이언트 아키텍쳐 전쟁, 서버 전쟁에서 이겨야 한다는 취지의 내용이 기재되어 있다. 이 전자우편에서 피심인들은 스트리밍 미디어 시장을 공략하기 위한 PC 운영체제와는 다른 독자적인 경영전략을 수립하고 있음을 알 수 있다. 이 자료를 통해 피심인들은 스트리밍 미디어 시장을 PC 운영체제 시장과 구분되는 별개의 시장으로 인식하고 있음을 알 수 있고, 이러한 사실은 스트리밍 미디어의 구성요소인 WMP에도 동일하게 적용되는 것이다.

77) 이 내용의 원문은 다음과 같다. "Windows Media Player 7.1 comprises seven features *in a single application* : CD player, audio and video player, media jukebox, media guide, internet radio, portable device music file tranfer, and an audio CD burner. These software programs are *combined into one easy-to-use application*, which is designed to make playing digital media a mainstream experience.(이하 생략)" 「Windows Media Player 7.1 for Windows 98」

<그림 3-7> 피심인 본사 고위급 직원간 전자우편 내용에서 발췌(1997. 6. 5.)

From : 000 (중간생략) 지난 금요일 a, b, c가 모여 진행한 회의에 대해 알려 주겠습니다. 기본적으로 a와 b는 다음과 같은 결정을 내렸습니다. 즉, 1) 프로그레시브 네트워크(Progressive Networks : 리얼네트웍스의 과거명칭)를 상대로 한 스트리밍 전쟁에서 승리할 필요가 있음 2) 전쟁에서 승리하기 위해 미화 65백만 달러 상당의 기업을 매수할 수 있도록 승인하여 줄 것(마이크로소프트 사상 5번째 큰 규모의 취득) 3) 스트리밍 전쟁에서의 승리란 3가지 측면에서의 승리, 즉 파일 포맷 전쟁, 클라이언트 아키텍쳐 전쟁, 그리고 서버 전쟁에서의 승리를 의미한다는 것 등입니다. a는 “이 분야가 전략적인 영역이며 반드시 승리할 필요가 있다”고 말했습니다. b는 “프로그레시브 네트워크는 넷스케이프와 비슷한데 단지 차이점이 있다면 우리가 보다 일찍 이 전쟁에서 게임을 시작할 수 있게 되었다는 점이다”라고 말했습니다.(이하 생략)

출처 : 리얼네트웍스 제출자료[78](2005. 1. 19.)

다) 통상적으로 미디어 플레이어는 PC 운영체제와 짝지어 하나의 단위로 판매되지 아니한다.

WMP를 제외한 다른 미디어 플레이어는 PC 운영체제와는 다른 공급자들이 존재하고 있고, 공급방식도 주로 인터넷을 통해 다운로드 방식으로 이루어지므로 PC 운영체제와 짝지어 판매·공급되지 않는다.

일부 PC 운영체제 사업자들이 자신의 운영체제에 미디어 플레이어를 설치하여 판매하는 사례가 있다. 예를 들어 일부 리눅스 업체의 경우 자기 자신의 미디어 플레이어를 결합 판매하는 것이 아니라 제3의 독립된 미디어 플레이어를 포함시켜 판매하기도 한다.

78) 이 전자우편의 원문은 다음과 같다. “I'd like to bring you up to speed on what happened in this last Friday's Bills/paulma/bob Muglia meeting. Basically, Bills and Paulma made the decision that 1) we need to win the streaming battle against progressive networks, 2) gave the approval for me to go buy a $65 million company(5th largest microsoft acquisition ever) in order to win the battle, 3) Winning the streaming battle means three things-winning the file format war, winning the client architecture war, and winning the server wars. Bills comment was "this is a strategic area and we need to win it". Muglia's comment was "PN is like Netscape, the only difference is we have a chance to start this battle earlier in the game.(이하 생략)”

그러나, 다음과 같은 점을 고려할 때 통상적으로 운영체제와 미디어 플레이어가 짝지어 하나의 단위로 판매되지 않는다는 사실에는 변함이 없다.

첫째, 여러 PC 운영체제 사업자들이 어떤 소프트웨어를 자신들의 PC 운영체제에 포함시켜 판매한다고 하여 PC 운영체제와 그 소프트웨어가 하나의 제품인 것은 아니다. 이는 사업자들의 영업 전략상 별개의 두 제품을 동시에 판매할 동기가 있음을 보여줄 수 있을 뿐이다.

예를 들어, 현재 삼성전자, TG 삼보, LG IBM 등 대부분의 국내 PC 제조업체들은 새로운 PC에 워드 프로세서(word processor ; 전자문서 편집기)를 기본 프로그램으로 탑재하고 있다. 피심인들이 위원회에 제출한 자료에 의하면, 삼성전자는 “훈민정음”이라는 워드 프로세서를 탑재하고 있으며, TG삼보는 “MS 워드 2000”을 탑재하고 있으며, LG IBM과 현주컴퓨터는 “한글2002”를 탑재하고 있다는 사실을 인정할 수 있다. 이렇게 국내 PC 제조업체들이 거의 모두 PC에 워드 프로세서를 탑재하고 있다는 이유를 들어 PC와 워드 프로세서 프로그램에 대한 별개의 수요 및 별개제품성이 부정될 수는 없는 것이다.

둘째, PC 운영체제에 미디어 플레이어를 포함하여 공급하는 일부 사례가 존재하더라도, 미디어 플레이어 공급자 대부분이 PC 운영체제와 무관하게 미디어 플레이어를 공급하고 있다는 사실은 변화하지 않는다. 예를 들어 피심인들은 WMP를 PC 운영체제에 포함하여 판매함과 동시에 PC 운영체제 공급과 무관하게 PC 운영체제와 별개로 인터넷 웹사이트를 통하여 공급하고 있다. 그리고 피심인들과 애플을 제외한 리눅스 업체들은 제3자의 미디어 플레이어를 라이센스 받거나 공개되어 있는 미디어 플레이어를 탑재하고 있다. 또한 대부분의 미디어 플레이어 공급자들이 다양한 PC 운영체제에서 작동하도록 여러 가지 버전의 미디어 플레이어를 공급하고 있다는 점은 PC 운영체제와 미디어 플레이어간 별개제품성을 보여주는 거래관행이라고 인정된다.

셋째, 피심인 이외의 다른 PC 운영체제 공급자들은 구매단계에서 또는 구매 이후에 소비자가 원할 경우 미디어 플레이어를 삭제할 수 있도록 하고 있다는 점에서 피심

인들의 미디어 플레이어와 커다란 차이가 있다. 이것은 미디어 플레이어가 운영체제와는 별개의 응용프로그램임을 나타내는 것으로 다른 PC 운영체제 공급자들의 인식 및 거래관행 역시 미디어 플레이어와 PC 운영체제가 통상적으로 짝지어져 하나의 단위로 판매되지 않음을 보여주는 것이다.

넷째, 국내 PC운영체제 시장의 99%를 차지하는 피심인들이 WMP를 결합판매하고 있는 상황에서 다른 PC 운영체제 사업자들의 행태는 거래관행에 참고가 되기 어렵다. 거래관행이란 일반적으로 경쟁시장에서 참여 기업간 경쟁을 통하여 자연스럽게 형성된 관행이라야 비로소 의미가 있는 것이라고 할 수 있다. 그런데 PC 운영체제 시장처럼 하나의 기업이 절대적 독점력을 보유하고 있는 상황에서 다른 기업의 경영전략이나 거래행태는 독점기업으로부터 크게 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 이들의 행태를 두고 정상적인 거래관행이 형성되었다고 할 수는 없다고 판단된다. 이러한 점은 특히 리눅스의 경우 최근에 이르러서야 미디어 플레이어를 탑재하여 판매하고 있는 사실로 뒷받침된다.[79)]

2) 피심인들의 행위는 WMP를 원하지 않는 거래상대방에게 부당하게 WMP의 구입을 강제한 것이다.

피심인들의 행위는 WMP를 원하지 않는 거래상대방에게 WMP의 구입을 강제함으로써 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래를 강제한다.

참고로, 「불공정거래행위심사지침(공정거래위원회 예규 제26호)」은 구입강제성 여부를 거래상대방의 입장에서 주된 상품과 종된 상품을 따로 구입하는 것이 자유로운지를 기준으로 판단하도록 규정하고 있다. 이때, 강제성은 주된 상품에 대한 구매자의 거래처 전환 가능성이 적을수록 큰 것으로 판단된다.

불공정거래행위 중 끼워팔기에 관한 판례도 구입강제에 대하여 거래상대방으로 하여

79) 리얼네트웍스는 2005.10월 의견서에서, 자신이 확인한 바로 피심인들이 결합판매를 시작하던 때에 스트리밍 미디어 플레이어를 자신의 운영체제와 함께 공급하고 있던 다른 PC운영체제 사업자는 없었다고 진술하고 있다.

금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 것으로 판시[80]하고 있다.

첫째, 피심인들이 PC 운영체제 시장을 거의 100% 독점하고 있는 상황에서, 피심인들이 WMP가 포함되지 않은 윈도우 PC 운영체제를 판매하지 않음으로 인해 소비자들은 WMP가 포함되지 않은 PC 운영체제를 선택할 자유를 박탈당하고 있다.

이는 PC 제조업체가 미국 연방지방 법원의 2002년 동의심결에 따라 WMP의 아이콘을 삭제하거나 자신이 원하는 다른 미디어 플레이어를 탑재하여 판매할 수 있다고 하여도 마찬가지이다. 왜냐하면, PC 제조업체가 자신이 원하는 다른 미디어 플레이어를 기본 프로그램으로 설정하여 소비자에게 판매하는 경우에도 PC 제조업체는 윈도우 PC 운영체제에서 WMP를 완전히 제거할 수 없고, 단지 WMP의 아이콘만 없앨 수 있기 때문이다. 이 경우에도 WMP 프로그램은 PC 운영체제에 포함되어 있는 것이므로 소비자가 WMP를 강제로 구입한다는 사실에는 변함이 없는 것이다.

둘째, 위원회가 실시한 미디어 플레이어 설문조사[81]에 의하면, 윈도우XP 구매자 중 상당수가 피심인들의 PC 운영체제에 포함된 WMP가 아닌 다른 미디어 플레이어를 사용하는 것으로 나타났다. 즉, 이들 상당수의 사용자는 피심인들의 WMP가 아닌 다른 미디어 플레이어를 사용하기 때문에 WMP를 필요로 하지 않는 자신의 의사와 관계없이 운영체제와 함께 WMP를 구입하도록 강제되었을 가능성을 시사하고 있다.

결국 WMP를 구입할 의사가 없는 경우에도 거래상대방은 WMP가 없는 PC 운영체제를 사실상 구입할 수 없다면 피심인들이 WMP를 PC 운영체제에 결합판매한 행위는 WMP 구입을 강제한 행위로 인정된다.

이에 대해 피심인들은 구입강제성이 인정되기 위하여는 유상구입이 전제[82]되어

---

80) 서울고등법원 2004. 2. 10. 선고, 2001누16288 판결,

81) 중앙리서치의 2004년 8월 조사에 따르면 스트리밍 미디어 플레이어 사용자 중 39.5%는 다른 미디어 플레이어를 주로 사용하고 있는 것으로 나타났다.

82) 설령, 피심인의 주장처럼 구입강제성에 유상성이 반드시 필요할지라도 소프트웨어 산업에서는 무상으로 제품을 공급하더

야 하는데, 미디어 기능은 무료로 제공되는 것이기 때문에 구입이 강제된 것은 아니라고 주장하나, 시장지배적지위 남용행위 중 사업활동 방해에 관한 법령에서는 결합판매에 있어 소비자들이 반드시 유상으로 종된 상품을 구입할 것을 요건으로 하고 있지 않으므로[83] 피심인들의 주장은 이유 없다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

공정거래법상 "불이익"이라 함은 반드시 거래상대방이 금전적으로 손해를 입는 것 뿐 아니라, 경제적·사회적으로 불리한 위치에 있게 되는 모든 현상을 의미한다고 보는 것이 타당하다. 즉, 거래상대방에게 당장의 경제적 손해는 없다 하더라도 잠재적으로 경제적 이익을 빼앗긴다거나 장래의 기대이익이 박탈당하는 경우, 거래선택의 자유를 침해당하는 경우, 그리고 상응하는 권리취득 없이 의무만을 부담하는 경우 등을 포괄하는 의미로 보는 것이 상당하다.

피심인들이 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매하는 행위는 다음에서 보는바와 같이 WMP의 구입을 원하지 않는 소비자에게 WMP의 구입을 강제함으로써 소비자의 상품 선택권을 침해함과 동시에 양질의 제품을 접할 수 있는 기회를 차단하여 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

첫째, 피심인들은 PC 운영체제 시장에서 거의 100%의 시장점유율을 보유한 확고한 독점사업자이기 때문에 WMP 결합판매는 WMP의 구입을 원하지 않는 거래상대방에게 WMP의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 상품 선택권을 과도하게 제약하며 결국 모든 거래상대방에게 불이익을 발생시키고 있다.

라도 이에 따른 부가서비스 제공 등으로 수입을 얻는 사업 모델이 일반화되어 있고 이러한 제품의 공급자는 직접 댓가를 지불받지는 않지만 다른 방식으로 반대급부를 얻는 경우가 많으므로 명목상 무료로 제품을 공급하고 있을지라도 공정거래법적 관점에서 WMP의 제공이 무료인 것은 아니다.

83) 이는 EC의 경쟁법 관련규정이나 심결상으로도 경쟁제한적인 결합판매는 강제성(coercion)만이 요구되고 유상성은 필요로 하지 않는 것과 맥을 같이 하는 것으로서, EC는 피심인의 WMP 결합판매와 관련된 결정문에서, 소비자가 WMP에 대해 추가적인 가격을 지불할 필요가 없으므로 끼워팔기가 성립할 수 없다는 MS의 주장에 대해, 끼워팔기의 성립에 댓가 지불(paying)을 요하지 않는다고 관련 법률을 해석하였다.(EC 결정문 제830항~831항)

둘째, 피심인들의 결합판매 행위는 뒤에서 살펴보는 바와 같이 상당수의 소비자가 미디어 플레이어의 품질, 기능, 안정성 등 측면에서 우월하거나 유사한 다른 미디어 플레이어가 있더라도 피심인들의 WMP가 자신의 PC에 기본으로 설치되어 있고 또한 이로 인하여 가장 많은 콘텐츠가 제공되고 있다는 이유로 WMP를 선택하도록 함으로써 거래상대방으로 하여금 우수하거나 다양한 품질의 타제품을 사용하는 것을 실질적으로 제약하는 불이익을 주고 있다.

4) 소결

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 WMP를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로서 이는 부당하게 소비자의 미디어 플레이어에 대한 상품 선택권을 침해하고, 이는 결국 종된 상품 시장인 미디어 플레이어 시장에서 품질 및 가격에 의한 경쟁을 침해하여 소비자가 우수한 다른 제품을 접할 기회를 제약하는 불이익을 초래하는 바, 따라서 피심인들의 결합판매 행위는 불이익한 거래를 강제한 행위에 해당한다.

참고로, 피심인들은 PC 운영체제에 WMP를 결합한 행위는 WMP가 제조단계에서 결합되어 추가비용의 지불없이 판매되므로 사용자가 쉽게 설치하고 무료로 사용할 수 있다는 점에서 거래비용을 감소시키고, 새로운 응용프로그램의 개발을 용이하게 하여 소프트웨어 개발업자에게 이익이 되며, PC 운영체제에 대한 수요의 증가를 가져와 컴퓨터 제조업체에 대한 혜택을 제공하는 등의 효율성이 있다는 취지의 주장을 한다.

그러나, 피심인들이 주장하는 편익은 WMP가 아니라 다른 미디어 플레이어를 결합하여 판매하는 경우에도 예상할 수 있는 결합으로 인한 단순한 편익에 불과하며, 이미 앞에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 결합판매 행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 불이익한 거래를 강제한 행위로 명백히 인정되는 반면, 가사 피심인들이 주장하는 결합판매로 인한 편익을 어느 정도 인정하더라도 피심인들의 결합판매 행위가 가져오는 심각한 경쟁제한의 폐해를 상쇄할 정도에 이르지 못하여 피

심인들의 주장을 받아들이기 곤란[84]하다.

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

피심인들이 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 종된 상품 시장인 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 WMP의 편재성을 발생시키고 DMS 구성요소간의 상호의존성은 이러한 편재성을 더욱 강화시켜 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한하고 신규 사업자의 진입을 곤란하게 하는 진입장벽을 형성하는바, 이러한 행위는 거래상대방인 소비자들의 미디어 플레이어에 대한 상품 선택의 자유를 침해하고, 미디어 플레이어 시장에서 상품의 품질과 가격을 통한 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업 활동을 방해한다.

1) 피심인들의 결합판매행위는 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 경쟁을 제한한다.

가) 피심인들의 행위는 WMP의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 미디어 플레이어 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

피심인들은 결합판매를 통해 거의 모든 PC에 WMP가 설치되도록 함으로써 다른 사업자가 누릴 수 없는 편재성을 획득하였다. 이에 비하여 피심인들의 경쟁사업자들은 인터넷 다운로드 경로 또는 PC 탑재 경로 등을 통하여 자신의 미디어 플레이어를 소비자에게 공급하고 있으나, 이러한 방법으로는 피심인들과 동등 또는 유사한 수준의 편재성을 누리기 곤란하다.

① 경쟁사업자들은 다운로드에 의해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다.

첫째, 피심인들을 제외한 다른 미디어 플레이어 사업자들도 PC 제조업체와의 협상을 통해 자신의 미디어 플레이어를 사전에 PC 운영체제에 탑재할 수 있으나, 뒤에서 살펴 보는 바와 같이 피심인들과 같은 편재성을 획득할 수는 없다.

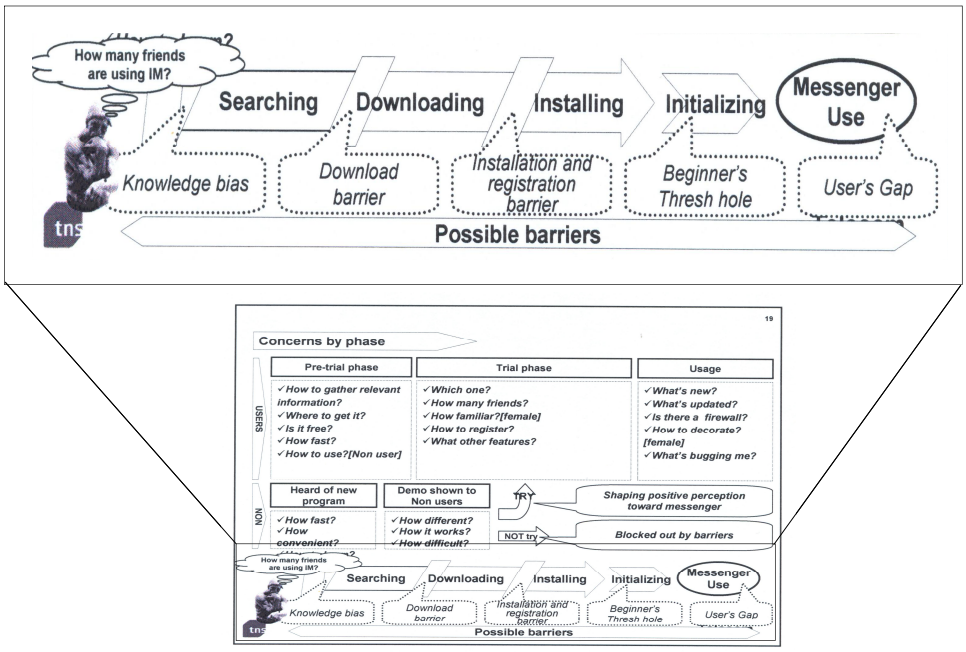
84) 이에 관한 구체적 주장에 대한 반박은 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기부분에서 자세히 기술한다.

따라서, 이들은 치열한 경쟁을 통해 인터넷 사용자들의 까다로운 선택을 받기위해 노력하여야 한다. 즉, 다운로드를 통해 미디어 플레이어를 배포하는 사업자는 WMP를 운영체제에 포함하는 방법을 이용하는 피심인들과는 달리 WMP 보다 성능 및 품질이 우수한 제품을 개발하여야 하고, 이를 인터넷을 통해 다운로드 받아 설치, 이용하도록 홍보하여야 한다. 이들은 이 과정에서 피심인들보다 커다란 노력과 비용을 부담할 수 밖에 없다.

다음으로, 소비자들이 자신이 이용할 미디어 플레이어를 다운로드를 통해 PC에 설치하기 위해서는, ㉠미디어 플레이어를 다운로드 받겠다고 결심하고, ㉡인터넷에서 다운로드 받을 수 있는 여러 프로그램을 탐색하여 장단점을 비교한 후 그 중에서 당해 프로그램을 고르고, ㉢선택한 미디어 플레이어를 다운로드 받을 인터넷 사이트에 접속하고, ㉣다운로드를 위한 기본절차를 여러 번 거친 후 ㉤다운로드 받은 프로그램을 설치하는 과정을 거치게 된다.

위와 같은 과정을 거치는 소비자들의 선택을 받기 위해서, 미디어 플레이어 사업자들이 많은 비용을 들여 치열하게 경쟁한다는 사실은, 다운로드 경로에 있어 미디어 플레이어와 유사한 피심인들의 메신저 시장조사 결과 보고서에도 잘 나타나 있다.

<그림 3-8> 메신저 탐색→다운로드→설치→실행의 단계적 어려움 등이 설명된 시장 조사 보고서(2003.12.)



* 출처 : 피심인 제출자료(2004. 6. 10.)

이 때 중요한 것은, 윈도우 PC 운영체제에 결합된 피심인들의 WMP는 위의 네 가지 장애물을 "결합판매"를 통해 단숨에 뛰어 넘는다는 사실이다. 즉 소비자의 탐색 여부, 인터넷 사이트 접속 여부, 다운로드 여부 선택, 설치 여부 선택이라는 소비자의 의사결정 과정을 거치지 않고, 소비자는 PC 운영체제를 구입할 때 피심인들의 WMP 설치를 이미 완료하도록 강제되어 있다.

따라서, 피심인들의 WMP도 다른 사업자의 미디어 플레이어와 마찬가지로 이러한 선택 과정을 거쳤다면 위에서 본 ㉡탐색 내지 ㉢프로그램 설치까지의 과정에서 다른 미디어 플레이어와 비교한 뒤 설치되지 않았거나 아예 이용자가 피심인들의 WMP를 다운로드받을 사이트를 찾는 정도의 노력을 다할 열의가 없어서 중단되어 지금과 같은 강력한 편재성을 누리지 못했을 가능성이 매우 클 것이다.

둘째, 다운로드 경로는 미디어 플레이어가 무엇인지 그리고 다운로드를 어떻게 받는지 조차 모르는 상당수의 초보 사용자들에 있어서 접근하기 어려운 경로이다.

이러한 사실은 피심인들이 신청한 참고인 문홍일(삼보컴퓨터 근무)의 2005. 8. 24.

심판정 진술에서 확인할 수 있다. 참고인 a는 주식회사 A가 '000'라는 미디어 플레이어를 일부 자사 컴퓨터에 탑재하여 판매하고 있는데, 그 이유 중 하나가 미디어 플레이어(WMP를 말함)조차 사용하지 못하는 초보자들을 위해서라고 진술하면서, 자사 고객 중 미디어 플레이어가 무엇인지 다운로드가 무엇인지 모르는 비율이 30% 내지 40%에 이른다고 응답하였다.

또한, 피심인들의 내부자료에 의하면 2004년도에 WMP 9에 대한 다운로드 실패율이 30%에 이르고 있는 것으로 나타나는데, 이 역시 다운로드가 WMP의 편재성을 상쇄하기 어려움을 보여준다.

<표 3-7> WMP 9 다운로드 실패현황(2003~2004. 6.)

구분		총시도횟수	성공횟수	실패횟수	실패율(%)
2003년	윈도우XP용	2,254,150	1,605,870	648,280	28.76
	윈도우98SE,Me,2000용	692,790	592,080	100,710	14.54
2004년	윈도우XP용	1,712,570	1,157,760	554,810	32.40
	윈도우98SE,Me,2000용	1,477,160	1,057,430	419,730	28.41
총계		6,136,670	4,413,140	1,723,530	28.09

* 출처 : 피심인 제출자료(2004. 6. 10.)

이러한 사실을 종합해 볼 때, 다른 미디어 플레이어를 다운로드 받을 수 있는 기술적 환경이 아무리 우수하더라도, 다운로드를 통한 미디어 플레이어의 배포는 윈도우 운영체제에 포함된 WMP의 편재성을 극복할 수 없는 정도인 것으로 인정된다.

② 경쟁사업자들이 PC 제조단계에서의 탑재경로에 의해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다.

PC 제조 단계에서의 메신저 탑재경로를 PC 제조업체 측면, PC 제조업체와 피심인들의 관계 측면 및 미디어 플레이어 사업자 측면에서 볼 때 경쟁사업자들이 PC 제조단계 탑재경로를 통해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다는 사실을 인정할 수 있다.

㉮ PC 제조업체 측면

첫째, PC 제조업체가 구매한 피심인들의 PC 운영체제에 이미 WMP가 포함되어 있고 삭제할 수 없다는 사실은 소프트웨어 테스트 비용 및 고객지원 비용의 절감을 위해 노력하는 PC 제조업체들의 입장에서 WMP와 거의 동일한 기능을 수행하는 미디어 플레이어를 중복 설치할 유인을 감소시킨다.

우선 PC 제조업체가 PC 제작단계에서 피심인들로부터 제공받는 운영체제 외에 어떤 소프트웨어를 추가로 설치하게 될 경우 테스트 비용[85] 및 소비자 지원 비용[86]이 추가 발생하기 때문이다.

이와 관련하여 익명을 요구한 국내 한 PC 제조업체는 2004. 8. 19. 위원회에 제출한 의견서에서 “특정 프로그램을 다수 설치할 경우 한 개의 프로그램을 설치할 때에 비하여 테스트에 드는 시간, 비용 및 애프터 서비스에 대한 추가비용이 발생한다”는 의견을 제시한 바 있다. 그리고 일반적으로 PC 제조업체들은 PC에의 소프트웨어 탑재 및 서비스 방식이 유사하다는 점을 고려할 때, 이러한 비용증가 현상은 거의 대부분의 PC 제조업체가 직면하는 사실일 것으로 인정된다.

둘째, PC 제조업체가 동일한 목적을 가지는 응용프로그램을 여러 개 설치하는 것을 꺼려한다는 사실은 미국 연방항소법원에서도 확인된 바 있다.[87]

결국, PC 제조업체의 낮은 경상이익률[88] 속에서 수익극대화를 추구하는 PC 제조업체들이 WMP의 경쟁 미디어 플레이어를 탑재하기를 꺼려하게 되고, 이에 따라 PC 제조업체를 통한 탑재경로는 WMP의 편재성을 극복할 수 있는 수단이 되기 어렵다.

85) “테스트 비용”은 특정 프로그램을 탑재할 경우에도 PC가 정상적으로 작동하는지를 검사하는데 소요되는 비용을 의미한다.

86) “소비자 지원 비용”은 소비자들이 PC를 사용하는 단계에서 해당 PC에 탑재된 특정 소프트웨어와 관련한 오류가 발생했을 때 PC 제조업체가 해당 소프트웨어에 대한 소비자 상담 등의 애프터 서비스를 수행하는 과정에서 발생하는 비용을 의미한다.

87) US. v. Microsoft, 84 F. Supp. 2d(2001) at ¶ 159.

88) 「한국신용평가정보-컴퓨터 시장 동향과 전망」(2003. 12. 31.)에 의하면, 국내 PC 제조업체의 경상이익률은 0.1%에 불과하다.

㉯ PC 제조업체와 피심인들의 관계 측면

PC 운영체제를 독점하고 있는 피심인과 PC 제조업체들이 동업자적 이해관계를 갖고 있다는 점은 PC 제조업체가 WMP와 경쟁관계에 있는 미디어 플레이어를 탑재할 유인을 감소시키고 있다. PC 제조업체와 피심인들은 기술개발, 마케팅 등 여러 분야에서 매우 밀접한 동업관계를 맺고 있는데, 이는 컴퓨터 하드웨어와 컴퓨터 운영체제가 다음과 같이 기술적 또는 상업적으로 매우 밀접한 상호의존성을 갖고 있기 때문이다.

첫째, 하드웨어와 운영체제의 양 분야 사업자가 기술정보를 공유하는 것은 기술개발에 필수적이다.[89] 특히 컴퓨터 하드웨어 시장은 다수의 사업자가 치열하게 경쟁하는 상황임에 비해 PC 운영체제 시장은 피심인들이 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 PC 제조업체들은 상대적으로 희소성을 갖고 있는 피심인 제품의 기술정보를 얻기 위해 피심인과 기술적인 측면에서 밀접한 동업관계를 형성할 유인을 강하게 갖게 된다.

2004. 4. 작성된 피심인들 내부문서에서도 피심인들은 PC 제조업체가 윈도우 PC 운영체제의 차기 제품인 롱혼(Longhorn)을 무리없이 탑재할 수 있는 제품을 개발할 수 있도록 협력을 계속할 것이라고 기재되어 있는데, 이로 미루어 PC 제조업체와 피심인 간 밀접한 기술적 동반관계를 확인할 수 있다.[90]

---

89) 피심인의 내부교육 교육자료(2001. 6. 30.)에는 다음과 같이 기재되어 있다. “마이크로소프트는 아직 부족하지만 다음과 같은 작업을 병행하고 있습니다.

(1) PC 관련한 모든 제품(PC 자체 뿐 아니라, 각종 카드, 주변기기 등)에 대해 Windows 제품과의 호환성을 테스트하고 인증하는 제도인 “Designed for Windows xxx"로고를 운영하여서 호환성 품질향상에 노력하고 있으며, 로고를 획득한 부품과 제품을 사용하기를 권장하고 있습니다.(중략) 본 로고를 획득한 부품과 PC는 전세계 어디에 수출해도 환영받을 수 있습니다.

(2) 제품개발단계에서부터 관련 기술자료를 계속 PC회사 전용 웹사이트에 업로드해서 누구나 쉽게 참조할 수 있도록 하고, MSDA 브리핑 등 무료 기술세미나를 주기적으로 계속 시행하고 있습니다. 개발완료 시점에서는 전문기관에서의 기술교육 등을 통해 PC 회사들의 소프트웨어 기술수준을 마이크로소프트와 동일하게 맞추는 노력을 합니다.

(3) 주요PC회사의 기술지원부서와는 무료로 핫라인을 개설하여 문제해결을 돕고 있습니다. 아울러서 모든 PC회사에는 무료로 온라인 뉴스그룹을 통해 기술지원 받을 수 있는 통로를 개설하고 있습니다.“ 「Microsoft OEM 및 시스템빌더용 제품의 불법복제 관련 Q&A」, 6쪽 참조

90) 이 문서의 영어 원문은 다음과 같다. “(앞생략) ▪ Develop opportunities for OEMs to participate in future Windows Client services offerings. We will also look to the future to Longhorn and will continue to engage with the OEMs to ensure their collective product feedback happens and that they complete the necessary steps in order to prepare for the next generation of Windows Client(이하 생략)”, 「OEM Division FY05 Plan(2004. 4. 9.)」, 3쪽~4쪽 참조

둘째, PC 제조업체들은 윈도우 PC 운영체제에 대한 직·간접적 광고를 수행하며, 피심인들은 이에 대한 대가로 상당한 금액의 마케팅 비용을 지원하는 등 밀접한 공동 마케팅 관계를 형성하고 있다[91]. 이는 피심인 운영체제가 탑재된 PC 판매의 증가가 곧 피심인의 PC 운영체제 매출 증대를 의미하기 때문이다. 이는 2004. 9. 9. 피심인 지사장 회의자료[92]에서도 잘 나타나 있다.

피심인과 PC 제조업체간 긴밀한 상업적 동업관계는 피심인과 대형 PC 제조업체간 체결하는 "시장발전협약(MDA ; Market Development Agreement)"에서 명확히 알 수 있다. 이 협약서에서는 피심인들이 PC 사용자의 편의성 등과 관련한 어떤 기준을 설정하고 이 기준을 충족시킬 경우 PC 제조업체가 피심인에게 지불해야 할 PC 운영체제 라이센스료에서 일정금액을 할인해 주고 있다.

이상의 사실에 비추어 볼 때, 피심인들과 PC 제조업체들간의 밀접한 관계로 인하여 WMP의 경쟁미디어 플레이어 사업자들이 자신의 미디어 플레이어를 PC 제조업체를 통하여 WMP에 필적하는 수준으로 효과적으로 보급하는 것은 매우 어려운 것으로 인정된다.

㉰ 미디어 플레이어 사업자 측면

피심인들과 경쟁관계에 있는 미디어 플레이어 사업자 입장에서도 새로운 PC에 자사 미디어 플레이어를 탑재하도록 노력하는 데는 한계가 존재한다.

---

91) 피심인들이 제출한 2004 회계연도 자료에 의하면 피심인들은 PC 운영체제에 대한 총 마케팅 비용 약 000원(미화 000 달러) 중 약 00억원(미화 000 달러)을 PC 제조업체에 대한 마케팅 지원용으로 사용하였다.

92) 이 문서의 영어 원문은 다음과 같다. "(앞부분 생략) OEM : Consumers generally do not acquire Windows separately from their PCs, other than a small percent who upgrade every year. Because of this, relationships and programs with our OEM partners will continue to be vital to our strategy in FY05, as is the retail channel which delivers about 80% of consumer PCs. The OEM account marketing managers and account managers must work with the OEM partners to ensure the appropriate product SKU mix is available to the retailers. In addition to this effort, the OEM team members should work with the OEM partners and HRD team to coordinate the retail execution and syndication of messaging in the OEM's marketing efforts.(이하 생략)" 「Consumer Strategy(2004. 4. 9.)」

첫째, 미디어 플레이어 사업자들이 자신의 미디어 플레이어를 새로운 PC에 탑재하도록 PC 제조업체를 설득하기 위해서는 현실적으로 일정한 대가를 PC 제조업체에게 지불해야 한다. 그러나 재정적 한계를 안고 있는 미디어 플레이어 사업자들이 모든 PC에 자신의 미디어 플레이어를 탑재하도록 모든 PC 제조업체들에게 일정한 대가를 지불한다는 것은 사실상 불가능하다.

둘째, 수많은 국내외 PC 제조업체들과 협상을 전개하기 위해서는 상당한 협상비용이 소요되는데, 미디어 플레이어 사업자들이 그 비용을 전부 감당하는 것은 사실상 불가능하다.

셋째, 미디어 플레이어 사업자들이 PC에 자신의 미디어 플레이어를 기본 프로그램으로 탑재하기 위해서는 다른 미디어 플레이어 사업자들과 경쟁하여 선택을 받아야 한다. 이러한 상황에서 특정 미디어 플레이어 사업자가 피심인들과 같은 수준의 편재성을 확보한다는 것은 기대하기 어려운 것으로 인정된다[93].

넷째, 피심인들의 PC 운영체제 유통경로 중에는 기업체, 정부기관, 개인 등에게 피심인들이 직접 PC 운영체제를 라이센스 하는 경우가 상당 수[94] 있는데, 다른 미디어 플레이어 사업자들이 이러한 직접 판매 경로에 접근하기에는 상당한 어려움이 존재한다. 즉 피심인 이외의 다른 사업자가 자신의 미디어 플레이어를 PC에 기본 탑재하기 위해서 PC 운영체제에 WMP가 탑재되어 있음을 인식하고 있는 이들 대규모 수요처와 개별적으로 일일이 접촉하고 계약을 체결하여 피심인들이 결합판매를 통하여 누리고 있는 편재성과 동등한 수준의 판로를 개척하는 것은 사실상 불가능하다.

결국, PC 제조업체를 통한 보급경로는 PC 제조업체가 WMP 외의 다른 미디어

93) 미디어 플레이어의 유력한 경쟁사업자인 리얼네트웍스 역시 미국 연방지방 법원의 동의심결 이후 컴퓨터 제조업체를 통한 공급을 위해 다방면의 노력을 기울였으나, 그 성과가 WMP의 편재성을 상쇄하기에는 턱없이 부족한 것이었음은 EC 결정문에도 잘 나타나 있다. 즉, EC는 2001년 4분기부터 2003년 1분기까지 피심인들과 경쟁관계에 있는 리얼네트웍스의 미디어 플레이어가 PC 제조업체를 통해 사전탑재된 비율이 전체 PC 판매량의 1% 내지 15% 미만에 불과하였다고 하고 있다.(EC 결정문 855항 참조)

94) 피심인들이 국내에 판매하는 PC 운영체제(OEM으로 판매된 것 포함) 중에 기업, 정부기관, 개인 등과의 직접 라이센스 판매비중은 매출 기준으로는 대략 13%를 차지하고 있다. 「피심인 제출자료(2001. 10. 16.)」

플레이어를 추가 설치할 유인이 적고 경쟁 미디어 플레이어 사업자에게 큰 부담이 되기 때문에, 경쟁 미디어 플레이어 사업자가 아무리 노력하더라도 WMP의 편재성을 극복하는 것은 사실상 불가능하다고 인정된다.

③ 코드제거 곤란은 WMP의 편재성을 더욱 강화시킨다.

WMP는 윈도우 운영체제에 들어있는 프로그램 제거기능(Program Add/Remove utility)을 이용하여 안전하게 제거할 수 없게 되어 있다. 미국에서의 2002년 동의심결에 따라 제공된 윈도우XP 서비스팩1을 설치하더라도 단지 아이콘 등의 접근수단만 삭제할 수 있을 뿐이다. 반면 경쟁 사업자들은 거의 대부분 미디어 플레이어를 안전하게 제거할 수 있는 기능(Program Add/Remove Utility)을 제공하고 있다.

그런데 윈도우 운영체제 사용자들은 프로그램 추가/제거 기능을 통하지 않고 특정 소프트웨어를 삭제할 경우 운영체제 오류의 원인이 될 수 있다 우려 때문에 WMP 제거를 매우 꺼리게 된다.

이와 같이 WMP가 컴퓨터에서 안전하게 제거되지 않는 성질은 소비자들이 항상 WMP에 노출되는 환경을 만들어 주기 때문에, 앞에서 본 편재성을 보다 공고히 하고 있다고 인정된다.

나) WMP의 편재성과 이에 따른 경쟁상 우위로 인하여 WMP로의 쏠림현상이 발생한다.

① 피심인들의 결합판매는 소비자들의 WMP 선택에 강한 영향을 미쳐 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

피심인들이 WMP를 결합판매한 것은 소비자의 미디어 플레이어 선택에 직접 강한 영향을 미쳤다. 위원회는 2004. 8. 미디어 플레이어에 관한 설문조사를 통하여 피심인들의 WMP 결합판매가 소비자들의 미디어 플레이어 선택에 어떤 영향을 미쳤는지에

대하여 조사한 바 있다.

첫째, 위원회는 PC 운영체제에 피심인들의 WMP가 설치되어 있다는 점이 WMP 사용에 얼마나 영향을 미쳤느냐는 질문에 대하여 전체 응답자 1,000명 중 61.0%는 영향이 있다고 응답하였고 전혀 영향이 없다고 응답한 자는 3.5%에 불과하였다.

둘째, 소비자들에게 현재 주로 사용하는 미디어 플레이어를 사용하는 이유에 대해서 질문하였다. 이에 대하여 WMP를 주로 사용하는 소비자들은 "컴퓨터에 원래 설치되어 있어서"라고 응답한 비율이 69.8%로서 다른 미디어 플레이어 주사용자가 그렇게 대답한데 비해 월등하게 많았다[95].

이상의 조사결과는 피심인들의 WMP 결합판매가 소비자들로 하여금 다른 미디어 플레이어를 선택할 유인을 감소시키고 WMP를 선택·사용하도록 하는데 강력한 영향을 미침으로써 미디어 플레이어 시장에서 WMP로의 쏠림현상을 발생시키는 요인이 되었음을 보여준다.

② 피심인들의 결합판매는 콘텐츠 및 소프트웨어를 통한 쏠림현상을 발생시킨다.

피심인들의 결합판매에 의한 WMP의 편재성에 따라 콘텐츠 제공업자들은 WMP 포맷으로 콘텐츠를 제공하게 되고 소프트웨어 개발자들은 WMP의 인터페이스에 의존하는 응용프로그램으로 제품을 개발하게 되어 소비자들은 WMP를 선택하는 쏠림현상이 발생하였다.

---

95) 여기에서 "컴퓨터에 원래 설치"되어 있다는 의미는 응답자를 기준으로 한 의미이다. 즉 다른 사람이 이용하였거나 공동으로 이용하는 컴퓨터의 경우에는 WMP와 함께 다른 사용자가 설치한 미디어 플레이어가 '처음부터 원래 설치'된 것에 해당할 것이다. 따라서 새로운 PC를 구입하여 혼자 사용한 컴퓨터의 경우만을 대상으로 같은 질문을 한다면 이 질문에서 WMP와 다른 미디어 플레이어 간의 응답비율 격차는 더욱 커질 것으로 보인다. 이는 새로운 PC에 다른 미디어 플레이어가 "원래 설치"되는 비율이 국내에서는 매우 미미하기 때문이다.

㉮ WMP 호환 포맷의 콘텐츠 양산에 따라 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

윈도우 PC 운영체제와 WMP의 결합판매로 나타난 WMP의 편재성은 콘텐츠 사업자로 하여금 피심인들의 고유 포맷을 이용한 콘텐츠를 양산하게 함으로써 미디어 플레이어 사용에 있어 WMP로의 쏠림현상을 초래하였다.

이러한 사실은 콘텐츠 사업자들이 어떤 포맷으로 콘텐츠를 제공할 것인지를 결정할 때 이용자 접근 가능성을 제고하기 위해 미디어 플레이어의 배포정도를 매우 크게 고려한다는 점, 두 가지 포맷으로 콘텐츠를 제공할 경우 상당한 중복비용이 발생하기 때문에 이를 회피하려고 한다는 점 등 두 가지 측면에서 확인할 수 있다.

첫째, 콘텐츠 사업자들은 어떤 포맷으로 콘텐츠를 제공할 것인지를 결정할 때 이용자 접근 가능성을 제고하기 위해 미디어 플레이어의 배포 정도를 매우 크게 고려한다.

이에 대해 피심인들은 콘텐츠 사업자들이 스트리밍 미디어 플레이어의 배포 정도를 고려하기는 하지만 이것이 스트리밍 솔루션을 선택하는 결정적 기준은 아니라고 하면서, 콘텐츠 사업자는 콘텐츠 지원품질, 압축효율성, 비용 등 다양한 요소를 고려하여 자신이 사용할 스트리밍 솔루션을 결정한다고 주장한다.

그러나, 이러한 피심인들의 주장은 다음의 사항을 고려할 때 이유 없다.

우선, 디지털 미디어 시스템의 특성에서 살펴 본 바와 같이 콘텐츠 사업자는 자신의 콘텐츠가 가장 널리 가장 많은 소비자들에게 이용되기를 바란다. 그 결과 콘텐츠 사업자는 미디어 포맷 및 이를 전송할 스트리밍 미디어 서버 프로그램을 선택함에 있어 사용자의 PC에 가장 널리 배포되어 있는 미디어 플레이어가 무엇인지를 고려하게 된다. 물론 미디어 플레이어를 결정함에 있어서 콘텐츠 지원품질, 압축효율성, 비용 등 다양한 요소를 고려하는 사실이나 다른 조건이 동일하다면 사용자에게 더 많이 이미 배포되어 있는 미디어 플레이어를 사용하는 것이 일반적이다.

이러한 사실은 한국소프트웨어진흥원이 콘텐츠 제공업자를 대상으로 한 '미디어 서버 사용현황 및 인식조사 보고서'(2004. 9. 10)에서 다음과 같이 확인할 수 있다.

㉠ 스트리밍 서비스 방식 선택시 어떤 미디어 플레이어가 얼마나 많은 이용자들에게 배포되어 있는지 어느 정도 고려하는가?

고려 정도	매우 고려	약간 고려	별로 고려않음	전혀 고려않음
비율(%)	58	33	7	2

㉡ 스트리밍 미디어 콘텐츠 포맷 선택시 이용자의 미디어 플레이어를 얼마나 고려하는가?

고려 정도	매우 고려	약간 고려	별로 고려않음	전혀 고려않음
비율(%)	66	30	3	1

둘째, 윈도우 PC 운영체제와 WMP의 결합판매로 인한 WMP의 편재성은 콘텐츠 사업자에게 윈도우 미디어 시스템이 제공하는 스트리밍 서비스가 WMP를 통해 안정적으로 작동한다는 인식을 갖게하여 준다는 사실도 쏠림현상의 요인이 되었다.

피심인들이 신청한 참고인 a(A 근무)도 2005. 8. 24. 심판정에서, 콘텐츠 사업자가 미디어 솔루션을 선택할 때 고려하는 중요한 요소 중 하나가 서비스의 안정성인데, WMP가 일반 사용자들의 PC에 광범위하게 보급되어 있다는 사실 자체가 바로 제품의 신뢰성, 안정성을 대별하는 것으로 인식하게 하는 것이라는 취지로 진술[96]한 바 있다.

셋째, 콘텐츠 사업자들이 두 가지 이상의 포맷으로 자신의 콘텐츠를 제작·배포하는 경우에는 하나의 포맷으로 서비스하는 경우보다 추가비용이 발생하는데, 이러한 추가비용의 발생은 콘텐츠 사업자로 하여금 특정한 한 가지 포맷으로만 서비스를 제공하도록 하는 경향을 유발한다. 이에 따라서 미디어 플레이어 시장에서 한 가지 포맷 또는 한 가지 미디어 플레이어로 수요가 쏠리는 현상이 더욱 강하게 나타난다고 할 수 있다.

96) 증거조사 신청 참고인 신문조서 87페이지 참조

㉯ WMP 인터페이스에 기반한 응용프로그램 양산에 따라 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

피심인들의 결합판매 행위는 소프트웨어 개발자에게 여러 미디어 플레이어에서 작동하도록 응용프로그램을 제작하는데 따른 개발비용, 테스트비용, 지원비용 등과 같은 중복비용을 발생시키기 때문에 윈도우 미디어 플레이어에 기반한 응용프로그램의 개발을 유인하게 한다.

이에 대해서 EC의 조사결과를 참고할 수 있다. EC는 그러한 유인과 관련하여 15개 소프트웨어 개발회사들을 대상으로 질의하였는데, 이 조사결과에서 응답회사들은 여러 미디어 기술에서 작동하도록 응용프로그램을 개발하는 것은 추가적인 비용을 발생시킨다고 응답하였고, 여러 가지 기술을 지원할 경우 발생하는 추가비용의 규모에 대해서는 평균 58%라고 응답하였다. 또한 모든 응답자들은 미래에 WMT용으로 응용프로그램을 개발하게 될 것 같다고 응답하였다. 그리고 14개 기업 중에 10개 기업은 PC에 미디어 플레이어가 존재한다는 것이 어떤 기술로 응용프로그램을 개발할 것인가를 결정함에 있어 가장 또는 두 번째로 중요한 요소라고 응답하였다.[97]

결국, 피심인들이 PC 운영체제에 WMP를 포함시켜 발생하는 편재성은 소프트웨어 개발자로 하여금 WMP의 인터페이스를 이용하여 응용프로그램을 개발하도록 하는 강력한 동기를 제공하였고 이는 WMP의 시장점유율을 높이는 중요한 요인이 된 것으로 인정된다.

③ 디지털 미디어 시스템 구성요소간 상호의존성에 따라 WMP로의 쏠림현상을 심화시킨다.

㉮ 디지털 미디어 시스템 구성요소간에는 기술적 상호호환성이 존재한다.

디지털 미디어 시스템 구성요소 간에 존재하는 상호의존성은 구성요소 상호간 서로의 효용을 배가시켜 어느 한 구성요소의 사용증가가 다른 구성요소의 사용 확산을

97) EC 결정문 892~896항 참조

초래한다. 이는 콘텐츠 제공업자 및 소프트웨어 제공업자에게 WMP 포맷으로 콘텐츠를 제공하도록 하고, WMP의 인터페이스에 의존하는 응용프로그램으로 제품을 개발하도록 하여 쏠림현상을 더욱 촉진시키게 된다.

이는 스트리밍 미디어 서비스를 제공함에 있어 WMS와 WMP의 결합은 강한 기술적 의존성을 가지고 있다는 사실에서 확인할 수 있는데 디지텔 미디어 시스템 구성요소간의 기술적 상호의존성에 대한 구체적인 내용은 2. 라. (다) 2) 다)에서 이미 살펴본 바와 같다.

㈏ 디지털 미디어 시스템간의 기술적 상호호환성에 대한 시장조사 분석결과

실제 시장에서는 디지털 미디어 시스템간의 기술적 상호호환성에 의해 콘텐츠 사업자가 WMS를 사용하는 경우에는 거의 예외 없이 항상 WMP를 사용자 측의 미디어 플레이어로 지정하고 있는 것이 현실이다. 이는 피심인이 2005. 7. 14. 제출한 국내 상위 40개 웹사이트 조사결과 및 2005. 8. 10. 한국소프트웨어 진흥원이 실시한 120개 웹사이트 조사 결과를 통해서 확인되고 있는데, 이에 대한 구체적 내용은 2. 라. (다) 2) 다)에서 이미 살펴본 바와 같다.

④ 시장조사 분석 결과는 시장에서의 쏠림현상 발생을 실증하고 있다.

㈎ 콘텐츠 시장 점유율 조사 분석 결과

복수 포맷으로 인코딩하는데 따른 추가비용은 앞에서 살펴본 바와 같이 미디어 플레이어 시장에서 WMP 포맷으로의 쏠림현상을 발생시키며, 이는 다음에서 보는 바와 같이 시장에서의 설문조사 결과 및 콘텐츠 시장점유율 조사 결과에서도 확인되고 있다.

첫째, 콘텐츠 서비스를 복수 포맷으로 제공할 경우 하나의 포맷으로 제공할 때에 비해 상당한 추가 비용이 발생한다는 사실은 한국소프트웨어진흥원의 '미디어 서버 사용현황 및 인식조사 보고서'(2004. 9. 10.)에서 확인할 수 있다. 설문조사 결과는 '잘모

름/무응답'을 제외한 응답업체 51개 중 42개 업체가 복수 포맷으로 서비스를 제공할 경우 하나의 포맷으로 제공할 때에 비해 25% 이상의 추가비용이 발생한다고 답변하였다. 특히, 그 중 14개 업체는 추가비용이 75% 이상 발생한다고 응답하였다.

또한, 피심인들이 2005. 7. 12. 위원회에 제출한 A의 진술서에서도 복수 포맷으로의 인코딩이 상당한 추가비용을 발생시킴을 알 수 있다. 즉, A는 진술서에서 "일단 하나의 포맷으로 인코딩하고 난 후에 추가적으로 다른 포맷으로 콘텐츠를 인코딩하게 되면, 한가지 포맷으로 인코딩하는 경우에 비하여 대략 70% 정도의 추가비용이 더 들어갑니다"라고 인정하였다.

위의 사실 등에 따라 시장에서는 콘텐츠의 포맷이 대부분 윈도우 미디어 포맷으로 쏠리게 되었는데, 이러한 사실은 시장에서의 포맷 사용 비율을 살펴보면 알 수 있다.

먼저, 피심인들이 2005. 7. 12. 제출한 국내 상위 40개 웹사이트의 스트리밍 미디어 포맷사용 현황을 살펴보면, <표 3-8>에서 보는 바와 같이 피심인들의 윈도우 미디어 포맷인 WMV와 WMA의 사용비율이 지배적임을 알 수 있다. 여기에서 오디오의 경우에 있어서는 MP3가 산업표준으로 인정되고 있음에도 불구하고 WMA의 사용률이 가장 많다는 것을 주목할 필요가 있다.

<표 3-8> 피심인 제출 40개 웹사이트의 스트리밍 미디어 포맷 사용 비율

	전체 사이트 수	사용 포맷별 사이트 수(복수사용 포함)
오디오 스트리밍	25	WMA: 14개 사이트 MP3: 9개 사이트 OGG: 7개 사이트
비디오 스트리밍	39	WMV: 34개 사이트 Divx: 8개 사이트 H.264: 6개 사이트 RM: 2개 사이트

* 출처: 피심인 의견서(2005. 7. 12)

또한, 리얼네트웍스가 2005. 10. 11. 제출한 랭키닷컴의 100개 웹사이트 조사결과

에 따르면, WMV, ASF, WMA 등 피심인 고유 포맷의 사용비율이 매우 높게 나타났다. <표 3-9>는 스트리밍 방식으로 오디오/비디오 서비스를 제공하는 웹사이트를 나타내는 바, 피심인 고유 포맷인 윈도우 미디어 포맷(WMV/WMA/ASF)으로 서비스를 제공하는 사이트가 무려 94개에 이른다.

<표 3-9> 100개 웹사이트 스트리밍 포맷별 사용비율

스트리밍 포맷	사용비율
WMV/WMA/ASF	94/100
MPEG(mp3 등)	11/100
OGG VORGIS	8/100

* 중복사용으로 합계는 100%를 초과
* 출처 : 리얼네트웍스 제출

이에 더하여 한국소프트웨어진흥원이 2005. 8. 10.부터 같은 해 9. 9.까지 국내 방송·미디어, 온라인 영화, 포털, 음악의 4개 카테고리별로 각각 상위 30개 사이트를 조사한 국내 120개 웹사이트 조사결과[98](2005. 11. 7.)에서도, <표 3-10>에서 보는 바와 같이 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 81개 사이트 중 80개 사이트가 WMV, ASF 등 윈도우 미디어 포맷을 사용하여 그 점유율이 무려 98.8%에 해당한다.

<표 3-10> 스트리밍 비디오 포맷 점유율

포맷	WMV/ASF	AVI/AVI(H.264)/ AVI(divx)/EBS(H.264)	MPEG	RM
방송사이트	23/23	4/23	1/23	0/23
영화사이트	23/24	2/24	0/24	0/24
포털사이트	8/16	4/19	0/19	1/19
음악사이트	15/15	0/15	1/15	0/15
합계(%)	80/81(98.8)	10/81(12.3)	2/81(2.5)	1/81(1.5)

* 포맷을 복수로 사용하는 사이트들이 있어 합이 맞지 아니함
* 출처 : 한국소프트웨어진흥원 제출

98) 「한국소프트웨어진흥원의 본 연구결과는 대구산업정보대학의 이문희 교수가 2005. 8. 10.부터 9. 9.까지 국내 방송/미디어, 온라인 영화, 포털, 음악의 4개 카테고리별로 각각 상위 30개 사이트를 조사, 분석한 결과이다. 이는 피심인의 상위 40개 웹사이트 조사와 동일한 방법을 채택하고 조사한 것으로서 조사 대상 사이트는 인터넷 사용행태에 관한 전문조사기관인 코리안클릭이 분류한 방송/미디어, 온라인 영화, 포털, 음악의 4개 카테고리별로 2005. 7. 순방문자 수를 기준으로 산정되었다.

또한, 오디오 스트리밍 서비스를 제공하는 46개 사이트 중 30개 사이트 즉, 65.2%가 스트리밍 오디오 포맷으로 WMA, ASF 등 윈도우 미디어 포맷을 사용하여 서비스를 제공하고 있다[99].

<표 3-11> 스트리밍 오디오 포맷 점유율

포맷	WMA/ASF	MP3	OGG
방송사이트	9/11	2/11	0/11
영화사이트	0/1	1/1	0/1
포털사이트	8/16	4/16	5/16
음악사이트	13/18	5/18	4/18
합계(%)	30/46(65.2)	12/46(26)	9/46(19.6)

* 포맷을 복수로 사용하는 사이트들이 있어 합이 맞지 아니함
* 포털사이트 중 1개 사이트는 포맷을 확인할 수 없어 제외됨
* 출처 : 위원회 미디어 플레이어 설문조사 결과(2004. 8.)

㈏ 미디어 플레이어 시장점유율 조사 분석 결과

피심인들의 결합판매로 인해 국내 미디어 플레이어 시장에서 WMP의 시장점유율이 급격히 상승하여 경쟁사업자들이 시장에서 축출되어 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한한다는 사실은 위원회의 미디어 플레이어 시장조사 자료 및 피심인 제출자료를 통하여 확인할 수 있다.

위원회가 2004. 8. 실시한 미디어 플레이어 설문조사에 따르면, <표 3-12>에서 보는 바와 같이 전체 응답자 1000명의 60.5%가 인터넷에 접속하여 실시간으로 음악이나 동영상 서비스를 이용할 때 주로 WMP를 이용한다고 답변하였으며, WMP 및 WMP의 구성요소를 이용한 미디어 플레이어(소위 WMP 아류)의 점유율은 78.3%에 이른다. 한편, EC에서와 같이 비디오만 분석하면 윈앰프[100]가 빠지고, 따라서 그 비율은 더 높아진다. 특히, 직접적 경쟁관계에 있는 원천기술 사업자만의 미디어 플레이어 점유율은 WMP가 무려 89%를 차지함으로써 국내 미디어 플레이어 시장에서 이미 WMP의 시장점유율이 압도적임을 알 수 있다.

99) 참고로, EC는 결정문에서는 비디오와 오디오 포맷을 모두 조사한 위원회와 달리 비디오 포맷만을 조사대상으로 하였다.(EC 결정문 927~942항)

100) 윈앰프는 2005년 하반기부터 비로서 스트리밍 기능을 본격적으로 제공하기 시작하였다.

<표 3-12> 주 사용 스트리밍 미디어 플레이어 현황(%)

	WMP	윈앰프	아드레날린	리얼플레이어	곰플레이어	서비스업체 제공	기타
점유율	60.5	16.6	1.2	5.0	2.3	13.7	0.7
WMP (WMP 구성 요소를 이용한 미디어 플레이어 포함)	78.3			5.0	2.3	13.7	0.7
원천기술 사업자[101]	89.2	-	-	7.4	3.4	-	-

* 출처 : 위원회 미디어 플레이어 설문조사 결과(2004. 8.)

이러한 사실은 피심인들이 2005. 7. 11. 위원회에 제출한 의견서에 첨부된 “심사보고서의 디지털 미디어 기술 경쟁봉쇄 주장에 관한 경제분석”에서도 확인할 수 있다. 이 경제분석 보고서는 국내 상위 국내 상위 23개 미디어 플레이어의 사용자 점유율[102]을 분석하고 있는데, 이에 따르더라도 WMP의 사용자 점유율은 61%[103]에 이른다.

그러나, 피심인들의 제출자료는 다음과 같은 문제점이 있어 그 점유율 수치에 신빙성이 떨어진다고 인정된다.

첫째, 피심인들의 자료는 해당 플레이어가 스트리밍으로 사용되는지 아니면 다운로드로 사용되는지의 여부가 구분되어 있지 아니하여 스트리밍 미디어 플레이어의 실제 사용 데이터로 보기 어렵다. 예를 들어, 랭킹 4위로 되어 있는 ‘소리바다 파도’는 스트리밍 기능이 없는 다운로드 전용 플레이어이므로 피심인들 의견서의 사용자 데이터는 오로지 다운로드 사용 데이터로서 스트리밍으로 사용된 데이터가 아니다. 또한, 피심인들이 자주 인용하는 ‘곰플레이어’ 등의 자료 역시 다운로드와 스트리밍이 혼합되어 있는 자료이므로 이를 스트리밍 미디어 플레이어의 시장점유율 산정의 직접 증거로 삼기 곤란하다. 더욱이 중앙리서치의 미디어 플레이어 설문조사 결과에 따르면, ‘곰플레이어’의 경우 다운로드용으로 주로

101) 곰플레이어를 원천기술사업자로 분류한 것임

102) “사용자 점유율”이란 전체 미디어 플레이어 사용자 중 해당 미디어 플레이어를 이용하는 사용자의 비율을 의미한다.

103) 코리안 클릭의 2005. 5. 자료를 인용하고 있는데. 조사결과 WMP의 사용자 점유율이 61.9%, 윈앰프 36.04%, 곰플레이어가 35.63%, 소리바다 파도 26.36%, 벅스플레이어 24.17%에 달함

사용한다는 응답이 전체 조사 대상자(1000명)의 61.2%에 해당하였다는 점은 이러한 사실은 잘 보여준다.[104]

둘째, 위 피심인들 자료의 미디어 플레이어 중 상당수가 오디오 전용 플레이어로서 비디오 재생 기능을 가지고 있지 않다. 시장획정 부분에서 이미 살펴본 바와 같이 오디오만을 재생할 수 있는 미디어 플레이어는 WMP에 대하여 제한적인 대체성 만을 가지고 있을 뿐이다. 윈앰프, 소리바다 파도, 벅스 플레이어, 멜론 플레이어, 네이버 뮤직플레이어 등이 이에 해당한다.

셋째, 피심인들 의견서에 따른 상위 23개의 미디어 플레이어에는 명칭만 다르지 그 자체가 WMP이거나, 2차 미디어 플레이어가 대부분이어서 사실상 WMP와 경쟁관계가 제한되어 있는 미디어 플레이어들이 대부분이다.

먼저, WMP 기반 html 플레이어로서 사실상 WMP 아류인 것으로 '터치 플레이어', 'KBS VOD 플레이어', '벅스 뮤직비디오 플레이어', '맥스 웹플레이어', '케익박스', '비트박스' 등이 있다. 이들은 이미 앞의 "시장획정"에서 본 바와 같이 사실상 WMP로서 사용자 점유율 산정에 있어서 합산하여 계산하여야 한다. 이를 감안하면 WMP의 사용자 점유율은 무려 70%에 해당하게 됨을 알 수 있는데, 이는 피심인들 제출자료(2005. 7. 11)인"심사보고서의 디지털 미디어 기술 경쟁봉쇄 주장에 관한 경제분석(류근관, 유진수, 이상승)"의 [표 A-12. "WMP와 피어링포털의 테크놀로지에 기반한 html 플레이어"도 WMP에 포함시켰을 때의 우리나라의 상위 16개 미디어 플레이어(2005. 5.)]에서 확인할 수 있다.

다음으로, 위 피심인들 의견서에서 인용된 미디어 플레이들의 상당수는 원천기술 사업자와 스트리밍 기술 차원에서 경쟁할 수 없는 2차 미디어 플레이어이다. 즉, 피심인들 의견서에서 열거된 미디어 플레이어 중에서 원천기술 사업자의 미디어 플레이어는 WMP, 곰플레이어, 리얼플레이어가 있을 뿐이다. 특히, 2차 미디어 플레이어 중 윈앰프, 아드레날린, KMPlayer, 뮤직온, 버디뮤직 플레이어, 맥싱플레이어 등은 WMP 컴포넌트를 이용하는 WMP 아류에 해당한다. 이러한 WMP 아류는 피심인들의 윈도우

104) 심사보고서의 첨부자료 중 나. 중앙리서치의 미디어 플레이어 설문조사 결과 27면

미디어 포맷 및 윈도우 미디어 기술을 실행하는데 이용됨은 물론 기술적으로 WMP에 종속적인 성격을 갖는다는 점은 이미 앞에서 살펴본 바와 같다. 따라서, 이들 플레이어는 쏠림현상 부분에서 제한적으로 분석되어야 한다.

다) 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에 진입장벽을 구축한다.

피심인들의 결합판매행위는 잠재적 진입기업이 직면하는 미디어 플레이어 시장의 규모를 축소시켜 미디어 플레이어 시장에 대한 진입장벽을 높인다.

2004. 7. 19. 위원회가 실시한 미디어 플레이어 설문조사 결과에 의하면 전체 조사대상 1000명 중 49.1%인 491명이 미디어 플레이어나 관련 코덱을 인터넷에서 다운로드 받아 설치해 본 경험이 없다고 응답하였고, 이들 중 61.1%는 그 이유로 지금 설치된 것만으로 충분해서라고 응답하고 있다. 이런 상황에서 거의 모든 PC 운영체제에 WMP가 미리 탑재되는 것은 소비자들이 추가로 설치하고자 하는 미디어 플레이어의 수가 크게 줄어드는 것을 의미한다. 이는 미디어 플레이어 시장에 진입하려는 잠재적 진입기업이 직면하는 미디어 플레이어 시장의 규모가 축소[105]되는 것이다. 잠재적 진입기업들은 시장규모 축소에 따라 그들의 기대수익이 감소하는 것을 발견하고 결국은 진입을 꺼리게 될 것이다.

이러한 부상품 시장의 진입장벽은 특히 주상품 시장에서 독점력을 가진 기업이 결합판매 행위를 하는 경우에 더욱 강하게 되는데, 이는 초기 연구투자개발비용이 큰 반면 한계비용은 사실상 0에 가까운 소프트웨어 산업의 특성과도 관련된다. 즉, 주상품 시장의 독점 사업자는 결합판매 형태의 판매를 통해 주상품 시장의 독점력을 바탕으로 부상품의 초기개발비용을 회수할 수 있는 반면, 독점사업자의 결합판매에 직면하는 신규진입자는 초기 연구투자 개발비용도 회수할 수 없기 때문에 부상품 시장의 신규 진입이 저지되는 효과가 발생하게 되는 것이다.

한편, 미디어 플레이어 시장에 대한 진입장벽은 DMS 구성요소간의 상호의존성에

105) 「권명중・정찬모, 위원회 연구용역보고서 : “지식기반경제시대의 산업구조 변화와 경쟁정책의 방향(2000. 11.)」 231쪽~232쪽

의해 더욱 강화된다. 왜냐하면 신규사업자가 스트리밍 미디어 플레이어 시장에 유효하게 진입하기 위해서는 DMS 전체 시장에 동반 진입하는 것이 필수적이나 피심인들이 스트리밍 미디어 플레이어 시장을 봉쇄하고 진입장벽을 높이고 있어 신규 사업자가 동 시장에서 WMP와 유효하게 경쟁하는 것을 사실상 어렵게 하기 때문이다.

2) 피심인들의 결합판매 행위는 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업 활동을 방해한다.

가) 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에서 리얼네트웍스 등 경쟁사업자의 사업 활동을 어렵게 한다.

① 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에서 경쟁사업자를 배제하고 있다.

㉮ 피심인들의 결합판매 후 WMP의 시장점유율이 급격히 상승하고 경쟁사업자의 시장점유율이 급격히 하락하고 있다.

미디어 플레이어 시장에서 결합판매로 인한 시장점유율의 급격한 변화는 소비자들이 주로 이용하는 미디어 플레이어가 무엇인지를 측정함으로써 직접 알아볼 수 있다. 이에 대한 조사 자료로는 피심인들의 내부 자료와 위원회가 최근 실시한 미디어 플레이어 설문조사 자료 등이 있다.

우선, 피심인들이 2000. 12., 2001. 3. 및 2001. 8. 전화설문 방식으로 실시한 조사 결과에 따르면, <표 3-13>에서 보는 바와 같이 당시에는 WMP와 리얼플레이어가 비슷하거나 오히려 리얼플레이어가 다소 높은(리얼쥬크박스도 리얼플레이어의 일종으로 포함시킬 경우) 시장점유율을 보이고 있었다. 즉, 이 시기에는 두 미디어 플레이어의 시장점유율이 비슷한 수준이라고 볼 수 있다.

<표 3-13> 피심인들이 조사한 미디어 플레이어 사용률 변화추이(국내)

(단위 : %)

구분	WMP	리얼	윈앰프	리얼 쥬크박스	야후	퀵타임	파도/ 소리바다
2000. 12.	39.4	37	14.4	-	1.9	0.05	-
2001. 3.	53.5	51.2	30.5	18.5	7.2	4	-
2001. 8.	67	65.5	49.5	27	8.8	10	51.8

* 출처 : 피심인들 제출자료(복수사용자 포함)

그런데 피심인들의 조사시기로부터 약 3년 후에 위원회가 다시 조사한 결과는 확연히 다른 점유율을 보인다. 즉, 위원회가 2004. 8.에 실시한 미디어 플레이어 설문조사에 따르면, 전체 응답자의 60.5%가 인터넷에 접속하여 실시간으로 음악이나 동영상 서비스를 이용할 때 주로 WMP를 이용한다고 응답한 반면에, 그 다음으로 윈앰프가 16.6%이며 리얼플레이어를 주로 이용한다는 응답은 겨우 5%에 불과하였다. 즉, 최근 2000. 12.부터 2004. 8.까지 3년 사이에 피심인들 미디어 플레이어의 시장점유율이 급격히 상승하고 가장 주요한 경쟁사업자였던 리얼플레이어의 시장점유율이 급격히 하락하는 변화가 생긴 것이다.

<표 3-14> 국내 미디어 플레이어 시장점유율(2004. 8.)

(단위 : %)

구분	WMP	윈앰프	서비스업체 제공 소프트웨어	리얼 플레이어	곰 플레이어	아드레 날린	기타
시장점유율	60.5	16.6	13.7	5.0	2.3	1.2	0.7

* 출처 : 위원회의 미디어 플레이어 설문조사

이 조사에서는 “미디어 플레이어”의 범위에 2차 미디어 플레이어 사업자가 공급하는 미디어 플레이어 및 오디오 전용플레이어도 포함시켰다. 그러나 결합판매의 경쟁제한성은 서로 직접 경쟁관계에 있는 원천기술 보유 사업자의 미디어 플레이어 간에서 파악하는 것이 보다 정확하게 된다. 이러한 관점에서 조사결과를 가공하면 WMP의 시장점유율은 90% 이상이 되어 경쟁제한 효과가 더욱 명확해진다.

또한 최근 한국소프트웨어진흥원이 2005. 11. 7. 수행한 국내 120개 웹사이트 조

사결과에서도, 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 81개 업체 중 무려 78개 업체(96.3%)가 스트리밍 미디어 플레이어로 WMP 또는 WMP기반 html 플레이어를 지정한 것으로 나타났는바, 이는 2004. 8. 조사보다도 훨씬 높아진 비율이다.

<표 3-15> 비디오서비스에 대한 스트리밍방식의 지정 미디어 플레이어 현황

	지정 미디어 플레이어							
	Windows Media Player	WMP 기반의 HTML 플레이어	WMP 및 피어링 포털 기술 기반의 HTML 플레이어	Turbo Player	SeeVideo Player /SeeLive Player	SM2 Player	Gom Plsyer	Real Player
방송사이트		22/30	1/30	3/30	2/30	1/30		
영화사이트	4/30	19/30			1/30	1/30		
포털사이트	4/30	15/30		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
음악사이트		14/30	2/30					
합계(해당업체/총웹사이트)	8/120	70/120	3/120	4/120	4/120	3/120	1/120	1/120
합계(단위: %)	6.7	58.3	2.5	3.3	3.3	2.5	0.8	0.8
합계(해당업체/스트리밍방식 사용업체)	8/81	70/81	3/81	4/81	4/81	3/81	1/81	1/81
합계(단위: %)	9.9	86.4	3.7	4.9	4.9	3.7	1.2	1.2

* 출처: 한국소프트웨어진흥원(2005. 11. 7)
* sbs.co.kr 처럼 한 사이트에서 여러 솔루션이 사용되는 경우도 있으며, 이런 경우 각각 합산하였다.

참고로, 위 120개 웹사이트 조사결과에서 오디오 스트리밍의 경우에도 이러한 서비스를 제공하는 46개 업체 중 29개 업체(63%)가 스트리밍 미디어 플레이어로 WMP 또는 WMP기반 html 플레이어를 지정하고 있다.

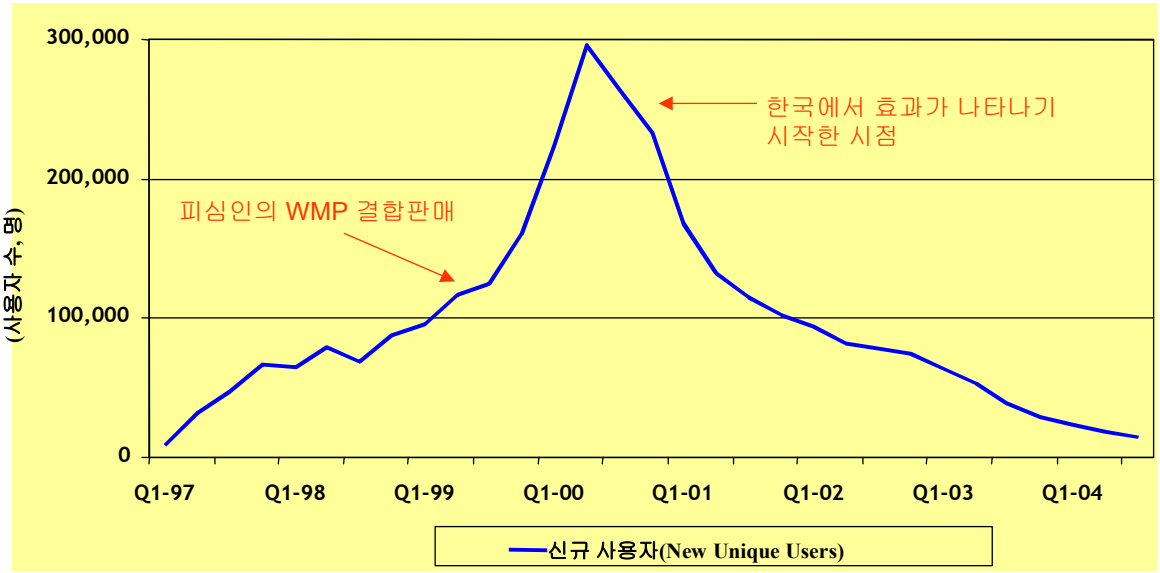
㉯ 구체적인 경쟁사업자 배제 사례

피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에서 경쟁사업자의 사업활동을 어렵게 하여 시장에서 경쟁사업자를 배제하는 효과를 초래하고 있는데 이는 다음의 사례를 통해서 확인되고 있다.

아래 그림은 한국시장에서 리얼네트웍스 신규가입자의 변화추세를 나타내고 있

는데, 이 변화추세는 피심인들의 미디어 플레이어 결합판매 행위가 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 피심인들과 같이 원천기술을 보유하여 DMS시장에서 대등하게 경쟁하고 있던 경쟁사업자를 배제할 우려가 실제 시장에서 나타나고 있다는 사실을 뒷받침하고 있다.

<그림 3-9> 한국시장에서 리얼플레이어 신규사용자의 변화추이('97.-'04.)



Notes: 1. "사용자"는 전자우편 주소에 kr이 포함된 자로 정의한다. 리얼네트웍스는 사용자가 분명한 전자우편 주소를 갖고 있을 경우 "유니크" 사용자라고 명명한다.
2. "유니크 사용자"는 반드시 리얼플레이어만을 사용할 것으로 기대하지 않는다.

*출처 : 리얼네트웍스 제출자료(2005. 1. 19.)

또한, 엔에이치앤(NHN)의 경우 자신의 포털사이트인 네이버에서 사용하고 있던 독자개발 미디어 플레이어인 터보플레이어를 2005. 7. WMP로 변경하였는데, 그 이유는 자사의 제품을 다운로드 받는 소비자의 불만, 윈도우 미디어 포맷으로의 쏠림현상이 나타난 상황에서 자사 제품으로의 전환에 따른 판매비용의 부담 등을 들고 있다[106].

다음으로, 그래텍 역시 NHN과 마찬가지로 곰솔루션에 대한 판매를 사실상 중단하고 있다. 즉, 그래텍의 곰솔루션 공급은 2004년 16개업체에서 2005년 9개업체로 줄어들고 있으며, 향후에도 솔루션 판매사업을 적극적으로 진행할 계획이 없다고 하였다. 그리고 그 이유에 대해 타사의 무료 미디어 솔루션 공급 등으로 솔루션 판매부분의 사업성이 검증되지 못하였기 때문이라고 답하였다.[107] 이는 결국 피심인들의 결합판매로 인해 경쟁사업자들이 시장에서 배제되는 경쟁제한 효과가 발생하고 있음을 실증하는 사례라 할 것이다.

106) NHN 제출자료(2005. 9. 12.)

107) 그래텍 제출자료(2005. 9. 12.)

② 피심인들의 결합판매는 경쟁사업자를 시장에서 배제하는 원인이다.

피심인들의 결합판매 행위는 앞에서 살펴본 바와 같이 WMP로의 쏠림현상을 초래하고 DMS 구성요소간의 상호의존성에 의해 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 더욱 제한하고 있다. 또한, 피심인들의 결합판매 행위로 인해 WMP의 시장 점유율이 급격히 상승하고 경쟁사업자들이 미디어 플레이어 시장에서 배제되는 결과를 초래하였다.

이러한 현상은 2004. 7. 19. 중앙리서치가 실시한 미디어 플레이어 설문조사 등을 고려할 때 WMP의 성능이 우수하기 때문이 아니라 피심인들의 결합판매 행위로 인한 부당한 경쟁상 우위에 기인한 것으로 판단된다.

미디어 플레이어 설문조사에 따르면, 주사용 미디어 플레이어를 변경한 적이 있다고 답변한 응답자들을 대상으로 그 변경이유를 문의한 결과, 기타 미디어 플레이어를 사용하다가 WMP로 전환한 응답자들은 '사용하기 편리해서'가 32.8%, '음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서'가 15.5%임에 반해, WMP에서 기타 미디어 플레이어로 전환한 응답자들은 '사용하기 편리해서'가 44.1%, '음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서'가 17.8%에 이른다. 이러한 사실은 곧 WMP가 다른 미디어 플레이어와 비교하여 성능이나 기능면에서 최소한 우월한 제품은 아니었음을 나타내고 있다.

또한, 앞으로 보편화될 것으로 예상되는 미디어 플레이어 및 그 이유를 제시해 달라는 질문에 대해 <표 3-15>에서 보는 바와 같이 WMP가 보편적으로 사용될 것이라는 이유로 '컴퓨터에 원래 설치되어 있어서'라고 응답한 비율이 무려 82.5%에 달하는데 비해, '성능이 우수해서'가 26%, '음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서'가 19.4%, 그리고 '사용하기 편리해서'는 0.6%에 불과하였다. 이와 대조적으로 다른 미디어 플레이어가 보편화될 것으로 응답한 사람들은 보편화 이유로 '성능이 우수해서', '음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서'라고 응답한 비율이 대체로 50%를 상회하는 것으로 나타났다.

위 조사결과를 다시 원천기술 보유 사업자의 미디어 플레이어에 한정하여 살펴보면, 리얼네트웍스의 리얼플레이어는 '컴퓨터에 원래 설치되어 있어서'라는 이유가

33.3%로서 WMP의 절반에도 미치지 못하였다. 그에 반해 '성능이 우수해서'는 WMP의 2배가 넘는 58.8%, '음질이나 화질 등 기능이 뛰어나서'는 WMP의 2배가 훨씬 넘는 49.0%에 달하였다.

위와 같은 사실은 곧 WMP가 보편적으로 널리 사용되는 이유가 성능이나 기능의 우수성 등 능률경쟁에 의한 것이 아니라 '컴퓨터에 원래 설치되어 있으며 그에 따라 접근가능성이 크다'는 결합판매행위에 기인한 것임을 보여주는 것이다.

<표 3-16> 미디어 플레이어별 보편화 이유(중복응답)

(단위 : %)

구분	전체	WMP	윈앰프	아드레날린	곰 플레이어	리얼 플레이어	KM 플레이어	퀵타임
응답자수(명)	993	527	189	113	102	51	7	3
컴퓨터에 원래 설치되어 있어서	52.6	82.5	23.8	8.0	13.7	33.3	14.3	33.3
그 소프트웨어로 볼 수 있는 파일형식이 많아서	46.4	47.4	49.2	49.6	43.1	25.5	57.1	33.3
성능이 우수해서	42.2	26.0	56.1	68.1	63.7	58.8	42.9	33.3
음질 등 기능이 뛰어나서	35.9	19.4	53.4	59.3	55.9	49.0	42.9	33.3
콘텐츠 제공업체에서 그 소프트웨어로 보도록 설정해서	19.3	22.0	15.3	14.2	13.7	27.5	14.3	33.3
사용하기 편리해서	1.1	0.6	1.6	0.0	3.9	0.0	14.3	0.0

* 출처 : 위원회 미디어 플레이어 설문조사 결과(2004. 8.)

참고로, EC에서도 각종 컴퓨터 관련 잡지[108]에서 여러 미디어 플레이어를 비교한 자료들을 인용하고 있는데, 피심인들의 WMP를 가장 우수한 미디어 플레이어라고 평가한 경우는 상대적으로 적음을 알 수 있다.[109]

피심인들과 다른 미디어 플레이어 사업자의 시장점유율 분포를 결정하는데 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 위에서 살펴 본 가격과 성능 외에 제품의 판매전략, 수요자 성향의 변화 등 다양한 요인을 고려할 수 있다. 그런데 이들 중 피심인들의 결합판매 후에 크게 달라진 것은 피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 WMP를 결합하는 판매행태 외에는 없는 것으로 보인다.

108) 피시 메거진, 피씨 월드, 피씨 컴퓨팅, CNET.com 등

109) EC 결정문 제949항

결국, 피심인들의 결합판매 행위로 다른 경쟁사업자들은 시장점유율이 감소되며 가격 및 품질에 의한 경쟁이 제한되어 미디어 플레이어 시장에서 배제되는 등 사업활동이 부당하게 방해받고 있는 것이다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 PC 운영체제 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 WMP를 원하지 않는 거래상대방에 대하여 그 구입을 강제하는 결과를 초래하므로 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래를 강제한 행위이다. 또한 이러한 WMP의 구입강제는 WMP의 편재성을 초래하여 미디어 플레이어 시장에서 경쟁을 제한함으로써 다른 경쟁사업자를 배제하거나 신규 사업자의 시장진입을 방해하는 결과를 초래하므로 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위이다. 따라서, 피심인들의 행위는 자기의 시장지배력을 이용하여 부당하게 거래상대방에 대하여 불이익이 되는 거래를 강제함으로써 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 시장지배적 지위남용 행위로서 공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호에 해당한다.

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지) 제1항 제5호의 규정취지나 이에 해당하기 위한 요건 및 명확성의 원칙에 반하여 위헌이라는 피심인들의 주장에 대한 판단 등에 관하여는 위 2. 마. (1) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 운영체제 시장에서 시장지배적사업자이다.

피심인들이 PC 운영체제 시장에서 공정거래법 제2조 제7호, 제4조에 의한 시장지배적사업자라는 사실은 위 3. 라. (2) (가) 에서 살펴본 바와 같다.

(나) 피심인들의 결합판매 행위는 부당한 행위이다.

피심인들의 윈도우 PC운영체제와 WMP가 별개제품임에도 불구하고 피심인들이 이를 결합하여 판매한 행위는 WMP를 원하지 않는 소비자에게 그 구입을 강제하는 부당한 행위라고 인정된다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 WMP는 별개제품이다.

WMP가 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니라 독립하여 거래의 대상이 될 수 있는 별개의 상품이라는 사실에 관하여는 위 3. 라. (2) (나) 1) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들의 행위는 WMP를 원하지 않는 소비자에게 WMP의 구입을 강제한 부당한 행위이다.

피심인들의 행위가 거래상대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 부당한 행위라는 사실은 위 3. 라. (2) (나) 2) 에서 살펴본 바와 같다.

(다) 피심인들의 결합판매 행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

피심인들이 윈도우 PC운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개 제품인 WMP를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로, 단기적으로 소비자의 상품 선택권을 침해함은 물론 중장기적으로 부상품 시장인 미디어 플레이어 프로그램 시장에서 품질 및 가격에 의한 경쟁을 제한하여 소비자의 후생을 감소시키므로, 공정한 경쟁과 혁신을 통하여 소비자가 얻을 수 있는 권익을 누릴 수 없게 하는 행위인 바, 이러한 피

심인들의 행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위이다.

1) 피심인들의 행위는 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한함으로써 소비자의 이익을 저해할 우려가 있다.

위 3. 라. (2) (다) 1) 에서 살펴 본 바와 같이 피심인들의 결합판매행위는 WMP의 편재성을 발생시켜 미디어 플레이어 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 하고, 사용자에 대한 접근성과 이용가능성을 증대시켜 소비자들이 WMP를 더욱 많이 선택하게 하는 결과를 초래한다. 이러한 경쟁제한 효과는 미디어 플레이어 시장에서 피심인들의 미디어 플레이어인 WMP의 시장점유율을 비약적으로 높여 기술적으로 우수하거나 동등한 기업들을 시장에서 부당하게 축출하거나 사업활동을 방해하고, 신규 사업자가 시장에 진입하는 것에 대한 장벽을 형성한다.

이는 장·단기적으로 소비자들의 후생을 감소시켜 소비자의 이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있다.

경쟁이 제한된 시장에서 소비자의 이익이 어떻게 저해될 우려가 있는지는 운영체제 시장에서의 피심인들의 가격 추이와 하드웨어 및 다른 경쟁 사업자의 운영체제 가격의 추이를 살펴 보면 알 수 있는데 구체적 내용은 2. 마. (2) (다) 에서 살펴 본 바와 같다.

2) 결합판매행위는 소비자들의 미디어 플레이어에 대한 상품 선택권을 침해한다.

피심인들은 WMP를 구입할 의사가 없는 소비자에게 WMP없는 윈도우 PC운영체제를 구매할 선택의 여지를 제공하지 않았다. 즉, 피심인들은 소비자들이 WMP를 구입하지 아니하고서는 PC운영체제 시장의 독점적 제품인 자신의 윈도우 PC운영체제를 구입할 수 없도록 하였는바, 이는 자신의 선호에 따라 다양한 제품을 선택할 수 있는 소비자의 권리를 침해한 것이다.

이는 PC 제조업체가 미국 연방지방법원에서의 2002년 동의심결에 따라 WMP의 아이콘을 삭제하거나 자신이 원하는 다른 미디어 플레이어를 탑재하여 판매할 수 있다고 하여도 마찬가지이다. 왜냐하면, PC 제조업체가 자신이 원하는 다른 미디어 플레이어를 기본 프로그램으로 설정하여 소비자에게 판매하는 경우에도 PC 제조업체는 피심인과의 라이센스 계약에 의해 윈도우 PC 운영체제에서 WMP를 완전히 제거할 수 없고, 단지 WMP의 아이콘만 없앨 수 있기 때문이다.

또한, 피심인들의 결합판매 행위는 WMP없는 PC 운영체제의 선택권을 소비자들로부터 박탈한 것 외에도, 다양한 미디어 플레이어 제품들 중에서 자신이 선호하는 제품을 자유롭게 선택할 수 있는 소비자의 권리도 제한하고 있다. 실제 상당수의 소비자가 WMP가 윈도우 PC운영체제에 기본 설치되어 있다는 이유로 WMP를 선택하고 있다는 사실, 그리고 이에 따라 WMP의 경쟁 미디어 플레이어들이 점차 시장에서 배제되고 있다는 사실은 이미 앞서 살펴본 바와 같다. 이러한 경쟁제한적 효과로 인하여 소비자들은 품질이나 기능 등이 우수한 제품을 선택할 범위가 현저히 축소되고 이는 결국 소비자들의 이익이 저해되었음을 의미한다.

3) 결합판매로 인한 경쟁제한 효과 유발은 기술 혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

피심인들의 결합판매 행위는 미디어 플레이어 시장에서 경쟁을 제한하고, 진입장벽을 형성하여 신규진입자가 시장에 진출하는 것을 매우 어렵게 한다는 사실은 이미 앞에서 살펴 본 바와 같다.

이는 피심인들이 미디어 플레이어 시장에서 품질 등 제품 자체에 의한 경쟁을 할 필요가 없다는 것을 의미[110]한다. 왜냐하면, 피심인들은 PC 운영체제의 시장지배력을

110) 노벨경제학상을 수상하기도 한 스티글리츠(Stiglitz) 교수가 본건 심의를 위하여 제출한 의견서에 따르면 결합판매로 인한 경쟁제한 효과는 다음과 같이 기술혁신을 저해한다고 한다. 먼저, 결합판매로 해당시장에서 독점적 지위를 구축한 사업자는 첫째, 독점으로 진입장벽을 높인 결과, 본인 스스로 기술혁신을 할 유인이 없어지게 되어 기술혁신을 저해하고, 둘째, 기술혁신을 하기는 하나, 소비자에게 이익이 되는 방향으로 하는 것이 아니라 해당시장에 대한 진입장벽을 높이고, 경쟁자의 비용을 증가시키는 방향으로 이를 하게 되며, 셋째, 기술혁신에 대한 독점적 사업자의 동기가 매우 제한적이어서 경쟁을 피하기 위한 낮은 수준의 혁신만을 꾀하게 되어 기술혁신을 저해하게 된다 할 것인바, 넷스케이프 사례는 위 세가지에 모두 해

이용한 윈도우 운영체제와 WMP의 결합판매를 통하여 언제나 경쟁사업자의 미디어 플레이어 제품과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있고, 우수한 제품이 시장에 진입하는 것도 막을 수 있기 때문이다.

피심인들이 결합판매 후 품질 경쟁을 할 필요가 없어 제품 개선을 하지 않아 기술 혁신을 저해한다는 사실은 과거 피심인들이 시장지배력을 보유한 PC 운영체제에 웹 브라우저인 인터넷 익스플로러를 끼워팔기한 사례 및 관련 전문가의 의견 등에 비추어 볼 때 그 가능성을 충분히 인정할 수 있는데, 이는 이미 위 2. 마. (2) (다) 부분에서 살펴 본 바와 같다.

이에 대해, 피심인들은 윈도우 운영체제에 새로운 기능을 추가하는 것은 소비자들에게 유익하기 때문에 소비자 이익을 저해하지 않는다고 주장한다. 특히 PC 초보자들은 PC를 처음 구입했을 때 바로 작동하기를 원하는 등 사용이 쉽기를 바란다고 한다. 이는 다음의 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, PC를 새로 구입하자마자 소비자들이 바로 응용프로그램을 접할 수 있도록 제품을 구성하는 것은 기본적으로 소비자의 선호를 보다 잘 파악할 수 있는 PC 제조업체가 더 효율적으로 할 수 있는 것이다. 또한, PC 제조업체가 어느 미디어 플레이어를 탑재하여도 WMP를 기본탑재하는 경우와 동일한 효과가 발생하고 이는 보다 WMP 결합판매 보다 경쟁제한성이 적은 방식이 존재함을 의미하는 것이다. 따라서, 운영체제 시장을 독점하는 사업자가 응용프로그램을 결합판매하는 것은 소비자 선호를 반영한 PC 제조업체의 선택권을 박탈하고 소비자들이 자신의 지불능력을 감안하여 다양한 PC와 프로그램을 선택할 수 있는 기회를 빼앗는데 불과하다고 인정된다.

둘째, 피심인들도 인정한 바와 같이, 기술적 지식이 별로 없는 사람들은 PC를 처음 사용할 때 바로 접하는 미디어 플레이어나 메신저를 사용할 가능성이 매우 높은 것이 사실이다. 이들에게 거의 모든 PC에서 피심인들의 미디어 플레이어나 메신저가 처음부터 시현된다는 것은, 미디어 플레이어 경쟁사업자들이 획득할 수 없는 부당한 경

당될 수 있다고 하고 있다.

쟁상 우위라고 할 수 있다.

따라서, 피심인들이 윈도우 운영체제에 WMP를 결합하여 판매하는 행위는 부당하게 경쟁을 제한하여 WMP 시장에서 사실상 독점적 지위를 획득하고 이러한 독점적 시장구조는 기술혁신을 저해하여 사회적 손실을 야기할 우려가 있음을 인정할 수 있다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 PC 운영체제 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 WMP를 원하지 않는 소비자에게 그 구입을 강제하는 부당한 행위이고, 이는 소비자의 상품 선택권을 침해하고 또한 WMP의 편재성을 초래하여 스트리밍 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한함으로써 소비자 후생을 감소시키는 결과를 초래하는 등 부당하게 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위로서 공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 후단에 해당한다.

바. 불공정거래 행위의 거래강제 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제23조 제1항 제3호 및 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕에서 구체화한 끼워팔기의 규정취지나 이에 해당하기 위한 요건 등에 관하여는 위 2. 바. (1) 에서 살펴본 바와 같다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

피심인들이 WMP와 PC 운영체제가 별개제품임에도 불구하고 이를 결합하여 판매

함으로써 WMP를 원하지 않는 소비자에게 구입을 강제하는 행위는 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 행위로 인정된다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 WMP는 별개제품이다.

주된 상품과 종된 상품이 별개 상품인지 여부를 판단하기 위해서는 기능·성격의 차이와 수요가 동일한지 여부가 가장 중요한 판단기준이 되며, 종된 상품에 대한 별도의 공급자 존재, 동종업계의 거래관행 피심인들의 인식등도 종합적으로 고려하여 판단해야 하는바, WMP가 PC 운영체제와 별개의 제품이라는 사실은 3. 라. (2) (나) 1)에서 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들은 별개제품인 WMP를 부당하게 거래상대방에게 구입을 강제한 것이다.

피심인들의 행위가 거래상대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 것으로 부당한 행위라는 사실은 위 3. 라. (2) (나) 2) 에서 살펴본 바와 같다.

(나) 피심인들의 행위는 공정한 거래를 저해한다.

'공정거래저해성'의 의미나 이에 해당하기 위한 요건 등에 관하여는 2. 바. (2) (나)에서 살펴본 바와 같다.

1) 피심인들의 행위는 경쟁제한 효과를 발생시킨다.

피심인들의 행위는 WMP의 편재성을 발생시켜 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 하고, 사용자에 대한 접근성과 이용가능성 및 DMS 구성요소간의 상호의존성에 의해 WMP로의 쏠림현상을 초래하며, 미디어 플레이어 시장의 진입장벽을 높이는 등 경쟁제한 효과를 초래한다. 이에 대한 구체적인 내용은 3. 라. (2) (다) 1) 에서 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들은 주된 상품의 시장지배적지위를 이용하여 불공정한 거래조건 또는 거래수단을 사용한다.

소비자들은 원칙적으로 자신이 원하는 상품을 시장가격에 구입하는 것이 정상적이고 바람직한 거래관행이다. 이는 소프트웨어에 있어서도 마찬가지이다. 따라서 어떠한 상품을 구입하도록 강제하는 것은 정상적인 거래관행으로 보기 어렵다. 피심인들은 다른 PC 운영체제 사업자들도 모두 미디어 플레이어를 포함하여 판매하고 있고 이는 소프트웨어 산업에 있어 정상적인 거래관행에 해당한다고 주장한다.

그러나, 국내 PC 운영체제 시장의 99%를 차지하고 있는 피심인들이 WMP를 결합판매하고 있는 상황에서 다른 PC 운영체제 사업자의 거래관행을 논하는 것은 타당하지 못하다. 왜냐하면, 정상적인 거래관행이란 일반적으로 경쟁시장에서 기업간 경쟁을 통해 자연스럽게 형성되는 것이라야 의미 있는 것이기 때문이다.

피심인들의 끼워팔기는 PC 운영체제를 구매하는 모든 소비자들로 하여금 그들의 의사와 관계없이 피심인들의 WMP 프로그램을 구입하도록 강제한다는 점에서 거래조건 또는 거래수단의 불공정성이 매우 크다. 즉, 피심인들이 거의 100% 독점하고 있는 PC 운영체제에 WMP 프로그램을 끼워서 판매한 결과, PC 운영체제의 소비자들 중 WMP 프로그램을 원하지 않는 상당수의 소비자들도 이를 함께 구입할 수 밖에 없게 된 것이다.

이에 더하여, 피심인들은 WMP의 끼워팔기를 통하여 다른 미디어 플레이어 경쟁사업자가 어떠한 수단으로도 획득할 수 없는 불공정한 방법으로 경쟁상 우위를 가지게 되었다. 즉, 거의 절대적인 시장지배적지위를 갖고 있는 윈도우 PC 운영체제에 WMP 프로그램을 끼워서 판매함으로써 피심인들은 미디어 플레이어 시장에서 강한 편재성을 누리게 되었으며, 이에 따라 자연스럽게 미디어 플레이어 프로그램 시장의 점유율을 크게 높일 수 있는 경쟁상의 우위를 누린 것이다. 이와 같은 내용은 앞에서 이미 본 바 있다. 이와 같은 편재성이 미디어 플레이어 프로그램 시장의 경쟁질서에 미치는 효

과가 크기 때문에 경쟁사업자들이 우수한 품질과 저렴한 가격에 의하여 공정한 경쟁을 함으로써 극복할 수 있는 정도를 넘어선 것으로 인정된다. 즉, 미디어 플레이어 프로그램 시장에서의 경쟁사업자들이 가격과 품질에 의한 장점에 의한 경쟁(competition on the merits)을 할 수 있는 여지가 크게 제약된 것이다.

피심인들이 끼워팔기라는 불공정한 거래수단을 사용하는데 따라 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁이 왜곡되는 효과는 특히 피심인들이 PC 운영체제 시장에서의 독점적 사업자이기 때문에 더욱 증폭되어 발현되는 것으로 인정된다. 즉, 독점력을 갖고 있는 피심인의 불공정한 행위로 인하여 미디어 플레이어 프로그램 시장에서의 공정거래저해성이 더욱 커졌고, 그 결과 미디어 플레이어 프로그램 시장을 피심인들이 거의 독점하게 된 것이다.

3) 피심인들의 행위로 인한 효율성 증대효과는 미약하여 경쟁제한 효과를 능가하지 못한다.

피심인들이 PC 운영체제와 WMP의 결합판매가 유통비용 감소, 응용프로그램 개발 편의 등 효율성 증대효과가 있다고 주장하나 이는 다음의 점을 고려할 때 경쟁제한 효과를 능가하지 못한다.

가) 유통비용 등 거래비용이 감소된다는 주장에 대하여

첫째, 피심인들은 PC 운영체제에 WMP가 사전에 탑재되어 판매되는 결과 소비자에 대한 거래비용이 감소하는 효율성 증대효과가 발생한다고 주장한다. 그러나 이러한 거래비용 감소효과는 어떤 미디어 플레이어를 PC에 기본으로 탑재하더라도 동일하게 발생하는 것이며 WMP를 PC 운영체제에 기본 프로그램으로 탑재했을 때에 고유로 발생하는 효과는 아니다. 따라서, 동일한 효율성을 달성할 수 있고 상대적으로 경쟁제한성이 적은 방법이 있다고 인정되므로, 효율성 효과는 결합판매 고유의 효율성 효과로 인정하기 어렵다.

둘째, 피심인들은 WMP가 결합판매됨에 따라 별개의 제품으로 공급되는 경우 발생하게 되는 유통비용을 절감할 수 있다고 주장한다. 그러나 오늘날 소프트웨어 공급

과정에서 소요되는 유통비용은 미미하고, 소프트웨어 프로그램은 적은 노력으로도 복사되어 공급될 수 있다는 점을 감안하여야 한다. 또한 초고속 인터넷이 발달한 국내에서는 인터넷을 통한 다운로드를 통해서도 미디어 플레이어가 소비자들에게 효율적으로 공급될 수 있다. 결국, PC 운영체제에 WMP가 포함되어 공급됨으로써 절감될 수 있는 유통비용은 그 크기가 작은 수준인 것으로 판단된다.

<표 3-19>는 피심인들이 제출한 자료 중, WMP 다운로드 및 설치에 소요되는 시간을 정리한 표인데, 인터넷을 통해 다운로드 받아 설치하는데 소요되는 시간이 아주 작음을 알 수 있다.

<표 3-19> WMP를 다운로드 받는데 소요되는 시간

구분	윈도우 XP 용 (파일크기 : 9,660Kb)	윈도우 98 SE, Me 및 2000용 (파일크기 : 13,330Kb)
28.8Kbps (14Kbps)*	5분 36초 (11분 30초)	7분 42초 (12분 30초)
56.6Kbps (14Kbps)	2분 48초 (5분 18초)	3분 54초 (7분 24초)
2Mbps (540Kbps)	4.8초 (18초)	6.6초 (25초)
8Mbps (650Kbps)	1.2초 (13초)	1.7초 (18초)

* 괄호안의 속도는 실제 구현 속도를 상정한 경우임
* 출처 : 피심인 제출자료(2004. 8. 31.)

<표 3-20> 윈도우미디어 플레이어를 설치하는데 소요되는 시간

운영체제	CPU 종류	설치 소요시간
윈도우 XP	펜티엄(Pentium) Ⅲ	39초
윈도우 XP	펜티엄(Pentium) Ⅳ	31초
윈도우 98 SE	펜티엄(Pentium) Ⅲ	38초
윈도우 98 SE	펜티엄(Pentium) Ⅳ	33초

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 8. 31.)

이와 관련하여 피심인들은 WMP를 다운로드 하여 설치하는데 걸리는 시간이 매우 적어 결합판매에 따른 배포상의 효율성이 매우 작다고 판단하면서, 다운로드에 의해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다고 주장하는 것은 모순이라고 주장하고 있다.

그러나, 다운로드의 효율성과 결합판매의 효율성을 비교하기 위해서는 소비자가 다운로드 받을 미디어 플레이어를 선택했다는 전제하에 그 이후의 미디어 플레이어 설치에 드는 거래비용을 비교하여야 하므로 절약되는 거래비용의 크기가 상대적으로 적다고 인정된다. 반면, 결합판매의 편재성과 관련하여서는 소비자가 다운로드 받을 미디어 플레이어를 탐색하고 선택하는 전 과정을 모두 고려해야 하므로 앞에서 살펴본 바와 같이 다운로드 방식에 의해 WMP의 편재성을 극복할 수 없는바, 양 주장이 모순된다는 피심인들의 주장은 이유 없다.

나) 응용프로그램의 개발편의를 제공한다는 주장에 대하여

피심인들은 WMP가 제공하는 인터페이스를 이용하여 소프트웨어를 개발하게 되면 반복되는 코드(code) 작성의 수고가 감소하여 소프트웨어 개발자들은 전문적이고 상업적인 콘텐츠에 집중할 수 있게 되며 운영체제의 가치 또한 증가하게 된다고 주장한다.

그러나 피심인들이 주장하는 이러한 개발편의 제공효과는 다른 사업자의 미디어 플레이어가 PC에 탑재되더라도 동일하게 제공될 수 있다는 점에서 다른 수단에 의해 대체가 불가능한 것은 아니므로 피심인들의 WMP 결합판매만에 의해서 발생하는 효율성 증대효과는 아니다.

우선 미디어 플레이어는 일반적으로 응용 프로그램과 플랫폼 소프트웨어의 특성을 동시에 갖고 있으므로 피심인들의 WMP가 결합판매 되어야만 발생할 수 있는 성격의 효율성은 아니다.

또한 피심인들의 WMP는 PC 제조업체에 의해 사전에 설치되더라도 개발자들은 동일한 편익을 누릴 수 있다. 예컨대 WMP 9가 운영체제 업그레이드와 별도로 공급되더라도 개발자는 동일한 편익을 누릴 수 있다.

그리고 다른 경쟁업체의 미디어 플레이어도 피심인들의 WMP와 마찬가지로 응용프로그램 개발자를 위한 인터페이스를 제공하고 있다. 리얼네트웍스의 미디어 플레이어의 경우 1,000가지 기능이 넘는 인터페이스를 제공하고 있으며, 500명 이상의 개발자 및 수천의 인터넷 콘텐츠 제공업자들이 리얼네트웍스의 인터페이스를 이용하여 응용프로그램을 개발하고 있다. 따라서 리얼네트웍스와 같은 경쟁사업자의 미디어 플레이어를 제외한 피심인들의 WMP를 사용하여야만 응용프로그램 개발편의가 제공된다는 주장은 인정하기 어렵다.

다) PC 제조업체에 대한 편익이 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 윈도우 운영체제에 새로운 기능을 통합한 것은, 보다 더 우수하고 다양한 PC의 기능을 원하는 소비자의 수요를 충족해야 하는 동시에 휴대폰과 같은 새로운 기기와 치열한 경쟁에 직면하고 있는 컴퓨터 제조업체들에게도 큰 이익이 된다고 주장한다.

그러나 PC 제조업체는 스스로 PC 수요자의 선호를 충족하기 위하여 미디어 플레이어와 같은 각종 응용프로그램을 탑재할 의사와 능력이 있고 실제로 다른 응용프로그램을 다수 탑재하고 있다. 그러므로 피심인들이 획일적으로 자신의 미디어 플레이어를 탑재하는 것은 소비자의 요구를 충실히 반영하는 것이라고 보기 어려우며, 오히려 소비자 및 PC 제조업체의 선택권을 박탈하는 행위로서 PC 제조업체에 대해 편익을 준다고 단정할 수 없다.

라) 소비자에 대한 이익이 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 윈도우 운영체제에 새로운 기능을 추가하는 것은 소비자들에게 유익하다고 주장한다. 특히 PC 초보자들은 PC를 처음 구입했을 때 바로 작동하기를 원하는 등 사용이 쉽기를 바란다고 한다.

PC를 새로 구입하자마자 소비자들이 바로 응용프로그램을 접할 수 있도록 제품을 구성하는 것은 기본적으로 소비자의 선호를 보다 잘 파악할 수 있는 PC 제조업체가 더 효율적으로 할 수 있는 것이다. 운영체제 시장을 독점하는 사업자가 응용프로그

램을 결합판매하는 것은 소비자 선호를 반영한 PC 제조업체의 선택권을 박탈하고 소비자들이 자신의 지불능력을 감안하여 다양한 PC와 프로그램을 선택할 수 있는 기회를 빼앗는데 불과하다고 판단된다.

피심인들이 인정하듯이, 기술적 지식이 별로 없는 사람들은 PC를 처음 사용할 때 바로 접하는 미디어 플레이어를 사용할 가능성이 매우 높은 것이 사실이다. 이들에게 피심인들이 독점하고 있는 운영체제와의 결합판매를 통해 예외없이 피심인들의 미디어 플레이어가 처음부터 보여 진다는 것은, 미디어 플레이어 경쟁사업자들이 획득할 수 없는 사업상 우위로서 부당한 경쟁상 우위라고 할 수 있다.

(다) 소결

피심인들의 결합판매행위는 미디어 플레이어 시장에서 우수한 경쟁사업자의 사업활동을 현저히 곤란하게 하고, 신규 사업자에 대한 진입장벽을 형성하며, WMP의 미디어 플레이어 시장에서의 점유율을 비약적으로 높이는 등 부당하게 경쟁을 제한하였음을 인정할 수 있고, 이러한 행위는 윈도우 PC 운영체제 구매자들에게 WMP의 구입을 강제하여 미디어 플레이어에 대한 선택권을 침해하는 행위로서 정상적인 거래관행이라 할 수 없으므로 거래 수단 또한 불공정하다고 인정된다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 PC 운영체제와 WMP가 별개제품임에도 불구하고 이를 결합하여 판매한 행위는 WMP를 원하지 않는 소비자에게 그 구입을 강제하는 결과를 초래하므로 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 행위이고, 이와 같은 피심인들의 행위는 WMP의 편재성을 초래하여 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한할 뿐만 아니라 그 거래 내용 또는 경쟁수단이 불공정한 반면, 그로 인한 효율성증대효과는 미약하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 불공정거래행위이므로 공정거래법 제23조 제1항 제3호 후단, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목의 '끼워팔기'에 해당한다.

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의2) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

‘과징금 산정의 기준이 되는 고시’는 피심인들의 결합판매 행위가 1999. 7.부터 이 사건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」(2005. 7. 13. 공정거래위원회 고시 제2005-15호, 이하 ‘과징금 고시’라 한다)를 적용한다.

과징금 산정의 기초가 되는 ‘위반행위의 기간’은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하는 것으로 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 공정거래위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는, 당해 사건에 대한 공정거래위원회의 심의일을 위반행위의 종료일로 보되, 심의가 2일 이상 진행되었다면 마지막 심의일을 의미하는 바, 본 사안에서 피심인들의 위반 행위가 1999. 7.부터 지금까지 계속 되고 있으므로 종료일은 본 사안의 마지막 심의 종료일인 2005. 10. 26.이다.

과징금 산정의 기준 금액이 되는 ‘관련 매출액’은 위반사업자가 위반기간 동안 판매 또는 매입한 관련 상품의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하는 것으로서 본 사안에서 법 위반기간 동안 윈도우 PC 운영체제의 매출액은 피심인 엠에스 1,209,309,260천원, 피심인 한국 엠에스 163,321,280천원이다.

(나) 과징금의 결정

‘기본 과징금’은 관련매출액에 위반행위 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 피심인들의 법위반행위의 내용과 정도에 따라 산정되는 점수가 매우 중대한 위반행위에 해당하므로 최대의 부과기준율 2.0%를 적용하여, 피심인 엠에스에 대해서는 24,186,185천원, 피심인 한국 엠에스에 대해서는 3,266,425천원이 산출된다.

‘의무적 조정 과징금’은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법위반 행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

‘임의적 조정 과징금’은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로, 위에서 산정된 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 26,604,803천원, 한국 엠에스는 3,593,067천원이 산출된다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 시장지배적지위 남용행위 중 다른 사업자에 대한 사업활동 방해행위와 관련한 과징금액은 위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여 피심인 엠에스는 26,604백만원, 피심인 한국 엠에스는 3,593백만원이 산출된다.

(2) 불공정거래행위의 금지 규정(제23조) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

‘과징금 산정의 기준이 되는 고시’는 피심인들의 결합판매행위가 1999. 7.부터 본건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」(2005. 7. 13. 공정거래위원회 고시 제2005-15호, 이하 ‘과징금 고시’라 한다)를 적용한다.

(나) 과징금의 결정

‘기본 과징금’은 관련매출액에 위반행위 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 피심인들의 법위반행위의 내용과 정도에 따라 산정되는 점수가 매우

중대한 위반행위에 해당하므로 과징금 부과기준율 중 최대인 1.0%를 적용하여 피심인들 엠에스에 대한 기본과징금 12,093,092천원, 피심인들 한국 엠에스에 대한 기본과징금 1,633,212천원이 산출된다.

‘의무적 조정 과징금’은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법위반 행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

‘임의적 조정 과징금’은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 13,302,401천원, 피심인 한국 엠에스는 1,796,533천원이 된다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기와 관련한 과징금액은 위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여 피심인 엠에스는 13,302백만원, 피심인 한국 엠에스는 1,796백만원이 산출된다.

(3) 부과과징금의 결정

이 사건 피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 WMP를 결합하여 판매한 행위는 공정거래법상 제3조의2 시장지배적지위의 남용행위 중 제1항 제3호 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위 및 같은 항 제5호 후단의 소비자 이익 저해행위, 제23조 제1항 제3호 후단, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목의 ‘끼워팔기’에 각 해당하는바, 이는 기본적 사실관계가 동일한 하나의 행위에 수개의 조항을 적용한 경우에 해당하므로 이 중 과징금의 법정한도가 더 무거운 공정거래법 제3조의2 시장지배적 지위의 남용금지 규정위반에 따른 과징금을 피심인들에게 부과하기로 한다.

4. 윈도우 PC 운영체제와 메신저의 결합판매

가. 기초사실

(1) 메신저 현황

(가) 메신저의 의의 및 주요 기능

메신저 프로그램(messenger program : 이하 “메신저”라 함)이란 상대방이 인터넷에 접속되어 있는지 확인하고 실시간으로 문자를 주고 받으며 채팅, 파일교환 등 사이버 공간 내에서의 쌍방향 커뮤니케이션을 실현하는 프로그램이다.

메신저의 주요기능은 실시간 메시지 송수신, 대화상대 관리, 파일전송 등이다. 이외에도 여러 가지 다양한 기능들이 부가되고 있다.

첫째, “실시간 메시지 송수신 기능”이란 마치 대화를 주고 받듯이 실시간으로 인터넷을 통해 대화할 수 있는 기능이다. 이 기능을 통해 자신의 메신저에 등록된 대화상대에게 문자메시지를 전송할 수 있다.

둘째, “대화상대 관리 기능”이란 메신저를 통해 통신할 대화상대를 추가 또는 삭제하고, 대화상대의 상태를 보는 것을 말한다.

셋째, “파일전송 기능”이란 대화 상대 목록에 기재된 사용자에게 파일을 전송할 수 있는 기능이다. 자신과 대화 상대가 메신저 서비스에 로그인되어 있는 한 파일 용량에 관계없이 무제한으로 파일을 전송할 수 있는 것이 보통이다.

이러한 메신저의 주요기능은 사용자들의 메신저 사용 목적에 관한 설문조사에도 그대로 반영되어 나타난다. 전자신문과 엠브레인이 공동조사[111]한 결과에서도 메신저

서비스의 주요 이용 목적은 의견교환(86.8%), 파일교환(30.3%)의 순으로 나타났다.

위에서 설명한 주요 기능 이외에도 메신저 사업자들은 인터넷전화(VoIP ; Voice over Internet Protocol)기능, 이동전화 문자전송 기능, 쇼핑·음악·영화 제공 웹사이트로의 연결기능 등 새로운 부가기능들을 계속 개발하고 있다.

(나) 메신저 사업자 현황

현재 국내 메신저 시장의 주요 메신저 및 메신저 사업자 현황은 아래와 같다.

우선 피심인들은 1999. 7.부터 'MSN 메신저'라는 명칭의 한글화된 메신저를 국내에 공급하기 시작하였으며, 현재 '윈도우 메신저'라는 명칭의 메신저도 함께 공급하고 있다. 2002년부터 2004년까지의 기간 동안 MSN 메신저와 관련된 광고 및 아바타(avatar) 서비스 판매 등으로 발생한 수입은 대략 000달러[112]이다.

주식회사 에스케이(SK)커뮤니케이션즈(이하 "SK커뮤니케이션"이라 함)는 2003. 1.부터 메신저 사업을 개시하여 '네이트온'(NateOn)이라는 명칭의 메신저를 공급하고 있다. 문자전송서비스(SMS ; Short Message Service)를 에스케이텔레콤(SK telecom) 가입자에게 월 50건을 무료로 제공하고 있다는 특징을 갖고 있다.

주식회사 버디버디(이하 "버디버디"라 함)의 경우 2000. 1.부터 사업을 개시하여 '버디버디'라는 명칭의 메신저를 공급하고 있다. 버디버디 메신저는 주 사용층이 10대 연령층에 집중되어 있다는 점에서 고른 연령대 분포를 보이고 있는 피심인 메신저와 차이가 있다.

주식회사 다음커뮤니케이션(이하 "다음커뮤니케이션"이라 한다)의 경우 2000. 9. 당시 시장점유율 1위를 차지하고 있던 주식회사 유인커뮤니케이션즈라는 메신저 업체를 인수한 후 명칭은 '다음메신저'로 변경하여 메신저 사업을 수행하고 있다.

---

111) 전자신문 기사(2001.9. 12.) 4면

112) 피심인들 제출자료(2004. 10. 15.)이나, 피심인들의 비공개 요청에 따라 구체적 액수는 비공개함

이외에도 주식회사 드림위즈의 '지니'(Genie), 주식회사 네오위즈의 '세이클럽 타키'(Sayclub Tarchy) 등이 국내 메신저 시장에서 경쟁하고 있다. 피심인들이 2003. 4. 코리안클릭에 의뢰하여 실시한 조사결과에 의하면 '지니'의 경우 전체 사용자 중 24세까지의 비중이 62.5%에 달하고 세이클럽 타키도 전체 사용자 중 24세까지의 비중이 56.8%에 달하여, 버디버디와 마찬가지로 주 수요층이 저연령층에 편중되어 있는 특징을 나타내고 있다.

<표 4-1> 국내 메신저 사업자 현황(2005년 5월 기준)

순위	메신저	순사용자수
1	네이트온	11,032,997
2	MSN(윈도우 메신저 포함)	10,230,077
3	버디버디	4,461,821
4	세이클럽 타키	2,654,761
5	다음 터치	1,696,862
6	드림위즈 지니	775,386
7	파란 아이맨	517,913
8	아아팝 핑	495,050
9	다모임	476,166
10	한게임 하니	148,556
11	야후	110,039

* 출처 : 2005. 7. 8. 피심인들 제출(코리안클릭 로그온 자료)

(다) 메신저 시장의 규모

피심인들을 포함하여 메신저를 공급하는 사업자들은 대부분 각종 소프트웨어 및 인터넷 서비스 제공 사업 등을 함께 영위하고 있는데, 이들의 재무제표에는 메신저 관련 매출액이 다른 사업과 분리되어 기재되지 않는 것이 보통이다. 따라서 이들 사업자의 회계자료에 근거하여 국내 메신저 시장의 전체 매출액 규모를 산정하기는 곤란하다.

이에 따라 위원회는 메신저 시장의 매출액 규모를 추정하기 위하여 국내 메신저 사업자들에게 직접 관련 매출액의 규모를 질의[113]하였다. 그 답변 결과를 종합하면 국내 메신저 시장의 매출액 규모는 2003년 기준 대략 500억원 내지 600억원대인 것으로

113) 위원회는 2004. 6. 22. 국내 7개 메신저 사업자에 대하여 메신저 사업 개시일, 매출액 등의 일반현황 및 이 사건과 관련한 각종 의견제출을 요청하였다. 이 자료요청에 대해 6개 사업자가 응답하였는데, 매출액 규모 추정은 사업자들이 제출한 이 자료를 종합하여 추정한 것이다.

추정된다. 그리고 이러한 매출규모는 메신저 이용자의 증가 및 다양한 유료서비스의 등장 등에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세에 있다. 메신저 시장의 매출은 주로 광고, 아바타[114] 판매, 실시간 증권정보 등 유료정보 제공 등에서 발생하고 있다.

(라) 메신저의 유통경로

메신저의 유통경로는 크게 소비자들이 인터넷을 통해 다운로드하는 것과 PC 운영체제에 결합하여 판매 하는 것 등 두 가지 경로로 구분할 수 있다. 인터넷을 통한 다운로드 경로는 다시 두 가지로 구분할 수 있는데, 메신저를 제작·공급하는 특정회사가 자신의 웹 사이트에서 직접 공급하는 경로와 여러 가지 다양한 소프트웨어를 제공하는 제3자의 다운로드 전문 웹 사이트에서 공급하는 경로가 있다.

PC 운영체제 제작·판매사업을 병행하고 있는 피심인들의 경우 PC 운영체제에의 결합판매 경로 및 인터넷을 통한 다운로드 경로를 모두 이용하고 있다. 예를 들어 피심인들은 2002. 7. 한 달 동안 총 1,797,616개의 메신저를 공급하였는데 이중 432,952개는 PC 운영체제 결합판매 경로를 통하여 공급하였고, 나머지 1,364,664개는 인터넷 다운로드 경로를 통해 공급하였다.

그러나 PC 운영체제 제작·판매사업을 병행하지 않는 대부분의 메신저 사업자들의 경우에는 피심인들과 달리 거의 대부분 인터넷을 통한 다운로드 경로를 통해서만 메신저를 공급하고 있다. 따라서, 이러한 사업자들은 인터넷 사용자들이 자신의 메신저를 다운로드 받도록 하기 위해서 통상 별도의 웹 사이트를 운영하고 있다. 이러한 웹 사이트 중 상당수는 자신이 운영하는 포털(portal) 웹 사이트와 연결(링크 ; link)되어 있는 것이 일반적이다.

(2) 메신저 시장의 특성

메신저 시장은 소프트웨어 제공을 포함한 일종의 통신서비스 시장이라는 성격 때

114) 아바타(avatar)는 사이버공간(cyber space)에서 사용자를 표현하는 만화 인물(animation character) 등을 의미한다.

문에 네트워크 효과와 고착효과라는 특성을 나타내고 있다. 또한 메신저 사업자들은 광고, 아바타 판매, 인터넷 전화 등 다른 수익창출 방법을 다양하게 개발하고 있다.

(가) 네트워크 효과

메신저 시장에서는 네트워크 효과(Network effect)가 발생하고 있다. 네트워크 효과란 자신이 사용하는 메신저의 사용자가 증가하거나 다른 사람의 컴퓨터에 같은 종류의 메신저 설치가 증가할수록 사용자의 편익이 증가하는 효과를 말한다. 즉 네트워크의 크기가 증가할 때 해당 네트워크에 속해 있는 구성원의 편익이 증가하는 효과라고 할 수 있다.

메신저에는 해당 메신저를 이용하여 통신할 수 있는 상대방의 목록이 “대화 상대 목록”, “친구 목록”, “버디리스트(buddy list)” 등의 명칭(이하 “대화상대 목록”이라 함)으로 존재하는데, 메신저 사용자가 향유하는 네트워크 효과는 구체적으로는 이러한 대화상대 목록의 증가에 의해 나타나게 된다. 이는 당해 메신저 가입자의 수가 많을수록 사용자가 통신하기 원하는 상대방이 그 메신저를 이용하고 있을 가능성이 높아지는 비례적 관계가 있기 때문이다.

(나) 네트워크 효과의 폐쇄성

메신저도 그 기능과 성격상 일종의 통신 서비스에 속하는 것이 사실이다. 그러나 현재 국내 메신저 시장에서는 사업자별로 프로토콜(protocol)이 달라 상호접속이 되지 않는 경우가 대부분이다. 즉, 다른 메신저를 이용하는 사용자들 간에는 서로 통신할 수 없다. 이에 따라 메신저의 네트워크 효과는 사업자가 다른 메신저 별로 발생하게 되는 폐쇄성을 갖게 된다. 예를 들면 다음커뮤니케이션의 메신저와 피씨인의 메신저는 프로토콜이 다르기 때문에 서로 대화하거나 파일 등을 주고 받을 수 없는데, 이러한 상호 비접속은 메신저 사용자들의 편익을 감소시키는 결과를 야기하고 있다.

이렇게 메신저의 통신범위가 당해 메신저 사용자들의 집단으로 한정되는 상황에서

특정 메신저의 가치는 당해 메신저가 갖는 네트워크 효과의 크기, 즉 가입자가 얼마나 많은지 여부 또는 얼마나 많이 설치되어 있는지에 따라 결정된다. 각종 조사기관[115]이 실시한 각종 설문결과에서도, 소비자들이 메신저를 선택하는 가장 중요한 기준은 “주변 사람이 많이 이용하는지 여부”로 확인되었는바, 이는 서로 다른 메신저끼리 통신을 할 수 없는 폐쇄성 때문이다.

(다) 고착효과

위에서 본 네트워크 효과 및 컴퓨터 이용자의 행태 등에 따라 메신저 이용에는 고착효과(lock-in effect)가 발생하고 있다. 고착효과란 기존에 사용하고 있는 메신저에서 다른 사업자의 메신저로 교체할 경우 발생하는 비용(전환비용; switching cost)의 존재 때문에 설사 품질 등에 불만이 있더라도 불가피하게 기존 메신저를 사용하게 되는 것을 말한다. 고착효과의 크기는 결국 이러한 전환비용의 크기에 의해 결정된다고 할 수 있는데, 전환비용에는 대화상대 목록의 수가 중요한 요인이 된다.

(라) 네트워크효과 및 고착효과에 의한 진입장벽

이렇게 메신저의 가치가 폐쇄적 특성을 갖는 네트워크 효과에 달려있다는 사실은 메신저 시장에 신규진입하려는 사업자에게는 진입장벽으로 작용하게 된다. 즉, 이용자들이 메신저를 이용하여 여러 사람과 통신하는 목적을 실효성있게 달성하기 위해서는 그 메신저를 이용하는 가입자가 어느 정도 이상 존재(critical mass)하여야 하는데, 일정한 숫자 이상의 가입자를 확보하는 것이 신규 사업자에게는 매우 어렵기 때문이다.

또한, 고착효과의 존재도 이미 성숙단계에 이른 현재의 메신저 시장에서는 기존의 다른 메신저 사용자를 끌어들어야 하는 신규 진입자에게 커다란 진입장벽으로 작용하게 된다.

115) 코리안 클릭(2002. 2. 2003. 4. 및 12.), 베스트 사이트(2002. 7.)

(마) 다양한 수익창출 형태

현재 메신저 사업자들은 여러 가지 다양한 형태로 수익을 창출하고 있는데, 크게 직접적인 수익창출 형태와 간접적인 수익창출 형태로 분류할 수 있다.

우선 직접적인 수익창출 형태로는 메신저 광고 게재, 아바타 판매, 고급기능(프리미엄 기능 ; 실시간 증권정보 제공 등) 유료판매, 이동전화용 메신저의 유료판매, 인터넷전화(VoIP ; Voice over Internet Protocol)를 통한 전화사업 등이 있다.

다음으로 간접적 수익 창출 형태가 있는데, 메신저가 인터넷 포털 사이트로 고객을 유인하는 통로(gateway)로서 매우 효과적인 수단인 점을 이용하는 것이다. 즉, 고객이 일단 메신저를 통해 인터넷 포털 사이트로 이동하게 되면, 인터넷 포털 사이트에서 제공되는 각종 유료 서비스를 이용하도록 유인한다든가 광고에 노출되도록 함으로써 간접적으로 수익을 창출하는 형태이다.

(3) 메신저 시장의 연혁

국내 메신저 시장의 연혁은 메신저 사용자의 양적 변화 등을 기준으로 판단할 때 도입기, 확장기, 성숙기 등으로 구분할 수 있으며 피심인들이 메신저가 포함된 윈도우Me와 그 후속제품인 윈도우XP를 판매한 행위는(윈도우Me : 2000. 9., 윈도우XP : 2001. 10.)은 국내 메신저 이용자가 큰 폭으로 증가하는 확장기에 발생하였다.

이하에서는 메신저 시장의 성장단계를, 주로 메신저 사용자의 양적 규모를 중심으로 도입기, 확장기, 그리고 성숙기의 3단계로 구분하여 설명한다.

(가) 도입기(1996년부터 1999년)

메신저는 1996년부터 미라빌리스(Mirabilis)[116], 에이오엘(AOL)[117] 등의 외국 사

116) 미국의 미라빌리스(Mirabilis)는 1996년 하반기 “ICQ(I Seek You)”라는 명칭의 메신저 프로그램을 세계 최초로 출시하였다. 미라빌리스는 1998. 6. 에이오엘(AOL ; America Online Inc.)에 인수되었다.

업자들에 의해 처음 국내에 보급되기 시작하였다. 이 당시에는 국내에 이와 유사한 서비스를 제공하는 메신저 사업자가 존재하지 않았으며, 따라서 국내에서 메신저를 사용하려는 자들은 이들 외국 사업자의 메신저를 인터넷을 통해 다운로드 받아 PC에 설치하여 사용하였다.

국내사업자가 공급하는 메신저가 처음 출시된 것은 1998. 11. 주식회사 디지토(현재 디지토닷컴 주식회사)의 "소프트메신저(Soft Messenger)"가 처음이었으며 1999. 2.에는 유인커뮤니케이션즈가 "인터넷친구"라는 메신저를 출시하였다. 그리고 1999년 하반기에 피심인들의 "MSN 메신저(한글판)", 야후코리아의 "야후메신저(한글판)", 드림위즈의 "지니", 드림라인의 "투드림", 천리안의 "큐메신저(CQM)", 나우누리의 "님(NiM)" 등이 출시되었다.

(나) 확장기(2000년부터 2002년)

메신저 사용인구는 2000년부터 2002년까지의 기간동안 인터넷 이용자[118], 초고속 인터넷 이용자의 증가[119] 및 메신저 제공업체의 증가 등에 기인하여 크게 증가하기 시작하였고 이에 따라 메신저 시장의 경쟁상황이 급변하고 시장규모도 커지게 되었다.

정보통신정책연구원의 조사결과에 의하면, 2000. 11. 현재 인터넷 이용자의 메신저 이용률은 16%였다.[120] 그리고 넷밸류코리아의 조사결과에 의하면, 2001년 1월 25.8%, 2월 29.9%, 3월 33.8%, 4월 40.4%로 메신저 이용률이 크게 증가하였다.[121]

또한, 엔에프오 코리아(NFO Korea) 및 리서치 인터내셔널(Research International)의 조사결과에서도 2001. 11.부터 2002. 11.까지 메신저 이용의 증가추세가 가파르다가

117) 미국의 에이오엘은 1997. 5.에 "AOL Instant Messenger"라는 이름의 메신저를 출시하였다. 참고로 AOL은 미국 시장에서 줄곧 사용자수 1위를 유지하다가 2004. 8. 경 MSN 메신저에 의해 추월당한 것으로 보도되고 있다. 미국의 닐슨/넷레이팅이라는 시장조사기관의 발표(2004. 9.)에 의하면 2004. 8. 현재 AOL은 27.6백만명(2위), MSN 메신저는 28.6백만명(1위), 야후 메신저는 18.1백만명의 사용자(unique user 기준 : 한달동안 한번이상 특정 메신저를 사용한 사람 수) 수를 기록하였다.

118) 국내 인터넷 이용자는 2000. 1. 11,340천명에서 2002. 12. 26,270천명으로 크게 증가하였다.

119) 한국인터넷진흥원(HTTP://isis.nic.or.kr)의 자료에 의하면 2000. 1. 496천명에서 2002. 12. 10,405천명으로 급증하였다.

120) 「정보통신정책연구원, 인터넷 이용 소비자 형태 분석 조사결과 보고서(2000.12.10.)」

121) 「정보통신정책연구원 문주영, 인스턴트 메시징 서비스 시장의 현황 및 가능성(2001. 8.)」

2002년 말부터 다소 둔화되는 것을 알 수 있다.[122]

이러한 확장기의 특징으로는 메신저 시장 도입기에 상당한 시장점유율을 차지하고 있던 외국 사업자와 국내 메신저 전문개발업체의 시장점유율이 급격히 감소하고 인터넷 포털 업체들의 메신저 시장점유율이 증가하면서 메신저 시장의 대부분을 차지하였다는 점을 들 수 있다.

(다) 성숙기(2003년부터 현재)

2003년 이후 현재까지는 메신저 사용자 증가추세가 둔화되고 있다는 점에서 시장 성숙기라고 할 수 있다. 이는 인터넷 이용자 및 초고속 인터넷 이용자가 거의 포화상태라는 점, 메신저 서비스가 도입된 지 상당기간이 경과하여 새롭게 메신저 시장으로 유입되는 잠재사용자가 많지 않다는 점, 메신저 시장에의 신규진입 사업자가 적은 점 등에 기인한 것으로 인정된다.

우선 전체 인터넷 이용자의 경우 2002. 12. 26,270천명에서 2003. 12. 29,220천명으로 1년 동안 6%가 증가하는데 그치고 있으며 증가추세가 더욱 둔화되었다는 점에서 거의 포화상태임을 확인할 수 있다. 이는 메신저 사용자의 증가추세 둔화에도 중요한 요인이 된 것으로 판단된다.

또한, 초고속 인터넷 이용자도 거의 포화상태인데 2003. 10.에는 오히려 초고속인터넷 이용자가 감소하기도 하였다. 이러한 초고속인터넷 이용자의 포화상태 또한 메신저 사용자의 증가 둔화 요인이 되고 있다.

이 시기에 메신저시장에서 발생한 중요한 사건으로 피심인들의 다른 사업자 메신저와의 연동차단을 들 수 있다. 드림위즈, SK커뮤니케이션 등 국내 일부 메신저 사업

122) 2001년 8월부터 2002년 11월까지의 자료는 NFO Korea가 수집하였고, 2003년 11월 자료는 Research International이 수집하였다. 조사개요 - (ⅰ) 자료수집방법 : 전화조사 (ⅱ) 조사지역 : 서울 (ⅲ) 조사대상자 : 최근 일주일동안 2회이상 인터넷을 접촉한 자 (ⅳ) 표본추출방법 : 할당표본 추출 (ⅴ) 조사표본 구성 : 총 400표본 「다음커뮤니케이션 제출자료(2004. 4. 24.)」

자들은 피심인들의 메신저 서비스와 연동되도록 자신들의 메신저를 개발하였으나, 피심인들은 연동에 보안 문제 등을 이유로 피심인들과 라이센스 계약을 체결하는 업체에 한해 피심인들의 메신저 서비스에 접속할 수 있는 프로그램을 개발하고 배포하는 것을 허용하도록 하는 정책(이하 “메신저 라이센스 정책”이라 함)을 실시하였다. 그러나 현재 피심인 엠에스 본사의 정책이 변화되어 이러한 메신저 라이센스 정책은 실행되지 않고 있다.[123)]

나. 행위사실

피심인들은 2000. 9. 15.부터 윈도우 미(Windows Me 이하 “윈도우 Me” 라 한다)라는 PC 운영체제에 MSN 메신저를 포함시켜 2001. 10월경까지 판매하였고, 이후 2001. 10. 8.부터 현재까지 윈도우 Me의 후속제품인 윈도우 엑스피(Windows XP)에 윈도우 메신저를 포함시켜 판매하고 있다.

다. 관련 시장 획정

피심인들의 행위가 공정거래법에 위반되는지 여부를 판단하기 위해서는 먼저 피심인의 행위가 사업자들간의 경쟁에 영향을 미치는 범위 즉 일정한 거래분야를 획정하여야 한다. 이를 위해서는 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 거래분야의 특정이 전제되어야 한다.

(1) 관련 상품 시장

‘관련 상품 시장’이라 함은 시장의 경쟁상황을 평가함에 있어서 가격이나 물량 등의 면에서 하나의 독립한 시장으로 작동한다고 평가되는 상품의 집합을 말하며, 상품의 기능 및 효용의 유사성, 상품 가격의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식,

123) 피심인 한국지사 직원 장호의 관련진술은 다음과 같다. “(앞생략)그런데 어떤 이유에선지 정확히 모르겠지만 본사의 정책이 변화되어 지금은 연동을 위한 계획들을 추진하지 않고 있는 것으로 알고 있습니다.(이하 생략)”「피심인 직원 진술서(2004. 11. 1.)」
“(앞생략)결과적으로 이 프로그램을 이용하고자 Microsoft와 라이센스를 체결한 업체의 수가 너무 적어서 위 프로그램은 점차 실행되지 않게 되었을 뿐입니다.(이하 생략)” 「피심인 직원 추가 진술서(2004. 12. 8.)」

판매자들의 대체가능성에 대한 인식 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 사실에 관하여는 3. 다. (1)에서 살펴본 바와 같다.

(가) 이 사건에서 주된 상품 시장은 '인텔호환 PC 운영체제 시장'이다.

이에 대한 구체적 내용은 3. 다. (1) (가) 에서 살펴본 바와 같다.

(나) 이 사건에서 종된 상품 시장은 '일반용 메신저 시장'이다.

메신저 프로그램은 크게 일반용 메신저과 기업용 메신저로 나눌 수 있는바, 양자는 기능과 용도가 상이하고 수요자 및 구매형태가 다르며, 피심인들도 이를 다른 상품으로 인식하고 있다는 점에서 별개의 시장이다.

1) 일반용 메신저는 기업용 메신저와 기능 및 용도가 상이하다.

기업용 메신저는 회사내의 지식관리, 결재관리 등 다른 기업용 응용프로그램과의 연동기능을 갖추거나 암호화 기능을 갖추는 등 일반용 메신저와는 차별화된 기능을 보유하고 있으며, 서로 대체가 불가능하다. 이러한 사실은 피심인들이 2005. 10. 기업용 메신저 솔루션인 라이브 커뮤니케이션 서버(Live Communication Server)를 설명한 인터넷 웹 문서[124]에서, 기업용 메신저의 장점을 설명하면서 "일반용 메신저는 데이터 암호화를 지원하지 않으며, 대부분의 회사 보안 표준을 충족시키지 못한다"고 하여 기술적으로 일반용 메신저와 기업용 메신저간에 대체가 어렵다는 것을 스스로 인정하고 있다.

2) 일반용 메신저와 기업용 메신저는 수요자 및 구매형태가 상이하다.

기업용 메신저와 일반용 메신저의 가장 중요한 차이점으로는 특정조직의 구성형태가 메신저에 반영되어 있다는 점 및 자체 서버를 사용한다는 점 등이 있다. 반면, 일반용 메신저에서는 이와 비슷한 성격의 대화상대 목록을 최종사용자가 특정조직 내외

124) 「http://www.microsoft.com/korea/office/livecomm/prodinfo/publicim.mspx#EAB」

에 구애받지 않고 일반사용자 중에서 임의로 설정하게 되어 있다.

기업용 메신저는 해당 기업 내의 자체 서버하고만 연결되어 있고 외부 서버와 연결되어 있지 않은 경우가 보통이다. 이에 따라, 기업용 메신저는 메신저 개발단계에서부터 기업고객의 특정한 수요에 맞게, 그리고 기업용 메신저 서버와 함께 연동되도록 개발되고 판매되는 특징을 갖고 있고, 기업 수요자는 클라이언트 메신저 소프트웨어뿐만 아니라 메신저 네트워크를 관리할 서버 소프트웨어까지 함께 구매하는 경우가 보통이므로 수요자와 구매 형태 측면에서 일반 메신저와는 다르다.

3) 피심인들도 일반용 메신저와 기업용 메신저를 별개 시장으로 인식하고 있다

피심인들은 기업용 메신저와 일반용 메신저 시장을 별개시장으로 인식하여 마케팅하고 있다. 이러한 사실은 피심인들이 2003년 4월 코리안클릭에 의뢰하여 작성한 전략보고서[125]에서, 기업용 메신저 시장은 증권가 등의 특수한 집단이 대상이거나 기업 내부의 의사소통을 위해 운영하는 경우가 많으므로 일반용 메신저인 MSN 메신저가 고려해야 하는 시장은 아니라고 적시하고 있다는 점에서 인정할 수 있다.

(2) 관련 지리적 시장

관련 지리적 시장이란, 다른 모든 지역에서의 당해 상품의 가격은 일정하나 특정지역에서만 상당기간 어느 정도 의미 있는 가격인상이 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 지역전체를 말하며, 구매자의 특성 또는 상품의 특수성에 의하여 상품, 지역 또는 거래단계별로 특정한 구매자 군이 존재하는 경우에는 이러한 구매자 군 별로 일정한 거래분야가 획정될 수 있다.

주된 상품인 PC 운영체제 시장의 지리적 시장은 국가간 운송 및 거래비용이 미미한 점, PC 운영체제 사업자들 대부분 세계적으로 유사한 가격 및 거래조건으로 판매하고 있다는 점, 제품의 개발 및 판매 전략을 비롯한 중요한 사업전략을 세계시장에서 유사하게 수행하고 있다는 점 등을 고려할 때 세계시장이다.

125) MSN을 위한 IM시장 확대 및 경쟁사 유저 확보 전략보고서(2003.4.)

메신저 프로그램의 지리적 시장은 다음과 같은 이유로 국내 시장으로 획정하는 것이 타당하다고 판단된다.

첫째, 국내에서 주로 사용되는 메신저는 대부분 한국어 버전이며, 국내 소비자들은 외국과는 차별되는 광대역 초고속 인터넷 환경과 특이할 정도로 까다로운 소비성향을 갖고 있다.

둘째, 메신저 시장은 이동전화 등과 마찬가지로 서비스 시장(가입자목록 관리, 국내화된 컨텐츠 제공)의 성격이 있기 때문에 현지화되지 않고서는 시장진입이 쉽지 않다.

셋째, 국내 메신저 시장은 세계 시장과 달리 순수 국내 사업자의 시장점유율이 매우 높고, 세계 시장에서 상당한 점유율을 가지고 있는 AOL이나 야후의 시장점유율은 거의 없거나 미미하다는 점에서 시장구조면에서 큰 차이를 보이고 있으며 이러한 상태가 비교적 오랜 기간동안 유지되고 있다.[126]

라. 윈도우 메신저와 MSN 메신저의 관계

피심인들이 각각 공급하고 있는 윈도우 메신저와 MSN 메신저가 별개의 제품인지 아니면 동일한 제품인지 여부는 메신저 결합판매 위법성 판단의 중요한 선결문제이다. 왜냐하면 결합판매가 시장에 미친 효과, 메신저 시장의 점유율 등을 판단하는데 있어서 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 따로 검토할 것인지 아니면 동일한 제품으로 보아 하나로 검토할 것인지를 결정해야 하기 때문이다.

여기서 '동일한 제품'이란 공정거래법 집행의 관점에서 같은 제품인지 여부를 의미하는 개념으로서, 모든 기능이나 파일구성이 동일할 것을 요구하지는 않는다. 윈도우 메신저와 MSN 메신저가 동일한 제품인지 여부를 판단하기 위해서는 그 외형, 관련시장의 구성주체인 수요자와 피심인들 자신의 인식 등을 종합적으로 고려하여야 하는바, 결론적으로 윈도우 메신저와 MSN 메신저는 동일한 제품으로 인정된다(이하 양자를 통칭하여 '피심인 메신저'라고 한다).

126) 피심인들이 2004. 7. 16. 전세계 16개 국가를 대상으로 조사한 결과 전세계 메신저 시장에서 AOL과 야후 메신저가 시장점유율 2위와 3위를 차지하고 있다.

(1) 관련사실

'MSN 메신저'는 윈도우 Me에 결합판매된 메신저의 명칭이다. 동시에, MSN 메신저는 1999. 9.부터 지금까지 인터넷 다운로드 등의 경로를 통해서도 윈도우 XP, 윈도우 Me, 애플의 매킨토시 사용자 등을 대상으로 널리 공급되고 있다.

'윈도우 메신저'는 윈도우 XP에 결합판매된 메신저의 명칭이다. 동시에, 윈도우 XP , 윈도우2000 서비스팩 2 사용자 등을 대상으로 인터넷 다운로드 등의 경로를 통해서도 공급되고 있다.

(2) 윈도우 메신저와 MSN 메신저는 사실상 동일한 제품이다

(가) 두 메신저는 외형이 동일하여 수요자들이 동일한 제품으로 인식한다.

첫째, 피심인들은 사용자가 윈도우 메신저의 모든 기능을 사용하기 위해서는 "엠에스엔 애드인(msnaddin : 이하 "msnaddin"이라 함)"이라는 명칭의 파일을 다운로드 받아 설치하도록 제품을 설계하였다.("Add-in 아키텍쳐") 피심인들은 사용자들이 msnaddin 파일을 많이 다운로드 받도록, 윈도우 메신저에서 중요한 역할을 하는 기능("받은 편지함으로 이동", "채팅방 들어가기"등) 에 이 파일과의 연결메뉴(링크)를 설정해 놓고 있다. 이에 따라 사용자가 msnaddin이라는 파일을 다운로드 받아 설치하면 두 메신저는 사용자들이 그 전체적인 외형의 차이점을 구별하기가 어렵도록 거의 동일한 모습이 된다.

특히, 윈도우 메신저의 경우, 아래 그림에서와 같이 주화면 상단에는 "windows messenger"라고 표시되는 반면, 주화면 하단에는 "MSN Messenger .Net"이라고 표시되어 지금 자신이 사용하는 메신저가 윈도우 메신저인지 아니면 MSN 메신저인지 구분하기 어려운 외형이 된다.

<그림 4-1> 윈도우 메신저와 MSN 메신저 외형 비교



* 그림 설명 : 좌측 메신저가 윈도우 메신저(버전 4.7), 우측 메신저가 MSN 메신저(버전 6.2)임

이와 관련하여, 2005. 8. 24. 이 사건 심의시 피심인들의 참고인 a, b, c의 심판정에서의 진술에 의하면, 모두 소비자들이 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 구분하기 어려울 것이라는 취지로 진술[127]하고 있어 일반인들로서는 사실상 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 구분하기 어렵다는 사실을 확인해 주고 있다.

(나) 피심인들은 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 사실상 하나의 제품으로 인식하고 있다.

메신저 공급자인 피심인들이 윈도우 메신저를 MSN 메신저의 한 종류로서 두 제품을 사실상 하나의 제품으로 인식하고 있다는 사실은 다음의 자료에서 확인된다.

첫째, 피심인들은 윈도우XP를 출시하기 전 피심인들 내부직원 교육을 위해 작성한 윈도우 XP 설명문서[128]에서 "윈도우 메신저는 MSN 메신저의 새로운 버전(v.4.0)"이라고 설명[129]한 사실이 있다. 이 자료는 피심인들이 윈도우 메신저를 MSN 메신저의 한 버전으로 인식하고 있음을 나타내고 있다.

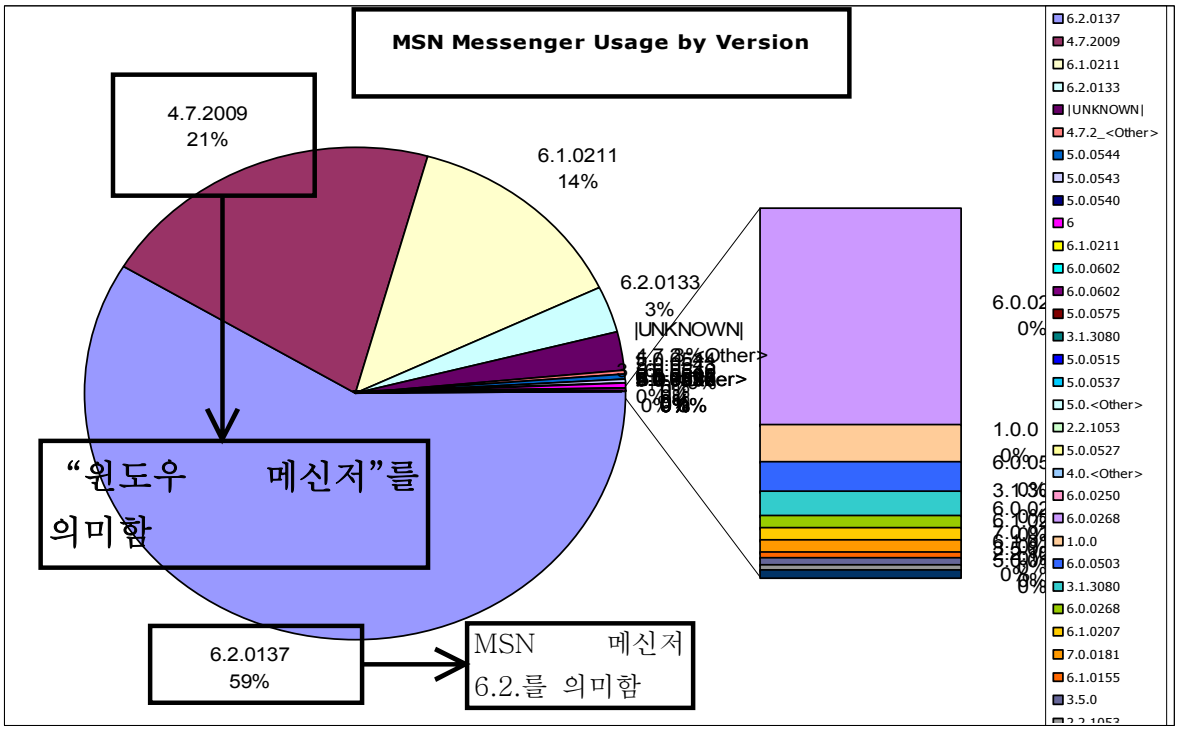
127) 증거조사신청 참고인 신문조서 108페이지

128) Windows Messenger Overview, 3쪽

129) 영어 원문은 다음과 같다. "Windows Messenger is the new version(v.4.0) of MSN Messenger."

둘째, 피심인들은 "NetMetrix"라는 시스템을 이용하여 메신저 사용현황 자료를 생산하는데, 이 시스템에서 'MSN 메신저 사용현황'을 버전별로 추출해 내면 아래 그림에서 보이는 바와 같이 "MSN Messenger Usage by Version"이라는 제목하에 '윈도우 메신저' 및 'MSN 메신저'의 각 버전별 사용현황이 생성된다. 이러한 피심인들의 자료 생성 행태는 피심인들이 윈도우 메신저를 MSN 메신저의 한 버전으로 인식하고 있음을 잘 나타내고 있다.

<그림 4-2> 피심인들의 MSN 메신저 사용현황 전산문서(2004.9.30.)



* 출처 : 피심인들 제출자료(2004.11.3)

셋째, 피심인 한국지사의 MSN사업부는 2002. 5. 피심인 메신저의 강점 및 약점을 분석한 적이 있는데, 이 검토문서[130]에서는 MSN 메신저와 윈도우 메신저를 구별하지

130) 이 문서는 피심인 엠에스 회사에서 MSN 메신저를 담당하고 있는 직원에 의해 작성되었다. 동 문서에서 피심인 엠에스는 메신저에 대한 스윗 분석(SWOT 분석 ; 경영전략을 수립하기 위하여 현재와 미래의 환경을 분석하는 전통적인 경영분석기법)을 수행하고 있는데, 강점(Strengths)으로서 운영체제에의 기본설치 이외에도 클라이언트 소프트웨어의 안정성(Client Stability), 배우고 사용하기 쉬움(Easy to learn and use)을 들고 있으며, 미래의 위협(threats)으로서는 다음커뮤니케이션(Daum)과 같은 경쟁자들의 새로운 기능 개발 등을 들고 있다. 【「Messenger & Alerts Service(2002. 5. 3.)」, 5쪽】

않고 “메신저” 또는 “MSN 메신저”라는 명칭으로 포괄하고 있다. 이 문서에 의하면 메신저가 운영체제에 기본프로그램으로 설치되어 있다는 점(“OS Default installation”)을 자사 메신저의 강점으로 평가하고 있다. 또한 기회요인으로서 원격통제(Remote Control) 및 화상대화(Video Chat)를 들면서 이는 윈도우 XP에만 특유한 기능이라고 기재하고 있다. 피심인 엠에스 직원이 윈도우 메신저에만 특유한 기능을 들면서 이를 MSN 메신저의 기회요인으로 분석에 포함시킨 점으로 미루어 볼 때, 피심인들 스스로 윈도우 메신저를 MSN 메신저의 일종으로 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

넷째, 피심인 직원간에 2002. 8. 30. 주고받은 전자우편 자료[131]에 의하면, 윈도우 메신저 버전 4.7까지는 PC 운영체제를 담당하는 부서가 아닌 MSN 메신저를 담당하는 MSN팀이 책임부서였으나, 윈도우 메신저 버전 5.0부터는 책임부서도 윈도우팀으로 이관될 예정이라고 기재되어 있다. 이는 피심인들이 심사대상 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 하나의 제품으로 간주하고 개발·관리하였다는 것을 의미한다.

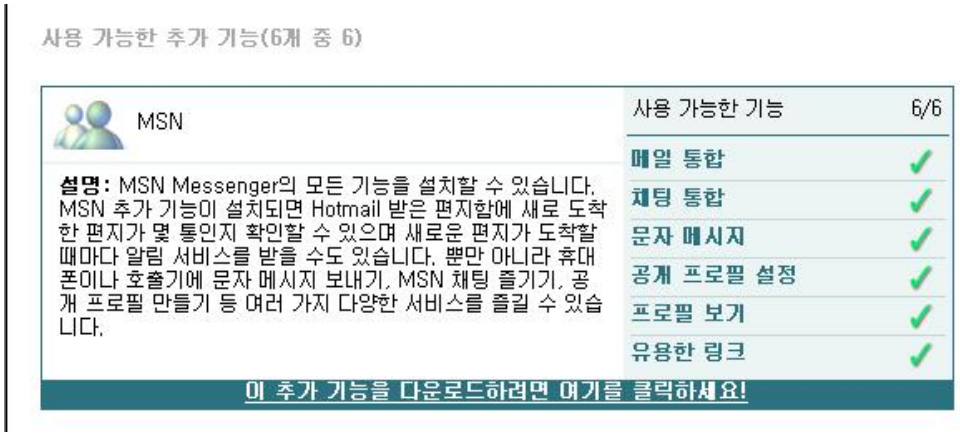
(3) 윈도우 메신저는 그 사용자로 하여금 MSN 메신저를 사용하도록 유인한다.

(가) 피심인들은 ‘애드인 아키텍쳐’를 이용하여 MSN 메신저로의 사용을 사실상 유인하고 있다.

첫째, 윈도우 메신저 애드인 웹페이지에는 아래 그림에서 나타나는 바와 같이 “MSN 메신저의 모든 기능을 설치할 수 있습니다”, “MSN 추가기능이 설치되면 (중략) MSN채팅 즐기기, 공개 프로필 만들기 등 여러 가지 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다”라고 표시되어 사실상 MSN 메신저를 다운로드받도록 하기 위한 웹사이트로 표시되고 운영되고 있음을 알 수 있다.

131) 피심인 제출자료 (피심인 직원간 전자우편, 제목 : “RE : Windows Messenger ver 5 출시계획”)

<그림 4-3> msnaddin 파일 다운로드를 제공하는 웹사이트 화면



*출처 : 피심인들이 운영하는 인터넷 웹사이트(www.microsoft.com/windows/messenger/KO/addin.asp)

둘째, 피심인들의 MSN 메신저 담당 직원간 전자우편[132]에 의하면 "(앞 생략) 원래 기존의 Windows Messenger에는 "대화방 가기", "메일 확인" 등 MSN 관련 특징(Feature)들이 없습니다. 그래서 Windows XP 사용자들이 메신저에서 MSN 관련 기능을 사용할 수 있도록 하기 위하여 플러그인과 비슷한 기능의 Add-in을 추가로 설치할 수 있도록 해 왔었습니다. (이하 생략)"라고 되어 있다. 이 전자우편은 피심인들이 윈도우 메신저 애드인 웹 페이지를 MSN 홍보사이트처럼 운영한 의도가 소비자들로 하여금 MSN 메신저 기능을 이용하게 하기 위한 것임을 나타내고 있다.

결국 "애드 인 아키텍쳐"와 해당 웹사이트는 사실상 윈도우 메신저를 MSN 메신저처럼 보이도록 만들고 윈도우 메신저의 사용자를 MSN 메신저 쪽으로 유도하기 위한 장치로 만들어지고 운영되는 것으로 인정된다.

(나) 피심인들도 MSN 메신저를 윈도우 메신저의 업그레이드 버전으로 설명하고 있다.

피심인들은 다음에서 보는 바와 같이 MSN 메신저가 윈도우 메신저의 업그레이드 버전이라고 설명한다. 이에 따라 사용자들은 MSN 메신저가 윈도우 메신저의 '업그레이드 버전[133]'이라고 인식하게 되며 이는 윈도우 메신저 사용자가 MSN 메신저로 전

132) 피심인 제출자료(2002. 8. 1.) 제목 : RE : Windoe Messenger ver5 출시계획

133) 기본적으로 기존 제품과 동일한 제품인데, 오류를 시정하거나 기능을 향상시킨 소프트웨어를 의미하며 일반적으로 소비자들은 최신버전의 소프트웨어를 사용하고자 하는 성향이 있다.

환하도록 유인하는 역할을 한다.

첫째, 피심인들은 사용자가 구 버전의 윈도우 메신저를 실행시킬 경우, 자동적으로 새로운 버전의 파일을 설치하라는 안내창을 내보냄으로써 윈도우 메신저 새 버전을 공급하고자 하고 있다. 이 안내에 따라 사용자가 “예”를 선택하면 소비자에게 윈도우 메신저에서 “전화걸기 기능”이 삭제됐다면서 이 기능을 이용하기 위해 MSN 메신저를 다운로드할 것을 권유[134]한다. 이에 따라 사용자들은 MSN 메신저가 윈도우 메신저의 업그레이드 버전이라고 인식할 가능이 커지게 되며 이는 윈도우 메신저의 사용자가 MSN 메신저 사용자로 이동할 가능성이 커지게 됨을 의미한다.

둘째, 윈도우 메신저 주화면 상단의 “도움말” 메뉴 ⇒ “.NET 서비스 정보”라는 메뉴를 선택할 경우, “메신저를 업그레이드하세요”라는 문구가 적힌 창이 나타난다. 그리고 사용자가 이 문구를 선택할 경우 MSN 메신저를 공급하는 웹 사이트[135]로 이동한다 이에 따라 사용자들은 MSN 메신저가 윈도우 메신저의 업그레이드 버전이라고 자연스럽게 인식하게 된다.

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 다른 사업자의 사업활동 방해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2 제1항 제3호의 규정취지나 이에 해당하기 위한 요건 등에 관하여는 위 2. 라. (1) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 운영체제 시장에서 시장지배적사업자이다.

피심인들이 공정거래법 제2조 제7호, 제4호의 규정에 의한 시장지배적사업자라는

134) 피심인 메신저 실행화면(2004. 10. www.microsoft.com/windows/messenger/KO/whatsnew.asp)

135) 피심인 메신저 실행화면(2004. 10. http://messenger.msn.com/help/UPgrade.aspx?mkt=ko-kr#Q3t)

사실은 이미 위 2. 라. (2) (가)에서 이미 살펴본 바와 같다.

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

피심인들이 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저가 별개제품임에도 불구하고 결합판매하여 피심인 메신저를 구입하도록 함으로써 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래를 강제한 행위라고 인정된다. MSN 메신저가 윈도우 PC 운영체제와 별개의 제품임이 명백하고 피심인들도 이를 부인하지 않으므로 이하에서는 윈도우 XP에 포함된 윈도우 메신저에 초점을 맞추어 본다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저는 별개제품이다.

주된 상품과 종된 상품이 별개 상품인지 여부를 판단하기 위해서는 기능·성격의 차이와 수요가 동일한지 여부가 가장 중요한 판단기준이 되며, 종된 상품에 대한 별도의 공급자 존재, 동종업계의 거래관행, 피심인들의 인식 등도 종합적으로 고려하여 판단한다.

참고로, 서울고등법원은 공정거래법 제23조에 의한 끼워팔기 불공정거래행위 관련 한국토지공사 시정명령 취소 소송[136]에서 “거래상대방이 구입하고자 하지 않는 종된 상품이란 주된 상품의 밀접불가분한 구성요소가 아닌 별개의 상품으로서 독립하여 거래의 대상이 될 수 있고, 통상적으로 주된 상품과 짝지워 하나의 단위로 판매 또는 사용되지 않는 상품이면 족하다”고 판시한 바 있다.

가) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제의 밀접 불가분한 구성요소가 아니다.

PC 운영체제는 하드웨어와 응용프로그램간의 인터페이스(API : Application Program Interface) 역할 및 CPU, 주기억장치, 입출력장치 등의 컴퓨터 자원을 관리하는 기능 등을 수행하는 반면, 메신저는 인터넷 사용자들간 상호 인터넷 접속여부 확인,

136) 서울고등법원 2004. 2. 10. 선고, 2001누16288 판결

실시간 메시지·파일 전송 등의 전혀 다른 기능을 수행하고 있다. 그리고 메신저는 상업적인 인터넷 포털 웹 사이트로의 링크기능과 온라인 광고의 기능을 수행한다는 점에서도, 응용프로그램에 대한 기반 프로그램(platform)의 역할을 수행하며 위의 기능을 갖추지 않은 PC 운영체제와는 확연히 구분되는 별개의 소프트웨어이다.

이와 관련하여 피심인들은 PC 운영체제의 개념에 대해서는 확립된 정의가 존재하지 않으므로 운영체제의 개념에서 메신저 기능을 배제하는 것은 아무런 근거가 없으며, PC 운영체제의 일부 기능인 “그림판”, “워드패드”, “계산기”와 유사하게 윈도우 메신저도 단지 윈도우XP 운영체제에 의하여 제공되는 수많은 기능 하나일 뿐이라고 주장한다.

그러나, 피심인들의 이러한 주장은 다음의 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들은 2003. 9. 17. 위원회에 제출한 의견서에서 “MSN 메신저는 윈도우XP 운영체제의 구성요소로 디자인, 개발 또는 테스트되지 않았고, 따라서 윈도우 구성요소로서 작용하지 않습니다.(이하 생략)”라고 기재하여, MSN 메신저는 “독립적인 응용프로그램의 성격이 강하다”라는 의견을 제출하였다. 이러한 주장은 위에서 살펴본 바와 같이 윈도우 메신저가 MSN 메신저의 한 종류(version)에 불과하므로 윈도우 메신저도 PC 운영체제와 구분되는 응용프로그램임을 사실상 시인하고 있는 것이다.

둘째, 피심인들이 메신저의 별개제품성을 부인하기 위하여 비교대상으로 삼고 있는 그림판, 워드패드, 계산기 기능은 다음과 같은 점에서 오히려 피심인 메신저가 왜 PC 운영체제와 명백히 구분되는 별개제품인지를 보여주는 사례라고 인정된다.

㉠ 그림판, 워드패드, 계산기 기능은 PC 운영체제와 별개로 공급하는 사업자가 없거나 있어도 극히 미미하나, 메신저는 PC 운영체제와 별개로 공급하는 사업자가 다수이다.

㉡ 그림판, 워드패드, 계산기 등의 기능은 PC 운영체제의 업그레이드와 별도로 개선되는 경우가 없음에 비해 피심인 메신저는 PC 운영체제의 업그레이드와 별개로

수시로 업그레이드 되고 있다.

㉢ 그림판, 워드패드, 계산기 기능을 사용하기 위해서는 단지 그 프로그램을 실행한 후 사용하면 되는데 비해, 피심인 메신저는 그 사용을 위해 피심인들이 PC 운영체제 사업과 독자적으로 운영하고 있는 “닷넷 메신저서비스”에 회원으로 가입해야 한다.

또한, 피심인들은 메신저가 윈도우98에 포함되어 있던 운영체제의 일부인 넷미팅(NetMeeting)을 개량한 것에 불과하며, 윈도우 Me에 포함된 MSN 메신저와 윈도우 XP에 포함된 윈도우 메신저를 넷미팅과 구별해야 할 아무런 합리적인 근거도 찾을 수 없다고 주장한다. 그렇기 때문에 메신저도 PC 운영체제의 일부라는 것이다.

넷미팅이 윈도우98에 포함된 운영체제의 일부인지 또는 운영체제로부터 독립한 응용프로그램인지 여부에 대한 판단은 이 사건의 심사대상이 아니므로 하지 않기로 한다. 그러나 그에 관한 판단과는 별도로, 다음과 같은 점을 고려할 때 넷미팅 자체가 메신저와는 다른 별개의 프로그램이기 때문에 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

첫째, 피심인들은 소비자들에게 메신저와 넷미팅을 별개의 프로그램으로 구분하여 제공하고 있다. 피심인들이 소프트웨어개발자에게 윈도우 메신저와 넷미팅을 설명하는 웹문서[137]에 의하더라도, “넷미팅”과 “윈도우 메신저”를 별개의 프로그램으로 구분하여 설명하고 있다.

둘째, 피심인들이 메신저 결합판매를 시작한 윈도우 Me 제품에 대한 안내 웹사이트[138]에 의하면 윈도우 Me에 포함된 MSN 메신저를 설명하면서 넷미팅을 별개의 프로그램으로 서술하고 있다. 즉 MSN 메신저로 할 수 있는 기능을 설명하면서 “NetMeeting 3.1을 이용하면 텍스트 채팅에서 화상대화로 바로 이동할 수 있어요”라고 기재하고 있어서 피심인들이 메신저와 넷미팅을 별개의 프로그램으로 인식하고 있음을 알 수 있다.

137) http://msdn.microsoft.com/library/default.asp「MSDN NetMeeting과 윈도우 메신저를 구분하고 있는 화면」

138) 「Windows Me 홈페이지 - 제품안내 - 온라인 화상 채팅하기」

셋째, MSN 메신저, 윈도우 메신저의 프로그램 파일은 넷미팅 프로그램 파일과 별도의 폴더에 존재하고 있다. 이와 같이 소스 코드가 별도의 그룹으로 나뉘어 존재하고 있음에도 MSN 메신저, 윈도우 메신저와 넷미팅을 구별할 근거가 없다는 피심인들 주장은 인정하기 곤란하다.

한편, 피심인들은 메신저와 관련된 코드를 제거하는 것은 소프트웨어 개발자 및 서비스 사업자, 그리고 소비자에게 상당한 피해를 입히고, 따라서 메신저는 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소라고 주장한다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 위원회는 2005. 11. 21. 한국소프트웨어진흥원에 의뢰하여 메신저 제거가 윈도우 운영체제에 미치는 영향을 실험하였다. 그 결과, 윈도우 XP와 유사한 윈도우 XP 임베디드에서 윈도우 메신저를 제거 한 후 제3의 메신저를 설치하여도 '원격지원 기능'을 제외한 OS 설치 및 부팅, 하드웨어 식별 및 제거, 네트워크 기능 등이 모두 정상적으로 작동한다는 사실을 확인하였다. 원격지원 기능은 운영체제와 무관하게 피심인들의 메신저에 의해서만 기능을 수행할 수 있도록 설정되었기 때문에 원격지원 기능이 오작동하더라도 윈도우 운영체제의 오작동과는 관련이 없는 것이다.

둘째, 인터넷 웹사이트[139]에서는 윈도우 XP에서 윈도우 메신저를 안전하게 제거할 수 있는 프로그램이 일반인들에게 제공되고 있다. 이 명령을 수행하면 윈도우 메신저 관련 레지스트리(registry)를 정리하고, 관련파일들을 지우고, 불필요한 DLL파일을 제거하는 등의 프로그램 제거작업이 수행된다. 위원회는 이 소프트웨어를 사용하여 윈도우XP에 설치된 윈도우 메신저를 제거하였는데, 인터넷 익스플로러 상단에 표시되어 있던 윈도우 메신저 아이콘이 제거되는 등 다른 PC 운영체제의 오작동 없이 윈도우 메신저가 안전하게 제거된 것으로 나타났다.

결국, 윈도우 PC 운영체제에서 메신저를 제거한다고 하여도 일반적인 응용프로그램이

139) 웹사이트(http://www.ngweb.biz/software/remmsg.shtml)에서 윈도우 메신저를 안전하게 제거해주는 소프트웨어(remmsg.zip)를 다운로드받을 수 있다.

제거되는 경우보다 특별히 더 많은 부정적 효과가 발생한다고 보기는 어려우므로 피심인들의 메신저는 윈도우 PC 운영체제의 밀접 불가분한 구성요소가 아니라고 인정된다.

나) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

소비자들은 PC 운영체제와 별개로 메신저를 수요하고 있으며, 공급자들 또한 PC 운영체제와 독립적으로 메신저를 공급하고 있어 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 된다.

① 소비자들은 PC 운영체제와 별개로 메신저를 수요하고 있다.

PC 운영체제와 메신저는 소비자들의 구매방법, 실제 수요, 그리고 실제 사용행태 등의 면에서 현격한 차이를 보이기 때문에 별개로 수요되고 있다고 인정된다. 이에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 두 제품에 대한 수요자의 구매방법에 대하여 살펴본다. 보통 PC 운영체제는 컴퓨터 제조업자로부터 컴퓨터를 구매할 때 운영체제에 대한 금전적 대가를 지불하거나, 소매상에게 운영체제에 대한 금전적 대가를 직접 지불하는 방식으로 거래된다. 반면, 메신저의 경우 사용자들은 운영체제 거래와 무관하게 인터넷을 통해 다운로드 받아 설치한 후 사용하고 있으며 메신저에 대하여 별도의 금전적 댓가를 지불하지 않고 있다.

둘째, 피심인 메신저 없는 운영체제를 사용하려는 수요가 상당수 존재하는 사실도 양 자의 수요가 분리되어 있음을 입증한다. 즉, 피심인들이 2003년 11월 코리안클릭에 의뢰하여 실시한 조사결과에 따르면 <표 4-2>, <표 4-3>에서 보는 바와 같이 1000명의 전체 응답자의 19.5%가 피심인 메신저가 컴퓨터에 기본 장착되어 있어 컴퓨터나 인터넷을 이용할 때 불편하다고 답하였다. 그리고 이들 불편함을 느끼는 사용자 중 피심인 메신저를 컴퓨터에서 완전히 삭제하기를 원하는 소비자가 68.7%(134명)에 달하였다. 이상의 응답결과들은 피심인 메신저 없는 PC 운영체제에 대한 수요의 존재

를 분명하게 나타내고 있는 것으로 인정된다.

<표 4-2> 피심인 메신저가 장착되어 있는 것이 불편한지 여부(2003. 11.)

구분	전혀 불편하지 않음	별로 불편함을 주지 않음	보통이다/ 그저 그렇다	어느정도 불편을 줌	매우 불편을 줌
윈도우XP 사용자(427명)	19.9	34.4	26.0	16.4	3.3
윈도우XP외 사용자(573명)	14.0	38.4	28.3	17.4	1.9
전체 응답비율	16.5	36.7	27.3	17.0	2.5

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 6. 10.)

<표 4-3> 피심인 메신저 장착이 불편할 경우 완전한 삭제 희망여부(2003. 11.)

구분		피심인 메신저 제거 희망	별로 상관없다
운영 체제별	윈도우XP 사용자(84명)	69.0	30.9
	윈도우XP외 사용자(111명)	68.5	31.5
연령대별	10~18세	64.4	35.6
	19~24세	65.8	34.2
	25~29세	80.0	20
	30~34세	73.3	26.7
	35~39세	65.4	34.6
	40세 이상	61.9	38.1
전체 응답비율		68.7	31.3

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 6. 10.)

② 공급자들은 PC 운영체제와 독립적으로 메신저를 공급하고 있다.

공급 측면을 살펴보아도, PC 운영체제와 메신저는 별개의 제품임이 명백하다.

첫째, 피심인들을 제외한 대부분의 메신저 사업자들은 PC 운영체제 개발 및 판매업을 영위하지 않고 메신저를 독립적으로 개발하여 공급하고 있다[140]. 양 자를 같이 개

140) 이러한 공급관행은 본건 심사의 대상이 되는 일반용 메신저 뿐만 아니라 기업용 메신저 시장에서도 동일하다.

발·공급하는 피심인들 또한 PC 운영체제와는 다른 방법으로 메신저를 사용자들에게 공급하고 있다.

둘째, 피심인들은 자신 및 다른 사업자의 PC 운영체제에 설치할 수 있도록 다양한 버전의 메신저를 제작하여 공급[141]하고 있다. 이렇게 사용자가 어떤 PC 운영체제를 갖고 있는지에 상관없이 메신저를 사용할 수 있도록 피심인들이 거의 모든 PC 운영체제에 설치할 수 있는 메신저를 공급하고 있다는 점은 PC 운영체제와 메신저가 별개제품이라는 사실을 입증하고 있다.

③ 피심인들도 피심인 메신저를 PC 운영체제의 일부가 아닌 응용프로그램의 일종으로 인식하고 있다.

피심인들은 1999. 7. 21. 배포한 보도자료[142]에서 “MSN 메신저 서비스는 사용자들이 요구하고 있는 상호호환성을 제공하는 최초의 메시징 응용 프로그램이다”(중간생략)”, 라고 기재하여 피심인들은 MSN 메신저가 응용프로그램임을 분명히 하고 있다. 또한 2001. 12. 4. 피심인들이 위원회에 제출한 답변자료에서도 MSN 메신저는 ‘다음커뮤니케이션의 메신저 프로그램과 유사하게 포털 사이트로의 연결, 광고 등을 포함하고 있어서 독립적인 응용프로그램으로서의 성격이 강한 제품’임을 인정하고 있는데, 피심인들이 앞에서 살펴 본 바와 같이 윈도우 메신저를 MSN 메신저의 한 버전으로 인식하고 있으므로, 결국 피심인들은 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 모두 응용프로그램으로 인식하고 있는 것으로 인정된다.

다) 통상적으로 메신저는 PC 운영체제와 하나의 단위로 판매되지 아니한다.

피심인 메신저 외의 메신저는 PC 운영체제와는 다른 공급자들이 존재하고 있고,

141) 윈도우 메신저의 경우 윈도우XP 및 윈도우2000의 서비스팩 2 이후 버전에서 설치될 수 있는 버전이 별도로 제공되고 있으며, MSN 메신저의 경우, 윈도우95, 윈도우98, 윈도우Me, 윈도우2000 프로페셔널, 윈도우XP 뿐 아니라 애플의 매킨토시 설치용 등 거의 모든 PC 운영체제 별로 그에 적합한 메신저가 공급되고 있다

142) 원문은 다음과 같다. "MSN Messenger Service is the first messaging application to offer the interoperability people are demanding." (중간생략) With a program size of only 320 KB, MSN Messenger Service is the smallest of any major instant messaging client application.

공급방식도 주로 인터넷을 통해 다운로드 방식으로 이루어지므로 PC 운영체제와 짝지어 판매·공급되지 않는다.

물론, 일부 PC 운영체제 사업자들이 자신의 운영체제에 메신저를 설치하여 판매하는 사례가 있다. 즉, 미국 애플(Apple)사는 2002. 7. 출시한 Mac OS X 10.2(Jaguar) 운영체제에 인스턴트 메시지 프로그램인 아이챗(ichat)을 포함하고 있고, 공개 운영체제인 한국 와우리눅스의 배포판('파란 R2')에는 메신저 프로그램인 가임(GAIM)이 옵션으로 포함되어 있다. 그러나 이러한 사실에도 불구하고 다음과 같은 이유로, 운영체제와 메신저가 별개의 프로그램이라는 사실에는 변함이 없는 것으로 판단된다.

첫째, 피심인들을 제외한 대부분의 메신저 사업자들은 PC 운영체제 개발 및 판매업을 영위하지 않고 메신저를 독립적으로 개발하여 공급하고 있다. 양자를 같이 개발·공급하는 피심인들 또한 PC 운영체제와는 다른 방법으로 메신저를 사용자들에게 공급하고 있다. 예를 들어, 피심인들은 MSN 메신저를 윈도우Me라는 PC 운영체제에 포함하여 판매함과 동시에 PC 운영체제 공급과 무관한 별도의 방법으로 MSN 메신저를 공급하고 있으며, 윈도우 메신저의 경우에도 PC 운영체제와 결합판매하는 것과는 별도로 인터넷 웹사이트를 통하여 공급하고 있기도 하다.

둘째, 애플이나 리눅스 운영체제는 시장점유율이 극히 미미한 수준에 불과하다. 특히 피심인들을 제외한 일부 PC 운영체제 사업자들이 운영체제에 포함하고 있는 메신저는 시장에서의 존재가 극히 미미한 소프트웨어이기 때문에 메신저 시장내 경쟁관계에서 차지하는 의미가 무시할 정도이다. 따라서 이와 같이 무시할 정도의 경쟁상 존재가치 밖에 없는 경우를 들어 일반적인 거래관행이라고 하기는 어렵다고 판단된다.

셋째, 피심인들 이외의 다른 PC 운영체제 공급자들은 구매단계에서 또는 구매 이후에 소비자가 원할 경우 메신저를 삭제할 수 있도록 하고 있다는 점에서 피심인 메신저와 커다란 차이가 있다.

이와 관련하여 피심인들은 기존의 운영체제에 새로운 기능을 추가·통합하여 더

향상된 운영체제를 개발하는 것은 사업자의 시장지배력 유무에 관계없이 매우 빈번하게 일어나는 보편적인 현상이라는 점, 그리고 윈도우 메신저가 MSN 메신저와 달리 윈도우 플랫폼의 일부로서 소프트웨어 개발자에게 시스템 서비스를 제공하고 있다는 점 등을 들어 별개제품성을 부인하고 있다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, PC 운영체제 소프트웨어 시장에서 새로운 기능이 추가되는 기술혁신이 발생하고 있다는 일반적 사실은 PC 운영체제 산업의 일반적인 특성에 관한 참조사항에 불과하며, PC 운영체제와 메신저의 별개제품성을 판단하기 위한 구체적인 기준이 될 수는 없다. 이러한 산업의 일반적인 특성을 이유로 별개제품성을 부인할 경우, PC 운영체제 사업자들이 새로운 제품에 포함시키는 어떤 기능에 대해서도 별개제품성이 부인되는 부당한 결과가 초래될 우려가 있다.

소프트웨어산업의 보편적 특성과 관련하여서는 동태적인 기술혁신의 결과라는 긍정적 효과 이외에 시장지배력 남용에 의한 독점력 확장의 가능성이 존재한다는 주장[143]도 있다. 따라서 피심인들의 위 주장처럼 소프트웨어산업의 보편적 특성을 이유로 PC 운영체제와 메신저의 별개제품성을 부인할 수는 없다고 판단되며, 두 제품간 별개제품성에 대한 판단을 위해서는 앞에서 기술한 바와 같이 별개 수요의 존재 여부 등에 대한 구체적인 검토가 수행되어야 한다.

둘째, 윈도우 메신저가 소프트웨어개발자에게 응용프로그램 개발을 위한 일부 기능을 제공하고 있다는 점을 이유로 별개제품성을 부인하는 것 또한 위와 마찬가지로 피심인들의 주관적 의사결정에 의하여 별개제품성을 부인하게 되는 부당한 결과가 초래된다는 점에서 타당하지 않다. 나아가 제3의 소프트웨어 개발자를 위한 기능 제공은 PC 운영체제와 별개임이 명백한 다른 응용프로그램들도 유사하게 제공하고 있는 사실이 감안되어야 한다.

143) 「정보통신 기술혁신에 대응한 공정경쟁정책 연구(2000. 12.)」, 정보통신정책연구원 김희수 외 5인 공저

2) 피심인들의 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 거래상대방에게 부당하게 피심인 메신저의 구입을 강제한 것이다.

「불공정거래행위 심사지침」은 '구입강제성' 여부를 거래상대방의 입장에서 주된 상품과 종된 상품을 따로 구입하는 것이 자유로운지를 기준으로 판단하도록 규정하고 있다. 이때, 강제성은 주된 상품에 대한 구매자의 거래처 전환 가능성이 적을 수록 큰 것으로 판단된다. 불공정거래행위 중 끼워팔기에 관한 판례도 구입강제에 대하여 거래상대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 것으로 판시[144]하고 있다.

피심인들의 결합판매행위는 다음의 점을 고려할 때 구입강제성이 존재하는 것으로 인정된다.

첫째, 피심인들이 PC 운영체제 시장을 거의 100% 독점하고 있는 상황에서, 피심인들이 메신저가 포함되지 않은 윈도우 PC 운영체제를 판매하지 않음으로 인해 소비자들은 메신저가 포함되지 않은 PC 운영체제를 선택할 자유를 박탈당하고 있다.

둘째, 윈도우 XP 구매자 중 상당수가 이에 포함된 메신저를 사용하지 않고 다른 메신저를 사용하는 것으로 나타났다. 예를 들어 피심인들이 코리안클릭에 의뢰하여 2003. 11.에 조사한 결과에 의하면, 윈도우 XP 사용자의 45.0%가 피심인 메신저 대신 다른 사업자의 메신저를 이용하고 있는데, 적어도 이들 사용자들에 대하여는 본인이 사용할 의사가 없는 메신저를 자신의 의사와 관계없이 운영체제와 함께 구입하도록 강제되었다고 볼 수 있다.

셋째, 기업소비자의 경우, 상당수가 보안 누출, 바이러스 침투, 직원의 근무 태만 등을 우려하여 메신저 사용 자체를 금지하고 있다는 점에서, 메신저 없는 운영체제를 원한다는 사실을 간접적으로 나타내고 있다.

또한 상당수의 소비자들이 윈도우 PC 운영체제에 메신저가 기본적으로 설치된다는

144) 서울고등법원 2004. 2. 10. 선고, 2001누16288판결

사실 자체에 불편함을 느끼고 이들 중 상당수는 윈도우 메신저가 컴퓨터에서 제거되기를 희망하고 있다는 사실에 대하여는 별개제품성 인정부분에서 이미 살펴본 바 있다.

결국, 피심인들이 PC 운영체제 시장을 독점하고 있는 상황에서 메신저가 포함된 윈도우 PC 운영체제만을 판매하고 메신저가 포함되지 않은 윈도우 PC 운영체제를 판매하지 않는 행위는, 피심인들의 시장독점에 따라 피심인들의 PC 운영체제를 구입할 수밖에 없는 소비자에게 메신저의 구매를 사실상 강제한 행위라고 인정된다.

이에 대해 피심인들은 구입강제성이 성립하기 위하여는 유상구입[145]이 전제되어야 하는데, 메신저는 무료 제공되는 것이기 때문에 구입강제성이 성립하지 않는다고 주장하나, 시장지배적지위 남용행위 중 사업활동 방해에 관한 법령에서는 결합판매에 있어 소비자들이 반드시 유상으로 부상품을 구입할 것을 요건으로 하고 있지 않으므로 피심인들의 주장은 이유 없다[146].

또한, 피심인들은 소비자들이 메신저 사용을 강제당하지 않고 다른 메신저를 사용할 수 있으므로 구입강제성이 없으며 컴퓨터나 전자제품과 같이 다양한 기능을 갖춘 소비자 제품의 경우 소비자들이 일부 기능을 사용하지 않는다고 하여 그 사용하지 않는 기능에 대해 구입강제가 있다고 할 수 없다고 주장한다.

그러나, 구입강제성은 운영체제의 구입시점에서 판단되어야 하는 것으로, 구입 후 소비자가 다른 사업자의 미디어 플레이어를 선택할 수 있다는 사실은 강제성과 무관하며 구입강제의 성립여부는 소비자가 실제로 강제된 부상품을 사용하는지의 여부에 달린 것이 아니라, “소비자가 부상품 없는 주상품을 구입할 수 있는지 여부”와 관계된 것이므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

145) 윈도우 메신저의 제공이 무상이라는 피심인들의 주장도 앞에서 살펴본 바와 같이 소프트웨어 산업 특성상 경쟁법적 관점에서 이를 무상으로 보기 어렵다.

146) EU의 경쟁법 관련규정이나 심결상으로도 경쟁제한적인 결합판매는 강제성(coercion)만이 요구되고 유상성은 필요로 하지 않는데 이는 이미 앞에서 살펴본 바와 같다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

공정거래법상 “불이익”이라 함은 반드시 거래상대방이 금전적으로 손해를 입는 것 뿐 아니라, 경제적·사회적으로 불리한 위치에 있게 되는 모든 현상을 말한다고 보는 것이 타당하다. 즉, 거래상대방에게 당장의 경제적 손해는 없다 하더라도 잠재적으로 경제적 이익을 빼앗긴다거나 장래의 기대이익이 박탈당하는 경우, 거래선택의 자유를 침해당하는 경우, 그리고 상응하는 권리취득 없이 의무만을 부담하는 경우 등을 포괄하는 의미로 보는 것이 상당하다.

피심인들이 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매하는 행위는 다음에서 보는 바와 같이 피심인 메신저의 구입을 원하지 않는 소비자에게 피심인 메신저에 대한 구입을 강제하여 소비자의 상품 선택권을 침해함과 동시에 양질의 제품을 접할 수 있는 기회를 차단하여 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

첫째, 피심인들은 PC 운영체제 시장에서 거의 100%로의 시장점유율을 보유한 독점적 사업자이기 때문에 보통의 소비자들이 다른 운영체제를 선택하는 것은 사실상 불가능하다고 여겨진다. 이는 소비전환비용의 존재와 응용프로그램에 의한 고착효과 등이 매우 크기 때문이다. 이는 피심인 메신저의 구입을 원하지 않는 거래상대방에게 메신저의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 상품 선택권을 과도하게 제약하는 불이익을 발생시키고 있다.

둘째, 피심인들에 의해 PC 운영체제에 응용프로그램인 피심인들의 메신저가 결합되어 있다는 점은 PC 제조업체들로 하여금 피심인들의 메신저와 유사한 기능을 수행하는 다른 사업자의 메신저를 탑재할 유인을 상당히 감소시키게 된다. 이는 소비자에게 피심인 메신저와 유사한 기능을 수행하는 다른 사업자의 메신저를 선택할 권리를 상당히 제약하게 되며 결국 성능과 품질에 의한 경쟁을 저해하여 거래상대방으로 하여금 우수한 제품의 사용을 사용할 수 있는 권리를 사실상 박탈하는 불이익을 발생시키고 있는 것이다.

4) 소결

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개제품인 피심인 메신저를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로서 이는 부당하게 소비자의 메신저에 대한 선택권을 침해하고, 이는 결국 종된 상품 시장인 메신저 시장에서 품질 및 가격에 의한 경쟁을 저해하여 소비자가 우수한 다른 제품을 접할 기회를 제약하는 불이익을 초래하는 바, 따라서 피심인들의 결합판매행위는 불이익한 거래를 강제한 행위에 해당한다.

참고로, 피심인들이 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합한 행위는 피심인 메신저가 제조단계에서 결합되어 추가비용의 지불 없이 판매되므로 사용자가 쉽게 설치하고 무료로 사용할 수 있다는 점에서 거래비용을 감소시키고, 새로운 응용프로그램의 개발을 용이하게 하여 소프트웨어개발업자에게 이익이 되며, PC 운영체제에 대한 수요의 증가를 가져와 컴퓨터 제조업체에 대한 혜택을 제공하는 등의 효율성이 있다는 취지의 주장을 한다.

그러나, 피심인들이 주장하는 편익은 피심인 메신저가 아니라 다른 메신저를 결합하여 판매하는 경우에도 발생할 수 있는 것으로서, 본 건 결합판매에 특유한 편익이라고 보기 어렵다. 이미 앞에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 결합판매행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 불이익한 거래를 강제한 행위로 명백히 인정되는 반면, 가사 피심인들이 주장하는 결합판매로 인한 편익을 어느 정도 인정하더라도 피심인들의 결합판매행위가 가져오는 심각한 경쟁제한의 폐해를 상쇄할 정도에 이르지 못하여 피심인들의 주장을 받아들이기 곤란[147]하다.

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

피심인들이 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 종된 상품 시장인 메신저 시장에서 피심인 메신저의 편재성을 발생시켜 피심인 메신저로의 쏠림현상을 초래함으로써 메신저 시장의 경쟁사업자의 사업활동을 어렵게 하고 신규 사업

147) 이에 관한 구체적 주장에 대한 반박은 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기부분에서 자세히 기술한다.

자의 진입을 곤란하게 하는 진입장벽을 형성하는바, 이러한 행위는 거래상대방인 소비자들의 메신저에 대한 상품 선택의 자유를 침해하고, 메신저 시장에서 양질·염가의 상품을 제공함으로써 고객을 확보한다는 “장점에 의한 경쟁”을 저해하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

1) 피심인들은 결합판매를 PC 운영체제 시장의 독점력 전이수단으로 사용하고 있다.

피심인들은 윈도우 XP 등 PC 운영체제에 메신저를 결합판매하여 PC 운영체제 시장의 독점적 지배력을 지렛대로 활용하여 메신저 시장의 경쟁상 우위를 획득하는 등 PC 운영체제시장에서의 독점력 전이수단으로 이용하려는 의도를 가지고 있다.

첫째, 피심인 한국 엠에스의 MSN사업부 총괄이사가 1999년 하반기에 작성한 「MSN Thunderstorm Partner」라는 전략보고서에는 MSN 관련 제품의 공급을 위해 피심인의 자산(“MS assets″)을 지렛대로 활용한다(“Marketing Strategies (중간생략) Leverage MS assets for distribution”)고 기재하고 있다.

이 보고서는 피심인의 자산으로서 윈도우 운영체제, 오피스(Office) 프로그램, 인터넷 익스플로러 등을 들고 있다. 당시 MSN사업부는 메신저, 전자우편 서비스, 포털사이트 운영 등의 마케팅 현안을 갖고 있었으므로, 결국 피심인 한국 엠에스는 윈도우 운영체제의 시장지배력을 메신저 공급에 활용한다는 전략을 수립한 것으로 추정할 수 있다. 그리고 이러한 의도는 실제 윈도우Me에 MSN 메신저를 포함하여 판매하는 행위로 실현되었으므로, ‘의도의 존재’ 여부는 ‘피심인들의 행동’으로서도 확인된다.

특히 이 문서를 작성한 피심인 MSN사업부는 피심인 스스로 PC 운영체제와 별개의 제품으로 인정하고 있는 MSN 메신저 등 각종 응용프로그램 및 서비스 판매 사업 등을 담당하는 부서이므로, 위 문서들에 나타난 메신저 결합판매의 의도는 PC 운영체제와 별개제품의 관계에 있는 MSN 메신저를 통한 수익 확대를 위해 PC 운영체제의 독점력을 지렛대로 이용하려는 것임을 알 수 있다.

둘째, 피심인 한국엠에스 MSN사업부가 2001. 3. 13.에 작성한 “다음 단계 수익창

출(“Next Level″ Revenue Generation)이라는 또 다른 전략보고서에서도 한 단계 도약하기 위한 전략(Level-up Strategy)으로서 윈도우XP 출시, MSN전용 인터넷 브라우저(코드명 “MARS″)를 지렛대로 사용한다고 기재되어 있다[148]. 당시 MSN사업부의 이 전략보고서는 메신저를 포함한 MSN사업 전체와 관련된 것이었으므로, 윈도우XP 출시를 지렛대로 활용하여 한 단계 도약한다는 전략은 메신저에도 적용되는 것으로 인정된다.

따라서 이 보고서의 내용 역시 피심인들이 윈도우XP와 메신저를 결합판매하는 방법으로 PC 운영체제 시장의 지배력을 지렛대로 활용하여 메신저 사업에서 경쟁상 우위를 차지하기 위한 의도를 갖고 있었음을 알게 한다.

셋째, 피심인 엠에스의 MSN사업부가 2004. 1. 28. 작성한 「Communication Services and Member Platform - MYR Strategy Deck」라는 보고서에서도 결합판매를 통해 PC 운영체제의 지배력을 지렛대로 활용하려는 의도를 엿볼 수 있다.

이 보고서에 의하면 차기 PC 운영체제와 MSN 서비스를 결합하는 것은 아래 그림에 나타나는 것과 같이 가입자당 매출(ARPU : Average Revenue Per User), 방문율(attach rate), 피심인들 핵심제품의 사용(adoption of key Microsoft products) 등을 증가시킨다면서, 향후 출시될 PC 운영체제의 각 버전에 따른 MSN서비스 통합 계획을 보여주고 있다[149].

피심인의 이러한 MSN서비스와 차기 윈도우 운영체제의 결합 의도는 결국 PC 운영체제 시장의 지배력을 이용하여 MSN서비스를 제공하여 경쟁상 우위를 획득하겠다는 것인데, 이러한 의도는 이미 출시된 윈도우 Me 및 윈도우 XP에서의 메신저 결합판매에도 그대로 적용되었을 것으로 추정된다.

---

148) 파워포인트로 작성된 해당부분 영어 원문은 “Leverage the Mars/Windows XP momentum”

149) 피심인들이 차기 운영체제에 MSN 서비스를 결합시킬 의도를 갖고 있었다는 점은 피심인들이 위원회에 제출한 다음 전자우편에서도 알 수 있는데, 이 전자우편의 내용은 다음과 같다. “(앞 생략) This is an update on the status of the high-level plan for integrating messenger in Longhorn - and some changes happening in the Windows team to support it vis a vis RTC and Windows Messenger. (중략) MSN Messenger becomes the Default IM experience in Longhorn. - MSN Messenger will be in the Longhorn builds by the end of CY 2003 - Will participate in Windows processes - project reviews, basics, scenario reviews (중략) We are going to pull together a brown bag meeting in early September with the Windows, MSN and RTC teams to provide a forum for further discussion and Q&A. (이하 생략)”「피심인 직원간 전자우편(제목 : “Fw : Messenger in Longhorn″(2003. 8. 22.)」

<그림4-4> 피심인 엠에스 내부 보고서(2004. 1.)

* 내부보고서의 구체적 내용은 피심인들이 사업상 비밀에 관한 사항으로 비공개를 요청한 사항임

2) 피심인들의 행위는 메신저 시장에서 경쟁을 제한한다.

가) 피심인들의 행위는 피심인 메신저의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 메신저 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

피심인들은 결합판매를 통해 거의 모든 새로운 PC에 피심인 메신저가 설치되도록 함으로써 다른 사업자가 누릴 수 없는 편재성을 획득하였다. 이에 비하여 피심인들의 경쟁사업자들은 인터넷 다운로드 경로 또는 PC 탑재 경로 등을 통하여 자신의 메신저를 소비자에게 공급하고 있으나, 이러한 방법으로는 피심인들과 동등 또는 유사한 수준의 편재성을 누리기 곤란하다.

① 경쟁사업자들이 다운로드에 의해 피심인 메신저의 편재성을 극복하기 어렵다.

첫째, 피심인들을 제외한 다른 메신저 사업자들이 PC 운영체제에 자신의 메신저를 탑재하더라도 뒤에서 살펴보는 바와 같이 피심인 메신저가 누리는 정도의 편재성을 갖지 못하기 때문에 인터넷망이 발달한 우리나라 환경에서도 사업자들이 치열한 경쟁을 뚫고 인터넷 사용자들의 까다로운 선택을 받을 수 있도록 노력하고 있음은 3. 라. (2) (다) 1) 가) ①에서 살펴본 바와 같다

'네이트온'이라는 메신저를 공급하고 있는 SK커뮤니케이션즈 또한 2005. 9. 21. 전원회의에서 이러한 취지의 의견을 제출하였다. 즉, 자신들은 소비자들로 하여금 인터넷을 통해 네이트온 메신저를 다운로드 받도록 하기 위한 막대한 마케팅 비용을 지속적으로 지출하고 있는데 비해, 피심인들은 이러한 노력없이 모든 PC에 자신의 메신저를 설치토록 하고 강력한 네트워크를 창출하고 있다는 점에서 경쟁기반에 커다란 차이가 있다는 것이다.

둘째, 소비자들은 필요 이상의 소프트웨어 설치를 꺼리는 것이 일반적이다. 특히, 상당수 소비자들은 동일한 기능을 수행하는 여러 개의 소프트웨어의 경우에 더욱 중복 설치를 꺼리기 때문에, 이미 PC에 피심인들의 메신저가 존재한다는 사실은 다른 사업자들의 메신저 다운로드 유인을 감소시키게 된다. 결국 경쟁사업자들이 다운로드 경로를 통해 피심인 메신저의 편재성을 달성하는 것은 거의 불가능하다고 할 수 있다.

셋째, 인터넷을 통한 메신저 프로그램 다운로드를 어려워 하는 초보 사용자들이 상당수에 달하기 때문에 인터넷 다운로드 경로가 피심인들의 결합판매 경로에 비해 현저히 열등한 경로임은 3. 라. (2) (다) 1) 가) ①에서 살펴본 바와 같다.

이러한 사실을 종합해 볼 때, 경쟁 메신저를 다운로드 받을 수 있는 기술적 환경이 아무리 우수하더라도, 다운로드를 통한 메신저의 배포는 윈도우 운영체제에 포함된 피심인 메신저의 편재성을 상쇄할 수 없는 정도인 것으로 인정된다.

② 경쟁사업자들이 PC 제조단계에서의 탑재경로에 의해 피심인 메신저의 편재성을 극복할 수 없다.

㉮ PC 제조업체 측면

첫째, PC 제조업체가 구매한 피심인들의 PC 운영체제에 이미 피심인들의 메신저가 포함되어 있고 이를 삭제할 수 없다는 사실은 이익률이 극히 낮은 상황[150] 하에서 테스트 비용 및 고객지원 비용의 절감을 위해 노력하는 PC 제조업체로 하여금 거의 동일한 기능을 수행하는 메신저를 중복 설치할 유인을 감소시킨다는 사실은 3. 라. (2) (다) 1) 가) ②서 살펴본 바와 같다.

둘째, 국내 상당수 기업들이 보안 유출, 바이러스 및 스팸 침투, 업무효율성 저하 등을 우려하여 직원들의 일반용 메신저 사용을 금지시키고 있다는 사실은 이미 앞에서

150) 국내 PC 제조업체의 경상이익율은 0.1%에 불과하다 「한국신용평가정보-컴퓨터 시장 동향과 전망(2003. 12. 31.)

기재한 바 있다. 이러한 스팸 및 바이러스 침투시 발생하게 되는 애프터 서비스 비용의 증가 등에 대한 PC 제조업체들의 우려는 피심인 메신저 이외에 추가적으로 다른 사업자의 메신저를 탑재할 유인을 현저히 감소시키게 된다.

㉯ PC 제조업체와 피심인들의 관계 측면

PC 제조업체와 피심인들이 동업자적 이해관계를 갖고 있다는 점은 PC 제조업체가 피심인들과 경쟁관계에 있는 메신저를 탑재할 유인을 감소시키고 있다. PC 제조업체와 피심인들은 기술개발, 마케팅 등 여러 분야에서 매우 밀접한 동업관계를 맺게 되는데 이는 컴퓨터 하드웨어와 컴퓨터 운영체제가 다음과 같이 기술적 또는 상업적으로 매우 밀접한 상호의존성을 갖고 있기 때문이며 이에 대한 구체적 내용은 3. 라. (2) (다) 1) 가) ②에서 살펴본 바와 같다.

㉰ 메신저 사업자 측면

피심인들과 경쟁관계에 있는 메신저 사업자가 피심인들과 동등 또는 유사한 수준의 편재성을 획득하는 것은 불가능한 것으로 판단된다. 이는 위에서 본 바와 같이 새로운 PC에 자사 메신저를 탑재하는 데 상당한 어려움이 존재하는 것과 같은 현실적 제약 때문에 더욱 그러하다. 이에 대한 구체적은 내용은 3. 라. (2) (다) 1) 가) ②에서 살펴본 바와 같다.

③ 코드제거 곤란은 피심인 메신저의 편재성에 의한 네트워크 효과를 더욱 강화시키는 것으로 인정된다.

피심인들은 윈도우Me에 포함된 MSN 메신저에 대해서는 안전하게 MSN 메신저를 제거하는 기능(Program Add/Remove Utility)을 제공하였다. 이에 따라 사용자는 자신이 다른 메신저를 사용하여 MSN 메신저를 설치할 필요가 없다고 판단되는 경우 PC 운영체제의 오류없이 안전하게 MSN 메신저 코드를 제거할 수 있었다. 그러므로 윈도우Me와 관련하여서는 코드 제거 곤란에 따른 경쟁상 우위는 발생하지 않는다[151].

그러나 피심인들은 윈도우XP에서는 윈도우 메신저 코드를 안전하게 삭제할 수 있는 기능을 제거하였다.

피심인들이 2003. 11. 코리안클릭에 의뢰하여 실시한 설문조사결과에서 윈도우 메신저가 컴퓨터에 기본 장착되어 있어 컴퓨터나 인터넷을 이용할 때 불편하다고 응답한 자가 전체(1,000명)의 19.5%에 달하고, 이들 불편함을 느끼는 자 중 윈도우 메신저를 컴퓨터에서 완전히 삭제하기를 원하는 소비자가 68.7%(134명)에 달하였음은 이미 앞에서 살펴 보았다. 또한 윈도우XP 사용자(427명) 중 윈도우 메신저가 완전히 제거되기를 원하는 소비자가 19.7%(84명)에 달한다. 그럼에도 소비자들이 운영체제의 오작동 우려 등을 이유로 제거하지 못한다는 점은 다른 메신저 사업자들에 비해 또 하나의 경쟁상 우위 요소가 되며 이는 피심인 메신저의 네트워크 효과를 증가시키는 효과를 발생시킨다.

나) 피심인 메신저의 편재성은 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시킴으로써 피심인 메신저로의 쏠림현상을 초래한다.

① 피심인 메신저 결합판매가 피심인 메신저 사용률에 강한 영향을 미친다.

피심인들의 메신저 결합판매가 메신저 가입자 확보에 강력한 영향을 미친다는 사실은 피심인들 내부문서, 설문조사 결과, 메신저이용 행태에 대한 통계분석 결과 등을 살펴보면 알 수 있다.

㉮ 피심인 한국 엠에스의 내부문서

피심인들의 메신저 결합판매가 피심인 메신저에 강력한 경쟁상 우위를 제공하였음은 우선 피심인 한국 엠에스의 내부문서에서 확인된다. 이는 다음에서 살펴볼 설문조사 결과 및 메신저 이용률 분석결과 등과도 일치하는 것이다.

첫째, 피심인 한국 엠에스의 MSN사업부가 2002. 5. 메신저 시장 현황, 마케팅 주

151) 다만, MSN 메신저가 결합되어 발생하는 강한 편재성은 별론으로 한다.

요현황, 메신저의 강점 및 약점을 분석한 전략보고서[152]에 의하면 메신저가 운영체제에 기본프로그램으로 설치되어 있다는 점("OS Default installation")을 강점의 하나로 평가하고 있다. 이는 피심인들 스스로 윈도우Me 및 윈도우XP에 메신저를 포함한 행위가 메신저 가입자 확보에 상당한 영향을 미쳤음을 인정하고 있는 것이다.

둘째, 피심인 엠에스 MSN사업부가 2004. 1. 작성한 전략보고서[153]에서는 차세대 윈도우 운영체제와 MSN 메신저를 결합하는 것이 가입자당 매출, 방문율, 피심인들의 핵심제품의 사용 등을 증가시킬 것이라고 기재[154]하고 있다. 이때 동 문서가 MSN 메신저 등 각종 응용프로그램 및 서비스 판매 사업 등을 담당하는 피심인 한국 엠에스 MSN 사업부에서 작성된 것이라는 점을 고려할 때 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합판매 하는 것이 MSN 제품의 공급과 매출 등을 확대시켜 메신저 시장점유율 확보 등에서 상당한 경쟁상 우위를 제공할 수 있음을 피심인들 스스로 인정하고 있다고 판단된다.

㈏ 메신저 사용자에 대한 설문조사 결과

피심인들의 메신저 결합판매가 가입자 확보 경쟁에서 피심인들에게 강력한 경쟁상 우위를 제공하였다는 점은 메신저 사용자에 대한 설문조사에서도 확인된다.

첫째, 피심인들이 코리안클릭에 의뢰하여 2003. 10월경 실시한 「OS에 따른 메신저 이용행태 리서치」라는 설문조사 결과 보고서에 의하면, 윈도우XP에 윈도우 메신저가 기본 설치되어 있다는 사실이 메신저를 선택하는데 얼마나 영향을 미쳤는지에 대한 질문에 윈도우 메신저 이용자(109명)의 21.1%가 "매우 영향을 미쳤다"고 응답하였고,

---

152) 이 문서는 피심인 엠에스에서 MSN 메신저를 담당하고 있는 직원에 의해 작성되었다. 동 문서에서 피심인들은 메신저에 대한 스윗 분석(SWOT 분석 ; 경영전략을 수립하기 위하여 현재와 미래의 환경을 분석하는 전통적인 경영분석기법)을 수행하고 있는데, 강점(Strengths)으로서 운영체제에의 기본설치 이외에도 클라이언트 소프트웨어의 안정성(Client Stability), 배우고 사용하기 쉬움(Easy to learn and use)을 들고 있으며, 미래의 위협(threats)으로서는 다음커뮤니케이션(Daum)과 같은 경쟁자들의 새로운 기능 개발 등을 들고 있다. 【「Messenger & Alerts Service(2002. 5. 3.)」】

153) 「Communication Services and Member Platform - MYR Strategy Deck(2004. 1. 28.)」 25~26페이지 참조

154) 원문은 다음과 같다. "(앞 생략)Next generation Windows and Office integrated with services provides increased ARPU, attach rates and adoption of key Microsoft products as well as service revenue for MSN providing more overall customer value while utilizing a vast array of Microsoft channels and licensing practices"

20.2%가 “어느 정도 영향을 미쳤다”고 응답하였다. 즉, 전체의 41.3%가 윈도우XP에 윈도우 메신저가 기본 설치되어 있다는 사실이 윈도우 메신저를 선택하는데 영향을 미쳤다고 응답하였다[155].

<표 4-4> 메신저 결합판매가 선택에 미친 영향력(코리안클릭, 2003. 11.)

구분	전혀 영향을 미치지 않았다	거의 영향을 미치지 않았다	보통이다/ 그저 그렇다	어느정도 영향을 미쳤다	매우 영향을 미쳤다	총응답인원
응답비율 (단위 : %)	9.2	23.9	25.6	20.2	21.1	109명

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 6. 10.)

둘째, 피심인들이 티엔에스(TNS)에 의뢰하여 2003. 11월경 수행한 조사[156]에서도, 응답자 27명 중 16명은 피심인 메신저가 운영체제에 포함되어 있다는 점을 장점이라고 응답[157]하였다.

티엔에스(TNS)는 이러한 응답결과를 종합하여 피심인 메신저의 강점 및 약점을 분석하면서, 피심인들이 윈도우 운영체제 공급자라는 점을 장점으로 평가하고 있다. 이러한 설문조사 결과는 위 코리안클릭의 설문조사 결과와도 일치하는 것으로, 피심인 메신저 결합판매가 가입자 확보를 둘러싼 경쟁에서 피심인들에게 상당한 경쟁상 우위를 제공하였다는 근거로 인정된다.

㉰ 메신저 이용행태에 대한 통계분석

155) 이 응답결과에서는 윈도우XP 외의 다른 PC 운영체제를 이용하는 사람들도 응답(전체 응답자 109명 중 28명, 25.7%)하고 있는데, 윈도우 메신저가 윈도우XP에만 설치된다는 점을 고려하면 응답의 신뢰성이 문제될 수 있다. 그러나 앞에서 살펴본 것처럼 일반 소비자 상당수가 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 동일한 메신저라고 인식하고 있는 점을 감안하면 다음과 같은 해석이 가능하다. 즉 소비자 상당수는 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 동일한 메신저라고 인식하고 있으므로 윈도우 메신저를 사용한다고 답한 자의 상당수는 실제로는 MSN 메신저를 사용하고 있다고 추정할 수 있다. 그런데 이들이 피심인 메신저를 사용하게 된 데에 윈도우XP에의 메신저 결합판매가 영향을 미쳤다고 응답한 것은 윈도우XP 결합판매에 따라 피심인 메신저 이용자가 급증하자 이에 영향을 받아 MSN 메신저를 선택했다는 의미인 것으로 추정할 수 있다고 판단된다.

156) 이 조사는 18명의 메신저 사용자 및 9명의 메신저 비사용자를 대상으로 심층면접형식으로 실시되었다

157) 구체적인 답변내용을 인용하면 “MSN은 내가 컴퓨터를 구입하자마자 사용할 수 있도록 되어 있다”(MSN was ready to use when I purchased computer), “마이크로소프트의 운영체제 및 이와 관련된 유용한 프로그램이 원활한 작동을 보장한다”(MSN(Micorosft) OS and its related useful programs guarantee its smooth operation) 등이었다.

신고인 다음커뮤니케이션은[158] 2002. 12.부터 2004. 12.까지 코리안클릭이 생산한 로그온 패널데이터(log-on panel data)를 이용하여 메신저 결합판매가 이용자 선택에 미친 영향을 분석[159]한 의견서를 제출하였다.

이 분석에 의하면, 피심인 메신저가 결합판매된 결과 사용자들이 피심인 메신저를 선택할 가능성이 대략 22% 내지 35% 정도 상승한 것으로 나타났다. 또한 이러한 결합판매로 인해서 피심인 메신저를 주사용 메신저로 바꿀 때까지 걸리는 시간이 2개월 내지 4개월 정도 단축된 것으로 분석되었다.

결국 피심인들은 결합판매로 인해서 메신저 시장이라는 '경주'에서 다른 사업자보다 훨씬 앞서 출발하기 때문에, 결합판매는 PC 운영체제 시장에서의 독점적 지위에 기인하여 피심인들을 메신저 시장에서 부당하게 유리한 위치에 놓는다고 할 수 있으며, 이러한 출발선에서의 유리함은 고착효과 및 네트워크 효과로 인해서 더욱 확대되었을 수 있다는 의견이다.

이러한 신고인 측 연구결과는 피심인들이 2003. 10월경 실시한 설문조사에서 윈도우 메신저 이용자의 21.1%가 결합판매가 윈도우 메신저를 선택하는데 매우 영향을 미쳤다고 응답한 사실 및 메신저 결합판매가 자신들의 강점이라고 스스로 평가한 피심인 한국 엠에스의 내부보고서를 통해서도 뒷받침되고 있다.

이러한 분석결과와 상반되게 피심인들은 자신들의 전문가가 위 신고인측 전문가와 동일한 데이터를 이용하여 윈도우 PC 운영체제별 주 사용메신저 사용비율을 분석한 결과, 메신저 결합판매가 사용자들의 결정에 실질적으로 영향을 미치지 않았다는 결론이 나

158) 위원회에 제출한 연구보고서(이명재, 2005. 10. 24.) 「메신저와 윈도우의 결합판매가 MS 메신저의 주사용에 미치는 영향」 이 연구는 피심인들이 자신의 시장조사 및 분석을 위하여 코리안클릭에 의뢰하여 생산한 데이터를 피심인들로부터 제공받아 분석한 것이다.

159) 피심인 메신저를 사용하지 않던 동일한 조건하의 사람들이 각기 메신저가 결합판매되고 있는 윈도우 PC 운영체제로 전환함에 따라 피심인 메신저를 사용하게 되는 숫자를 비교하는 매칭 방법(Matching method)을 사용하였으며 이 방법은 시장효과와 네트워크 효과, 연령·교육 수준·직업상의 차이에 따른 효과, 운영체제의 기능 차이 등에 의한 효과 등이 모두 통제될 수 있다는 장점을 갖고 있는 것으로 판단된다.

왔다고 주장한다.

그 근거로, 피심인들은 윈도우Me 사용자와 윈도우98 사용자의 피심인 메신저 사용률에 거의 차이가 없다는 점, 메신저가 포함되지 않은 윈도우2000 사용자의 피심인 메신저 사용비율이 윈도우XP·윈도우Me 사용자의 피심인 메신저 사용비율보다 높다는 점 등을 제시하였다. 또한 성별, 연령 등을 통제하고 실시한 통계분석 결과에서도 피심인들의 메신저 결합판매가 피심인 메신저 사용률에 어떤 영향도 미치지 않았다는 결과가 나왔다고 주장한다.

그러나, 피심인들의 전문가에 의한 경제분석은 그 수행방법에 있어 다음과 같은 문제점을 가지고 있어 그 결과를 신뢰하기 어렵다.

첫째, 피심인들의 전문가는 운영체제 사용자별 피심인 메신저 이용비율을 분석함에 있어 코리안클릭의 패널 데이터(panel data : 일정 기간동안 정기적으로 표본집단의 변화를 추적하는 데이터)를 횡단면 자료(cross section data)로 전환하여 분석하였다. 그 결과, 2,749명의 25개월간 메신저 접속 데이터를 마치 68,725(2,749 × 25) 명의 데이터인 것처럼 취급하였다. 이러한 방법론상 오류는 시간의 흐름에 따른 메신저 사용행태의 변화를 무시하게 되어 결과의 왜곡[160]을 초래할 소지가 크다.

둘째, 피심인들의 전문가는 메신저 사용 시간이나 사용하는 메신저의 수와 같이 피심인 메신저의 사용 여부와 동시에 결정되는 내생변수를 독립변수로 사용한 문제점이 있다. 이외에도 이 분석에서는 고착효과가 제외되고, 운영체제 변수와 그 외 변수들 간의 상호연관성이 무시되는 등 많은 방법론상 문제점을 안고 있는 것으로 평가되어 그 결과를 신뢰하기 곤란하다.

160) 예컨대, 피심인들 보고서는 메신저가 결합판매 되지 않은 윈도우 2000과 메신저가 결합판매 된 윈도우 XP 사용자들의 피심인 메신저 사용률이 유사하기 때문에 결합판매 효과가 없다고 주장한다. 그러나 이는 잘못된 주장일 수 있다. 왜냐하면 윈도우 2000 사용자가 피심인 메신저를 사용하다가 12개월 후에 다른 메신저로 이동하고, 윈도우 XP 사용자는 이와 반대로 다른 사업자의 메신저를 사용하다가 피심인 메신저로 이동하였다고 할 경우, 이러한 상황은 피심인들의 메신저 결합판매가 메신저 선택에 영향을 미쳤음을 나타내는 자료일 수 있음에도 불구하고, 피심인들의 분석에 따를 경우 인위적인 횡단면 데이터 상의 피심인 메신저 사용률은 두 집단에서 동일하게 나타나게 되는 왜곡이 나타나기 때문이다.

② 피심인들의 결합판매에 의해 메신저 시장에서 피심인 메신저로의 쏠림현상이 발생하였다.

피심인 메신저의 결합판매는 메신저 가입자 확보에 강력한 영향을 미치고 이는 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시켜 피심인 메신저로의 쏠림현상을 초래하게 된다.

이와 관련하여 피심인들은 메신저 서비스가 일반적 네트워크 효과를 갖는 전화 등 통신서비스와는 다르며, 따라서 네트워크 효과가 쏠림현상으로 연결되지 않는다고 주장한다. 왜냐하면 메신저의 대화상대는 친구, 가족 및 친지 등 기존에 알고 있었던 사람들로 제한되어 있기 때문에 메신저와 관련된 네트워크의 규모는 국지적인데 불과하다는 것이다.

그러나, 메신저의 네트워크 효과가 국지적인데 불과하다는 주장은 모든 통신서비스에 적용되는 특징을 지적한 것으로 메신저 시장에만 고유하게 존재하는 특징이 아니다.

즉 통신 서비스는 기본적으로 자신이 아는 가족, 친척, 친구, 거래처와 이루어지는 것이라는 점에서 모든 통신서비스는 그 네트워크의 규모가 무한대일 수 없는 태생적 한계를 갖는 것이다. 따라서, 메신저와 다른 통신서비스의 네트워크가 갖는 특성은 기본적으로 동질적이며, 다만 서비스의 내용과 사용방법 또는 관행상 차이에 기인한 부분적인 차이가 존재할 뿐이다.

결국, 쏠림현상 발생여부의 핵심은 호환성에 있다고 할 것이다. 전화 등은 서로 다른 네트워크가 호환성을 갖기 때문에 시장점유율이 작은 사업자들도 시장에서 살아남을 수 있으나 메신저 시장에서는 현재 호환성이 없기 때문에 네트워크가 큰 메신저로 점차적인 시장쏠림이 발생하게 되는 것이다. 즉 호환성이 결여된 상황에서는 시장점유율, 혹은 네트워크 크기가 작은 메신저는 장기간 시장에서 살아남을 수 없는 것이다. 따라서, 메신저가 기존에 사용자가 알고 있는 사람들과의 의사소통을 위한 수단으로 사용된다는 점을 들어 네

트워크 효과의 크기가 작아 쏠림현상이 발생하지 않는다는 주장은 타당하지 않다.

다) 피심인 메신저로의 쏠림현상은 메신저 시장에서 품질 및 가격 등에 의한 경쟁을 제한하게 된다.

① 윈도우 Me와 MSN 메신저 결합 관련

2000. 9.부터 피심인들이 윈도우Me에 MSN 메신저를 결합판매한 이후 윈도우 메신저의 시장점유율이 1위가 되는 쏠림현상이 발생되기 시작했다.

2000. 9.부터 피심인들이 윈도우Me에 MSN 메신저를 결합판매한 행위는 2001. 9월경 피심인 메신저가 2위와 근소한 차이를 보이면서 시장점유율 기준 1위 사업자가 되는데 결정적 원인이 된 것으로 인정된다.

그 결과를 보면, 피심인들이 윈도우Me 판매를 개시한 지 3개월이 경과한 2000. 12. 시점에서의 메신저 시장점유율을 보면, <표 4-5>에서 보는 바와 같이 피심인 메신저가 주사용 메신저 기준 3위를 차지하고 있었다. 이 시기는 윈도우Me가 판매된 지 3개월밖에 경과하지 않은 시점이었고 그 판매량도 많지 않았기 때문에 결합판매에 의해 획득한 피심인들의 경쟁상 우위가 아직 시장에서 나타나지 않았던 것으로 보인다.

<표 4-5> 메신저 시장점유율(2000. 12.)

메신저 명	다음 메신저[161]	야후 메신저	MSN 메신저	ICQ	버디버디	AOL	기타[162]
사용비율 (%)	20.0	14.9	9.9	8.7	8.7	3.7	34.1

* 출처 : 정보통신정책 연구원(2000. 12. 10.)

그런데 피심인들이 윈도우Me 판매를 개시한 지 약 1년의 시간이 경과한 2001. 8,

161) 다음메신저는 유인커뮤니케이션즈가 공급하던 “인터넷친구” 메신저와 2000년 9월 유인커뮤니케이션즈 인수이후 공급한 “다음메신저”를 합친 사용비율이다.

162) 본 설문문항은 주관식으로 실시되었는데, 응답자들의 답변 중 상당수는 메신저가 아닌 쪽지보내기, 전자우편 서비스 등이어서 이를 “기타”로 재분류함

9월경의 시장점유율 자료를 보면 <표 4-6>에서 보는 바와 같이 피심인 메신저가 근소한 차이로 1위를 차지한 것으로 나타난다.

<표 4-6> 메신저 시장점유율(2001. 8., 2001. 9.)

구분	MSN 메신저	다음 메신저	라이코스 (버디버디)[163]	드림위즈 지니	야후	기타
엔에프오 코리아 (2001.8.)	29.4	20.3	20.3	15.3	4.5	10.2
엠브레인 (2001.9.)	28.9	23.9	10.8	17.4	7.5	11.5

* 출처 : 엔에프오코리아(2001.8.), 엠브레인(2001.9.)

이때 다른 경쟁메신저들의 품질 변화, 마케팅 변화 등 급격한 시장상황의 변화를 합리적으로 설명할 만한 사유가 발견되지 않기 때문에 이러한 시장변화의 요인을 피심인들의 결합판매에 기인한 것으로 보는 것이 타당하다.

이러한 사실은 앞에서 본 바와 같이, 피심인들 스스로 내부문서에서 PC 운영체제에의 결합판매가 경쟁상 주요 강점이라고 평가하고 있는 점 및 피심인 메신저 이용자의 41.3%는 PC 운영체제에 메신저가 포함되어 있다는 사실이 메신저 선택에 상당한 영향을 미쳤다고 응답하고 있는 점 등을 반영한 결과로 인정된다.

② 윈도우 XP와 윈도우 메신저 결합관련

2001. 10.부터 피심인들이 윈도우XP에 윈도우 메신저를 결합판매한 행위는 4. 라. (3)에서 이미 살펴 본 바와 같이 MSN 메신저의 사용을 유인하고, 이는 MSN 메신저의 네트워크 효과 및 쏠림현상을 더욱 심화시키게 된다.

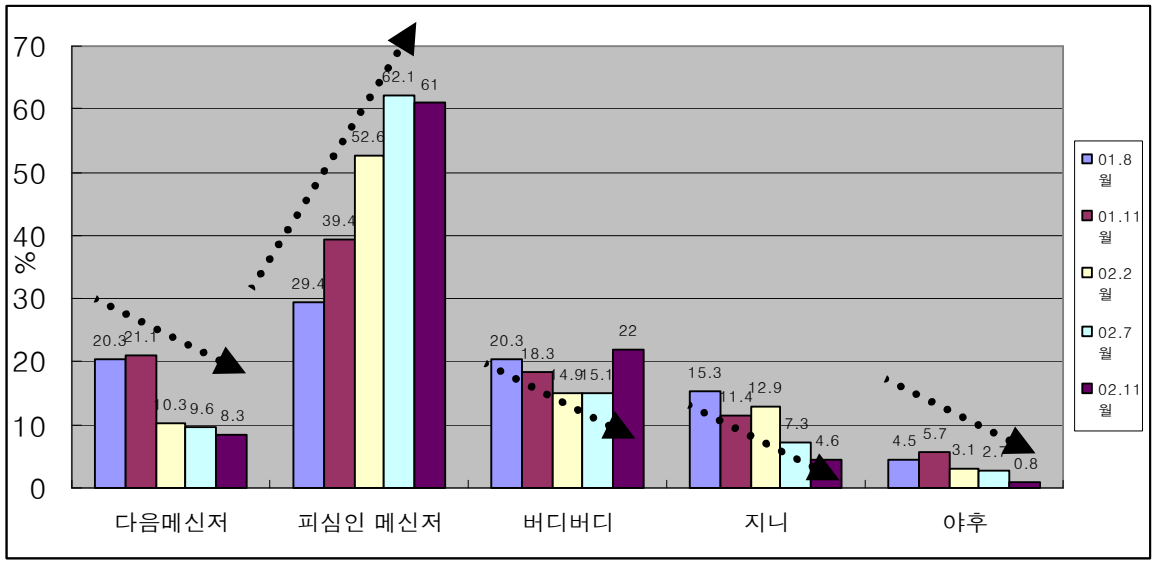
또한, 윈도우XP 뿐 아니라 윈도우Me에서의 MSN 메신저 결합판매 효과도 이 기

163) 당시 버디버디는 자체적으로 메신저를 공급하는 이외에, 라이코스라는 인터넷 포털 업체에도 '라이코스 버디버디'라는 명칭의 메신저를 공급하였다. 2002년 이후 버디버디는 단독으로만 메신저를 공급하고 있다.

간 중에 누적적으로 영향을 미친 것으로 인정된다. 이는 네트워크 효과의 전개형태가 기본적으로 시간의 경과에 따라 계속 확산되는 성격[164]을 갖고 있기 때문이다.

피심인들이 제출한 엔에프오 코리아의 조사자료에 의하면, 피심인 메신저의 시장점유율은 윈도우XP가 출시된 2001. 11.부터 2002. 7.까지 지속적으로 증가한데 반해 다음커뮤니케이션, 버디버디, 드림위즈 등 다른 메신저의 시장점유율은 대체로 하향하고 있음을 알 수 있다.

<그림 4-6> '주로 이용하는 메신저' 변화추이(2001. 8 ~ 2002. 11.)



* 출처: 다음커뮤니케이션 제출자료(2004. 9. 30.)

또한, 피심인들이 2003. 4월경 코리안클릭에 의뢰하여 실시한 설문조사 결과를 보아도 메신저 시장에서 피심인 메신저로의 쏠림현상이 나타나고 있음을 알 수 있다. 피심인들이 메신저 사용자를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 의하면, 전체 응답자의

164) 예를 들기 위해 1기-2기로 이루어진 2기간 모형에서 '갑'이 1기와 2기에서 메신저 결합판매에 의해 가입자(네트워크) 확보 경쟁에서 강력한 우위를 획득한다고 가정하자. 네트워크 효과가 중요한 메신저 시장에서 1기에서의 네트워크 효과는 1기 자체에서 뿐 아니라 2기에도 영향을 미친다. 왜냐하면 2기에서는 1기에서의 결합판매에 의해 갑의 네트워크가 증가하였다는 사실 자체가 또 다른 경쟁상 우위이기 때문이다. 따라서 2기에서는 2기 자체에서의 결합판매에 따른 경쟁상 우위에 더하여, 1기에서의 경쟁상 우위 획득이 가져온 효과가 합쳐지므로 '갑'이 누리게 되는 네트워크 효과는 시간의 경과에 따라 누적적으로 나타날 수 있음을 알 수 있다. 이러한 논리는 메신저 시장에도 적용되는 것이므로, 윈도우XP 출시 이후의 피심인 메신저로의 쏠림현상을 나타내는 시장점유율 분석에는 윈도우Me가 판매된 2000년 및 2001년도의 시장점유율 자료도 포함시키기로 한다.

51%가 메신저를 변경한 경험이 있다고 응답하였고, 이들 중 60%는 다른 메신저에서 피심인 메신저로 변경하였다고 답변하였다. 이는 결국 급격한 시장점유율 변화를 설명할 메신저의 품질, 마케팅 변화 등 다른 시장요인을 발견하기 어려운 상황에서 피심인들의 결합판매행위로 인해 메신저 시장에서 피심인 메신저로의 쏠림현상이 발생하여 메신저 시장의 경쟁이 제한되고 있음을 실증하고 있는 것이다.

<표 4-7> 주 사용 메신저의 변경비율(코리안클릭, 2003. 4.)

변경 전 메신저	변경 후 메신저	응답비율(%)
기타 메신저	피심인 메신저	19.9
버디버디	상동	14.8
다음 메신저	상동	12.1
드림위즈 지니	상동	9.4
야후	상동	3.9
타 메신저 ⇒ 피심인 메신저 소계		60.1

* 출처 : 피심인들 제출자료(2004. 6. 10.)

라) 메신저 결합판매는 메신저 시장에서 진입장벽을 높인다.

피심인들의 결합판매행위는 다음의 점을 고려할 때 잠재적 경쟁사업자가 참여 가능한 메신저 시장의 규모를 축소시키고 네트워크 효과 및 쏠림현상을 통해 메신저 시장에서의 진입장벽을 높이는 것으로 인정된다.

첫째, 피심인들이 PC 운영체제와 메신저를 결합판매한 행위는 우선 메신저 시장에 진입하려는 잠재적 경쟁사업자가 참여 가능한 메신저 시장을 축소시키고 이에 따라 기대수익 감소에 직면하게 하여 진입장벽을 높이는 반경쟁적 결과를 초래한다.

즉, 피심인들의 메신저 결합판매행위는 소비자로 하여금 피심인 메신저를 강제로 구매하게 하므로 소비자가 다른 메신저를 구매 또는 사용할 가능성이 크게 감소한다. 이는 현존하는 사업자 뿐 아니라 잠재적 진입자에게 사실상 자신의 메신저를 공급할 가능성이 있는 시장의 축소를 의미[165]하게 되며 이는 시장진입에 따른 기대 수익의 감

165) 「지식기반경제시대의 산업구조 변화와 경쟁정책의 방향(권명중·정찬모 공저)」 231~232페이지 참조

소를 의미하게 된다.

둘째, 메신저 시장에 대한 진입장벽은 결합판매에 의한 네트워크 효과에 의하여도 발생한다. 즉, 피심인들의 결합판매는 다른 사업자와 비교할 때 현격한 격차로 강력한 네트워크 효과 및 쏠림현상을 발생시키게 되었고, 경쟁기업은 신규진입시 피심인들이 향유하는 네트워크 효과에 필적할 만한 효과를 일시에 달성하기가 매우 곤란하다는 이유로 진입장벽에 직면하게 되는 것이다.

셋째, 이러한 쏠림현상은 소비자에게 상당한 전환비용 및 고착효과를 발생시키고, 종전에 새로운 메신저 사용자들을 대상으로 시장에 진입할 수 있던 것과 달리 이미 성숙단계에 이른 메신저 시장에서 기존의 메신저 사용자를 끌어들여야 하는 신규 진입자에게 커다란 진입장벽으로 작용하고 있다.

이와 관련하여 피심인들은 코리안클릭의 2002. 12.부터 2004. 12월까지의 기간동안의 로그온 데이터(log-on data) 분석결과 피심인 메신저를 주이용 메신저로 사용하던 사용자 중 상당수가 다른 사업자의 메신저로 전환했다는 점 등을 들어 메신저 시장에 고착효과는 존재하지 않는다고 주장하나, 메신저 사용자들이 주사용 메신저를 전환한 원인에는 고착효과 이외의 다른 원인[166]이 있을 수 있어 고착효과가 존재하지 않았더라면 더 많은 사용자가 피심인 메신저에서 다른 메신저로 전환할 수도 있었다고 볼 수도 있다. 따라서 단순히 2002년부터 2004년까지의 기간동안 피심인 메신저 사용자의 어느 정도가 다른 메신저로 전환하였는지 여부를 통해 고착효과가 존재하는지 여부를 밝힐 수는 없으므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 메신저시장에서의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

① 쏠림현상 및 이에 따른 경쟁제한 효과의 발생 원인은 피심인들의 결합판매행위이다.

166) 예를 들어 강력한 고착효과 외에도 불구하고 피심인 메신저가 지속적으로 오류를 발생시켜 사용자들이 전환하였다고 볼 수도 있으며 이에 대한 구체적 내용은 후술하기로 한다.

피심인들의 결합판매행위는 앞에서 살펴 본 바와 같이 피심인 메신저로의 쏠림현상을 초래하고 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시켜 메신저 시장의 경쟁을 제한하고 있다.

이러한 현상은 메신저 선택이유를 분석한 아래의 자료를 고려할 때 피심인 메신저의 성능이 우수하기 때문이 아니라 피심인들의 결합판매행위에 의한 부당한 경쟁상의 우위에 기인한 것으로 판단된다.

2003. 4. 피심인들이 코리안클릭에 의뢰하여 주 사용 메신저를 선택할 때 가장 중요하게 고려했던 요소가 무엇인지를 분석한 결과를 살펴보면 <표 4-8>에서 살펴보는 바와 같이 피심인 메신저를 주 사용 메신저로 선택했다고 응답한 사람들 중 그 이유로 기능적 우수성을 든 비율이 47.2%로 다른 메신저의 경우에 비하여 현저한 격차로 가장 낮은 비율을 보이고 있음을 확인할 수 있다.

<표 4-8> 주 사용 메신저를 이용하는 이유(두가지 선택)

(단위 : %)

구 분[167]	피심인 메신저	네이트온	다음 메신저	지니	버디버디	타키	야후 메신저	기타
사례수(명) 전체 : 500명	279	19	36	35	64	41	16	10
주변사람들의 이용여부	122.6	73.7	94.5	105.7	106.2	102.4	93.8	70.0
성능 요인	47.2	116	91.8	71.4	70.5	75.6	87.4	100.0
안정성 요인	27.2	22.4	8.3	20.0	21.9	17.1	12.5	20.0
기타	2.9	3.4	5.6	2.9	1.6	4.9	6.2	10.0

* 출처 : 피심인들 제출

167) 실제 설문문항의 종류가 다양하여, 다음과 같이 큰 범주로 재분류하였다.

▪ 주변사람들의 이용여부 : 1) 가족들이 주로 사용하고 있어서 2) 친구들이 주로 이용하고 있어서 3) 직장동료들이 주로 이용하고 있어서

▪ 성능 요인 : 4) 새로운 대화상대 찾기가 가능해서 5) 아이디와 이메일로 대화상대 검색이 가능해서 6) 파일 전송 실패시 이어받기 기능이 있어서 7) 대화 기록이 자동 저장 되어서 8) 원하는 부가정보가 제공되어서(뉴스,주식, 연예정보 등) 9) 원하는 부가서비스 기능이 있어서(파일보내기, 음성채팅, 문자전송서비스(SMS)등) 10) 검색가능 여부 11) 아바타서비스 제공여부 12) 커뮤니티, 이메일-해당 포털 사이트와의 연동여부 13) 타 메신저와의 호환여부 14) 게임서비스 제공여부 15) 음악서비스 제공여부 16) 미팅 서비스 제공여부 17) 핸드폰에서 메신저를 이용할 수 있는지 여부

▪ 안정성 요인 : 메신저 프로그램이 안정적인지 여부

또한, 피심인들과 다른 메신저 사업자의 시장점유율 분포를 결정하는데 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 위에서 살펴 본 가격과 성능 외에 제품의 판매전략, 수요자 성향의 변화 등 다양한 요인을 고려할 수 있다. 그런데 이들 중, 2001년과 2002년을 전후하여 크게 달라진 것은 피심인들이 윈도우XP를 출시함으로써 피심인 메신저의 판매형태가 바뀐 것 외에는 없는 것으로 보인다.

결국, 피심인들의 결합판매행위로 다른 경쟁메신저 사업자들은 시장점유율이 감소되며 가격 및 품질에 의한 경쟁이 제한되어 메신저 시장에서 배제되는 등 사업활동이 부당하게 방해받고 있는 것이다.

② 네이트온의 사례 분석

피심인들은 네이트온의 강력한 성장은 메신저 시장에 어떤 쏠림현상 및 경쟁제한 효과도 존재하지 않는다는 사실을 증명한다고 주장하고 있다.

네이트온의 성장 자체는 사실로 인정된다. 그러나 그 성장의 내용과 배경을 구체적으로 살펴보면, 메신저 시장에는 피심인들의 결합판매로 인한 커다란 경쟁상의 제약이 있으며 네이트온 역시 이러한 제약을 극복하기 위하여 정상적인 경쟁시장에서라면 필요 없을 수도 있는 다양한 수단과 자원을 동원하였다는 사실을 알 수 있다.

이와 같이 경쟁사업자가 정상수준보다 커다란 경쟁비용을 투입할 수 밖에 없었다는 사실은 곧 피심인들의 결합판매가 경쟁을 실질적으로 제한한다는 사실을 입증하는 것이다. 나아가 네이트온 외의 다른 대부분의 메신저 사업자들이 지속적으로 점유율을 상실하고 있다는 사실 역시 피심인들의 결합판매가 경쟁사업자를 시장에서 축출하는 효과를 갖고 있다는 점을 잘 입증하는 것이다. 아래에서는 네이트온의 성장배경과 다른 대부분 메신저 사업자의 시장배제 경과에 대하여 알아본다.

첫째, 네이트온의 성장은 피심인 메신저가 결합판매로 부당하게 경쟁상 우위를 획득하여 메신저 시장의 경쟁을 제한하였다는 것에 대한 반증이 될 수 없다고 판단된다.

왜냐하면 메신저 시장에 고착현상 및 피심인 메신저로의 쏠림현상이 없었다면 네이트온은 지금보다도 더 빨리, 더 많이 시장 점유율을 획득할 수도 있기 때문이다. 따라서 네이트온의 성장을 들어 고착현상 및 쏠림현상의 우려, 그리고 결합판매에 의한 피심인들의 경쟁상 우위 존재여부를 부정하는 것은 타당하지 못하다.

둘째, 피심인 메신저는 2004년 하반기 이후 심각한 오류가 지속되었는데, 이러한 오류가 네이트온의 성장 및 피심인 메신저의 시장점유율 하락에 상당한 영향을 미친 것으로 판단된다. 피심인 메신저 서비스에서 나타난 여러 가지 오류 중 특히 한글입력 오류는 메신저 사용에 매우 치명적인 오류이다. 기본적으로 메신저는 문자를 통해 실시간으로 통신하는데, 한글이 제대로 입력되지 않는다는 것은 전화 등 음성통신에서 음성이 전달되지 않는 것과 비견될 수 있는 치명적인 오류이다. 그럼에도 피심인들은 이러한 한글입력 오류에 대해 그 근본적인 처방책 제시를 지연하였다.

<표 4-9>는 피심인 메신저의 한글입력 오류에 따른 사용자들의 인터넷 상에서의 질의 응답 목록[168]을 제시한 것인데, 게재 날짜 등을 보면 이 오류가 상당기간동안 근본적으로 해결되지 못하고 지속되었으며, 특히 2004. 11. 18. 게재된 정보에 대하여는 조회건수가 2만건이 초과할 정도로 상당히 많음을 알 수 있다. 아래 목록에 나타난 지식의 조회건수만 합산해도 무려 95,862건에 달한다.

이러한 조회건수는 네이버(Naver)라는 단 한개의 인터넷 포털사이트에서 적극적으로 한글입력오류를 해결하려는 방법을 알아보려고 노력한 사람들의 수를 나타낼 뿐이고, 다른 포털사이트에서 오류 해결방법을 찾아본 사람, 그 밖의 다른 경로를 통해 한글입력 오류방법을 알아내려고 한 사람 등을 감안하면 한글입력 오류를 겪고 이를 해결하고자 하는 사람은 이러한 조회건수의 몇 배 또는 몇 십 배에 달할 것으로 추정된다.

168) 2005. 10. 다음커뮤니케이션이 제출한 자료로서 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 한국입력 오류에 대한 질문에 대한 조회건수를 조사하고 편집한 것임

<표 4-9> 피심인 메신저에서의 한글입력 오류에 대한 질문 목록('04.9.~'05.6.)
- 조회수가 3,000건을 넘는 경우만 발췌함

등록일	내용	조회수
04.9.25.	msn 메신져 대화창에서 한글이 안 써져요	7,402
04.9.29.	MSN 메신저에서 한글타자가 안 되요	7,891
04.11.18.	메신저msn한글이 안 쳐져요	20,477
04.11.18.	메신저MSN에서 채팅할때 한글입력이 안 되요. 도와주세요	4,177
04.11.19.	MSN메신져에서 한글이 안 써지는 현상	4,523
04.11.22.	메신저MSN한글입력이 안됩니다. 또 실행하면 한동안 응답도 없어요	4,140
04.11.22.	MSN 메신저에서 최근 발생하는 한글 입력 안 되는 문제	16,245
04.11.22.	msn 메신저 한글이 잘안 나와요ㅜ.ㅜ	4,727
04.11.22.	msn메신져 사용하는데 한타가 안되고 자꾸 영타가 됩니다	4,015
04.11.23.	메신저msn 메신저를 사용하는데 한글로 전환이 안 되요	6,559
04.11.25.	메신저msn에서 채팅할 때 한글이 안 써져요	4,464
05.1.6.	MSN 메신저 한글입력 오류에 대해서	3,965
05.1.16.	메신저msn하다 보면 한글이 나와야 하는데 영어로 바뀌어요	7,277
계		95,862

* 출처 : 네이버

특히 메신저는 통신 수단이기 때문에 한 사용자의 한글입력오류는 그와 통신하려는 다른 사람에게도 직접적인 불편으로 전파된다는 점에서 실제 피심인 메신저의 한글입력 오류로 인해 불편을 겪은 사용자들은 자신이 직접 오류를 겪은 사람보다 그 규모가 훨씬 컸을 것으로 추정된다. 특히 오류발생 당시 사용자들이 피심인들이 이러한 오류에 무성의하게 대응했다면서 상당한 불만을 표출했다는 점을 주목할 필요가 있다.[169]

셋째, 네이트온 성장의 상당부분은 이러한 피심인들 메신저의 지속적인 오류현상 따른 반사이익으로 획득된 것으로 해석된다. 네이트온을 제공하고 있는 SK커뮤니케이션즈는 2005. 9. 21. 전원회의에서 피심인들 메신저의 지속적인 장애, 오류, 보안문제로 인해 네이트온이 반사이익 효과를 입었다는 의견을 제시했다. 결국 한글입력 오류 등

169) 경향신문은 2004. 10. 14. 피심인들의 메신저 오류에 대한 무성의한 대응에 대해 소비자들의 불만이 표출되고 있다고 보도하였다. 보도된 내용의 일부를 발췌하면 "이에 대처한 방식도 문제였다. 미리 알림 메시지를 띄우지 않고, 게시판에만 공지하는 등 매우 무성의했다. 당시 해당 상황을 모르는 이용자들은 자신의 컴퓨터나 회사 네트워크에 문제가 있는 것으로 오해, 윈도우를 다시 설치하는 등의 소동을 빚었다. 게다가 MSN 측은 해당 오류의 원인에 대해 자세히 밝히는 최소한의 예의도 지키지 않았다. 현재 MS사 및 MSN 메신저에 대한 회의론이 번지고 있는 상태다. 회사원 이정민(26)씨는 "이번 일을 계기로 MS사에 대한 불신이 생겼다"고 말했다." 등으로 기재되어 있다.

의 지속적 발생은 문자메시지 무료제공을 통해 상당수 소비자에게 설치된 네이트온 메신저가 주된 메신저로서 쓰이게 하는데 상당한 기여를 했을 것으로 추정된다.

넷째, 네이트온을 공급하고 있는 SK커뮤니케이션즈는 2005. 9. 21. 전원회의에서 자신들의 네이트온 메신저가 상당히 성장한 것은 사실이나, 피심인들의 적극적인 마케팅 활동 재개시 자신들이 피심인 메신저와의 경쟁에서 뒤떨어질 가능성은 여전히 상존하고 있다는 의견을 제시하였다. SK커뮤니케이션즈는 그 이유로써 피심인들의 PC 운영체제에의 결합판매 효과와 달리 네이트온 성장의 발판이 된 싸이월드(Cyworld) 서비스는 유행을 타는 속성이 있어 그 인기가 하락할 경우 네이트온에도 부정적 영향을 미칠 것이 우려된다는 점, 정상적 상황보다 과다한 비용을 지출하고 있는 각종 마케팅을 중단할 경우의 고객이탈 가능성 등을 들고 있는데 피심인 메신저의 결합판매로 인한 경쟁상 우위가 지속되는 여건에서 SK커뮤니케이션즈의 진술은 합리적 근거가 있다고 인정된다.

다섯째, 참고로 유럽 1심법원(CFI)도 “원고는 자신의 시장점유율과 가격이 계속하여 하락하고 있다는 사실을 논거로 삼을 수 없다. 사업자가 경쟁을 제한하기 위한 영업을 현실적으로 실행하였다면, 원하던 결과가 실제로 현실화되지 않더라도 EC 조약 제82조의 적용을 피할 수는 없다. 만약 대상결정에서 위법하다고 판단한 영업행위가 실행되지 않았더라면 원고의 시장점유율 및 가격의 하락폭은 보다 컸을 가능성이 높다”(Case T-203/01, Manufacture francaise des pneumatiques Michelin vs. Commission, para. 24.)라고 판시하였다.

결국 특정 사업자의 성장을 이유로 피심인들의 메신저 결합판매가 제기하고 있는 반경쟁적 효과에 대한 우려가 배제될 수는 없다고 인정된다.

③ 피심인들의 결합판매행위로 메신저 시장의 진입장벽을 높여 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

피심인들의 결합판매는 시장규모 축소에 의한 기대수익의 감소, 고착효과 및 네

트워크효과에 의해 메신저 시장에서 진입장벽을 높여 기술적으로 우수하고 효율적인 경쟁기업이 해당 시장에서 신규 진입하는 것을 어렵게 한다.

피심인들도 자신의 결합판매행위가 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 효과가 있음을 스스로 인정하고 있다. 피심인들이 2005. 7. 8. 위원회에 제출한 의견서에서는 피심인들의 결합판매로 인해 경쟁자들이 피심인들 제품과 동등 수준으로는 경쟁할 수 없고, 이를 넘는 기능을 개발해야 한다고 언급[170]하고 있어 피심인들의 결합판매로 인해 정상적인 경쟁상황 보다 큰 부담이 경쟁사업자에게 지워지는 인위적인 진입장벽 구축효과가 발생한다는 사실을 스스로 밝히고 있다. 이는 또한 피심인들의 결합판매로 인해 경쟁사업자의 사업활동이 방해받고 있음을 나타내는 것이다.

이와 관련하여, 익명을 요구한 국내 한 메신저 프로그램 개발자[171]는 2005년 피심인들의 메신저 결합판매행위 때문에 일반용 메신저 시장에의 진입을 포기한 사실이 있다는 의견[172]을 위원회에 제출하여 위 판단을 뒷받침하고 있다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 PC 운영체제 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 피심인 메신저를 원하지 않는 거래상대방에 대하여 그 구입을 강제하는 결과를 초래하므로 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 시장지배적지위 남용행위로서 부당하게 거래상대방에 대하여 불이익이 되는 거래를 강제한 행위이다. 또한, 이러한 피심인 메신저의 구입강제는 피심인 메신저의 편

170) 「컴퓨터 운영체제의 기능 추가가 소비자 후생에 미치는 효과에 관한 경제분석」(최재필 교수, Albert L. Nichols 박사) 31쪽 "물론 운영체제에 새로 부가된 기능과 유사한 기능의 제품을 공급하는 제3의 업체는 새로운 경쟁자가 등장한다는 점에서 이를 반길 리가 없다. 운영체제 내에 기본적으로 장착된 기능으로 인하여 이제 경쟁업체들은 계속 성공적으로 살아남기 위해서는 이미 운영체제에 통합된 기능을 뛰어 넘는 기능을 추가하거나 아니면 보다 저렴한 가격으로 이들 기능을 공급해야만 한다"

171) 이 메신저 프로그램 개발자는 11년의 소프트웨어 개발경력을 보유한 전문가로 『VC++ .NET으로 구현한 메신저 프로그래밍』(가메 출판사)등 메신저 개발서적을 저술한 메신저 프로그래밍 전문가이다.

172) 이 개발자의 의견은 다음과 같다. "마이크로소프트가 자사 운영체제에 메신저를 포함하여 판매함으로 인해 국내 메신저 업체에 심대한 타격을 가져다 준 것은 사실입니다. 정확한 수치는 모르지만 초기에는 버디버디 등 국내 업체 메신저가 더 많이 사용되다가 현재는 마이크로소프트 메신저가 더 많이 사용되고 있는 것 같은데, 이러한 결과의 핵심은 윈도에 기본으로 설치되어 있어서 또 다른 설치를 필요로 하지 않기 때문입니다."

재성을 초래하고 이는 다시 네트워크 효과와 고착효과를 통해 메신저 시장에서 경쟁을 제한함으로써 다른 경쟁사업자를 배제하거나 신규 사업자의 시장진입을 방해하는 결과를 초래하므로 공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호에 해당한다.

바. 시장지배적지위의 남용행위 중 소비자이익 저해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 후단이 규정취지 및 이에 해당하기 위한 요건 등에 관하여는 2. 마. (1)에서 이미 살펴본 바와 같다.

(2) 사실의 인정

(가) 피심인들은 주된 상품인 PC 운영체제 시장에서 시장지배적사업자이다.

피심인들이 시장지배적사업자라는 사실은 위 3. 라. (2) (가)에서 살펴본 바와 같다.

(나) 피심인들의 결합판매행위는 부당한 행위이다.

윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저가 별개 제품임에도 불구하고 피심인들이 이를 결합하여 판매한 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 구입을 강제하는 부당한 행위라고 인정된다.

1) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제와 별개의 제품이다.

피심인 메신저가 윈도우 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니라, 독립하여 거래대상이 되는 별개의 상품이라는 사실은 위 4. 마. (2) (나) 1)에서 이미 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들의 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 피심인 메신저 구입을 강제한 부당한 행위이다.

피심인들의 행위가 거래상대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 부당한 행위라는 사실은 위 4. 마. (2) (나) 2) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

(다) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 부당하게 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 별개 제품인 메신저를 거래상대방인 소비자에게 강제로 구입하게 한 것으로 직접적으로는 소비자의 상품 선택권을 침해하고, 장기적으로는 메신저 시장에서 경쟁을 제한하여 소비자의 후생을 현저히 감소시키게 되므로 제품 공급자간의 공정한 경쟁과 혁신을 통해 얻을 수 있는 소비자 이익을 누릴 수 없게 하는 행위인 바, 이러한 피심인들의 행위는 소비자의 이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위이다.

1) 피심인들의 결합판매행위는 메신저 시장에서 경쟁을 제한함으로써 소비자의 이익을 저해한다.

4. 마. (2) (다) 2) 에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 행위는 피심인 메신저의 편재성을 발생시키고, 이는 피심인들로 하여금 메신저 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다. 이러한 피심인 메신저의 편재성은 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시킴으로써 피심인들 메신저로의 쏠림현상을 초래하고 피심인들 메신저의 편재성과 그로 인한 고착효과와 네트워크 효과는 메신저 시장에서 진입장벽을 높여 메신저 시장의 경쟁을 제한한다. 이는 장·단기적으로 소비자들의 후생을 감소시켜 소비자의 이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있다.

경쟁이 제한된 시장에서 소비자의 이익이 어떻게 저해되는 지는 운영체제 시장에서의 피심인들의 가격 추이와 하드웨어 및 다른 운영체제 사업자의 운영체제 가격의 추이를 살펴보면 알 수 있는데 구체적 내용은 2. 마. (2) (다) 에서 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 선택권을 침해하여 소비자의 이익을 저해한다.

피심인들의 결합판매행위는 PC 운영체제 시장에서의 지배적 사업자인 피심인들이 PC 운영체제 시장에서의 지배력을 이용하여 독점 상품인 피심인들의 운영체제에 메신저를 결합하여 판매하는 것으로서 이는 피심인 메신저의 구입을 원하지 않는 윈도우 운영체제 소비자들의 메신저에 대한 선택권을 침해한다.

메신저 시장에서는 피심인 메신저가 포함되지 않은 윈도우 운영체제를 원하는 소비자들이 상당수 있다. 즉, 일부 기업들은 메신저에 의한 보안 누출의 우려, 직무태만 등을 우려하여 직원들이 메신저를 사용하지 못하도록 하고 있고, 일반 소비자들도 일부는 메신저 기능을 원하지 않고 있다. 그럼에도 이들 소비자까지도 윈도우 PC 운영체제를 구입하면서 피심인들의 메신저를 구입할 수 밖에 없는 것이다.

따라서, 피심인들의 결합판매행위는 소비자들이 메신저가 포함되지 않은 PC 운영체제를 선택할 기회를 봉쇄하거나 또는 다른 메신저 제품을 이용할 기회를 사전에 차단하여 공정한 경쟁에 의하여 소비자가 성능과 품질 면에서 우수한 제품을 선택할 권리를 침해하는 것인 바, 이는 소비자의 이익을 저해하는 행위이다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 기술혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

피심인들의 결합판매행위는 메신저 시장에서 경쟁을 제한하고, 진입장벽을 형성하여 신규 진입자가 시장에 진출하는 것을 매우 어렵게 한다는 사실은 위에서 살펴 본 바와 같다.

이는 피심인들이 메신저 시장에서 품질 등 제품 자체에 의한 경쟁을 할 필요가 없다는 것을 의미한다. 왜냐하면 피심인들은 PC 운영체제의 시장지배력을 이용한 윈도우 운영체제와 메신저의 결합판매를 통하여 언제나 경쟁사업자의 메신저 제품과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있고, 우수한 제품이 시장에 진입하는 것도 막을 수 있기 때문이다.

피심인들이 결합판매 후 품질 경쟁의 필요성이 거의 사라져 제품 개선을 하지 않는 등 기술혁신을 저해한다는 사실[173]은 이미 2. 마. (2) (다) 에서 살펴 본 바와 같다.

따라서, 피심인들이 윈도우 운영체제에 메신저를 결합하여 판매하는 행위는 부당하게 경쟁을 제한하여 독점적 지위를 획득하고 이러한 독점적 시장 구조는 기술혁신을 저해하여 사회적 손실을 야기할 수 있음을 인정할 수 있다.

(3) 결론

피심인들의 윈도우 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 PC 운영체제 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 그 구입을 강제하는 부당한 행위이고, 이는 소비자의 상품 선택권을 침해하고 또한 피심인 메신저의 편재성으로 이로 인한 네트워크 효과와 고착효과를 통해 메신저시장의 경쟁을 제한함으로써 소비자 후생을 감소시키는 결과를 초래하므로 부당하게 소비자 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 시장지배적 지위 남용행위로서 공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 후단에 해당한다.

사. 불공정거래행위의 거래강제행위 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

공정거래법 제23조 제1항 제3호 등 관련규정의 취지나 이에 해당하기 위한 요건

173) 노벨 경제학상 수상자인 스티글리츠(Stiglitz) 교수는 2005. 10. 위원회에 제출한 보고서에서 독점사업자는 세 가지 방법으로 기술혁신의 속도를 늦출 수 있다고 하고 있는데, 그에 대한 구체적 내용은 이미 살펴본 바와 같다.

등에 관하여는 위 2. 바. (1) 에서 이미 살펴본 바와 같다.

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

피심인들이 피심인 메신저와 PC 운영체제가 별개제품임에도 불구하고 이를 결합하여 판매함으로써 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 구입을 강제하는 행위는 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 행위로 인정된다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저는 별개 제품이다.

주된 상품과 종된 상품이 별개 상품인지 여부를 판단하기 위해서는 기능·성격의 차이와 수요가 동일한지 여부가 가장 중요한 판단기준이 되며, 종된 상품에 대한 별도의 공급자 존재여부, 동종업계의 거래관행, 피심인들의 인식 등도 종합적으로 고려하여 판단하여야 하는바, 피심인 메신저가 PC 운영체제와 별개의 제품이라는 사실은 4. 마. (2) (나) 1)에서 이미 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들의 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 피심인 메신저의 구입을 강제하는 부당한 행위이다.

「불공정거래행위 심사지침」(공정거래위원회 예규 제26호)에 의하면 구입강제성 여부는 거래상대방의 입장에서 주된 상품과 종된 상품을 따로 구입하는 것이 자유로운지를 기준으로 판단하도록 규정하고 있다. 이때, 강제성은 주된 상품에 대한 구매자의 거래처 전환 가능성이 적을수록 큰 것으로 판단된다. 판례도 구입 강제에 대하여 거래상대방으로 하여금 자기가 구입하고자 하지 않는 상품의 구입을 강제함으로써 거래상대방의 선택의 자유를 침해하는 것으로 판시[174]하고 있다.

174) 서울고법 2004. 2. 10. 선고, 2001누16288 판결

따라서, 본 건에 있어 구입강제성의 핵심은 소비자가 종된 상품을 사용하는지 여부가 아니라 종된 상품을 구입하지 않고서는 시장지배력이 있는 주된 상품을 구입할 수 없다는 점에 있다고 할 수 있다. 이러한 기준하에서 피심인들의 결합판매행위는 4. 마. (2) (나) 2) 에서 살펴본 바와 같이 피심인 메신저의 구입을 강제한 부당한 행위이다.

(나) 피심인들의 행위는 공정거래를 저해한다.

'공정거래저해성'의 의미와 이에 해당하기 위한 요건에 대해서는 이미 2. 바. (2) (나)에서 살펴본 바와 같다.

1) 피심인들은 결합판매를 운영체제 시장의 독점력 전이 수단으로 사용하고 있다.

피심인들이 윈도우Me와 윈도우XP 등 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합판매하여 PC 운영체제 시장의 독점적 지배력을 지렛대로 활용하고 메신저 시장의 경쟁상 우위를 획득하고자 하는 의도를 갖고 있음은 4. 마. (2) (다) 1)에서 살펴본 바와 같다.

2) 피심인들의 행위는 메신저 시장에서 경쟁을 제한하는 효과를 초래한다.

피심인들의 행위는 피심인들 메신저의 편재성을 발생시키는데 이는 피심인들로 하여금 메신저 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다. 피심인들 메신저의 편재성은 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시킴으로써 피심인들 메신저로의 쏠림현상을 초래한다. 이러한 고착효과와 네트워크 효과로 인하여 경쟁사업자는 시장에서 축출되거나 위축되고 메신저 시장의 진입장벽이 높아져 메신저 시장의 경쟁이 제한된다. 이에 대한 구체적 내용은 4. 마. (2) (다) 2)에서 살펴본 바와 같다.

3) 피심인들은 불공정한 거래내용 또는 경쟁수단을 사용한다.

피심인들의 끼워팔기가 불공정한 거래내용 또는 경쟁수단이며, 국내 PC 운영체제 시장을 피심인들이 독점하는 상황에서 정상적인 거래관행이 큰 의미가 없음은 이미 3.

바. (2) (나) 2)에서 살펴본 바와 같다.

4) 피심인들의 행위로 인한 효율성 증대효과는 미약하여 경쟁제한 효과를 능가하지 못한다.

피심인들은 PC 운영체제와 피심인 메신저의 결합판매가 유통비용 감소, 응용프로그램 개발 편의 등 효율성 증대효과가 있다고 주장하나 이는 다음의 점을 고려할 때 이유 없다.

가) 유통비용 등 거래비용이 감소된다는 주장에 대하여

피심인들은 PC 운영체제에 피심인들의 메신저가 사전에 탑재되어 판매되는 결과 소비자에 대한 거래비용이 감소하는 효율성 증대효과가 발생한다고 주장하나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들이 주장하는 이러한 거래비용 감소효과는 어떤 메신저를 PC에 기본으로 탑재하더라도 동일하게 발생하는 것으로써 피심인 메신저를 PC 운영체제에 기본 프로그램으로 탑재할 경우에만 발생하는 고유한 효과가 아니다.

둘째, PC 제조업체들은 경쟁제품으로부터 자신을 차별화하고 고객의 특별한 요구를 충족시키기 위해 PC의 하드웨어와 소프트웨어를 구성하고 판매하게 된다. PC 제조업체들은 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 숙련된 기술을 보유하고 있으므로 메신저를 포함한 다양한 소프트웨어를 자신의 PC에 설치할 능력과 동기를 모두 가지고 있다. 따라서, PC 제조업체가 자유롭게 소프트웨어를 선택·설치할 수 있도록 하는 경우 소비자들은 그들의 선호에 따라 PC 제조업체들이 제공하는 PC 운영체제와 다양한 메신저의 결합상품을 선택할 수 있게 되어 시장의 효율도 높아지게 된다. 결국 피심인들이 본건과 같이 메신저를 PC 운영체제에 사전에 결합판매하는 행위가 유발하는 거래의 효율성은 인정하기 어렵다.

셋째, 메신저와 같이 작은 크기의 소프트웨어 프로그램은 아주 적은 노력으로 복사되어 공급될 수 있고 이를 원하는 사용자는 인터넷 다운로드라는 효과적인 공급경로를 통해 쉽게 얻을 수 있기 때문에, 소프트웨어 라이센싱 과정에서 야기되는 유통비용은 미미한 수준이다. 따라서 이를 절약하는데서 오는 비용감소 효과도 그 크기는 아주 작을 것으로 판단된다. <표 4-10>는 메신저를 인터넷에서 다운로드 받아 설치하는데 소요되는 시간을 보여 주는데, 극히 미미함을 알 수 있다.

<표 4-10> 피심인 메신저 다운로드 소요시간

메신저 종류 / 통신속도	MSN4.0(1,390Kb)	WIN4.7(986Kb)	WIN4.6(953Kb)
28.8Kbps(14Kbps)	1분 33초	1분 10초	1분 8초
56.6Kbps(30Kbps)	46초	33초	32초
2Mbps(200Kbps)	7초	4.9초	4.8초
8Mbps(300Kbps)	4.6초	3.3초	3.2초

* 괄호( )안의 속도는 인터넷 통신망에서의 실제적인 평균 구현 속도
* MSN : MSN 메신저, WIN : 윈도우 메신저
* 출처 : 피심인들 제출자료(2002. 9. 27.)

<표 4-11> 피심인 메신저 설치 소요 시간

운영체제	CPU 속도	메신저 종류	인스톨 소요시간
윈도우 XP	Pentium Ⅳ	윈도우 메신저 V.4.7.	10초
윈도우 XP	Pentium Ⅲ	윈도우 메신저 V.4.7.	10초
윈도우 98 SE	Pentium Ⅲ	MSN 메신저V.4.6	7초
윈도우 98 G	Pentium Ⅲ	MSN 메신저V.4.6	5초

* 출처 : 피심인들 제출자료(2002. 9. 27.)

넷째, 피심인들 스스로 메신저 결합판매에 의한 거래비용 절감 편익이 극히 미미함을 인정하고 있다. 피심인들은 2005. 7. 8. 위원회에 제출한 의견서 별첨자료 Ⅰ B4 58항에서 “인스턴트 메신저의 주 사용층은 인터넷을 빈번하게 이용하는 사람들로 구성되어 있기 때문에 다운로드는 인스턴트 메신저를 위한 매우 효율적인 배포채널이 되고 있습니다. 인스턴트 메신저를 다운로드 하는데에 소요되는 시간 또한 실로 미미한 수준입니다.”라고 기재하여 운영체제에 메신저를 결합판매하여 발생하는 거래비용의 감

소효과는 극히 미미함을 스스로 인정하고 있는 것이다[175].

나) 응용프로그램 개발편의가 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 메신저 통합이 사실상 다른 사업자에게 새로운 경쟁기회를 창출하고 새로운 응용프로그램의 개발을 용이하게 하였다고 주장하면서, 윈도우 메신저 기능은 기업고객들을 위한 서버 솔루션 개발에도 활용되고 있으며 그 사례로 MCI가 기업고객들에게 윈도우 메신저를 기반으로 하여 "MCI Advantage"라는 커뮤니케이션 솔루션을 제공한 점을 들고 있다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들의 메신저 결합판매가 사업자들에게 미치는 효과는 결합판매에 직면하는 사업자의 성격에 따라 다르다. 우선, 피심인들의 기술에 의존하지 않고 기술적으로 대등하게 경쟁하고 있는 사업자들은, 소비자들이 자신과 경쟁하던 피심인들의 제품을 운영체제와 하나로 묶어 구매하게 되므로 부당한 사업활동 방해 및 경쟁봉쇄 효과에 직면하게 된다.

즉, 피심인들과 대등한 경쟁관계에 있지 않고 협력 또는 보완적 관계에 있는 메신저 사업자들이 피심인들의 윈도우 메신저 API를 이용한 응용프로그램을 개발한다고 가정하더라도, 이는 피심인들과 경쟁관계에 있는 사업자들에게는 오히려 불이익으로 작용하게 된다. 즉, 피심인 메신저 기술에 종속된 사업자들이 증가하면 피심인들이 PC 운영체제시장의 독점력을 활용하여 메신저 시장의 표준을 장악할 우려가 더 커지기 때문이다.

---

175) 이와 관련 하여 피심인들은 메신저를 다운로드 하여 설치하는데 걸리는 시간이 매우 적어 결합판매에 따른 배포상의 효율성이 매우 작다고 판단하면서, 다운로드에 의해 피심인 메신저의 편재성을 극복하기 어렵다고 주장하는 것은 모순이라고 주장하고 있다. 그러나, 다운로드의 효율성과 결합판매의 효율성을 비교하기 위해서는 소비자가 다운로드 받을 메신저를 선택했다는 전제하에 그 이후의 메신저 설치에 드는 거래비용을 비교하여야 하므로 절약되는 거래비용의 크기가 상대적으로 적은 반면, 결합판매의 편재성과 관련하여서는 소비자가 다운로드 받을 메신저를 탐색하고 선택하는 과정까지 고려해야 하므로 앞에서 살펴본 바와 같이 다운로드 방식에 의해 메신저의 편재성을 극복할 수 없는바, 양 주장이 모순된다는 피심인들의 주장은 이유 없다.

둘째, 국내 메신저 시장에서 피심인들의 윈도우 메신저를 활용하여 개발된 사례를 시장에서 단 한건도 찾아볼 수 없다. 이러한 사실은 위에서 본 바와 같이 피심인들이 윈도우 메신저 사용자에게 MSN 메신저를 사용하도록 권유하는 태도와도 직접적 관련이 있다고 생각된다.

결론적으로, 피심인들이 주장하는 응용프로그램 개발효과는 거의 존재하지 않는다고 판단된다.

다) 서비스 제공업자의 편익이 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 다수의 SIP 프로토콜 기반 VoIP 서비스 사업자들이 윈도우 메신저에 의존하여 고객들에게 서비스를 제공하고 있고, 다수의 SIP 프로토콜 기반 솔루션 사업자들이 PC에 윈도우 메신저 기능이 탑재되어 있다는 전제 하에, 통신서버 솔루션을 개발하여 제공하고 있다고 주장한다. 그리고 그 사례로서 2002년 및 2003년 경 KT가 제공한 VoIP(Voice over Internet Protocol)를 들고 있다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들이 메신저를 결합판매 한지 6년이 경과하고 있음에도 불구하고 국내 서비스 사업자 중 윈도우 메신저에 의존하여 서비스를 제공한 사례는 사실상 단 한건도 존재하지 않는다.

둘째, 피심인들은 KT가 윈도우 메신저를 기반으로 VoIP(Voice over Internet Protocol)를 제공한 사례가 있다고 주장하나, KT가 2005. 9. 14. 위원회에 제출한 의견서에 의하면 이 VoIP 서비스는 인터넷에서 다운로드 받는 MSN 메신저를 윈도우98에 설치한 사용자도 이용할 수 있는 서비스라는 점에서 피심인들의 주장은 사실이 아닌 것으로 인정된다.

㉠ KT가 피심인 메신저를 기반으로 2002년부터 2004년까지 실시한 VoIP 서비스는 윈도우XP 뿐 아니라 윈도우98, 윈도우2000 사용자들도 모두 이용 가능한 서비스였다. 피심인들은 KT의 VoIP 서비스가 윈도우XP에 메신저를 포함한데 따른 편익으로 주장하고 있으나, 윈도우98 등 다른 운영체제 사용자도 이용 가능한 서비스였다는 점에서 사실이 아니라고 인정된다.

㉡ KT에 따르면, 이 VoIP 서비스는 MSN 메신저에서만 이용 가능한 서비스였다. 다만 윈도우 메신저의 경우에는 msnaddin 파일을 인터넷에서 다운로드 받아 설치한 경우에만 이용할 수 있었으며, msnaddin 파일을 설치한 윈도우 메신저는 MSN 메신저로 전환된 것이라는 취지로 답변하였다.

이렇게 MSN 메신저에서 작동하도록 VoIP 서비스가 제공되었다는 점은 이 서비스가 피심인들의 고유한 닷넷메신저 프로토콜을 이용한 서비스였다는 것을 의미한다. 따라서 이 VoIP 서비스가 윈도우 메신저의 SIP 프로토콜을 기반으로 제공된다는 피심인들의 주장은 사실이 아닌 것으로 판단된다.

결국 국내 서비스 사업자 중 윈도우 메신저 기능에 의존하여 제대로된 서비스를 개발한 사례를 피심인들은 단 한 건도 제시하지 못하고 있다. 이렇게 피심인들의 메신저를 이용한 서비스제공 실적이 극히 미미하다는 점은 피심인들이 주장하는 서비스 제공업자에 대한 편익 제공 주장이 비현실적임을 보여준다.

라) PC 제조업체에 대한 편익이 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 윈도우 운영체제에 새로운 기능을 통합한 것은, 보다 더 우수하고 다양한 PC의 기능을 원하는 소비자의 수요를 충족해야 하는 동시에 휴대폰과 같은 새로운 기기와 치열한 경쟁에 직면하고 있는 컴퓨터 제조업체들에게도 큰 이익이 된다고 주장한다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들의 메신저 결합판매는 소비자들이 메신저 없는 운영체제를 구입할 선택권을 박탈한 행위라는 점에서 소비자들의 수요에 부합한 행위라고는 할 수 없다.

둘째, 피심인들이 PC 제조업체에게 제공하는 이익의 예로 들고 있는 원격지원 기능은 다른 메신저들 또는 다른 소프트웨어도 제공할 수 있는 기능으로서 반드시 피심인들이 메신저를 운영체제에 결합판매하여야 향유할 수 있는 편익이 아니다. 예를 들어 원격지원 기능을 수행하는 케이티에이치(KTH)의 파란 메신저나 소프트웨어를 탑재하여도 PC 제조업체는 원격지원기능을 제공할 수 있는 것이다. 결국, 피심인들이 주장하는 PC 제조업체에 대한 효과는 무시할 정도라고 판단된다.

마) 소비자에 대한 편익이 증가한다는 주장에 대하여

피심인들은 윈도우 운영체제에 새로운 기능을 추가하는 것은 소비자들에게 유익하다고 주장한다. 특히 PC 초보자들은 PC를 처음 구입했을 때 바로 작동하기를 원하는 등 사용이 쉽기를 바란다고 한다.

그러나, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

첫째, 피심인들이 주장하는 기능들은 메신저 자체의 기능이지 결합판매로 인한 직접적인 편익은 아니다. 즉 이들 기능은 다른 사업자가 제공하는 메신저에서도 동일하게 제공될 수 있는 기능이므로 피심인들의 메신저를 운영체제에 결합 판매하는데 따른 편익으로 주장될 수 없다. 또한, 피심인들이 주장하는 결합판매의 편익도 PC 제조업체에 의한 메신저 탑재를 통해서도 동일한 편익을 얻을 수 있으므로 피심인들의 결합판매로 인한 고유한 편익이라고 할 수도 없다.

둘째, 피심인들은 2005. 7. 8. 위원회에 제출한 의견서[176]에서 피심인 메신저가 윈도우 운영체제 안에 포함되었을 때 느끼는 효용은 다운로드 받아 설치하지 않아도 되

176) 「컴퓨터 운영체제의 기능 추가가 소비자 후생에 미치는 효과에 관한 경제분석」(최재필 교수, Albert L. Nichols 박사) 48 페이지 참조

는 편리함에 불과하고 피심인 메신저를 사용하지 않는 소비자의 경우 메신저 결합판매가 제공하는 편익이 극히 미미함을 스스로 인정하고 있다.

(3) 결론

피심인들이 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저가 별개 제품임에도 불구하고 이를 결합하여 판매한 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 그 구입을 강제하는 결과를 초래하므로 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 행위이고 이와 같은 피심인들의 행위는 피심인 메신저로의 편재성을 초래하고 이로 인해 발생한 네트워크 효과 및 고착효과를 통해 메신저 시장의 경쟁을 제한할 뿐 아니라 그 거래내용 및 경쟁수단이 불공정한 반면, 그로 인한 효율성 증대효과는 미약하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 불공정한 거래행위라고 인정되므로 공정거래법 제23조 제1항 제3호 후단, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 〔별표 1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목의 '끼워팔기'에 해당한다.

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의2) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

'과징금 산정의 기준이 되는 고시'는 피심인들의 결합판매행위가 2000. 9.부터 이 사건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」(2005. 7. 13. 공정거래위원회 고시 제2005-15호, 이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용한다.

과징금 산정의 기초가 되는 '위반행위의 기간'은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하는 것으로 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 공정거래위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는, 당해 사건에 대한 공정거래위원회의 심의일을

위반행위의 종료일로 보되, 심의가 2일 이상 진행되었다면 마지막 심의일을 의미하는 바, 본 사안에서 피심인들의 위반 행위가 2000. 9.부터 지금까지 계속되고 있으므로 종료일은 본 사안의 마지막 심의 종료일인 2005. 10. 26.이다.

과징금 산정의 기준 금액이 되는 '관련 매출액'은 위반사업자가 위반기간 동안 판매 또는 매입한 관련 상품의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하는 것으로서 본 사안에서 법 위반기간 동안 윈도우 PC 운영체제의 매출액은 피심인 엠에스 1,209,309,260천원, 피심인 한국 엠에스 163,321,280천원이다.

(나) 과징금의 결정

'기본 과징금'은 관련매출액에 위반행위 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 피심인들의 법위반행위의 내용과 정도에 따라 산정되는 점수가 매우 중대한 위반행위에 해당하므로 최대의 부과기준율 2.0%를 적용하여, 피심인 엠에스에 대해서는 24,186,185천원, 피심인 한국 엠에스에 대해서는 3,266,425천원이 산출된다.

'의무적 조정 과징금'은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법위반 행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

'임의적 조정 과징금'은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로, 위에서 산정된 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 26,604,803천원, 한국 엠에스는 3,593,067천원이 산출된다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 시장 지배적 지위남용행위 중 다른 사업자에 대한 사업활동 방해행위와 관련한 과징금액은 위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여

피심인 엠에스는 26,604백만원, 한국 엠에스는 3,593백만원이 산출된다.

(2) 불공정거래행위의 금지 규정(제23조) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

'과징금 산정의 기준이 되는 고시'는 피심인들의 결합판매행위가 2000. 9.부터 본 건에 대한 심의 종료일 이후 현재까지 계속되고 있으므로 「과징금고시」를 적용한다.

(나) 과징금의 결정

'기본 과징금'은 관련매출액에 위반행위 중대성에 따라 정해지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 피심인들의 법위반행위의 내용과 정도에 따라 산정되는 점수가 매우 중대한 위반행위에 해당하므로 과징금 부과기준율 중 최대인 1.0%를 적용하여 피심인 엠에스에 대한 기본과징금 12,093,092천원, 피심인 한국 엠에스에 대한 기본과징금 1,633,212천원이 산출된다.

'의무적 조정 과징금'은 위반행위의 기간, 위반행위의 회수, 획득한 부당이익의 규모 등의 사유에 의하여 기본 과징금을 조정할 수 있으나, 피심인들의 법위반 행위에 대하여는 해당 사항이 없다.

'임의적 조정 과징금'은 법위반 행위자가 가지는 요소에 의하여 과징금을 조정하는 과정으로서, 피심인들의 법위반행위는 피심인들의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우라고 인정되므로 기본과징금에 100분의 10을 가중하여 피심인 엠에스는 13,302,401천원, 피심인 한국 엠에스는 1,796,533천원이 된다.

(다) 과징금액

따라서 피심인들의 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기와 관련한 과징금액은

위 과징금 산정의 기초 및 과징금액의 결정에 의하여 피심인 엠에스는 13,302백만원, 피심인 한국 엠에스는 1,796백만원이 산출된다.

(3) 부과과징금의 결정

이 사건 피심인들이 윈도우 PC 운영체제에 피심인 메신저를 결합하여 판매한 행위는 공정거래법상 제3조의2 시장지배적지위의 남용행위 중 제1항 제3호 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위 및 같은 항 제5호 후단의 소비자 이익 저해행위, 제23조 제1항 제3호 후단, 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련〔별표 1〕 불공정거래행위 유형 및 기준 제5호 가. 목의 '끼워팔기'에 각 해당하는바, 이는 기본적 사실관계가 동일한 하나의 행위에 수개의 조항을 적용한 경우에 해당하므로 이 중 과징금의 법정한도가 더 무거운 공정거래법 제3조의2 시장지배적 지위의 남용금지 규정위반에 따른 과징금을 피심인들에게 부과하기로 한다.

5. 이 사건 시정명령을 하게 된 구체적 이유는 다음과 같다.

본건 피심인들의 결합판매로 인하여 현재 국내시장에서 소비자와 PC제조업체는 부상품(미디어 서버, 미디어 플레이어, 메신저)없는 주상품(윈도우 운영체제)을 구입할 선택권을 박탈당하고, 부상품 시장에서 경쟁사업자가 축출되어 피심인들이 독점력을 확대 또는 고착화시키는 반경쟁적이며 소비자 이익을 저해하는 효과가 발생하고 있다.

특히, EC 등 다른 나라와 비교할 때 피심인들의 시장 독점화 정도가 높고 초고속 인터넷 등의 발달하여 미디어 플레이어 등 소프트웨어를 선택한 후 프로그램을 다운로드 받는데 소요되는 시간이 매우 작은 국내 현실에 비추어 볼 때 피심인들의 결합판매는 효율성 증대 효과는 극히 미미한 반면, 경쟁사업자 배제, 소비자 이익 저해 등의 경쟁제한 효과는 매우 심각하여 적극적인 시정조치가 필요하다.

이러한 효과를 제거하고 장점에 의한 경쟁이 이루어지도록 하기 위하여는, 피심인들로 하여금 2가지 버전의 윈도우 PC 운영체제(부상품이 분리된 버전 및 부상품을 탑

재하되 경쟁제품에 대한 접근기회가 보장된 버전)를 PC제조업체 및 소비자에게 제공토록 함으로써 이들에게 부상품 없는 주상품을 구입할 선택의 기회를 제공하고, 경쟁제품이 탑재된 버전의 경우 경쟁사업자가 피심인들 제품과 대등한 수준의 판촉 및 소비자 접근기회를 가질 수 있도록 하여 적정한 소비자 상품 선택권을 제공함으로써 이에 기초한 공정한 경쟁환경을 조성토록 할 필요가 있다.

다만, WMS가 결합된 윈도우서버 운영체제의 경우에는, 경쟁제품이 탑재된 버전을 공급하도록 한다 하더라도 경쟁사업자의 미디어 서버 제품이 대부분 상당한 가격에 거래되는 등의 이유로 그 실효성이 크지 않다는 점을 감안하여 WMS가 분리된 단일버전 제품만을 출시토록 하는 것이 타당하다.

이러한 시정조치는 윈도우 운영체제의 디자인을 본질적으로 변경하지 않는 것으로써, 현재의 왜곡된 국내시장 현실을 감안할 때 필요 최소한의 적합한 수단이며, 피심인들의 자유로운 영업활동에 대한 개입을 최소화하면서도 부당한 결합판매로 인한 시장폐해를 빠르고 효과적으로 회복시키게 될 것이다. 또한, 이미 관련시장에서 피심인들 제품으로의 쏠림현상이 가속화되고 이에 따라 경쟁사업자의 영업이 큰 지장을 받고 있는 사례가 나타나고 있는 시장현실에 비추어 피심인들의 결합판매로 인한 위법상태를 그대로 방치할 경우 독과점상태의 고착화로 인해 회복할 수 없는 경쟁제한효과가 발생할 우려가 있음을 고려한 것이다.

6. 결론

피심인들의 위 2. 나, 3. 나. 및 4. 나.의 행위사실은, 각각 공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 제5호 후단, 제23조 제1항 제3호 후단에 해당하므로, 공정거래법 제5조, 제6조 및 제24조의 규정에 의거 주문과 같이 시정명령하고 과징금을 부과하기로 한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2006년 2월 24일

의 장 위 원 장 강 철 규

위 원 안 희 원

주심위원 서 동 원

위 원 장 항 석

위 원 윤 창 호

위 원 최 정 표

위 원 김 영 호 의원면직으로 서명날인 불능
의 장

위 원 정 해 남 의원면직으로 서명날인 불능
의 장

(별지1)

이유부분 목차

1. 공통사실

가. 피심인 마이크로소프트 코퍼레이션에 대한 관할권

나. 피심인 적격성

다. 피심인 엠에스와 피심인 한국 엠에스의 관계

라. 피심인들의 일반현황

. 마. 미국과 유럽연합에서의 피심인 엠에스에 대한 경쟁당국의 조사 및 조치경위

바. 이 사건의 심의경위

2. 윈도우 서버 운영체제와 윈도우 미디어 서비스 결합판매

가. 기초사실

(1) 서버 운영체제의 현황

(가) 피심인들의 윈도우 서버 운영체제

(나) 피심인들 이외의 서버 운영체제

1) 유닉스 제품군

2) 리눅스 제품군

3) 기타 운영체제

(2) 미디어 서버 프로그램 현황

(가) 피심인들의 미디어 서버 프로그램

(나) 피심인들 이외의 미디어 서버 프로그램

1) 리얼네트웍스의 리얼 미디어 서버

2) 디디오넷의 씨비디오

3) 쌘뷰텍의 쌘스트림

4) 기타

나. 행위 사실

다. 관련 시장의 획정

(1) 관련 상품 시장

(가) 이 사건의 주된 상품 시장은 'PC 서버 운영체제 시장이다.

1) 클라이언트용 PC 운영체제는 PC 서버 운영체제를 대체하기 어렵다.

2) PC 서버 운영체제는 중대형 서버 운영체제를 대체하기 어렵다.

가) PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제는 기능 및 효용의 차이가 크다.

나) PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제는 가격이 유사하지 않다.

다. 소비자들은 PC 서버 운영체제와 중대형 서버 운영체제를 구분하여 인식하고 소비한다.

라) 판매자들은 양 서버 운영체제에 대한 판매전략 등 경영계획을 구분하여 수립하고 실행한다.

(나) 이 사건의 종된 상품 시장은 '스트리밍 미디어 서버 프로그램 시장'이다.

(2) 관련 지리적 시장

라. 시장지배적지위의 남용행위 중 사업활동 방해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 시장지배적사업자이다

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

1) 윈도우 서버 운영체제와 WMS는 별개의 제품이다.

가) WMS는 윈도우 서버 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니다.

나) WMS는 윈도우 서버 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

다) 통상적으로 서버 운영체제와 미디어 서버프로그램은 짝지워 하나의 단위로 판매 되지 않는다.

2) 피심인들의 행위는 부당하게 WMS를 원하지 않는 거래상대방에게 WMS의 구입을 강제한 것이다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

4) 소결

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

1) 피심인들의 행위는 WMS의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 미디어 서버 프로그램 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

2) 편재성으로 인한 경쟁상 우위는 쏠림현상을 발생시켜 경쟁제한 효과를 심화시킨다.

가) WMS의 편재성은 사용자들에 대한 접근성 및 이용가능성을 증가시킨다.

나) 피심인들의 결합판매행위는 WMS로의 쏠림현상을 발생시켜 경쟁을 더욱 제한한다.

다) 피심인들의 결합판매행위는 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소간 의존성으로 인하여 경쟁을 더욱 크게 제한한다.

① 피심인들의 디지털 미디어 시스템 구성요소 간에는 서로 의존성이 존재한다.

② 피심인들의 결합판매 행위는 피심인들 디지털 미디어 시스템 구성요소 간의 의존성으로 인하여 경쟁을 더욱 크게 제한한다

라) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장에 진입장벽을 구축하여 경쟁을 제한한다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

가) 윈도우2000 서버 운영체제와 WMS 4.1의 결합판매는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

① 피심인들의 결합판매 후 시장점유율이 급격하게 변화한 사실이 있다.

② 피심인들의 결합판매는 경쟁사업자인 리얼네트웍스의 한국시장에서의 사업활동을 방해한 사실이 있다.

나) 윈도우서버 2003 운영체제와 WMS 9의 결합판매는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

① 피심인들의 결합판매 후 시장점유율이 급격하게 변화한 사실이 있다.

② 피심인들의 결합판매행위는 경쟁사업자인 디디오넷 등의 사업활동을 방해한 사실이 있다.

다) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장에서 진입장벽을 구축하여 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

라) 소결

(3) 결론

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 소비자 이익을 현저히 저해하는 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 시장지배적사업자이다.

(나) 피심인들의 결합판매행위는 부당한 행위이다.

(다) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

1) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한하여 소비자

의 이익을 저해하거나 저해할 우려가 크다.

2) 결합판매는 소비자들의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해한다.

3) 결합판매로 인한 경쟁제한효과 유발은 기술혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

(3) 결론

바. 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

1) 윈도우 서버 운영체제와 WMS는 별개의 제품이다.

2) 피심인들은 부당하게 거래상대방에게 WMS의 구입을 강제한 것이다.

3) 소결

(나) 피심인들의 행위는 공정거래를 저해한다.

1) 피심인들의 결합판매 행위는 경쟁을 제한한다.

2) 피심인들의 결합판매 행위는 거래조건 또는 수단이 불공정한 행위이다.

3) 피심인들의 행위로 인한 효율성증대 효과는 미약하여 경쟁제한 효과를 능가하지 못한다.

4) 소결

(3) 결론

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의2)에 위반한 각 행위에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(2) 불공정거래행위의 금지 규정(제23조)에 위반한 행위에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(3) 부과과징금의 결정

아. 결론

3. 윈도우 PC 운영체제와 윈도우 미디어 플레이어의 결합판매 부분

가. 기초사실

(1) PC 운영체제 현황

(가) 피심인들의 윈도우 PC 운영체제 출시 및 가격

(나) 피심인들의 윈도우 PC 운영체제 국내판매 현황

(다) 윈도우 PC 운영체제 이외의 PC 운영체제

1) 리눅스 제품군

2) 멕(Mac) 운영체제

(라) PC 운영체제의 유통경로

(2) 디지털 콘텐츠

(3) 스트리밍 미디어 플레이어 현황

(가) 피심인들의 미디어 플레이어

(나) WMP 외의 미디어 플레이어

1) 원천기술 보유 사업자

2) 2차 사업자

(다) 미디어 플레이어의 유통경로

나. 행위 사실

다. 관련 시장 획정

(1) 관련 상품 시장

(가) 이 건에서 주된 상품 시장은 '인텔호환 PC 운영체제 시장'이다.

1) 비인텔호환 PC 서버 운영체제는 인텔호환 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

2) PC 서버 운영체제는 클라이언트 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

3) 휴대용 개인정보 단말기 등 개인용 정보기기를 위한 운영체제는 PC 운영체제를 대체하기 어렵다.

(나) 이 건에서 종된 상품 시장은 '스트리밍 미디어 플레이어 시장'이다.

1) CD나 DVD재생기와 같은 전통적인 기기는 스트리밍 미디어 플레이어를 대체하기 어렵다.

2) 스트리밍 미디어 플레이어는 오디오 전용 미디어 플레이어를 대체하기 어렵다.

3) 스트리밍 미디어 플레이어와 다운로드용 미디어 플레이어를 대체하기 어렵다.

4) 원천기술 사업자는 2차 사업자의 경쟁을 제한할 수 있으나, 2차 사업자는 원천기술 사업자와 대등한 경쟁을 하기 어렵다.

(2) 관련 지리적 시장

라. 시장지배적지위의 남용행위 중 사업활동방해 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 사실의 인정

(가) 피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 시장지배적사업자이다

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 WMP는 별개의 제품이다.

가) WMP는 윈도우 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니다.

나) WMP는 윈도우 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

① 소비자들은 PC 운영체제와는 별개로 미디어 플레이어를 수요하고 있다.

② 공급자들은 PC 운영제체와 독립적으로 미디어 플레이어를 공급하고 있다.

③ 피심인들도 WMP를 운영체제의 일부가 아닌 응용프로그램의 일종으로 인식하고 있다.

다) 통상적으로 서버 운영체제와 미디어 서버프로그램은 짝지워 하나의 단위로 판매 되지 않는다.

2) 피심인들의 행위는 부당하게 WMP를 원하지 않는 거래상대방에게 WMP의 구입을 강제한 것이다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

4) 소결

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

1) 피심인들의 결합판매행위는 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 경쟁을 제한한다.

가) 피심인들의 결합판매행위는 WMP의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 스트리밍 미디어 플레이어 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

① 경쟁사업자들이 다운로드방식에 의해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다.

② 경쟁사업자들이 PC 제조단계에서 탑재경로에 의해 WMP의 편재성을 극복하기 어렵다.

㉮ PC 제조업체 측면

㈏ PC 제조업체와 피심인들의 관계 측면

㈐ 미디어 플레이어 사업자 측면

③ 코드제거 곤란은 WMP의 편재성을 더욱 강화시킨다.

나) WMP의 편재성과 이에 따른 경쟁상 우위로 인하여 WMP로의 쏠림현상이 발생한다.

① 피심인들의 결합판매는 소비자들의 WMP 선택에 강한 영향을 미쳐 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

② 피심인들의 결합판매는 콘텐츠 및 소프트웨어를 통한 쏠림현상을 발생시킨다.

㈎ WMP 호환 포맷의 콘텐츠 양산에 따라 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

㈏ WMP 인터페이스에 기반한 응용프로그램 양산에 따라 WMP로의 쏠림현상을 발생시킨다.

③ 디지털 미디어 시스템 구성요소간 상호의존성에 따라 WMP로의 쏠림현상을 심화시킨다.

㈎ 디지털 미디어 시스템 구성요소간에는 기술적 상호호환성이 존재한다.

㈏ 디지털 미디어 시스템간의 기술적 상호호환성에 대한 시장조사 분석결과

④ 시장조사 분석 결과는 시장에서의 쏠림현상 발생을 실증하고 있다.

㈎ 콘텐츠 시장 점유율 조사 분석 결과

㈏ 미디어 플레이어 시장점유율 조사 분석 결과

다) 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에 진입장벽을 구축한다.

2) 피심인들의 결합판매행위는 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

가) 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에서 리얼네트웍스 등 경쟁사업자의 사업활동을 어렵게 한다.

① 피심인들의 결합판매는 미디어 플레이어 시장에서 경쟁사업자를 배제하고 있다.

㉮ 피심인들의 결합판매 후 WMP의 시장점유율이 급격히 상승하고 경쟁사업자의 시장점유율이 급격히 하락하고 있다.

㉯ 구체적인 경쟁사업자 배제 사례

② 피심인들의 결합판매는 경쟁사업자를 시장에서 배제하는 원인이다.

(3) 결론

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 부당하게 소비자 이익을 현저히 저해하는 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 시장지배적사업자이다.

(나) 피심인들의 결합판매행위는 부당한 행위이다.

(다) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

1) 피심인들의 결합판매는 미디어 서버 프로그램 시장의 경쟁을 제한하여 소비자의 후생을 저해하거나 저해할 우려가 크다.

2) 결합판매는 소비자들의 미디어 서버 프로그램에 대한 선택권을 침해한다.

3) 결합판매로 인한 경쟁제한효과 유발은 기술혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

(3) 결론

바 . 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 WMP는 별개의 제품이다.

2) 피심인들은 별개제품인 WMP를 부당하게 거래 상대방에게 구입을 강제한 것이다.

(나) 피심인들의 행위는 공정거래를 저해한다.

1) 피심인들의 행위는 경쟁제한효과를 발생시킨다.

2) 피심인들은 주된 상품의 시장지배적지위를 이용하여 불공정한 거래조건 또는 거래수단을 사용한다.

3) 피심인들의 행위로 인한 효율성증대효과는 미약하여 경쟁제한효과를 능가하지 못한다.

가) 유통비용 등 거래비용이 감소한다는 주장에 대하여

나) 응용프로그램의 개발편의를 제공한다는 주장에 대하여

다) PC 제조업체에 대한 편익이 증가한다는 주장에 대하여

라) 소비자에 대한 이익이 증가한다는 주장에 대하여

(다) 소결

(3) 결론

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의2) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(2) 불공정거래행위의 금지 규정(제23조) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(3) 부과과징금의 결정

아. 결론

4. 윈도우 PC 운영체제와 메신저의 결합판매 부분

가. 기초사실

(1) 메신저 현황

(가) 메신저의 의의 및 주요기능

(나) 메신저 사업자 현황

(다) 메신저 시장의 규모

(라) 메신저의 유통경로

(2) 메신저 시장의 특성

(가) 네트워크 효과

(나) 네트워크 효과의 폐쇄성

(다) 고착효과

(라) 네트워크 효과 및 고착효과에 의한 진입장벽

(마) 다양한 수익창출 형태

(3) 메신저시장의 연혁

(가) 도입기

(나) 확장기

(다) 성숙기

나. 행위 사실

다. 관련 시장 획정

(1) 관련 상품 시장

(가) 이 건에서 주된 상품 시장은 '인텔호환 PC 운영체제 시장'이다.

(나) 이 건에서 종된 상품 시장은 '일반용 메신저 시장'이다.

1) 일반용 메신저는 기업용 메신저와 기능 및 용도가 상이하다.

2) 일반용 메신저와 기업용 메신저는 수요자 및 구매형태가 상이하다.

3) 피심인들도 일반용 메신저와 기업용 메신저를 별개 시장으로 인식하고 있다.

(2) 관련 지리적 시장

라. 윈도우 메신저와 MSN 메신저의 관계

(1) 관련사실

(2) 윈도우 메신저와 MSN 메신저는 사실상 동일한 제품이다.

(가) 양자는 외형이 동일하여 수요자들이 동일한 제품으로 인식한다.

(나) 피심인들도 윈도우 메신저와 MSN 메신저를 사실상 하나의 제품으로 인식하고 있다.

(3) 윈도우 메신저는 그 사용자로 하여금 MSN 메신저를 사용하도록 유인한다.

(가) 피심인들은 '애드인 아키텍쳐'를 이용하여 MSN 메신저로의 사용을 사실상 유인하고 있다.

(나) 피심인들도 MSN 메신저를 윈도우 메신저의 업그레이드 버전으로 설명하고 있다.

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 사업활동 방해행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 PC 서버 운영체제 시장의 시장지배적사업자이다

(나) 피심인들의 행위는 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 것이다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저는 별개의 제품이다.

가) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제의 밀접불가분한 구성요소가 아니다.

나) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제와 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

① 소비자들은 PC 운영체제와는 별개로 메신저를 수요하고 있다.

② 공급자들은 PC 운영제체와 독립적으로 메신저를 공급하고 있다.

③ 피심인들도 메신저를 운영체제의 일부가 아닌 응용프로그램의 일종으로 인식하고 있다.

다) 통상적으로 메신저와 PC 운영체제는 짝지워 하나의 단위로 판매 되지 않는다.

2) 피심인들의 행위는 부당하게 피심인 메신저를 원하지 않는 거래상대방에게 피심인 메신저의 구입을 강제한 것이다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 거래상대방에게 불이익을 초래한다.

4) 소결

(다) 피심인들의 행위는 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

1) 피심인들은 결합판매를 운영체제 시장의 독점력 전이수단으로 사용하고 있다.

2) 피심인들의 행위는 메신저 시장에서 경쟁을 제한한다.

가) 피심인들의 결합판매행위는 피심인 메신저의 편재성을 발생시키고, 피심인들로 하여금 메신저 시장에서 경쟁상 우위를 획득하게 한다.

① 경쟁사업자들이 다운로드를 이용하여 피심인 메신저의 편재성을 극복하기 어렵다.

② 경쟁사업자들이 PC 제조단계에서 탑재경로를 이용하여 피심인 메신저의 편재성을 극복하기 어렵다.

㉮ PC 제조업체 측면
㉯ PC 제조업체와 피심인들의 관계 측면
㉰ 메신저 사업자 측면

③ 코드제거 곤란은 피심인 메신저의 편재성에 의한 네트워크효과를 더욱 강화시킨다.

나) 피심인 메신저의 편재성은 다른 사업자가 향유할 수 없는 강력한 네트워크 효과를 발생시킴으로써 피심인 메신저로의 쏠림현상을 초래한다.

① 피심인 메신저 결합판매가 피심인 메신저 사용률에 강한 영향을 미친다.

㉮ 피심인 내부문서

㉯ 메신저 사용자에 대한 설문조사 결과

㉰ 메신저 이용행태에 대한 통계분석

② 피심인들의 결합판매에 의해 메신저 시장에서 피심인 메신저로의 쏠림현상이 발생한다.

다) 피심인 메신저로의 쏠림현상은 메신저시장에서 품질 및 가격 등에 의한 경쟁을 제한하게 된다.

① 윈도우 Me 와 MSN 메신저 결합 관련

② 윈도우 XP와 윈도우 메신저 결합 관련

라) 피심인들의 결합판매는 메신저시장의 진입장벽을 높인다.

3) 피심인들의 결합판매행위는 미디어 플레이어 시장의 경쟁을 제한하여 경쟁사업자의 사업활동을 방해한다.

① 쏠림현상 및 이에 따른 경쟁제한 효과의 발생요인은 피심인들의 결합판매행위이다.

② 네이트온의 사례 분석

③ 피심인들의 결합판매행위는 메신저 시장의 진입장벽을 높여 다른 사업자의 사업활동을 방해한다.

(3) 결론

마. 시장지배적지위의 남용행위 중 소비자 이익을 현저히 저해하는 행위의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들은 시장지배적사업자이다.

(나) 피심인들의 결합판매행위는 부당한 행위이다.

1) 피심인 메신저는 윈도우 PC 운영체제와 별개의 제품이다.

2) 피심인들의 행위는 부당하게 피심인 메신저를 원하지 않는 거래상대방에게 피심인 메신저의 구입을 강제한 것이다.

(다) 피심인들의 결합판매행위는 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있다.

1) 피심인들의 결합판매는 메신저시장의 경쟁을 제한하여 소비자의 후생을 저해하거나 저해할 우려가 크다.

2) 결합판매는 소비자들의 메신저에 대한 선택권을 침해한다.

3) 결합판매로 인한 경쟁제한효과 유발은 기술혁신을 감소시켜 소비자의 이익을 저해한다.

(3) 결론

바. 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기의 성립

(1) 관련 규정의 해석

(2) 위법성 판단

(가) 피심인들의 행위는 거래상대방에 대하여 자기의 상품을 공급하면서 부당하게 다른 상품을 자기로부터 구입하도록 하는 행위이다.

1) 윈도우 PC 운영체제와 피심인 메신저는 별개의 제품이다.

2) 피심인들의 행위는 피심인 메신저를 원하지 않는 소비자에게 피심인 메신저의 구입을 강제하는 부당한 행위이다.

(나) 피심인들의 행위는 공정거래를 저해한다.

1) 피심인들은 결합판매를 운영체제 시장의 독점력 전이수단으로 사용하고 있다.

2) 피심인들의 행위는 메신저시장에서 경쟁을 제한하는 효과를 초래한다.

3) 피심인들은 불공정한 거래내용 또는 경쟁수단을 사용한다.

4) 피심인들의 행위로 인한 효율성증대효과는 미약하여 경쟁제한효과를 능가하지 못한다.

가) 유통비용 등 거래비용이 감소된다는 주장에 대하여

나) 응용프로그램의 개발편의를 제공한다는 주장에 대하여

다) 서비스 제공업자의 편익이 증가한다는 주장에 대하여

라) PC 제조업체에 대한 편익이 증가한다는 주장에 대하여

마) 소비자에 대한 이익이 증가한다는 주장에 대하여

(3) 결론

사. 과징금 부과

(1) 시장지배적지위의 남용금지 규정(제3조의2) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(2) 불공정거래행위의 금지 규정(제23조) 위반에 대한 과징금 산정

(가) 과징금 산정의 기초

(나) 과징금의 결정

(다) 과징금액

(3) 부과과징금의 결정

아. 결론

5. 이 사건 시정조치를 하게 된 구체적 이유

6. 결론

(별지2)

이 사건 관련 공정거래법 규정

1. 시장지배적지위의 남용금지 중 다른 사업자의 사업활동 방해행위 관련

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지)

① 시장지배적사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위(이하 “남용행위”라 한다)를 하여서는 아니된다.

3. 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위

② 남용행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정할 수 있다.

<같은 법 시행령>

□ 제5조(남용행위의 유형 또는 기준)

③ 법 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지) 제1항 제3호의 규정에 의한 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해는 직접 또는 간접으로 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 함으로써 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 경우로 한다.

4. 제1호 내지 제3호외의 부당한 방법으로 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위로서 공정거래위원회가 고시하는 행위

<시장지배적지위남용행위의심사기준> (공정거래위원회 고시 제2002-6호)

Ⅳ. 시장지배적지위 남용행위의 세부 유형 및 기준

3. 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해행위(법 제3조의2 제1항 제3호)
“직접 또는 간접적으로 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 함으로써 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 경우”(영 제5조 제3항)

라. 이외에 다음과 같은 행위로서 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위(영 제5조 제3항 제4호)

(3) 부당하게 거래상대방에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제하는 행위

2. 시장지배적지위의 남용금지 중 소비자이익 저해행위 관련

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지)

① 시장지배적사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위(이하 “남용행위”라 한다)를 하여서는 아니된다.

5. 부당하게 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하거나 소비자의 이익을 현저히 저해할 우려가 있는 행위

3. 불공정거래행위의 거래강제 중 끼워팔기 관련

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이라 “불공정행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

3. 부당하게 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

<같은 법 시행령>

□ 제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1과 같다.

[별표1] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항 관련)

5. 거래강제

: 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항제3호 후단에서 “부당하게 경쟁사의 고객을 자기와 거래하도록 강제하는 행위”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 끼워팔기

거래상대방에 대하여 자기의 상품 또는 용역을 공급하면서 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 다른 상품 또는 용역을 자기 또는 자기가 지정하는 사업자로부터 구입하도록 하는 행위

<불공정거래행위 심사지침>(공정거래위원회 예규 제26호)

Ⅲ. 위법성 심사의 일반원칙

1. 위법성 심사기준

가. 공정한 거래를 저해할 우려

(1) 법 제23조제1항에 열거된 개별행위 유형이 법위반에 해당되는지 여부를 판단하는 기준은 당해 행위가 '공정한 거래를 저해할 우려'(이하 "공정거래저해성"이라 함)가 있는지 여부이다.

(2) 공정거래저해성의 의미

(가) 상기의 '공정거래저해성'과 법 제23조제1항 각호에 규정된 '부당하게'는 그 의미가 동일한 것으로 본다.

(나) 공정거래저해성이란 경쟁제한성과 불공정성(unfairness)을 포함하는 개념으로 본다.

(다) 경쟁제한성이란 당해 행위로 인해 시장 경쟁의 정도 또는 경쟁사업자(잠재적 경쟁사업자 포함)의 수가 유의미한 수준으로 줄어들거나 줄어들 우려가 있음을 의미한다.

(라) 불공정성(unfairness)이란 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않음을 의미한다. 경쟁수단의 불공정성은 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있음을 의미한다. 거래내용의 불공정성이라 함은 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 의미한다.

Ⅴ. 개별행위 유형별 위법성 심사기준

5. 거래강제

가. 끼워팔기

(2) 위법성의 판단기준

(가) 끼워팔기가 바람직한 경쟁질서를 저해하는 불공정한 경쟁수단에 해당되는지 또는 경쟁을 제한하는지 여부를 위주로 판단한다.

(나) 이 때, 불공정한 경쟁수단에 해당 여부 또는 경쟁제한성 여부는 다음 사항을 종합적으로 고려하여 판단한다.

① 끼워팔기를 하는 사업자가 거래상대방에 대해 주된 상품(또는 용역)과 종된 상품(또는 용역)의 동반 구입을 강제할 수 있는지 여부. 이를 판단하기 위해 당해 상품 또는 용역의 시장지배력, 브랜드 특성, 소비실태 등을 고려한다.

② 끼워팔기가 정상적인 거래관행에 비추어 부당한지 여부, 정상적인 거래관행에 해당되는지 여부는 당해 시장에서의 통상적인 거래관행을 기준으로 하되, 통상적인 거래관행에 해당된다고 할지라도 끼워팔기에 의해 경쟁제한 효과가 발생하거나 소비자의 자율적 선택권이 침해되는 경우에는 부당한 것으로 본다.

③ 주된 상품(또는 용역)과 종된 상품(또는 용역)을 같이 구입하도록 강제하는지 여부 등. 강제성이 있는지 여부는 거래상대방의 입장에서 서로 다른 두 상품(또는 용역)을 따로 구입하는 것이 자유로운지를 기준으로 판단한다. 이때 '강제성'은 주된 상품(또는 용역)에 대한 구매자의 거래처 전환가능성이 적을수록 큰 것으로 보며, 다른 거래처에서 구입할 경우 주된 상품(또는 용역)의 거래거절이나 공급량 감소 등 각종 불이익이 예상됨으로 인하여 사실상 거래처를 전환할 수 없는 경우 등에는 강제성이 인정될 수 있다. 이때 거래상대방이 자기 또는 자기가 지정하는 사업자로부터 실제로 구입하였을 것을 필요로 하지 않는다.

(다) 끼워팔기가 불공정한 경쟁수단에 해당되거나 경쟁제한성이 있다고 판단되는 경우에도 다음과 같이 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 법 위반으로 보지 않을 수 있다.

① 끼워팔기로 인한 효율성 증대효과나 소비자 후생 증대효과가 경쟁수단의 불공정성으로 인한 공정거래 저해효과나 경쟁제한 효과를 현저히 상회하는 경우

② 끼워팔기를 함에 있어 기타 합리적 사유가 있다고 인정되는 경우 등

4. 관련 시장 획정 관련

<시장지배적지위남용행위의심사기준>(공정거래위원회 고시 제2002-6호)

Ⅱ. 일정한 거래분야의 판단기준

일정한 거래분야는 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 거래분야를 말하며, 거래대상, 거래지역, 거래단계, 거래상대방 등에 따라 구분될 수 있다.

1. 거래대상(상품 또는 용역시장)

가. 일정한 거래분야는 거래되는 특정 상품의 가격이나 용역의 대가(이하 “가격”이라 한다)가 상당기간 어느 정도 의미있는 수준으로 인상(인하)될 경우 동 상품이나 용역의 대표적 구매자(판매자)가 이에 대응하여 구매(판매)를 전환할 수 있는 상품이나 용역의 집합을 말한다.

나. 특정 상품이나 용역이 동일한 거래분야에 속하는지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.

(1) 상품이나 용역의 기능 및 효용의 유사성
(2) 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매행태
(3) 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태

2. 거래지역(지역시장)

가. 일정한 거래분야는 다른 모든 지역에서의 가격은 일정하나 특정 지역에서만 상당기간 어느 정도 의미있는 가격인상(가격인하)이 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자(판매자)가 이에 대응하여 구매(판매)를 전환할 수 있는 지역전체를 말한다.

나. 특정 지역이 동일한 거래분야에 속하는지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.

(1) 상품이나 용역의 특성(부패성, 변질성, 파손성 등) 및 판매자의 사업능력(생산능력, 구매망의 범위 등)
(2) 운송비용
(3) 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매지역 전환행태
(4) 판매자의 판매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경여의사결정행태
(5) 시간적, 경제적, 법적 측면에서의 구매지역 전환의 용이성

5. 시장지배적사업자 여부 판단기준

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제2조(정의)

이 법에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음과 같다.

7. “시장지배적사업자”라 함은 일정한 거래분야의 공급자나 수요자로서 단독으로 또는 다른 사업자와 함께 상품이나 용역의 가격·수량·품질 기타의 거래조건을 결정·유지 또는 변경할 수 있는 시장지위를 가진 사업자를 말한다. 시장지배적사업자를 판단함에 있어서는 시장점유율, 진입장벽의 존재 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모 등을 종합적으로 고려한다. 다만, 일정한 거래분야에서 연간 매출액 또는 구매액이 10억원 미만인 사업자를 제외한다.

□ 제4조(시장지배적사업자의 추정)

“일정한 거래분야에서 시장점유율이 다음 각호의 1에 해당하는사업자는 제2조(정의) 제7호의 시장지배적사업자로 추정한다”

1. 1사업자의 시장점유율이 100분의 50이상
2. 3이하의 사업자의 시장점유율 합계가 100분의 75이상. 다만, 이 경우에 시장점유율이 100분의 10미만인 자를 제외한다.

6. 시정조치 관련

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제5조(시정조치)

“공정거래위원회는 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지)의 규정에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 시장지배적사업자에 대하여 가격의 인하, 당해행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다”

7. 과징금 관련

<독점규제 및 공정거래에 관한 법률>

□ 제6조(과징금)

공정거래위원회는 시장지배적사업자가 남용행위를 한 경우에는 당해 사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액(대통령령이 정하는 사업자의 경우에는 영업수익을 말한다. 이하 같다)에 100分의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우로서 대통령령이 정하는 경우(이하 "매출액이 없는 경우등"이라 한다)에는 10억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

□ 제24조의2(과징금)

공정거래위원회는 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에**는** 당해사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 2(제7호의 규정에 위반한 경우에는 100분의 5)를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우 등에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

□ 제55조의3(과징금의 부과)

① 공정거래위원회는 이 법의 규정에 의한 과징김을 부과함에 있어서 다음 각호의 사항을 참작하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 회수
3. 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모등

③ 제1항의 규정에 의한 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

<같은 법 시행령>

□ 제61조(과징금 부과기준)

① 법 제6조(과징금), 법 제17조(과징금), 법 제17조의2(시정조치 등에 대한 특례) 제5항, 법 제22조(과징금), 법 제24조의2(과징금), 법 제28조(과징금), 법 제31조의2(과징금) 및 법 제34조의2(과징금)의 규정에 의한 과징금의 부과기준은 별표 2와 같다

[별표2] 위반행위의 과징금 부과기준 (제61조제1항관련)

1. 과징금 부과여부의 결정

과징금은 위반행위의 내용 및 정도를 우선적으로 고려하고 시장상황 등을 종합적으로 참작하여 그 부과여부를 결정하되, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 원칙적으로 과징금을 부과한다.

가. 자유롭고 공정한 경쟁질서를 크게 저해하는 경우
나. 소비자 등에게 미치는 영향이 큰 경우
다. 위반행위에 의하여 부당이득이 발생한 경우
라. 그 밖에 가목 내지 다목에 준하는 경우로서 공정거래위원회가 정하여 고시하는 경우

2. 과징금의 산정기준

과징금은 법 제55조의3(과징금 부과)제1항 각호에서 정한 참작사유와 이에 영향을 미치는 사항을 고려하여 산정하되, 기본과징금, 의무적 조정과징금, 임의적 조정과징금, 부과과징금의 순서에 따라 단계적으로 산정한다.

가. 기본과징금

법 제55조의3(과징금 부과)제1항제1호의 규정에 의한 위반행위의 내용 및 정도에 따라 위반행위를 “중대성이 약한 위반행위”, “중대한 위반행위”, “매우 중대한 위반행위”로 구분하고, 위반행위의 중대성의 정도별로 다음의 기준에 따라 산정한 금액을 기본과징금으로 한다.

위반행위 유형	세부 유형	관련 법조문	기본과징금
1.시장지배적 지위남용행위	시장지배적 지위남용 행위	1. 법 제3조의 2 제1항, 제6조	위반사업자가 위반기간 동안 판매 또는 매입한 관련상품(상품에는 용역을 포함한다. 이하 같다)의 매출액(매입액을 포함한다. 이하 같다) 또는 이에 준하는 금액(이하 “관련매출액”이라 한다)에 100분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서, 관련매출액에 중대성의 정도별로 정하는 부과기준율을 곱한 금액. 다만, 관련매출액을 산정하기 곤란하거나, 이영 제10조 각호의 1에 해당하는 경우(이하 “관련매출액을 산정하기 곤란한 경우 등”이라 한다)에는 10억원 이내에서 중대성의 정도별로 정하는 금액.
4.불공정거래 행위 등	가.불공정거래 행위 (부당한 지원행위 제외)	2. 법 제23조 제1항제1호 내지 제5호 및 제8호, 제24조의2	관련매출액에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서, 관련매출액에 중대성의 정도별로 정하는 부과기준율을 곱한 금액. 다만, 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우 등에는 5억원 이내에서 중대성의 정도별로 정하는 금액

비고: 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 정하고, 위반기간은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간으로 하며, 매출액은 사업자의 회계자료 등을 참고하여 정하는 것을 원칙으로 하되, 각각의 범위는 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.

나. 의무적 조정과징금

법 제55조의3(과징금 부과)제1항제2호의 규정에 의한 위반행위의 기간 및 횟수에 따라 각각 기본과징금의 100분의 50의 범위 안에서 공정거래위원회가 정하여 고시하는 기준에 따른 금액을 기본과징금에 가산한 금액과, 법 제55조의3(과징금 부과)제1항제3호의 규정에 의한 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모에 상당하는 금액을 비교하여, 이 중 큰 금액을 의무적 조정과징금으로 한다.

다. 임의적 조정과징금

법 제55조의3(과징금 부과)제1항 각호의 사항에 영향을 미치는 위반사업자의 고의·과실, 위반행위의 성격과 사정, 재정적 상황 및 시장 여건 등의 사유를 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 의무적 조정과징금을 가중 또는 감경한 금액을 임의적 조정과징금으로 한다. 이 경우 가중 또는 감경하는 금액은 각각 의무적 조정과징금의 100분의 50을 초과할 수 없다.

라. 부과과징금

(1) 임의적 조정과징금의 금액이 위반사업자(위반사업자단체를 포함한다)의 현실적 부담능력이나 그 위반행위가 시장에 미치는 효과 등을 충분히 반영하지 못하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에는 그 임의적 조정과징금을 100분의 50 이내에서 감액하여 부과과징금으로 할 수 있다.

(2) 위반사업자의 부채가 지급불능 또는 지급정지 상태에 있거나 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 등의 사유로 인하여 위반사업자가 객관적으로 과징금을 납부할 능력이 없다고 인정되는 경우, 위반사업자가 속한 시장 또는 산업의 객관적인 사정 또는 여건의 급격한 변화에 비추어 과징금을 부과하지 아니하는 것이 타당하다고 인정되는 경우, 그 밖에 이에 준하는 사유가 있는 경우에는 모든 사정을 종합적으로 고려하여 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

3. 세부기준의 제정

기본과징금의 부과기준율, 관련매출액의 산정에 관한 세부기준, 의무적 조정과징금 및 임의적 조정과징금의 산정을 위한 기준, 그 밖에 과징금의 부과에 관하여 필요한 세부적인 기준과 방법 등에 관한 사항은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

<과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시>(공정거래위원회 고시 2005-15호)

I. 목 적

이 고시는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)」 제55조의3(과징금 부과), 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제9조제2항, 제61조 제1항·제3항 및 별표 2의 규정에 따른 과징금 부과의 세부기준 및 기타 과징금을 부과함에 있어서 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

II. 정 의

1. 기본과징금

“기본과징금”은 법 제55조의3의 규정에 의한 참작사유중 위반행위의 내용 및 정도에 따라 위반행위를 “중대성이 약한 위반행위”, “중대한 위반행위”, “매우 중대한 위반행위”로 구분하고, 각 위반행위의 유형에 따라 위반행위의 중대성의 정도별로 정하는 기준에 의하여 산정한 금액으로서 과징금 산정의 기초가 되는 금액을 말한다.

2. 의무적 조정과징금

“의무적 조정과징금”은 법 제55조의3의 규정에 의한 참작사유중 위반행위의 기간 및 횟수와 부당이득의 규모를 고려하여 기본과징금을 조정한 금액을 말한다.

3. 임의적 조정과징금

“임의적 조정과징금”은 의무적 조정과징금에 법 제55조의3의 규정에 의한 각 참작사유에 영향을 미치는 위반사업자(위반사업자단체를 포함한다. 이하 같다)의 고의·과실 등 행위자요소, 위반행위의 성격과 사정, 재정적 상황 및 시장여건 등의 사유를 고려하여 의무적 과징금을 가중 또는 감경한 금액을 말한다.

4. 부과과징금

“부과과징금”은 임의적 조정과징금이 위반사업자의 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 기타 시장 또는 경제여건 등을 충분히 반영하지 못하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에 이를 감액(면제를 포함한다)하여 부과하는 금액을 말한다.

5. 관련매출액

가. “관련매출액”은 위반사업자가 위반기간 동안 판매 또는 매입한 관련상품(상품에는 용역을 포함한다. 이하 같다)의 매출액(매입액을 포함한다. 이하 같다) 또는 이에 준하는 금액을 말한다.

나. 관련상품의 범위

(1) 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다. 관련상품에는 당해 위반행위로 인하여 거래가 실제로 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품이 포함된다.

(2) 위 (1)에 의하여 관련상품의 범위를 정하기 곤란한 경우에는 당해 위반행위로 인하여 직접 발생하였거나 발생할 우려가 현저하게 된 다른 사업자(사업자단체를 포함한다. 이하 같다)의 피해와 연관된 상품을, 다른 사업자의 직접적 피해가 없는 경우에는 소비자의 직접적 피해와 연관된 상품을 관련상품으로 볼 수 있다.

(3) 관련상품의 범위를 결정할 때에는 「통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 5단위 분류 또는 광공업조사통계보고서상의 8단위 분류」또는「당해 사업자의 품목별 또는 업종별 매출액 등의 최소 회계단위」를 참고할 수 있다.

다. 매출액의 산정

(1) 매출액은 사업자의 회계자료 등을 참고하여 정하되, 위반행위로 인하여 발생한 매출이 없는 경우에는 과거 실적, 관련 사업자의 계획, 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 매출액을 산정할 수 있다. 다만, 이 경우 반품 등의 사유로 일부가 공제된 경우에는 이를 고려할 수 있다.

(2) 위반행위가 상품의 구매와 관련하여 이루어진 경우에는 매입액을 기준으로 하고, 입찰 또는 특정 계약에 직접 관련되거나 한정된 경우에는 계약금액을 기준으로 한다.

(3) 영 제9조의2(영업수익 사용 사업자의 범위)의 규정은 이 고시를 적용할 때에 적용된다.

6. 위반기간

가. “위반기간”은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다. 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업·재무관련 자료, 임직원·거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태·관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.

나. 다음의 경우에는 특정일을 위반행위의 종료일로 본다.

(1) 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 공정거래위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는, 당해 사건에 대한 공정거래위원회의 심의일을 위반행위의 종료일로 본다.

(2) 위반행위가 2일 이상 행하여지되 불연속적으로 이루어진 경우에는, 당해 위반행위의 유형·성격·목적·동기, 연속되지 아니한 기간의 정도와 이유, 위반행위의 효과, 시장상황 등 제반사정을 고려하여 경제적·사회적 사실관계가 동일하다고 인정되는 범위 내에서 이를 하나의 위반행위로 보아 마지막 위반행위의 종료일을 당해 위반행위의 종료일로 본다.

(3) 위반행위의 실행은 종료되었으나 사업자가 그 실행의 결과를 유지하면서 그로 인하여 지속적으로 이익을 취득하거나 손해를 발생시키고 있는 경우에는 이익의 취득 혹은 손해의 발생이 종료된 날을 위반행위의 종료일로 본다.

12. 심의일

“심의일”은 공정거래위원회의 전원회의 또는 소회의의 의장이 공정거래위원회회의운영및사건절차등에관한규칙(공정거래위원회 고시 제2004-8호, 이하 “사건절차규칙”이라 한다) 제3장에 정한 절차에 따라 심의에 부의한 사건에 대하여 각 회의가 의결을 위하여 심의를 진행한 날을 말한다. 만일 심의가 2일 이상 진행되었다면 마지막 심의일을 말한다.

III. 과징금 부과 여부의 결정

1. 일반원칙

가. 과징금 부과여부는 위반행위의 내용 및 정도를 우선적으로 고려하고 시장상황 등을 종합적으로 참작하여 결정하되, 위반행위로 인한 자유롭고 공정한 경쟁질서

의 저해효과가 중대하거나 소비자 등에게 미치는 영향이 큰 것으로 판단되는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.

나. 그 밖에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 가격 또는 물량을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하거나 가격 또는 물량의 결정·유지·변경 또는 제한을 목적으로 하는 위반행위의 경우

(2) 가격·물량 외의 거래조건과 관련된 위반행위는 경쟁질서를 저해하는 효과가 크거나 다수의 사업자 또는 소비자에게 미치는 영향이 중대하다고 인정되는 경우

(3) 위반행위에 의하여 위반사업자가 부당이득을 얻었거나 다른 사업자로 하여금 부당이득을 얻게 한 경우

다. III.2.에서 정한 행위유형별 기준은 위 가. 및 나.에 우선하여 적용한다. 다만, III.2.에서 과징금 부과대상으로 정해지지 아니한 행위로서 부과대상에서 제외함이 명시되지 아니하고 일반원칙상 부과대상인 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.

라. III.의 규정에 불구하고, 법 제55조의3제1항 각호의 사항을 종합적으로 고려할 때 위반행위에 대하여 과징금을 부과할 실익이 크지 아니하거나 과징금을 부과함으로써 달성할 목적이 분명하지 아니한 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

2. 행위유형별 기준

가. 시장지배적 지위 남용행위

(2) 법 제3조의2제1항제3호에 위반하는 행위에 대하여는, 다른 시장지배적 지위 남용행위를 달성하기 위한 수단으로 행해지거나 시장지배적 지위를 형성·유지·강화하기 위하여 행해진 경우에 원칙적으로 과징금을 부과한다. 그 외의 경우에는 위반행위와 관련된 위반사업자의 사정, 위반행위의 동기 및 효과, 시장상황 등 구체적 사정을 참작하여 과징금 부과 여부를 결정한다.

(3) 법 제3조의2제1항제4호 및 제5호에 위반하는 행위에 대하여는, 신규 사업자의 시장 진입 억제, 경쟁사업자 배제 또는 소비자 이익의 현저한 저해 효과가 단기간

에 나타나거나 나타날 우려가 현저한 경우에 원칙적으로 과징금을 부과한다. 그 외의 경우에는 위반행위와 관련된 위반사업자의 사정, 위반행위의 동기 및 효과, 시장상황 등 구체적 사정을 참작하여 과징금 부과여부를 결정한다.

라. 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외), 재판매가격 유지행위 및 부당한 국제계약 체결행위

(1) 공동의 거래거절, 계열회사를 위한 차별, 집단적 차별 등의 행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 그 외의 유형에 해당하는 불공정거래행위(시행령 별표 1에 규정된 25개 세부행위유형을 말한다), 재판매가격 유지행위 및 부당한 국제계약 체결행위에 대하여는 ①다수의 경쟁사업자, 거래상대방 또는 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 현저한 경우, ②위반사업자가 위반행위로 인하여 부당이득을 얻은 경우, 또는 ③위반행위가 악의적으로 행해진 경우에 원칙적으로 과징금을 부과한다.

(2) 위 (1)의 규정에도 불구하고, 사건절차규칙 제29조에 의한 심사보고서가 전원회의 또는 소회의에 제출된 날로부터 최근 3년 이내에 같은 유형의 위반행위(불공정거래행위의 경우는 영 별표 1에 규정된 행위유형 중 부당한 자금·자산·인력의 지원행위를 제외한 8개 행위유형을 말한다)로 인하여 2회 이상 공정거래위원회로부터 시정권고 이상(시정명령, 과징금 납부명령 및 고발을 포함한다)의 시정조치를 받은 사실이 있는 경우에는 당해 불공정거래행위 또는 재판매가격 유지행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 과거 위반사실의 횟수를 산정할 때에 시정조치의 무효 또는 취소판결이 확정된 건은 제외한다.

(3) 사건절차규칙 제50조제2항 관련 별표 경고의 기준중 2. 불공정거래행위 및 재판매가격 유지행위 부문의 각호의 1에 해당하는 경우에는 원칙적으로 과징금을 부과하지 아니 한다.

IV. 과징금의 산정기준

1. 위반행위 유형별 기본과징금

기본과징금은 위반행위를 그 내용 및 정도에 따라 “중대성이 약한 위반행위”, “중대한 위반행위”, “매우 중대한 위반행위”로 구분한 후, 위반행위 유형별로 아래에 정한 중대성의 정도별 부과기준율 또는 부과기준금액을 적용하여 정한다. 이 경우 위반행위 중대성의 정도는 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 시장에 미치

는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 기타 위반행위 전후의 사정 및 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 정한다.

가. 시장지배적 지위 남용행위

(1) 관련매출액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 기본과징금을 산정한다.

중대성의 정도	부과기준율
매우 중대한 위반행위	1.5~2.0%이하
중대한 위반행위	1.0~1.5%이하
중대성이 약한 위반행위	0.3~1.0%이하

라. 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외)·재판매가격 유지행위 및 부당한 국제계약 체결행위

(1) 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외), 재판매가격 유지행위 및 사업자의 부당한 국제계약 체결행위

(가) 관련매출액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 기본과징금을 산정한다.

중대성의 정도	부과기준율
매우 중대한 위반행위	0.8~1.0%이하
중대한 위반행위	0.4~0.8%이하
중대성이 약한 위반행위	0.1~0.4%이하

2. 의무적 조정과징금의 산정(행위요소에 의한 조정)

가. 위반행위의 기간에 의한 조정

기본과징금이 관련매출액을 기준으로 산정되지 아니한 경우에는 다음과 같이 위반기간에 따라 기본과징금을 조정한다.

(1) 단기 위반행위: 위반기간이 1년 이내인 경우는 기본과징금을 유지한다.

(2) 중기 위반행위: 위반기간이 1년 초과 2년 이내인 경우에는 기본과징금의 100분의 10에 해당하는 금액을, 2년 초과 3년 이내인 경우에는 기본과징금의 100분의 20에 해당하는 금액을 가산한다.

(3) 장기 위반행위: 위반기간이 3년을 초과하는 경우에는 기본과징금의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한다.

나. 위반행위의 횟수에 의한 조정

(1) 당해 사건에 관하여 사건절차규칙 제29조에 의한 심사보고서가 전원회의 또는 소회의에 제출된 날로부터 최근 3년간, 위반사업자가 공정거래위원회로부터 시정권고 이상(시정명령, 과징금 및 고발을 포함한다)의 시정조치를 3회 이상 받은 경우에는, 3회 위반행위 부터 위반행위 1회당 기본과징금의 100분의 10에 해당하는 금액을 가산한다. 다만, 가산금의 합계는 기본과징금의 100분의 50을 초과할 수 없다.

(2) 위 (1)에서 과거 시정조치의 횟수를 산정할 때에는 시정조치의 무효 또는 취소판결이 확정된 건을 제외한다.

(3) 위반행위의 횟수를 계산함에 있어서는 위반행위를 경제력집중 억제규정 위반행위, 부당한 지원행위와 그 외의 위반행위 등 3종으로 구분하고 이를 각각 별개로 보아 서로 합산하지 아니한다.

다. 부당이득에 의한 조정

(1) 당해 위반행위로 인한 부당이득의 전부 또는 일부를 산정할 수 있고 그 산정된 금액이 기본과징금에서 위 가.와 나.를 적용하여 조정된 금액을 초과하는 경우에는 그 산정된 부당이득 금액을 의무적 조정과징금으로 하고, 그러하지 아니한 경우에는 위 가.와 나.를 적용하여 조정된 금액을 의무적 조정과징금으로 한다.

(2) 부당이득 금액은 전체적인 경제적·사회적 관계 등을 고려하여 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 얻은 경제적 이익으로 산정하되, 관련 사업자의 회계자료 등을 기초로 한다. 이 때 위반기간중의 시장상황의 변동 등에 의한 부당이득 규모의 감소 또는 증가는 이를 주장하는 자가 입증하는 경우에 한하여 참작한다.

3. 임의적 조정과징금의 산정(행위자요소 등에 의한 가중・감경)

가. 일반원칙

행위자 요소 등에 의한 가중・감경은 위반사업자에게 다음 나. 및 다.에서 정한 가중 또는 감경사유가 인정되는 경우에 각각의 가중비율의 합에서 각각의 감경비율의 합을 공제하여 산정된 비율을 의무적 조정과징금액에 곱하여 산정된 금액을 의무적 조정과징금에 더하거나 빼는 방법으로 한다. 다만, 가중・감경의 결과 가감되는 금액은 의무적 조정과징금의 100분의 50 범위 내이어야 한다.

나. 가중사유 및 비율

(1) 다수의 사업자가 관련된 상황에서 위반행위를 주도하거나 선동한 경우 : 100분의 30 이내

(2) 위반행위의 위법성과 공정거래위원회의 조사가 진행되고 있음을 알면서도 정당한 이유없이 과징금 부과처분을 명하는 심의일까지 위반행위를 종료하거나 위반상태를 시정하지 아니한 경우 : 100분의 20 이내

(3) 위반사업자가 위반행위에 응하지 아니하는 다른 사업자에 대하여 보복조치를 하거나 하게 한 경우 : 100분의 20 이내

(4) 위반사업자 또는 그 소속 임원・종업원이 위반행위의 조사를 거부・방해 또는 기피하거나, 위반행위를 적극적으로 은폐하는 등의 방법으로 공정거래위원회의 조사를 어렵게 한 경우 : 100분의 20 이내. 다만, 위반사업자가 동일한 사유로 법 제69조의2의 규정에 의하여 과태료 처분을 받은 경우에는 그 금액을 가중금액에서 차감한다.

(5) 위반사업자의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우(사업자단체 금지행위는 제외한다) : 100분의 10 이내

(6) 기타 위 (1) 내지 (5)의 사항에 준하는 사유가 있는 경우 : 100분의 10 이내

다. 감경 사유 및 비율

(1) 사업자들간에 공동행위의 합의를 하고 실행을 하지 아니한 경우, 입찰담합의 경우로서 입찰이 무효가 된 경우(다만, 당해 담합이 있었다는 사실 또는 당해 담합에 대하여 공정거래위원회의 시정조치가 있었다는 사실을 이유로 입찰이 무효가 된 경우는 제외한다) 및 사업자단체가 제26조제1항제1호에 위반하는 합의를 하고 실행을 하지 아니한 경우 : 100분의 30 이내

(2) 다수의 사업자가 관련된 상황에서 위반행위에 단순 가담하거나 추종적인 역할만을 수행한 것이 명백한 경우, 또는 자신의 이익과는 무관하게 오로지 다른 사업자의 권유나 대리로 참여하였거나 기망 또는 강박에 의하여 부득이하게 참여한 경우 : 100분의 30 이내. 다만, 입찰담합에 있어서 탈락한 것을 이유로 기본과징금이 100분의 30 이상 감액된 참가사업자에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

(3) 조사에 적극 협력한 경우 : 100분의 20 이내. 다만, 법 제19조에 위반하는 행위의 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 정부의 시책(구속력이 있는 행정지도 포함)이 동인이 되어 위반행위가 이루어진 것으로 인정되는 경우 : 100분의 20 이내

(5) 위반행위를 자진 시정한 경우

(가) 사건심사 착수보고 전에 자진시정한 경우 : 100분의 20 이내
다만, (9)(나)에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

(나) 사건심사 착수보고 후, 심의일 전에 자진시정한 경우 : 100분의 10 이내

(6) 과실에 의한 것이거나 상당한 주의를 기울인 경우

(가) 복수의 외부 변호사 자문을 거치는 등 위법행위를 하지 아니하기 위하여 상당한 주의를 기울였음이 명백하나 위반행위로 인정된 경우 : 100분의 10 이내

(나) 통상의 업무 수행 중 과실에 의하여 위반행위를 한 사실이 객관적으로 명백한 경우 : 100분의 10 이내

(7) 법에 위반하는 내용의 계약이나 관행을 실제로는 이행하지 못한 경우 (다만, 부당한 공동행위는 제외한다) : 100분의 10 이내

(8) 재정적으로 과징금 부담능력이 부족한 경우에는 다음 각호의 1의 규정에 따라 감경할 수 있다.

(가) 전년도 당기순이익이 적자인 경우 : 100분의 10 이내
(나) 최근 2년 이상 당기순이익이 연속적자인 경우 : 100분의 20 이내
(다) 위반사업자에 대하여 회사정리, 화의, 파산 또는 기업구조조정촉진법상의 채권자 관리절차가 개시된 경우 : 100분의 50 이내

4. 부과과징금의 결정

가. 임의적 조정과징금이 위반사업자의 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 기타 시장 또는 경제여건 등을 충분히 반영하지 못하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에 공정거래위원회는 임의적 조정과징금을 마지막으로 다음과 같이 조정하여 부과과징금을 결정할 수 있다.

(1) 임의적 조정과징금 산정시 충분히 고려되지 아니한 위반행위의 파급효과, 구체적인 경제적 상황, 해당 사업자들이 발생시킨 경제적 또는 재정적 이익, 해당 사업자들의 구조적인 특징, 특정한 사회적 상황에서의 실제적인 지급능력 등과 같은 시장 또는 산업의 구조 및 객관적인 여건 등에 비추어 임의적 조정과징금이 부당이득의 환수, 법 위반의 방지 또는 제재 목적을 달성하기에 필요한 범위에 비하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에는 임의적 조정과징금의 100분의 50까지 감액할 수 있다.

(2) 위반사업자의 부채가 지급불능 또는 지급정지 상태에 있거나 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 등의 사유로 인하여 위반사업자가 객관적으로 과징금을 납부할 능력이 없다고 인정되는 경우, 위반사업자가 속한 시장 또는 산업의 객관적인 사정 또는 여건의 급격한 변화에 비추어 과징금을 부과하지 아니함이 타당하다고 판단되는 경우, 기타 이에 준하는 사유가 있는 경우에는 제반 사정을 종합적으로 고려하여 과징금을 면제할 수 있다

나. 법 제19조에 위반하는 행위로서 법 제22조의2(신고자등에 대한 감면)의 적용대상이 되는 경우에는 그 기준에 따라 임의적 조정과징금을 감경 또는 면제할 수 있다.

다. 하나의 사업자가 행한 여러 개의 위반행위를 함께 심의하여 1건으로 의결할 때에는 각 위반행위별로 이 고시에서 정한 방식에 의하여 부과과징금을 산정하고 이를 모두 합산한 금액을 당해 건에 대한 부과과징금으로 함을 원칙으로 하되, 그 합산

금액이 심히 과다하다고 인정되는 경우에는 위 가.의 기준에 따라 이를 조정할 수 있다. 부과과징금의 한도에 관하여도 각 위반행위별로 정해진 법상 한도를 합산하여 적용한다.

라. 임의적 조정과징금이 1백만원 이하인 경우는 과징금을 면제할 수 있다.

마. 부과과징금을 결정함에 있어서 1백만원 단위 미만의 금액은 버리는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공정거래위원회는 부과과징금의 규모를 고려하여 적당하다고 생각되는 금액단위 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정할 수 있다.